

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ



БИЛТЕН



Ниш, 2022. године

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ

БИЛТЕН



Pravna i ekonomska izdanja
za uspešno i zakonito poslovanje

Ниш, 2022. године

БИЛТЕН АПЕЛАЦИОНОГ СУДА У НИШУ

ПРИРЕЂИВАЧ: Апелациони суд Ниш

За приређивача: Данијела Николић, председник суда

ИЗДАВАЧ: Paragraf Lex д.о.о., Нови Сад

За издавача:

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Данијела Николић, судија Врховног касационог суда и председник Апелационог суда у Нишу

ЗАМЕНИК ГЛАВНОГ И ОДГОВОРНОГ УРЕДНИКА: Соња Симоновић Стојановић, судија Апелационог суда у Нишу

РЕДАКЦИЈСКИ ОДБОР: Данијела Николић, председник суда
Зоран Поповић, Јасмина Јововић,
Добрила Здравковић Зорица Стошић,
Ружица Јовановић, Тања Ристић,
судије Апелационог суда

СЕКРЕТАР РЕДАКЦИЈЕ: Мирјана Милутиновић, судијски помоћник Апелационог суда у Нишу

РЕДАКЦИЈСКА ПРИПРЕМА СЕНТЕНЦИ: Мирјана Милутиновић, судијски помоћник Апелационог суда у Нишу

ПРЕЛОМ, КОРЕКТУРА И ДИЗАЈН: Paragraf Lex д.о.о., Нови Сад

ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ОМОТА: Наталија Стојановић

ШТАМПАРИЈА: Београф, Нова Пазова

CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад

34(497.11)

БИЛТЕН/АпелационисудуНишу;главнииодговорни
уредник Драган Јоџић. - 2010, бр. 1- . - Нови Сад :
Paragraf Lex, 2010- (Нова Пазова : Београф). - 21 cm

Два до четири пута годишње.

ISSN 2217-4125 = Билтен Апелационог суда у Нишу
COBISS.SR-ID 179852044

Свако копирање, умножавање, објављивање и дистрибуирање целине или делова текста из ове публикације представља повреду ауторског права и кривично дело (сходно одредбама чл. 215.-217. Закона о ауторском и сродним правима, и чл. 198.-202. Кривичног законика). Коришћење делова текста из овог Билтена дозвољено је сходно ауторском праву и уз сагласност издавача.

Садржај

КОРИСНО ЈЕ ПОДСЕТИТИ СЕ	7
ГОДИШЊИ РАСПОРЕД ПОСЛОВА СУДИЈА У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У НИШУ ЗА 2022. ГОДИНУ	9
Шестомесечни извештај за 2022.годину	
Упоредни приказ података за апелационе судове	20

КРИВИЧНО ПРАВО

ТЕОРИЈСКО-ПРАКТИЧНА РАЗМАТРАЊА23

ЗЛАТНО ПРАВИЛО БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА	25
ЗАКОНСКИ ОСНОВИ ЗА УБЛАЖАВАЊЕ КАЗНЕ И СУДСКА ПРАКСА	35

КРИВИЧНО ПРАВО

СУДСКА ПРАКСА81

ЗАКОНИТОСТ ДОКАЗНЕ РАДЊЕ ПРЕПОЗНАВАЊЕ ЛИЦА ИЛИ ПРЕДМЕТА У СИТУАЦИЈИ КАДА ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДМЕТ НИСУ ДОСТУПНИ	83
ЗАМЕНА НАЧИНА ИЗВРШЕЊА КАЗНЕ ЗАТВОРА.....	84
НУЖНА ОДБРАНА	85
ОЦЕНА ДОКАЗА.....	87
РАЗГРАНИЧЕЊЕ РАДЊИ ИЗМЕЂУ КРИВИЧНОГ ДЕЛА ИЗ ЧЛ.322. КЗ И ЧЛ.23 ЗАКОНА О ЈАВНОМ РЕДУ И МИРУ	89
СЛУЧАЈНИ НАЛАЗ.....	91
УСЛОВНИ ОТПУСТ	92
ОБАВЕЗНО ИЗУЗЕЋЕ	94
БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА ИЗ ЧЛ.438. СТ.2. ТАЧ.1. ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ	94
ВЕЗАНОСТ СУДА ЗА ПРАВНУ КВАЛИФИКАЦИЈУ ТУЖИОЦА	96
КРИВИЧНО ДЕЛО СПРЕЧАВАЊЕ И ОМЕТАЊЕ ДОКАЗИВАЊА	98
ПРАВИЛНА ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЈА РАДЊИ ОПТУЖЕНОГ КАО КРИВИЧНО ДЕЛО ИЗ ЧЛ.246а СТ.1. КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА, А НЕ КРИВИЧНО ДЕЛО ИЗ ЧЛ.246. СТ.1. КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА	100

УПОЗНАВАЊЕ СА САДРЖИНОМ ЗАПИСНИКА О ИСКАЗИМА ЛИЦА КОЈА СУ ОСЛОБОЂЕНА ДУЖНОСТИ СВЕДОЧЕЊА	103
УЧЕСТВОВАЊЕ У ТУЧИ И НУЖНА ОДБРАНА	104

ГРАЂАНСКО ПРАВО ТЕОРИЈСКО-ПРАКТИЧНА РАЗМАТРАЊА107

ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА ДОКТРИНЕ *ПОЉА СЛОБОДНЕ ПРОЦЕНЕ* У ПРАКСИ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА	109
Остваривање права на издржавање између брачних и ванбрачних партнера У ПРАКСИ Основног суда у Нишу	124

ГРАЂАНСКО ПРАВО СУДСКА ПРАКСА141

НИШТАВОСТ ЗАВЕШТАЊА	143
ПРАВНО ДЕЈСТВО НАСЛЕДНИЧКЕ ИЗЈАВЕ О ОДРИЦАЊУ ОД НАСЛЕЂА	144
ПРАВО СВОЛИНЕ	146
ПРАВИЛНА ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА НАКНАДУ МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ	147
ПРАВО НА ИМОВИНУ	149
ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА- МАНЕ ВОЉЕ	150
ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ КОЈА ПОТИЧЕ ОД ЛОВОСТАЈЕМ ЗАШТИЋЕНЕ ДИВЉАЧИ	152
НЕПОСТОЈАЊЕ СПОСОБНОСТИ ЗА ДАВАЊЕ ЗАЛОЖНЕ ИЗЈАВЕ	154
ВОЉА ДА СЕ СТВАР НЕ КОРИСТИ, ПАСИВНО ПОНАШАЊЕ СУВЛАСНИКА И ОДСУСТВО ПРОТИВПРАВНОСТИ ДРЖАВИНЕ СТВАРИ КОД ДРУГОГ СУВЛАСНИКА.....	156
НЕДОЗВОЉЕНОСТ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ..	159
АЛЕАТОРНОСТ УГОВОРА О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ	161
ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ КОЈА ПОТИЧЕ ОД ЛОВОСТАЈЕМ ЗАШТИЋЕНЕ ДИВЉАЧИ	164

ДОКАЗИВАЊЕ УСВОЈЕЊА165

ПРОЦЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОД ТУЖБЕ РАДИ ПОНИШТАЈА ПРИЗНАЊА ОЧИНСТВА И ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОТПУПНЕ ПРОЦЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ	168
УТВРЂЕЊЕ АПСОЛУТНЕ НИШТАВОСТИ УГОВОРА.....	170
УГОВОР О РАСПОДЕЛИ ИМОВИНЕ ЗА ЖИВОТА	170
РАСКИД УГОВОРА О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ	172
ПРАВНИ ИНТЕРЕС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ТУЖБЕ ЗА УТВРЂЕЊЕ	174
НАКНАДА ТРОШКОВА У СПОРОВИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ.....	175
ПРАВНИ ОСНОВ ПОТРАЖИВАЊА И ПРЕДЛАГАЊЕ ДОКАЗА У ПОСТУПКУ КОЛИ СЕ ВОДИ КАО ПОВОДОМ ПРИГОВОРА ПРОТИВ ПЛАТНОГ НАЛОГА.....	176
САДРЖИНА ТУЖБЕ ПО ЗАКОНУ О ЗАБРАНИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ	177

РАДНО ПРАВО179

ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОСНОВУ ФАЛСИФИКОВАНЕ ДИПЛОМЕ	181
ВЕЗАНОСТ ПАРНИЧНОГ СУДА ЗА ПРАВНОСНАЖНУ ОДЛУКУ ДОНЕТУ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ	184
ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА У ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОЈ УСТАНОВИ И ГРАНИЦЕ ДИСКРЕЦИОНОГ ОВЛАШЋЕЊА КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ПРИ ИЗБОРУ КАНДИДАТА.....	186
ОДЛУКА УСТАВНОГ СУДА ПО ИЗЈАВЉЕНОЈ УСТАВНОЈ ЖАЛБИ КАО ПРЕТХОДНО ПИТАЊЕ У РАДНОМ СПОРУ И РАЗЛОГ ЗА ПРЕКИД ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА	190
ОБЈЕКТИВНА ОДГОВОРНОСТ ПОСЛОДАВЦА ЗА НАСТАЛУ ШТЕТУ	193
ПОНАШАЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ КАО РАЗЛОГ ЗА ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ	194
НЕПОШТОВАЊЕ РАДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ КАО РАЗЛОГ ЗА ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ	196
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ НА РАДУ	198
ПОСЕДОВАЊЕ СТАТУСА ЗАПОСЛЕНОГ КАО УСЛОВ ЗА СТИЦАЊЕ ПРАВА НА ЈУБИЛАРНУ НАГРАДУ	199

ПОСТОЈАЊЕ ПРАВНОГ ИНТЕРЕСА КАО ОПШТА ПРОЦЕСНА ПРЕТПОСТАВКА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ СУДСКЕ ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ	203
ПРАВА КОЈА ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ОБАВЉЕНОГ ФАКТИЧКОГ РАДА	206
САДРЖИНА ОБРАЗЛОЖЕЊА РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ОДЛУЧУЈЕ О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИМА ЗАПОСЛЕНОГ	209
ПРАВНОСНАЖНА УПРАВНА ОДЛУКА КАО ПРЕДУСЛОВ ЗА ВОЂЕЊЕ РАДНОГ СПОРА РАДИ НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗБОГ НЕПОСТУПАЊА ПОСЛОДАВЦА ПО ТОЈ ОДЛУЦИ	214
ПОВРЕДА ЗАПОСЛЕНОГ НА РАДНИЧКИМ СПОРТСКИМ ИГРАМА И ПРАВО НА НАКНАДУ ШТЕТЕ	218
УСЛОВИ ЗА ПРЕОБРАЖАЈ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	223
НЕПОСТОЈАЊЕ ОБАВЕЗЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ ОД СТРАНЕ ПОСЛОДАВЦА КАО ПОСЛЕДИЦЕ НЕПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНОГ У РАДНИ ОДНОС ПРЕМА ОБЈАВЉЕНОМ КОНКУРСУ	227

КОРИСНО ЈЕ ПОДСЕТИТИ СЕ

МОДЕЛ ОКВИРА КОМПЕТЕНЦИЈА – СУДИЈА

I ВЕШТИНЕ И СПОСОБНОСТИ

АДМИНИСТРАТИВНЕ И ОРГАНИЗАЦИОНЕ

- Обезбеђује ефикасан тимски рад у пријатној радној атмосфери.
- Ефикасно управља предметима: делотворно утврђује приоритете, избегава непотребна одлагања у поступку
- Ангажује се на професионалном развоју и усавршавању других: активно учествује у развијању компетенција сарадника, помоћника и особља
- Конструктивно сарађује са другима, нарочито са припадницима других професија, подстичући сарадњу и заједнички рад

ЛИЧНЕ, СОЦИЈАЛНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ

- Сагледава разноликост друштвеног окружења у којем суд функционише
- Поступа са другима са поштовањем и обзиром, правично и без предрасуда и дискриминације по било ком основу
- Поступа у складу са Етичким кодексом
- Поступа у складу са начелима независности и интегритета
- Показује смиреност и ауторитет у захтевним и непријатним ситуацијама
- Саопштава материјално-правне и процесне информације на одговарајући начин, једноставно и лако разумљивим језиком

ПРАВНОТЕХНИЧКЕ

- Суди ефикасно и делотворно
- Управља поступком на непристрасан и објективан начин
- Предузима неопходне припремне радње у поступку и сагледава различита процесна решења
- У стању је да ради брзо и под притиском
- У стању је да брзо и делотворно усвоји и анализира велики број информација, чињеница и правних аргумената
- Доноси јасно образложене одлуке

П ЗНАЊЕ

ПОЗНАВАЊЕ ПРАВА

- Поседује висок ниво познавања материјалног и процесног права и начелима на којима оно почива
- Стално тежи да ажурира, унапреди и прошири своје знање, у контексту друштвених и економских промена
- Редовно прати развој у судској пракси релевантних судова, као што су Врховни касациони суд, Уставни суд, Европски суд за људска права, Европски суд правде и слично

ПОЗНАВАЊЕ ВАНПРАВНИХ ОБЛАСТИ

- Поседује способност да делотворно користи различите изворе информација, укључујући и електронске базе података
- Користи информационе и комуникационе технологије у свакодневном раду
- Активно тежи стицању, развијању и унапређењу знања из ванправних области као што су медицина, економија, форензика, информационо-комуникационе технологије и слично



Република Србија
АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ
Су I-2-45/21-11
14.10.2022. године
Н и ш

Судска управа Апелационог суда у Нишу сачинила је пречишћен текст Годишњег распореда послова судија за 2022. годину.

Пречишћен текст Распоред послова судија за 2022. годину обухвата:

1. Годишњи распоред послова судија у Апелационом суду у Нишу за 2022. годину Су I-2-45/21 од 06.12.2021. године,
2. Измену Годишњег распореда послова судија у Апелационом суду у Нишу за 2022. годину Су I-2-45/21-1 од 26.01.2022. године,
3. Допуну Годишњег распореда послова судија у Апелационом суду у Нишу за 2022. годину Су I-2-45/21-2 од 03.03.2022. године,
4. Измену Годишњег распореда послова судија у Апелационом суду у Нишу за 2022. годину Су I-2-45/21-3 од 09.03.2022. године,
5. Измену Годишњег распореда послова судија у Апелационом суду у Нишу за 2022. годину Су I-2-45/21-4 од 14.04.2022. године,
6. Измену Годишњег распореда послова судија у Апелационом суду у Нишу за 2022. годину Су I-2-45/21-5 од 18.04.2022. године,
7. Допуну Годишњег распореда послова судија у Апелационом суду у Нишу за 2022. годину Су I-2-45/21-6 од 28.06.2022. године,
8. Измену Годишњег распореда послова судија у Апелационом суду у Нишу за 2022. годину Су I-2-45/21-7 од 22.07.2022. године,
9. Измену Годишњег распореда послова судија у Апелационом суду у Нишу за 2022. годину Су I-2-45/21-8 од 02.09.2022. године,
10. Измену Годишњег распореда послова судија у Апелационом суду у Нишу за 2022. годину Су I-2-45/21-9 од 06.09.2022. године,
11. Измену Годишњег распореда послова судија у Апелационом суду у Нишу за 2022. годину Су I-2-45/21-10 од 13.10.2022. године.

АПЕЛАЦИОНИ СУД У НИШУ
Судска управа
Су I-2-45/22-11 од 14.10.2022. године

ГОДИШЊИ РАСПОРЕДА ПОСЛОВА СУДИЈА У АПЕЛАЦИОНОМ СУДУ У НИШУ ЗА 2022. ГОДИНУ

I

СУДСКА УПРАВА

Пословима судске управе руководи **Данијела Николић**, в. ф. председник суда.

За заменика председника суда одређују се судија **Соња Симоновић Стојановић**.

Судији **Саше Бошковићу** поверавају се и посебне обавезе за информисање и контакте са јавношћу и медијима (портпарол).

За руководиоца службе председника суда одређује се **Јелена Јанчетовић**, секретар суда.

У њеном одсуству замењиваће је **Јасмина Кузмановић**, судијски помоћник.

II

СУДСКА ОДЕЉЕЊА

У суду постоје следећа одељења:

- **Кривично одељење;**
- **Грађанско одељење;**
- **Одељење за радне спорове;**
- **Одељење за поступање по захтевима за заштиту узбуњивача;**
- **Одељење судске праксе.**

ПРЕДСЕДНИЦИ И ЗАМЕНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА СУДСКИХ ОДЕЉЕЊА

- 1. Кривично одељење:** председник одељења је судија **Зоран Поповић**.
- 2. Грађанско одељење:** председник одељења је судија **Александар Пантић**, а у случају њене одсутности или спречености замењиваће је судија **Соња Симоновић Стојановић**.
- 3. Одељење радних спорова:** председник одељења је судија **Ђорђе Гојгић**, а у случају његове одсутности или спречености замењиваће га судија **Тања Ристић**.

За уређивање Веб сајта суда задужује се судија **Соња Симоновић Стојановић**.

За праћење и евиденцију одлука Европског суда за људска права, Уставног суда, стручних реферата и судске праксе других судова у штампаним публикацијама које суд прима у недовољном броју примерака за све судије задужују се судије **Весна Стевановић**, **Јасмина Јововић**, **Добрила Здравковић** и **Тања Ристић**.

III

КРИВИЧНО ОДЕЉЕЊЕ

I – ВЕЋЕ

1. Јасмина Јововић, председник већа;
2. Љиљана Миљковић, члан;
3. Томислав Трајковић, члан.

II – ВЕЋЕ

1. Дијана Јанковић, председник већа;
2. Александар Перуновић, члан;

III – ВЕЋЕ

1. Зоран Поповић, председник већа;
2. Весна Стевановић, члан;
3. Иван Булатовић, члан.

IV – ВЕЋЕ

1. Мирјана Ђорђевић, председник већа;
2. Саша Бошковић, члан;
3. Горана Митић, члан.

III-a

Одређују се већа која ће поступати по жалбама изјављеним против одлука Апелационог суда (Кж-3 предметима):

I- ВЕЋЕ

1. Горана Митић, председник већа;
2. Мирјана Ђорђевић, члан;

II- ВЕЋЕ

1. Зоран Поповић, председник већа;
 2. Јасмина Јововић, члан;
 3. Томислав Трајковић, члан.
- Председника већа замењује први члан већа.

III-б

Одређују се већа која ће поступати у предметима малолетних учинилаца кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица:

I – ВЕЋЕ

1. Зоран Поповић, председник већа;
2. Весна Стевановић, члан,
3. Иван Булатовић, члан.

II – ВЕЋЕ

1. Мирјана Ђорђевић, председник већа;
2. Саша Бошковић, члан;
3. Горана Митић, члан.

Судијски помоћници распоређени у веће чији су чланови судије одређене за поступање у предметима малолетних учинилаца кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица, као и судијски помоћници распоређени у већа чији су чланови судије одређене за поступање по жалбама изјављеним против одлука Апелационог суда у КжЗ-предметима, према распореду послова за 2022. годину, обрађиваће и предмете у овим материјама.

III-в

За предмете у којима већа поступају у петорном саставу, веће које је задужено предметима ће се допунити члановима првог наредног већа, до потребног броја.

Дежурна већа за време годишњих одмора у кривичном одељењу су:

- у јулу **I** веће;
- у августу **IV** веће.

У поновном поступку по правном леку, на основу члана 343 Законика о кривичном поступку, уколико је претходно укинута решење о потврђивању оптужнице, предмет се распоређује истом већу, које је претходно поступало у том предмету, судији у том већу који је на реду за пријем предмета, да би касније судије које нису одлучивале о потврђивању оптужнице, могле да одлучују о жалби на пресуду, имајући у виду да је члан 55. Судског пословника брисан Судским пословником о изменама и допунама Судског пословника (“Службени гласник Републике Србије” бр. 39 од 15.04.2016. године), као и упутство Министрства правде дато након тога.

III-г

Одређује се и посебно веће за поступање искључиво у старим предметима према Програму решавања старих предмета овог суда.

1. Данијела Николић, председник већа;
2. Марина Ђукић, члан;
3. Ђорђе Гојгић, члан.

С тим што ће члана овог већа чинити и судија који реферише старе предмете. Ово веће се не задужује новим предметима.

IV

ГРАЂАНСКО ОДЕЉЕЊЕ

I – ВЕЋЕ

1. Марина Ђукић, председник већа;
2. Драган Крстић, члан.

II – ВЕЋЕ

1. Снежана Лазич, председник већа;
2. Милица Златковић, члан.
3. Александар Пантић, члан.

III – ВЕЋЕ

1. Стојанка Вујосевић, председник већа;
2. Оливера Јовановић, члан;
3. Нела Алексић, члан.

IV-ВЕЋЕ

1. Соња Симоновић Стојановић, председник већа;
2. Јадранка Митровски, члан,
3. Горан Контић, члан.

V-ВЕЋЕ

1. Добрила Здравковић, председник већа;
2. Снежана Тодоровић, члан,
3. Зоран Стаменковић, члан.

VI-ВЕЋЕ

1. Зорица Стошић, председник већа;
 2. Миљана Стојковић, члан;
 3. Невена Благојевић, члан.
- Председника већа замењује први члан већа.

IV-a

Одређују се судије које ће одлучивати по жалбама изјављеним против решења Вишег суда у Нишу, која су донета у поступцима у којима се утврђују чињенице о статусу новорођене деце за коју се сумња да су нестала из породициштва или здравствених установа у Републици Србији и поступке у којима се досуђује правична новчана накнада нематеријалне штете.

I ВЕЋЕ

1. Соња Симоновић Стојановић, председник већа;
2. Јадранка Митровски, члан већа;
3. Горан Контић, члан већа.

II ВЕЋЕ

1. Марина Ђукић, председник већа;
2. Зорица Стошић, члан већа;
3. Невена Благојевић, члан већа.

Судију који је одсутан или спречен да поступа замениће судија Миљана Стојковић.

Судијама које буду задужене предметима ове материје, рачунаће се као редован прилив предмета.

V

ОДЕЉЕЊЕ РАДНИХ СПОРОВА

I – ВЕЋЕ

1. Ружица Јовановић, председник већа;
2. Зорица Радојчић, члан;
3. Сања Костић, члан

II – ВЕЋЕ

1. Биљана Стаменковић, председник већа;
2. Даниела Радовић, члан;
3. Мира Стефанова, члан.

III – ВЕЋЕ

1. Тања Ристић, председник већа;
2. Слађана Стојановић, члан;
3. Лидија Стошић, члан.

IV- ВЕЋЕ

1. Ђорђе Гојгић, председник већа;
2. Ксенија Џомбић, члан.
3. Зоран Милошевић, члан.

Председника већа замењује први члан већа.

V-a

У предметима рехабилитације поступаће судије:

1. Иван Булатовић;
2. Саша Бошковић;
3. Соња Симоновић Стојановић;
4. Ђорђе Гојгић;

5. Зорица Стошић.

У саставу овог већа, без обзира ко је судија известилац, члан већа биће судија који поступа у Кривичном одељењу.

VI

ПОСТУПАЊЕ У ПРЕДМЕТИМА ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ

На основу чл. 7. став 2. и члана 16. став 4. Закона о заштити права на суђење у разумном року, за поступање у предметима заштитите овог права, поред председника суда поступаће следеће судије:

У предметима из области Грађанског права

Стојанка Вујошевић

Јадранка Митровски

Оливера Јовановић

У предметима из области Радних спорова

Зоран Милошевић

Тања Ристић

Ђорђе Гојгић

У предметима из области Кривичне материје

Дијана Јанковић

Јасмина Јововић

Томислав Трајковић

Расподела предмета судијама вршиће се према материјама у којима судије поступају, с тим да је у одређивању надлежности грађанске материје или материје радних спорова одлучујућа ознака списка предмета првостепеног суда.

Поступци у предметима по приговорима и по жалбама се међусобно изједначавају приликом завођења и расподеле предмета.

Судијама које буду задужене предметима ове материје, рачунаће се као редован прилив предмета у материјама у којима поступају.

VII

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСТУПАЊЕ ПО ЗАХТЕВИМА ЗА ЗАШТИТУ УЗБУЊИВАЧА

По захтевима за заштиту узбуњивача у Гж- уз предметима

1. Јадранка Митровски, председник већа;
2. Добрила Здравковић, члан;
3. Миљана Стојковић, члан.

По захтевима за заштиту узбуњивача у Гж1 – уз предметима

1. Тања Ристић, председник већа;
2. Слађана Стојановић, члан;
3. Ксенија Џомбић, члан.

Председника већа замењује први члан већа.

За поступање у предметима унутрашњег узбуњивања поступаће судија **Добрила Здравковић**.

Предмети примљени у овој материји рачунаће се судијама који су њима задужени у редован прилив предмета.

VIII

ОДЕЉЕЊЕ СУДСКЕ ПРАКСЕ

Одељење судске праксе чине судије:

1. **Данијела Николић**, в. ф. председник суда, руководиоца судске праксе суда.
2. **Зоран Поповић**, председник Кривичног одељења, заменик руководиоца судске праксе суда.
3. **Јасмина Јововић**, руководиоца евиденције судске праксе у Кривичном одељењу.
4. **Добрила Здравковић**, руководиоца евиденције судске праксе у Грађанском одељењу, а у случају њене одсутности или спречености замењиваће је судија **Зорица Стошић**.

5. **Ружица Јовановић**, руководилац евиденције судске праксе у Одељењу радних спорова, а у случају њене одсутности или спречености замењиваће је **судија Тања Ристић**.

6. Судијски помоћник **Милан Ђорђевић** у Кривичном одељењу, а случају његове одсутности или спречености, замењиваће га судијски помоћник **Зоран Ђурђевић**.

7. Судијски помоћник **Миљана Поповић Ђурић**, у Грађанском одељењу, а случају њене одсутности или спречености, замењиваће је судијски помоћник **Јелена Голубовић**.

8. Судијски помоћник **Ивана Ђурђић Митровић** у Одељењу радних спорова, а случају њене одсутности или спречености, замењиваће је судијски помоћник **Наташа Митковић**.

Редакцију Билтена судске праксе суда чине судије овог одељења с тим да је главни и одговорни уредник Билтена в. ф. председника суда Данијела Николић, а његови заменици судије Зоран Поповић и Соња Симоновић Стојановић.

IX

Председницима већа умањује се прилив предмета за 20%.

Непотпуна већа биће допуњена, до пуног састава, судијама других већа из исте материје према месечном распореду који сачињава Судска управа, а на предлог председника одељења, и благовремено уручује судијама на које се допуна већа односи.

Судска одељења ће најмање једном у шест месеци вршити анализу судске праксе из своје области и оцењивати резултате рада одељења у целини и појединачно судија и судијских помоћника.

Годишњи распоред послова судија Апелационог суда у Нишу за 2022. годину, са изменама и допунама Распореда послова судија Апелационог суда у Нишу, примењује се од 14.10.2022. године.

В. Ф. ПРЕДСЕДНИКА СУДА

Данијела Николић

Шестомесечни извештај за 2022.годину Упоредни приказ података за апелационе судове

ПРИКАЗ ПОДАТАКА ЗА МАТЕРИЈУ “КЖ1”

АПЕЛАЦИОНИ СУД	БР. СУДИЈА У ОДЕЉЕЊУ	НЕРЕШЕНО НА ПОЧЕТКУ	ПРИМЉЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО ПРИМЉЕНО ПО СУДИЈИ	УКУПНО У РАДУ	РЕШЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ	ОСТАЛО НЕРЕШЕНО	СТАРИХ ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЈЕМА
НИШ	13	118	951	6.65	1.069	986	6.90	83	0
НОВИ САД	11	85	1.028	8.50	1.113	1.011	8.36	102	0
КРАГУЈЕВАЦ	11	56	886	7.32	942	900	7.44	42	0
БЕОГРАД	22	147	1.145	4.73	1.292	1.042	4.31	250	0

ПРИКАЗ ПОДАТАКА ЗА МАТЕРИЈУ “КЖ2”

АПЕЛАЦИОНИ СУД	БР.СУДИЈА У ОДЕЉЕЊУ	НЕРЕШЕНО НА ПОЧЕТКУ	ПРИМЉЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО ПРИМЉЕНО ПО СУДИЈИ	УКУПНО У РАДУ	РЕШЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ	ОСТАЛО НЕРЕШЕНО	СТАРИХ ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЈЕМА
НИШ	13	1	727	5.08	728	721	5.04	7	0
НОВИ САД	11	13	2.121	17.53	2.134	2.127	17.58	7	0
КРАГУЈЕВАЦ	11	4	830	6.86	834	834	6.89	0	0
БЕОГРАД	22	25	2.758	11.40	2.783	2.752	11.37	31	0

ПРИКАЗ ПОДАТАКА ЗА МАТЕРИЈУ “ГЖ”

АПЕЛАЦИОНИ СУД	БР. СУДИЈА У ОДЕЉЕЊУ	НЕРЕШЕНО НА ПОЧЕТКУ	ПРИМЉЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО ПРИМЉЕНО ПО СУДИЈИ	УКУПНО У РАДУ	РЕШЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ	ОСТАЛО НЕРЕШЕНО	СТАРИХ ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЈЕМА
НИШ	16	944	3.459	19.65	4.403	3.292	18.70	1111	1
НОВИ САД	23	686	2.982	11.79	3.668	3.263	12.90	405	0
КРАГУЈЕВАЦ	22	1.265	3.116	12.88	4.381	3.615	14.94	766	0
БЕОГРАД	38	4.034	7.704	18.43	11.738	7.848	18.78	3890	53

ПРИКАЗ ПОДАТАКА ЗА МАТЕРИЈУ “ГЖ1”

АПЕЛАЦИОНИ СУД	БР. СУДИЈА У ОДЕЉЕЊУ	НЕРЕШЕНО НА ПОЧЕТКУ	ПРИМЉЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО ПРИМЉЕНО ПО СУДИЈИ	УКУПНО У РАДУ	РЕШЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ	ОСТАЛО НЕРЕШЕНО	СТАРИХ ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЈЕМА
НИШ	11	1.616	3.689	30.49	5.305	3.886	32.12	1419	0
НОВИ САД	14	749	3.695	23.99	4.444	3.954	25.68	490	0
КРАГУЈЕВАЦ	11	1.507	3.927	32.45	5.434	3.540	29.26	1894	0
БЕОГРАД	17	1.623	4.067	21.75	5.690	4.060	21.71	1630	8

ПРИКАЗ ПОДАТАКА ЗА МАТЕРИЈУ “ГЖ2”

АПЕЛАЦИОНИ СУД	БР. СУДИЈА У ОДЕЉЕЊУ	НЕРЕШЕНО НА ПОЧЕТКУ	ПРИМЉЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО ПРИМЉЕНО ПО СУДИЈИ	УКУПНО У РАДУ	РЕШЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ	ОСТАЛО НЕРЕШЕНО	СТАРИХ ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЈЕМА
НИШ	16	54	470	2.67	524	491	2.79	33	0
НОВИ САД	13	32	520	3.64	552	525	3.67	27	0
КРАГУЈЕВАЦ	22	19	521	2.15	540	510	2.11	30	0
БЕОГРАД	38	75	576	1.38	651	560	1.34	91	0

ПРИКАЗ ПОДАТАКА УКУПНО НА НИВОУ СУДА

АПЕЛАЦИОНИ СУД	БР. СУДИЈА У ОДЕЉЕЊУ	РЕШЕНО НА ПОЧЕТКУ	ПРИМЉЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО ПРИМЉЕНО ПО СУДИЈИ	УКУПНО У РАДУ	РЕШЕНО	ПРОСЕЧНО МЕСЕЧНО РЕШЕНО ПО СУДИЈИ	ОСТАЛО НЕРЕШЕНО	СТАРИХ ПРЕМА ДАТУМУ ПРИЈЕМА
НИШ	40	2.814	10.841	24.64	13.655	11.211	25.48	2444	1
НОВИ САД	48	1.589	11.631	22.03	13.220	12.160	23.03	1060	0
КРАГУЈЕВАЦ	44	2.883	10.700	22.11	13.583	10.825	22.37	2758	0
БЕОГРАД	78	6.202	19.072	22.23	25.274	18.941	22.08	6333	62

АПЕЛАЦИОНИ СУД	проценат решених предмета у суду	савладавање прилива	АЖУРНОСТ	УКУПАН КВАЛИТЕТ
НИШ	82.10	103.41	2.71	99.23
НОВИ САД	91.98	104.55	1.09	98.66
КРАГУЈЕВАЦ	79.70	101.17	3.09	97.09
БЕОГРАД	74.94	99.31	3.98	98.18

КРИВИЧНО ПРАВО

ТЕОРИЈСКО-ПРАКТИЧНА РАЗМАТРАЊА

Весна Стевановић

Судија Апелационог суда у Нишу

ЗЛАТНО ПРАВИЛО БЕЗБЕДНОСТИ ЈАВНОГ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА

Резиме: Без обзира у ком својству учествујемо у саобраћају, право али дужност свих нас је да својим учешћем доприносимо безбедности саобраћаја, пре свега из људских разлога јер не желимо да страдамо због небезбедног понашања, тако и из разлога које нам важеће законске одредбе налажу. У раду указујемо на прво и најважније златно правило за безбедност јавног саобраћаја, под називом: „док нам се погледи не сретну“. Ово правило је применљиво у истој саобраћајној ситуацији и за пешаке и за возаче. На ово правило указујемо и кроз поједине примере из судске праксе. Циљ рада је да и на овај начин дамо допринос повећању безбедности саобраћаја на путевима.

Кључне речи: учесник у саобраћају, возач, пешак, безбедност јавног саобраћаја, златно правило

УВОД

Хтели ми то или не, сви смо ми учесници у саобраћају, јер у истом учествујемо свакодневно одлазећи на посао, у шетњу, бављењем својом професијом или обављањем својих животних функција ван куће. Неки од нас се као учесници у саобраћају јављају увек у истој ситуацији, а други мењају својство учесника у зависности од тога да ли су се негде упутили пешице или на два и више точкова.

Највећи део популације у саобраћају учествује увек у истом својству – у својству пешака јер немају возачку дозволу или возило, а рецимо нису љубитељи превозних средстава која имају педале или точкиће - ролери. У том својству јављамо се, неретко, наравно и сви ми који најрадије не излазимо из аутомобила, јер, макар по изласку из аутомобила прелазимо коловоз, раскрснице, користимо пешачке прелазе.

Без обзира у ком својству у саобраћају учествујемо, право али и дужност свих нас је да доприносимо својим учешћем његовој безбедности, како из природно људских разлога јер волимо себе и не желимо да због небезбедног понашања страдамо, уважавамо право на живот и имовину и других учесника у саобраћају те не желимо да их учинимо жртвама, тако и из разлога који нам важне законске одредбе налажу.

Безбедно понашање у саобраћају представља понашање прилагођено актуелној саобраћајној ситуацији, које, између осталог подразумева и поштовање саобраћајних прописа који су усмерени на очување своје безбедности и на неутрожавање других.

Закон о безбедности саобраћаја на путевима (даље: ЗБС)² садржи одредбе које нас обавезују на посебну опрезност када вршимо одређене радње на коловозу и као возачи и као пешаци јер прописују где, када и на који начин се сме прелазити коловоз, на који начин се врши укључивање у јавни саобраћај, полукружно окретање, када, како и на ком месту се може проћи кроз раскрсницу имајући у виду светло на семафору, постојање пешачких прелаза, присуство саобраћајних знакова, прописано првенство пролаза и слично. (2)

Ни у време када нас из дневних вести саблажњавају статистички подаци и извештаји о корона жртвама и различитим природним катастрофама, црне бројке и извештаји о страдалима у саобраћајним незгодама, не престају да нас забрињавају. Свакодневне саобраћајне незгоде, често и са веома тешким па и најтежим последицама. На жалост, саобраћајне незгоде су постале наша реалност која нас управо и упозорава на обавезу поступања учесника у саобраћају на начин прописан законом.

Као лица која на различите начине учествују у саобраћају, као возачи, као пешаци, као превожена лица, путници у јавном превозу, сматрамо да је од виталног интереса за безбедност јавног саобраћаја пре свега поштовање прописа који је регулишу, али апострофирамо постојање неких општих, рекли бисмо и врло једноставних и практичних правила, чије непоштовање законом није санкционисано, али би њихова примена могла допринети повећању безбедности јавног саобраћаја на путевима.

Указујући на њихову практичност и значај, та правила смо назвали златним правилима, а у овом раду указујемо на само једно од тих правила.

ЗЛАТНО ПРАВИЛО

Прво и нама најдраже златно правило за безбедност јавног саобраћаја је правило под називом : „ДОК НАМ СЕ ПОГЛЕДИ НЕ СРЕТНУ“.

Верујемо да већ наслућујете суштину овог правила у датом контексту, а суштина је у томе да се, поред поштовања саобраћајних прописа, са другим учесницима у саобраћају, ради безбедности, комуницира и визуелно – погледом. Ово правило се односи на све учеснике у саобраћају и оне који пешаче и оне који управљају неким возилом.

Наиме, када намераваате да пређете коловоз, чак и када то чините преко пешачког прелаза, у ситуацији када уочите наилазак возила које се приближава пешаком прелазу, уколико исто значајно не смањује брзину тако да вам је јасно да ће се испред пешачког прелаза зауставити, односно уколико не видите да се возило зауставило, никада не можете бити сигурни да вас је возач тог возила уочио, да ће возило зауставити и омогућити вам да безбедно пређете коловоз.

На то могу утицати разни фактори – возач телефонира приликом војње, разговара са сапутницима или је присутна нека друга околност која би утицала на то да не поступи по прописима и возило не заустави испред пешачког прелаза.

Уколико погледате возача наилазећег возила и видите да гледа у вас, те се тиме уверите да вас је сигурно уочио, можете наравно као пешак прећи коловоз, без опасности од налета наилазећег возила. Наведено поступање, иако наизглед делује некима можда и чудно, ако суштински уђете у проблематику применом овог златног правила на неке од конкретних саобраћајних ситуација, верујемо да ћете се сложити, да у значајној мери доприноси безбедности јавног саобраћаја.

Но, ово правило је применљиво не само за пешаке, већ у истој саобраћајној ситуацији, применљиво је и на возаче. Наиме, замислите ситуацију да управљате возилом и угледате пешака који стоји на тротоару испред пешачког прелаза. Не знате хоће ли и ког тренутка крочити на коловоз, или замислите пешака који је започео прелажење коловоза на пешачком прелазу или ван њега или оног који стоји уз саму ивицу коловоза, а при томе телефонира, куца поруке на телефону, разговара са особом поред себе.

Ове ситуације регулише и закон кроз обавезу да обратите пажњу на пешаке. Међутим, то често није довољно да би се незгода избегла иако је обавеза „обраћања пажње“ широко дефинисана. Не можете знати да ли ће, када и на који начин пешак предузети било коју радњу.

Наравно, није довољно нити дозвољено користити се увек својим правима прописаним ЗБС-ом у смислу да када имате упаљено зелено светло на семафору, имате безрезервно право да прођете возилом. Немамо право да возилом повредимо ни пешака који се на путањи нашег кретања нашао онда када то није смео да учини, ни пешака који претрчава коловоз ван пешачког прелаза, па ни оног који се по истом из ко зна којих разлога бесмислено креће.

Дакле, и у ситуацијама када према постављеној саобраћајној сигнализацији ви имате право да без заустављања прођете неки део коловоза, када имамо присуство пешака на коловозу или поред њега, без обзира на сва права и обавезе које закон прописује, управо због тога што не можемо знати какве су намере пешака и да ли је можда само физички присутан на коловозу, а мислима ко зна где, ово правило би се могло применити и на возаче у циљу побољшања безбедности јавног саобраћаја.

То суштински значи да, у таквој ситуацији као возач смањите брзину кретања, по потреби и застанете возилом ако је пешак рецимо на коловозу и гледа у телефон или у супротну страну, до тренутка када се уверите да вас је пешак уочио и тиме обезбедите да изненада не закорачи испред вашег возила које је у покрету. Дакле, златно правило „док вам се погледи не сретну“, сложићете се, у таквим ситуацијама, могло би бити од велике користи.

Ако вам се случајно учинило да ово правило делује мало детињасто или оптерећујуће, подсећамо вас да законом није прописано и обавезујуће, али да може помоћи у нашем настојању да улице безбедно пређемо или возимо коловозом на којем су присутни пешаци, без да ико буде угрожен или повређен.

Уколико је потребно да вас још мало „убеђујемо“ да наведено правило с правом заслужује епитет златног, осврнимо се на реалне саобраћајне ситуације које су резултирале контактом пешака и возила.

СУДСКА ПРАКСА

У погледу ове проблематике старија и новија судска пракса су јединствене.

Код изненадног прелажења пешака пресудно је да ли је он показао намеру да пређе коловоз, ако јесте, возач би био дужан да предвиди његово непрописно прелажење. То су врло чести случајеви у пракси уз различите начине непрописног понашања и возача моторног возила и пешака, при чему је понекад тешко утврдити на који начин је дошло до контакта између возила и пешака.

У судској пракси је спорно да ли је возач моторног возила дужан да предвиди непрописно понашање другог учесника. Требало би узети, полазећи од начела ограниченог поверења да та дужност постоји само онда када је према околностима конкретног случаја и искуству очигледно да се може очекивати такво непрописно понашање другог учесника.

С тим у вези, у судској пракси су посебно биле присутне и спорне следеће ситуације:

изненадно прелажење пешака преко коловоза, лежање пешака на коловозу у ноћним условима, вожња бициклиста и мотоциклиста, као и непрописно понашање деце и старијих лица.

Возач моторног возила мора водити рачуна о томе да ли други учесници у саобраћају крше саобраћајне прописе и да томе прилагоди своју вожњу. То се у пракси нарочито односи на пешаке и возаче двоточкаша (бицикала), када возач примети њихово неправилно прелажење преко коловоза или неправилно кретање по коловозу, односно кривудау и вожњу средином коловоза уместо уз десну ивицу коловоза. У тој ситуацији став судске праксе је да нема кривице ако је грешка другог уочена, али возач није изабрао најбоље решење за избегавање саобраћајне незгоде.

Гледано кроз судску праксу, велики је број саобраћајних незгода у којима имамо исказе: „видео сам возило али сам очекивао да ће се зауставити, ударило ме је предњим делом, полицајци су ми касније рекли да је телефонирао за време вожње“ или „док сам се возилом приближавао пешаку, видео сам пешака који стоји на ивици коловоза и гледа у телефон, није се кретао, стајао је и нисам очекивао да ће да крене“. Ту су и ситуације када пешак који прелази коловоз одједном стане, па опет крене или започне кретање ка тротоару са

којег је дошао, или „стајали су на ивици коловоза и разговарали, мислио сам да је уочио моје возило, нисам ишао брзо и нисам очекивао да ће да почне да прелази улицу“.

Бројне су ситуације у којима је до саобраћајне незгоде дошло јер пешак није уочио наилазеће возило и није ускладио своје понашање на коловозу са околношћу на коју би иначе реаговао или возач није уочио пешака у смислу напред изнетих казивања учесника у саобраћајним незгодама, а ситуација је још пуно озбиљнија када су у питању деца.

Тако, у једном случају наводи се: „Оптужени је управљајући путничким возилом у условима градске вожње уочио пешака који прелази коловоз у условима смањене видљивости, влажности коловоза, који доласком до средишне линије коловоза крене уназад, (при чему је суд сматрао да то за оптуженог као возача путничког возила не може представљати изненадну препреку)“ (3)

У другом случају наводи се :“...Брзина вожње није била прилагођена када се возач кретао брзином од 60 км/х, па и ако је на 50 метара испред свог возила приметио поред десне ивице коловоза пешака, није смањив брзину већ је дао звучно упозорење пешаку који је започео прелажење коловоза клатећи се, па је налетео на пешака и оборио га“(4).

У новијој судској пракси наводи се у погледу оваквих ситуација и следеће: „...оштећени за оптуженог није представљао изненадну препреку јер није изненада ступио на коловоз, да је оптужени могао благовремено да га уочи будући да је до незгоде дошло на правом и прегледном путу и да су оштећени и сведок М. били у истом положају и када је мопед био удаљен 50 м, као и када је био на мањој удаљености, затим да је оштећени извршио окретање на начин како је то оптужени у одбрани описао и тиме положај свог тела изместио за око 0,3 м ближе левој ивици коловоза за колико се и приближио путањи кретања mopеда али да наведено управо значи да је оптужени приликом обилажења оштећеног био на удаљености од 0,3 м која није довољна обзиром на стајање пешака по средини коловоза“ (5).

Из наведеног јасно произилази да, ако се као пешак уверите да вас је возач наилазећег возила уочио, или се као возач уверите да је ваше присуство, односно присуство вашег возила које је у покрету пешак уочио, верујемо да делите наше мишљење да сте тиме избегли ризик да дође до контакта возила и пешака и наравно последицу коју нико од нас не жели.

Судска пракса са правом искључује допринос пешака који прелази на обележеном пешачком прелазу, чак и код изненадне промене правца кретања пешака. Тако у једном случају из старије судске праксе наводи се: „...Возач који је оборио пешака и нанео му смртоносне повреде морао је, приближавајући се пешачком прелазу, пошто је угледао пешака, да смањи брзину кретања возила до те мере да је могао да заустави возило.

Понашање пешака, који се дошавши до средине коловоза изненада вратио назад, не доводи у питање постојање кривице окривљеног за кривично дело угрожавања јавног саобраћаја са смртном последицом“(6).

Исти став у том погледу заузима и новија судска пракса, па се у једном случају наводи:

„...из резултата правилне оцене изведених доказа произилази поуздано утврђење првостепеног суда да на месту предметне саобраћајне незгоде саобраћај није регулисан уређајима за давање светлосних саобраћајних знакова нити знацима полицијских службеника, да оптужени управљајући аутобусом није прилагодио брзину кретања возила којим управља тако да у свакој ситуацији коју види, односно има разлога да предвиди, може безбедно да заустави возило испред пешачког прелаза, те је чеоним делом аутобуса, којим је управљао, ударио пешака, оштећеног сада покојног Миливоја Дрињаковића, који је коловоз прелазио на обележеном пешачком прелазу са леве на десну страну, гледано у смеру кретања оптуженог, којом приликом је дошло до обраћања пешака, кога је оптужени затим и прегазео аутобусом и нанео му смртоносне повреде услед којих је пешак преминуо на лицу места“(7).

Са друге стране, непрописна вожња моторног возила је узрок саобраћајне незгоде и онда када пешак незгоди доприноси прелазећи ван обележеног пешачког прелаза. Тако је другостепени суд нашао да при брзини од 50 км/х окривљени није могао да избегне контакт са оштећеном када је кочење започео тек пошто је пешакиња закорачила на коловоз и прешла пут од 1,2 м, како је то установио вештак.

Како је вожња окривљеног била је противна члану 80. став 4. у вези става 3. ЗООБС, јер приближавајући се обележеном пешачком прелазу није благовремено смањио брзину кретања нити зауставио возило како би пропустио пешакињу, прелажење коловоза ван обележеног пешачког прелаза од стране пешакиње не искључује кривичну одговорност окривљеног. (8)

Слична ситуација анализира се идентично и у новијој судској пракси: „...Према правилном утврђењу првостепеног суда које је резултат правилне оцене изведених доказа и то како казивања саслушаних лица тако и материјалних доказа, а посебно налаза и мишљења вештака утврђено је да се је оптужени кретао брзином од 55 км/х на делу пута на којем је брзина постављеним саобраћајним знаком била ограничена на 40 км/х, да се је кретао кроз насељено место и био у обавези да брзину кретања прилагоди стању и ситуацији на путу пре свега из разлога што је уочио пешаке поред коловоза.

Супротно ставу жалбе, првостепени суд је правилно утврдио да је оптужени имао разлоге да оцени постојање опасности на путу због присуства пешака које је уочио у непосредној близини коловоза, да је у таквој ситуацији, имајући у виду и да се је кретао у насељеном месту где се иначе може очекивати наилазак пешака на коловозу, да је међу пешацима у непосредној близини коловоза уочио и децу за коју објашњава да су се “врпољила“, те уз оцену околности да је исте уочио на удаљености од 40 метара, оптужени је имао разлога да предвиди присуство пешака на коловозу и да брзину кретања смањи на безбедну и прилагођену како би возило по потреби могао благовремено да заустави без контакта са пешацима.

Оцењујући трагове кочења и остале трагове констатоване на увиђају, вештак саобраћајне струке изјаснио се је о брзини кретања возила оптуженог, дужини зауставног пута при конкретној, односно брзини која је максимално дозвољена постављеним саобраћајним знаком, изнео податке о потребном времену заустављања и кретању пешака, па је оценом и овог доказа првостепени суд поуздано утврдио да је оптужени поступио супротно одредби чл.45. ЗООБС-а, да се није кретао прилагођеном брзином и да је тај његов пропуст у директној узрочној вези са насталом саобраћајном незгодом, при чему је правилно утврдио да постоје пропусти и на страни малолетне оштећене која је небезбедно прелазила коловоз, као и на страни њене мајке која је пропустила да контролише кретање“ (9).

Када пешак на коловозу лежи или се пак креће, у ноћним условима пресудно је да ли је возач у ноћним условима управљао брзином која је била у складу са ограничењем брзине на деоници пута на којој је дошло до незгоде и под упаљеним одговарајућим светлима, као и да ли је с обзиром на положај пешака и одећу коју је он имао на себи могао на време уочити ту препреку.

У једном од случајева из судске праксе анализира се и та ситуација, па се наводи: „...околност да се је оштећени критичном приликом кретао ноћу, на неосветљеном месту, неосветљен, неозначен рефлектујућом метеријом, уз то и у алкохолисаном стању, дакле да се је небезбедно кретао по коловозу улице, која има и тротоар намењен за кретање пешака, правилно је првостепени суд закључио да је исти створио изненадну, покретну, опасну и блиску препреку на путањи пута возила оптуженог, тим пре што је могао лако да уочи светла наизлазећег возила оптуженог, да се склони у страну, уступи првенство пролаза возилу и избегне настанак саобраћајне незгоде, јер се је кретао на коловозу, на јавном путу, ван насеља и није користио тротоар који је био намењен за кретања пешака, без обзира што је на њему мањим делом ширине био риголо и што је на њему било снега“(10).

У погледу деце, инвалида и старијих лица постоји посебно ограничење начела поверења у тој мери да би се рећи да ово начело у односу на њих не важи, тако да њихово неправилно понашање за возача не би требало да буде изненађење. Постоји повећана обавеза опрезног поступања возача, тако да и онда када ова лица која се налазе поред коловоза не показују намеру да пређу коловоз, возач мора пажљивије него када су у питању други пешаци да процењује могућност њиховог изненадног прелажења коловоза.

Но не би требало сасвим отићи у крајност, па увек без обзира на понашање ових лица и друге околности конкретног случаја узимати да постоји могућност њиховог изненадног прелажења а тиме и обавеза прилагођавања вожње, а да се то ни из чега у конкретном случају није могло закључити, јер би то отежавало и знатно успоравало саобраћај.

ЗАКЉУЧАК

У свим наведеним ситуацијама има места примени овог златног правила за које се залажемо.

Суштински, овако једноставно и симпатично правило гледано кроз призму судских одлука којима су пресуђене и саобраћајне незгоде са веома тешким последицама, без позивања и на правила поверења у саобраћају односно ограниченог поверења у саобраћају које се примењује у одлукама надлежних судова приликом тумачења пропуста појединих учесника у саобраћајној незгоди, да је било примењено у великом броју саобраћајних ситуација које су добиле свој судски епилог, резултирало би тим да до саобраћајних незгода уопште не дође.

Стога, апелујемо на све оне који прочитају овај рад, да учине тај мали напор и покушају да примене у пракси правило „док нам се погледи не сретну“, те ако се увере да су тиме безбеднији када се у било ком својству крећу нашим путевима, такво искуство пренесу и свим себи драгим људима, уз обавезно објашњење да је то златно правило за безбедност јавног саобраћаја.

ЛИТЕРАТУРА:

- [1] Закон о безбедности саобраћаја на путевима, Сл. гласник РС, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 (Одлука Уставног суда), 55/2014, 96/2015, 9/2016 (Одлука Уставног суда), 24/2018, 41/2018 (други закон), 41/2018, 87/2018, 23/2019.
- [2] Решење Окружног суда у Чачку Кж1 бр.314/04 од 12.9.2004., Интермех правна база.
- [3] Пресуда Окружног суда у Београду Кж1 бр.2325/05 од 1.12.2005., Интермех правна база.
- [4] Пресуда Апелационог суда у Нишу, Кж1 330/2018 од 8.5.2018., необјављено
- [5] Пресуда Окружног суда у Београду, Кж 316/2005, Драгољуб Симоновић, Кривична дела у српској легислативи, „Службени гласник“, Београд, 2010,стр.583.
- [6] Пресуда Апелационог суда у Нишу, Кж1 686/2015 од 27.8.2015., необјављено
- [7] Пресуда Окружног суда у Београду Кж. 665/05 од 17. 3. 2005., Интермех правна база.
- [8] Пресуда Апелационог суда у Нишу, Кж1 3098/2013 од 16.1.2014.
- [9] Пресуда Апелационог суда у Нишу, Кж1 892/2016 од 26.7.2016.

Др Дијана Јанковић

Судија Апелационог суда у Нишу

ЗАКОНСКИ ОСНОВИ ЗА УБЛАЖАВАЊЕ КАЗНЕ И СУДСКА ПРАКСА

Анстракт: Системом кривичних санкција је предвиђена законска могућност да суд кад одмерава казну за одређено дело, може изрећи блажу казну од оне која је прописана. Суд може изрећи казну која је нижа од прописаног минимума казне за то дело, а може и уместо прописане врсте казне изрећи другу, блажу врсту казне. Полазећи од тога да изречена казна треба да буде одраз два интереса: интереса друштва за спречавање криминалног понашања и интереса учиниоца да казна одговара тежини кривичног дела које је извршио и да буде прихваћена као праведна, законом је прописан институт ублажавања казне, којим се тежи да оба ова захтева буду испуњена. Имајући увиду наведени значај института ублажавања казне, у раду су изложене, законске могућности за примену овог института предвиђене у Кривичном законiku и његова примена у судској пракси.

Кључне речи: казна, ублажавање казне, олакшавајуће околности, нужна одбрана, крајња нужда, подстрекавање, покушај, сила и претња, правна заблуда

1.УВОД

Казна представља стални облик друштвене реакције на криминалитет и као таква представља увек ограничење одређених права и слобода човека, етичку осуду учиниоца за учињено дело, неодобравање и прекор једног друштва а тиме и подстицај и позив за све да се понашају у складу са захтевима друштва.

Казна произилази из потреба заједничког живота људи у уређеној друштвеној заједници, из самог социјалног живота и стања у међуљудским односима. Међутим, оправданост казне, у једном хуманом друштву, не може се сагледати само са аспекта потреба тог друштва, нарочито имајући у виду примену најтежих кривичних санкција. Казна обухвата човека као потпуну

личност, као лице које има свест о свом достојанству, слободи, одговорности, кривици па и кажњавању. То упућује на закључак да уз друштвену нужност, казну оправдава и свест о праведности казне, и то како у свести самог учиниоца, тако и у схватању друштва. Може се рећи да казну уопште оправдава њена нужност у социолошком смислу, али да она садржи у себи и захтев за поштовањем етичких норми и основних права и слобода човека.

Управо је у наведеном суштина, постојања института ублажавања казне.

Под ублажавањем казне подразумева се одмеравање блаже казне од оне која је законом прописана за одређено кривично дело. Институтот ублажавања казне закон, осим, оквира казне одређених за свако поједино дело, успоставља нове, шире, посебне оквире, унутар којих суд може изрећи казну која је блажа од оне прописане за конкретно кривично дело. Постојање овог института је израз потребе да се законска, апстрактна казна усклади са стварним значењем криминалне ситуације и да при томе одговори захтевима индивидуализације казне.

Дакле, при одмеравању казне се утврђује (оценом личности учиниоца, радње кривичног дела, кривице, сврхе кажњавања и осталих околности), да ли има места примени института ублажавања казне, те уколико се казна ублажава, врши се даље одмеравање казне у оквиру основа за ублажавање казне.

Олакшавајуће и отежавајуће околности (чл.54. КЗ) имају дејство на одмеравање казне учиниоцу дела, у границама посебног минимума и максимума казне одређене законом за то дело. Међутим, у извесним случајевима кривично дело може бити извршено под таквим околностима које га чине лаким, а посебно са аспекта личности учиниоца па одмеравање казне у законом предвиђеним границама, не би били правични, нити би одговарали сврси кажњавања. У таквим случајевима, сврха кажњавања се може остварити и благом казном од прописане, па је зато оправдано и постојање института ублажавања казне (чл.56. КЗ). Може се рећи да у ширем смислу, ублажавање казне представља даљу конкретизацију и проширење могућности одмеравања казне и могућност још прецизнијег прилагођавања казне конкретном случају и личности учиниоца.

Предмет анализе у раду су законски основи за ублажавање казне и судска делатност приликом одмеравања и ублажавања казне. Посебан осврт је извршен на судску праксу и одређена спорна питања која се јављају у примени

овог института. Институт ублажавања казне је посебно разматран са аспекта законских института који могу бити основ за ублажавање казне, као што су: прекорачење нужне одбране, прекорачење крајње нужде и изазивање опасности из нехата, битно смањена урачунљивост, покушај, неуспело подстрекавање, помагање, извршење дела под дејством силе која није неодољива или претње, отклоњива правна заблуда, који имају широку примену у пракси судова.

2.УБЛАЖАВАЊЕ КАЗНЕ У СИСТЕМУ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

Систем кривичних санкција је средишње питање кривичног права сваке земље, јер се кроз систем кривичних санкција изражавају основни принципи кривичног права, криминалне политике као и однос друштва према учиниоцима кривичних дела. Ради се о одређивању задатака и циљева кривичног права и о кривичноправним средствима којима они треба да се остваре. У најширем смислу кривичне санкције су једно од средстава одбране друштва од криминалитета, и облици реакције друштва на кривична дела.

Из тако постављеног концепта, наш систем кривичних санкција предвиђа више врста кривичних санкција. Кроз плурализам (у ширем смислу) система кривичних санкција, остварује се и прва (законска) индивидуализација кривичних санкција. Предвиђање више врста кривичних санкција, усмерено је у правцу прилагођавања појединих санкција потребама диференцираног поступања према појединим категоријама учинилаца и према појединим учиниоцима кривичних дела.

Кривични законик у чл.4. КЗ¹ предвиђа четири врсте кривичних санкција: казне, мере упозорења, мере безбедности и васпитне мере. Свака од ових врста кривичних санкција има своје подврсте. Тако је одредбом чл.43. КЗ прописано да се учиниоцу кривичног дела могу се изрећи следеће казне:1) доживотни затвор; 2) казна затвора; 3) новчана казна;4) рад у јавном интересу; 5) одузимање возачке дозволе.

У најопштијој категоризацији извршиоца кривичних дела полази се од малолетних и пунолетних учинилаца, те се казне, мере упозорења и мере безбедности примењују само на пунолетне учиниоце, док се васпитне мере

¹ Кривични законик ("Сл. гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019)- у даљем тексту КЗ

примењују према малолетним лицима. При томе су казне, условна осуда и судска опомена са једне стране, а мере безбедности са друге стране. Како казне и мере упозорења чине једну сродну групу санкција, јер су мере упозорења практично замена за казну, таква законска систематика само додатно омогућава одмеравање и индивидуализацију казне. У том смислу би се могло говорити о дуализму кривичних санкција у нашем кривично правном систему, који би се састојао од казни (и мера које је замењују) и мера безбедности.

Казна као тип санкције, везана је за кривицу и још увек представља главну санкцију система и од одлучујућег је значаја за остваривање циљева кривичног права. На индивидуалном плану она посебно укључује индивидуалну (специјалну) превенцију, а на друштвеном утиче на друштвено одговорно понашање, као подстицај за јачање друштвене свести и дисциплине (генерална превенција).

Такође је значајно, да наш систем кривичних санкција прихвата систем релативно одређених казни, што значи да за свако кривично дело прописује казну у одређеним оквирима, одређујући њену доњу и горњу границу и остављајући суду да у тим законским оквирима одмери казну. Кроз овај систем прописивања казни, наш систем кривичних санкција омогућава да се приликом судског одмеравања казне, казна прилагоди конкретној ситуацији и личности учиниоца.

Овакво схватање казне долази до изражаја и у одредбама које предвиђају законске могућности за њену индивидуализацију у судском поступку, кроз институте ублажавања казне и ослобођења од казне, када кривицу не мора нужно пратити казна.

Ублажавање казне, прописано је у чл. 56. КЗ и састоји се или у томе да се учиниоцу одмери казна испод границе казне прописане у закону за одређено дело, или да се примени блажа врста казне. Када постоје услови за ублажавање казне суд може ублажити казну само у границама које су законом одређене (члан 57. КЗ).

3. УБЛАЖАВАЊЕ КАЗНЕ ПРЕМА КРИВИЧНОМ ЗАКОНИКУ

Ублажавање казне је прописано у чл.56. ст.1. КЗ, те је предвиђено да се казна може ублажити:

1. када закон предвиђа да се казна може ублажити (то су општи основи за ублажавање казне - који се могу применити на сваког учиниоца и то је ублажавање казне услед постојања општих законских института: прекорачење нужне одбране, прекорачење крајње нужде и изазивање опасности из нехата, битно смањена урачуњљивост и друго, као и ублажавање казне по одредбама прописаним за ублажавање казне код појединих кривичних дела, што представља посебне законске основе за ублажавање казне, који се могу применити само на та кривична дела за која су прописани као нпр. кривично дело одузимање малолетног лица - чл.191.ст.5.КЗ, кривично дело неовлашћена производња, држање стављање у промет опојних дрога - чл.246.ст.6. КЗ и др.).
2. када закон предвиђа да се учинилац може ослободити од казне, а суд га не ослободи од казне и
3. кад суд утврди да постоје нарочито олакшавајуће околности и оцени да се и са ублаженом казном може постићи сврха кажњавања.

Међутим, закон никад не предвиђа обавезно ублажавање казне, већ само оставља могућност суду, да казну индивидуализује, прилагоди сваком конкретном случају, имајући у виду пре свега циљеве специјалне превенције, те да исту изрекне по врсти и мери која ће највише одговарати учињеном делу и личности учиниоца. При томе, сваки облик ублажавања казне (и када закон предвиђа основе за блаже кажњавање, односно ослобођење од казне, и када прописује нарочито олакшавајуће околности као могући основ за ублажавање казне) представља факултативни основ, и исти подлеже судској оцени приликом изрицања казне.

Дакле, закон не предвиђа законске основе за ублажавање казне, који би уколико се утврди њихово постојање аутоматски довели до блажег кажњавања. Сви основи за ублажавање казне, како законски, тако и нарочито олакшавајуће околности, су практично судски основи за ублажавање казне, јер након што се, најпре утврде у конкретном случају, постају предмет судске оцене, те суд процењује да ли сходно конкретном случају има места ублажавању казне, чиме се на једној широкој платформи реализује принцип индивидуализације казне.

Када су у питању нарочито олакшавајуће околности, долазе у обзир све оне околности које се иначе могу узети као олакшавајуће, кад се казна одмерава у редовним законским оквирима. Међутим, онда морају бити, закон то изричито тражи, нарочито олакшавајуће околности. Од обичних олакша-

вајућих околности оне се разликују по интензитету: то су оне околности које дело чине лакшим, које знатно смањују степен противправности и кривице, које нарочито указују на личност учиниоца, која нема изражен степен опасности за друштво, тако, да се апстрактна законска казна показује као престога за одређени случај.

То не значи, да у датом комплексу чињеница и околности, морају постојати - само нарочито олакшавајуће околности. Могу уз њих постојати и околности друкчије природе, и „обичне“ олакшавајуће и отежавајуће околности.

Приликом одмеравања казне ради се о односу свих тих околности, и о целокупној оцени дела и учиниоца на бази свих тих околности.

За ублажавање казне суд ће се одлучити онда кад с обзиром на све околности конкретног случаја дође до закључка да се и са ублаженом казном може постићи сврха кажњавања. То значи да суд мора приликом ублажавања казне водити рачуна да та ублажена казна буде у складу са захтевима генералне и специјалне превенције - укупне сврхе кажњавања.

4. ОВЛАШЋЕЊА СУДА ПРИ УБЛАЖАВАЊУ КАЗНЕ

Судска делатност има одлучујући значај приликом ублажавања казне. Одређујући дело и казну законодавац полази од општег, апстрактног модела противправног понашања. Кад суд одмерава казну, он има у виду дело, у његовим животно остварним оквирима, као и конкретног учиниоца тог дела.

Противречност која настаје из тог различитог приступа законодавца и суда, у оцењивању дела и учиниоца решава се, тако што сам закон предвиђа институте (општа правила о одмеравању казне, поврат, ублажавање казне, ослобођење од казне и др), као инструменте, којима даје суду овлашћења у одмеравању врсте и висине законом предвиђене казне, како би могао апстрактно прописану казну довести у склад са конкретним кривичним делом и учиниоцем у датом случају.

Задатак је суда да из правних одредница у законском опису кривичног дела препозна и утврди подударност неког понашања са тим описом и да од прописаних казни изабере управо за то понашање потребну и одговарајућу врсту и висину кривичноправне принуде садржане у казни.

Тиме, суд правно обликује конкретно кривично дело, као јединство његовог оствареног описа и стварно примењене казне. Законодавац прописује мерила кажњавања, а суд наставља његову делатност тиме што на сваки конкретан животни случај примењује та мерила. Задатак суда дакле није сведен или ограничен само на посредничку улогу између закона и стварности. Суд не примењује само мисаоне творевине у апстрактном законском изразу на стварне догађаје у животу већ применом казне доприноси коначном обликовању закона.

При томе, одмеравање казне које обавља суд није ни у ком случају нека механичка примена законских одредби, нити је то скуп правила која закон предвиђа за одмеравање казне, већ је увек криминално-политичко оцењивање дела и учиниоца. Судске одлуке у области одмеравања казне су резултат креативне активности, којом се успостављају реални садржаји кривичноправне науке. Судска делатност при одмеравању казне није само техника примене закона, већ акт друштвеног обликовања у закону прописане казне. Тумачење закона од стране суда је *par excellence* стваралачки посао, а судска пракса има неспорно стваралачку улогу, и то управо у формирању научних сазнања.²

Материја одмеравања и индивидуализације казне је таква да се не може чврсто регулисати законским прописима и суду увек остаје широк простор за оцену о одговарајућој казни. Тиме је, објективно, створена могућност да на овом подручју кривичног права у знатној мери дођу до изражаја судске оцене и ставови.

Суд има изузетно велика овлашћења у избору врсте и висине санкције. Притом, најважније норме и већина норми којима се регулишу та овлашћења су у ствари оријентациона правила и путокази. Карактеристично је да те одредбе немају ону строгу одређеност, која је иначе карактеристична за законске норме. Одредбе о одмеравању казне нису тако формулисане да намећу и осигуравају обавезно њихову јединствену примену. Најважније норме, заправо су норме – смернице, тако да више указују на чињенице које судија мора узети у обзир при одлуци о казни, него што саме диктирају одређени резултат, одређену оцену (нпр. однос степена кривице и висине казне, или –

² Хорватић, Ж.: *Казнено право и друге казнене знаности*, Одабрани радови 1963-2003 године, Правни факултет у Загребу, Загреб, 2004.стр. 356.

које околности оценити као отежавајуће односно олакшавајуће, како ценити личност учиниоца као околност при одмеравању казне и др.).³

У судској одлуци о казни, ипак се не ради ни о слободној дискрецији, о некој арбитрарној одлуци, већ се ради о коришћењу великих овлашћења, везаних увек у крајњој линији, уз одређени материјални пропис (принцип законитости). У питању су увек правно везана дискрециона овлашћења.

Најпре, закон предвиђа врсте казни и њихове опште минимуме и максимуме, а у посебном делу Кривичног законика, код сваког појединог кривичног дела прописује врсту и посебне минимуме и максимуме казне. Одређујући овако казне у границама посебног и општег минимума и максимума, закон обавезује суд да на основу утврђеног чињеничног стања утврди и изрекне одређену висину казне. Законским прописивањем врсти кривичних санкција и граница у којима суд може да се креће, онемогућена је произвољност суда и обезбеђена законитост и истовремено дата суду могућност да буде активан фактор у одмеравању казне према конкретном случају.⁴

У том смислу судска одлука о казни истовремено је и чин примене права, али и чин одмеравања, вредносног оцењивања. Одмеравање казне је питање примене права, са специфичношћу да суд има знатан простор за процену. Зато се може рећи да је судска одлука о казни чин примене права, посебне врсте и она увек има велико значење. Она није никад једна гола, формална процена и примена закона, већ један стваралачки акт на црти утврђивања најсврхисходније санкције, наравно у границама постављеним законом.

Поменули бисмо, а у вези са одмеравањем и индивидуализацијом казне да се у правним разматрањима, нарочити значај се даје судији и његовој способности да у сваком конкретном случају приликом одмеравања казне, препозна суштину кривичног законодавства, његове основне принципе и идеје, основне идеје целокупног права, правно-филозофске основе кривичног права, смисао друштвеног система, да је у стању да нађе критеријуме и вредности за своје ставове при избору казне и да од њих полази.

³ Кос, Д.: *Институт ублажавања казне у процесу њезине индивидуализације*, Хрватски летопис за казнено право и праксу, бр.2/2003, Загреб., 2003.стр.429.

⁴ Јовановић, Љ. *Кривично право - општи део*, Научна књига, Београд, 1973, стр.267.

У савременом кривичном праву нема интенција да се ограниче овлашћења суда приликом одмеравања казне. Постоји настојање да се судско одмеравање казне, као изузетно значајна делатност, за појединца и друштво, стави у границе законске линије кажњавања и то одређивањем низа начелних ставова који треба да осигурају легалитет на овом подручју.

5.УБЛАЖАВАЊЕ КАДА ЗАКОН ПРЕДВИЂА ДА СЕ КАЗНА МОЖЕ УБЛАЖИТИ (чл.56.тач.1. КЗ)

Ублажавање казне, а с обзиром на околност да се уместо казне коју је закон прописао за једно дело, изриче нека друга блажа казна — је изузетак од редовног начина одмеравања казне, који се састоји у одмеравању казне у оквирима казне које је закон прописао за одређено дело.

По нашем кривичном закону ублажавање казне је институт општег значаја, оно може бити примењено код сваког кривичног дела, осим уколико се ради о кривичним делима која су изузета од ублажавања (чл.57. ст.2. КЗ). Казна се не може ублажити за кривична дела из чл. 114, 134. ст 2. и 3, 178, 179, 180, 214. ст. 2. и 3, 246. ст. 1, 3. и 4, 350. ст. 3. и 4. и 388. КЗ.

Закон предвиђа могућност ублажавања казне у чл.56. ст.1. КЗ, ако суд утврди да постоји:

- 1) прекорачење нужне одбране (чл. 19.ст.3. КЗ),
- 2) прекорачење крајње нужде и изазивање опасности из нехата (чл.20. ст.3. КЗ),
- 3) битно смањена урачунљивост (чл.23.ст.3. КЗ),
- 4) покушај (чл.30.КЗ),
- 5) неуспело подстрекавање (чл.34.ст.2. КЗ),
- 6) помагање (чл.35.ст.1. КЗ),
- 7) извршење дела под дејством силе која није неодољива (комплузивна сила) или претње (чл.21.ст.2.КЗ),
- 8) отклоњива правна заблуда (чл.29.ст.3 КЗ).

Наведени институти имају широку примену у пракси судова. У наредним излагањима ће бити разматрани законски услови за њихову примену а посебно њихова оцена од стране суда, приликом одмеравања и ублажавања казне, у случају када је након утврђеног чињеничног стања, утврђено да има места њиховој примени.

5.1. Прекорачење граница нужне одбране и ублажавање казне

Одредбом чл.19.ст.3. КЗ, је прописано да се учиниоцу који је прекорачио границе нужне одбране, казна може ублажити. Ако је учинилац прекорачио границе нужне одбране, услед јаке раздражености или препаста изазване нападом, може се и ослободити од казне. Тиме је регулисано тзв. прекорачење граница нужне одбране и утицај тог прекорачења на одмеравање казне.

Једно од најспорнијих питања у судској пракси је, када је дошло до прекорачења граница нужне одбране. Сагледавање личности учиниоца и остваривање принципа индивидуализације казне, је од превасходних значаја у примени овог института. У конкретним ситуацијама је врло тешко разграничити да ли се радило о одбрани која је била неопходно потребна за одбијање напада или је, пак, реч о прекорачењу граница нужне одбране, а последице тог разграничења су правно релевантне и за судску одлуку о казни.

Уколико суд утврди да одбрана није била неопходно потребна, онда нема једног услова за постојање нужне одбране и нападнути-учинилац одговара за извршено дело, с тим што му се околности под којима је дело учињено могу узети као олакшавајуће при одмеравању казне. С друге стране, прекорачење граница нужне одбране претпоставља да су постојали сви услови за нужну одбрану, али је приликом одбијања напада дошло до прекорачења нужности. И у таквој ситуацији учинилац одговара за учињено дело, али се може блаже казнити или ослободити од казне.

У одговору на питање да ли су прекорачене границе нужне одбране, потребно је прво поћи од питања: да ли је постојала нужна одбрана, да ли су били испуњени сви услови на страни напада и одбране и тек када се то утврди, може се поставити питање да ли су прекорачене границе нужне одбране.

Може се рећи да су границе нужне одбране прекорачене када постоји знатна несразмера између напада и одбране, посебно, када је у непоходном одбијању напада учињено више него што је требало.

Приликом оцене да ли има места ублажавању казне у случају прекорачења граница нужне одбране, суд ће приликом одмеравања казне, управо ценити израженост поменуте несразмере и колико је несразмерност допринела последицама дела, сагледавајући личност учиниоца и његове личне особине, као и околности под којима је дошло до прекорачења нужне одбране. Реч

је о једном фактичком питању које се процењује према сваком конкретном случају, а оцена о томе да ли је постојала знатна несразмера између одбране и напада те уколико је постојала који њен степен, заснива се на свим околностима датог случаја. За суд су, приликом утврђивања чињеничног стања, а следствено томе и одмеравање казне значајне три околности:

1. однос добра која су повређена или угрожена при нападу и то како по њиховој природи тако и по вредности,
2. употребљена средства при нападу и при одбијању напада и
3. личност нападнутог – учиниоца, пре свега у погледу његовог старосног доба, физичког стања и душевног здравља, личног или сродничког односа и др.

При томе је, у корелацији са сва три фактора при одмеравању казне, централна личност учинилац, и његов лични, субјективни однос према нападнутим и угроженим добрима.

Могућности ублажавања казне за дела учињена у прекорачењу нужне одбране, дају суду простора за индивидуализацију казне. При одмеравању казне, је посебно значајан однос учиниоца према последици и његов психички статус у време извршења дела. Битно је утврдити да ли је нападнути-учинилац био у стању да правилно процени ситуацију и да прилагоди границе своје одбране, истовременом противправном нападу. Поред тога, важно је утврдити интензитет прекорачења, односно да ли је до прекорачења евентуално дошло услед јаке раздражености или препаста изазване нападом, а што представља факултативни основ за ослобођење од казне.

Тако је у пресуди **Врховног суда Србије** Кж.34/91, утврђено да када оштећени оптуженог удара рукама по глави, а овај одбијајући напад удари га ножем, чини кривично дело у прекорачењу граница нужне одбране, јер постоји несразмерност у интензитету одбране и напада, на штету оштећеног као нападача.⁵

Апелациони суда у Нишу је у пресуди Кж1 703/2021 од 8.12.2021. године, оценио да се: „Неосновано жалбом браниоца оптуженог указује да је оптужени поступао у прекорачењу нужне одбране, те се жалбом браниоца оптуженог инсистира, да је оптужени узео нож и поступио на наведени на-

⁵ Симић, И.: *Збирка судских одлука из кривично-правне материје*, Службени гласник, Београд, 1994, стр.14

чин, јер се бојао оштећеног који је био крупније телесне грађе. Међутим, за постојање нужне одбране из чл.19. ст.1. и ст.2. Кривичног законика, као и прекорачења нужне одбране из чл. 19. ст.3 Кривичног законика, је неопходно да постоји истовременост напада и одбране, а не само страх од одређене особе. Наиме, првостепени суд је правилно утврдио да је напад оштећеног према оптуженом (оштећени је оптуженом задао четири ударца затвореном шаком у пределу лица) престао, у тренутку када је оптужени, оштећеном, нанео конкретне повреде.

Ово стога, јер је првостепени суд, на основу одбране оптуженог, а што је сагласно и са исказима оштећеног А.А. и сведока Б.Б., утврдио, да је оптужени, након што му је оштећени задао ударце, завукао руку у торбицу извукао нож на расклапање, исти расклопио и ножем замахнуо према оштећеном, којом приликом је оштећени задобио предметне повреде. Првостепени суд је правилно закључио да оптужени у својој одбрани (ни у истрази ни на главном претресу) није навео, да је постојао истовремени напад од стране оштећеног према њему у тренутку када је извадио нож и нанео оштећеном конкретне повреде. Осим тога, првостепени суд је правилно утврдио, на основу исказа оштећеног А.А. и сведока Б.Б., да је сведок Б.Б., након што је оштећени ударио оптуженог, стала између оптуженог и оштећеног а да је при томе оптужени све време имао нож у руци и замахивао према оштећеном ножем, као и из налаза и мишљења вештака медицинске струке да повреда коју је оптужени нанео оштећеном А.А., у виду секотине на задњој унутрашњој страни леве надлактице, положајем одговора повреди која се наноси нападној особи у положају подигнуте руке у ставу одбране.

Сходно наведеном, по оцени Апелационог суда у Нишу, првостепени суд је правилно утврдио да је напад оштећеног према оптуженом престао у тренутку када је оптужени предузео радње према оштећеном и нанео му повреде ближе описане у изреци побијане пресуде, те како у конкретном случају нема елемената нужне одбране из чл.19. ст. 1. и ст.2. Кривичног законика, то се жалбом браниоца оптуженог неосновано указује и на постојање прекорачења нужне одбране из чл.19. ст.3. Кривичног законика.“

Такође је и пресудом Врховног касационог суда КЗЗ 315/2022 од 19.04.2022. године, одбијен као неоснован захтев за заштиту законитости браниоца окривљеног, поднет против правноснажних пресуда Вишег суда у Београду и Апелационог суда у Београду, јер је нашао да се неосновано

захтевом браниоца окривљеног указује на постојање прекорачења нужне одбране.

Образлажући повреду закона бранилац је у захтеву за заштиту законитости навео:

„Да је побијаним пресудама повређен закон и то у домену кривично-правног института нужне одбране (члан 19. КЗ). По ставу одбране, ниже-степенни судови су извршили повреду закона, у делу правне квалификације, јер је оштећени АА, одбијајући напад окривљеног, који је применом силе развалио прихватник браве на вратима стана оштећеног, у правцу окривљеног први испалио пројектил из пиштоља и погодио га у пределу трбуха, носећи му тешку телесну повреду опасну по живот, те је након тога још једном испалио пројектил у правцу окривљеног.

На описани начин, по ставу браниоца оштећени је прекорачио границе своје нужне одбране и његова одбрана не представља одбрану која је била неопходно потребна за одбијање напада, већ прекорачење (екцес) граница нужне одбране у виду такозваног интензивног прекорачења које представља кривично дело.

Даље, бранилац закључује да то значи да је окривљени као првобитни нападач на имовину оштећеног имао право на нужну одбрану у односу на кривично дело које је оштећени АА извршио у прекорачењу нужне одбране. Ово тим пре што постоји очигледна несразмера између вредности нападачевог добра и добра које се брани. Даље се наводи да се одбрана окривљеног огледала у томе да је окривљени у стању повишене афективне напетости са садржајем страха високог интензитета, из трпезарије, кроз затворена врата, из пиштоља који је неовлашћено носио, на удаљености од 20 центиметара од врата, испалио пројектил у правцу где је непосредно пре тога стајао оштећени и погодио га у пределу главе.

Ову одбрану је окривљени применио за одбијање истовременог противправног напада оштећеног, извршеног у прекорачењу нужне одбране, јер је оштећени АА из пиштоља у правцу окривљеног први испалио пројектил (први употребио ватрено оружје) и погодио га у пределу трбуха којом приликом је задобио тешку телесну повреду опасну по живот, па је након тога испалио још један пројектил у правцу окривљеног бранећи се од багателног напада окривљеног, који је снагом развалио прихватник браве врата и ушао у његов стан и тиме напао имовину оштећеног, делујући на ствари.

По оцени Врховног касационог суда, неосновано бранилац у поднетом захтеву указује на повреду кривичног закона из члана 439. тачка 1. ЗКП. Околности наведене у предметном захтеву, одбрана окривљеног изнета је и у жалби изјављеној против првостепене пресуде, а другостепени суд је нашао да су ти жалбени наводи неосновани и с тим у вези, у образложењу пресуде, дао довољне и јасне разлоге, које Врховни касациони суд прихвата и, у смислу одредбе члана 491. став 2. ЗКП, на те разлоге упућује.“

Прекорачење нужне одбране је у утврђено и у пресуди **Апелационог суда у Нишу**, Кж1 420/20 14 од 14.10.2015. године. Апелациони суд у Нишу је у образложењу пресуде навео да је: „Оценом одбране оптуженог, као и исказа сведока А.А. и Б.Б., утврдио да је током критичног догађаја оштећени најпре сустигао оптуженог који је бежао од њега и ударио му два шамара затим га је шутнуо га од којих ударца је оптужени пао на тло и да је затим наставио и даље да га шутира у пределу грудног коша и стомака, те да је оптужени узео нож на расклапање дужине сечива 10 цм, који му је при паду пао на бетон и три пута убо оштећеног у пределу трбуха и грудног коша и два пута у пределу лица и нанео му напред наведене телесне повреде.

По оцени Апелационог суда оптужени је критичном приликом одбијајући истовремени нескривљени противправни напад оштећеног, прекорачењем граница нужне одбране покушао овога да лиши живота, јер је оштећени оптуженог ногама ударао у пределу груди и стомака, те га је оптужени одбијајући напад ударио ножем, тако што му је нанео три убода у виталне делове тела и то убодну рану испод левог ребарног лука, убодну рану испод десног ребарног лука и убодну рану у петом међуребарном простору, које повреде представљају тешке телесне повреде опасне по живот, а затим још две посекотине у пределу лица, што указује на несразмерност у интензитету одбране и напада на штету оштећеног као нападача.

Сходно наведеном, оценом доказа изведених на претресу пред другостепеним судом, Апелациони суд је утврдио да се у радњама оптуженог стичу сва обележја кривичног дела убиство у покушају у прекорачењу нужне одбране из чл.113. у вези чл. 19. ст.3 и чл. 30 КЗ. Оптужени је у конкретном случају прекорачивши границе нужне одбране покушао да лиши живота оштећеног Ц.Ц. на напред утврђени начин, при чему је био свестан забрањености свога дела и да таквим својим чињењем може лишити живота оштећеног па је то и

хтео, а дело није довршио јер је оштећеном пружена благовремена лекарска помоћ.“

5.2. Прекорачење граница крајње нужде и ублажавање казне

Законском одредбом чл.20.ст.3. КЗ је предвиђено да учиниоцу који је сам изазвао опасност, али из нехата или је прекорачио границе крајње нужде, може се казна ублажити. Дакле, у наведеном погледу закон разликује две ситуације: кад је опасност изазвана из нехата и када је дошло до прекорачења граница крајње нужде.

Посебна ситуација је, ако је учинилац прекорачио границе крајње нужде под нарочито олакшавајућим околностима, и тада се може ослободити од казне. У сваком конкретном случају, за одмеравање казне је од превасходног значаја утврдити стање у коме се учинилац налазио у време извршења дела, да ли је поступао у страху, бесу и сл. С друге стране, значајни моменти се односе и на саму личност учиниоца у оној мери у којој је та личност дошла до изражаја у извршеном делу.

На крајњу нужду се не може позивати учинилац, који је сам скривео опасност а затим приликом њеног отклањања повредио нечије правно добро и на тај начин остварио обележје неког кривичног дела. Суд ће у сваком конкретном случају утврђивати да ли је у питању скривљена опасност, тј. да ли је опасност изазвана са умишљајем или из нехата. Посебно ће суд при одмеравању казне ценити и опште интелектуалне способности учиниоца, у погледу његовог схватања значаја дела.

Када је у питању прекорачење крајње нужде, претпоставља се да су постојали сви услови за постојање крајње нужде, и то како на страни опасности тако и отклањања опасности, али да је прекорачена граница сразмерности добара, која се тражи за крајњу нужду.

Неопходно је најпре у сваком конкретном случају утврдити да ли је:

1. у отклањању нескривљене опасности било нужно повредити нечије правно добро, и
2. да је учињено зло веће од зла које је претило, односно да је у отклањању опасности учињено више штете (нането више зла) него што је било неопходно да би се опасност отклонила.

Након што суд утврди постојање крајње нужде, а затим и њено прекорачење, приступа се оцени личности учиниоца и његовом односу према делу и последици као и степена кривице. Осим тога, суд ће сагледати и посебно психичко стање учиниоца у коме се он налазио у време извршења дела. Суд ће оценом свих околности утврдити, пре свега, околности прекорачења крајње нужде, и извршити оцену да ли на основу истих треба ублажити казну (и применити одредбу чл.57.КЗ) или пак можда има основа исте сматрати „нарочито олакшавајућим околностима“ и учиниоца ослободити од казне (чл.58.КЗ).

Приликом утврђивања околности конкретног случаја, суд ће ценити све околности објективне и субјективне природе везане за крајњу нужду, посебно природу и интензитет опасности, стање лица које се налази у опасности и његове могућности за њено отклањање и сл. Након наведене оцене у зависности од утврђених чињеница, суд ће процењивати да ли су оне по својој природи такве, да иду у прилог учиниоца дела (олакшавајуће) и да ли по својој природи и интензитету у извесној мери „оправдавају“ прекорачење граница крајње нужде. У складу са наведеном проценом суд ће извршити и одмеравање казне.

У судској пракси, је примена института крајње нужде била предмет оцене, међутим, након сагледавања свих околности конкретног случаја суд може оценити и да нема места његовој примени.

У пресуди **Врховног суда Србије** Кж.407/93 од 06.03.1993 године, је утврђено: „Да нема места примени института крајње нужде, када је оптужени, пуцајући у возача, кога је хтео да спречи да не побегне путничким возилом, које је управо одузео од оптуженог, истог усмрти“. У образложењу наведене пресуде је оцењено: „Да нема места примени института прекорачења граница крајње нужде, иако је оптужени био овлашћен да поврати власт, над својим возилом које му је противправно одузето, јер је људски живот, неупоредиво веће добро него путнички аутомобил“.⁶

Из поменуте одлуке произилази да је суд нашао, да се у утврђеној ситуацији, уопште не може применити институт крајње нужде, јер позивање на тај институт, у наведеној ситуацији и није могуће. Суд је дакле посебно ценио

6 Симић, И.: *оп.cit.*стр.24.

личност и понашање учиниоца, које практично представља драстично одступање од уобичајеног поступка за повраћај имовине.

Пресудом **Врховног касационог суда**, КЗЗ 166/2020 од 27.02.2020. године, одбијен је као неоснован захтев за заштиту законитости браниоца окривљеног, поднет против правноснажних пресуда Вишег суда у Београду и Апелационог суда у Београду, јер је нашао да се неосновано захтевом браниоца окривљеног указује на постојање крајње нужде.

„Поднетим захтевом браниоца окривљеног се указује на повреду кривичног закона из члана 439. тачка 1. и тачка 2. ЗКП у вези члана 19. и члана 20. КЗ, јер је окривљени, по ставу одбране, морао бити ослобођен од оптужбе или применом института нужне одбране или применом института крајње нужде. Одбрана налази да је суд у редовном кривичном поступку побијане осуђујуће пресуде донео заузимајући погрешно становиште да „напад оштећеног ББ није био противправан, те с'тога окривљени АА није имао право на нужну одбрану“. Осим тога, одбрана налази да је окривљени морао бити ослобођен од оптужбе применом института крајње нужде „с'обзиром да је од свог добра отклонио истовремену нескривљену опасност која се на други начин није могла отклонити, када је оштећеног само одгурнуо, ослободивши се његовог загрљаја, након чега је наставио да трчи, при чему учинено зло није веће од зла које је њему претило.“

Према ставу Врховног касационог суда у наведеној пресуди: „Институт нужне одбране је могуће применити у ситуацији када из чињеничног описа радње извршења кривичног дела произлази постојање истовременог противправног напада. Како из изреке побијане пресуде Вишег суда у Београду не произлази постојање противправног напада извршеног од стране оштећеног ББ према окривљеном АА, у смислу члана 19. став 2. КЗ, то ни у радњама окривљеног нема елемената одбијања од себе или другог истовременог противправног напада, из ког разлога, по налажењу Врховног касационог суда, није могуће поступање окривљеног АА у нужној одбрани, те нема места примени института нужне одбране.

Из истих разлога неосновано је и указивање одбране окривљеног да је суд окривљеног морао ослободити оптужбе применом института крајње нужде односно применом одредби члана 20. КЗ, јер изреком побијане пресуде Вишег суда у Београду није описано, нити утврђено, постојање елемената крајње нужде - у смислу члан 20. став 2. КЗ.

Из наведених разлога, супротни наводи у захтеву браниоца окривљеног, да су побијане правноснажне пресуде донете уз повреду Кривичног закона из члана 439. тачка 1. и тачка 2. ЗКП у вези са одредбом члана 19. и члана 20. КЗ су оцењене као неосноване.“

5.3.Битно смањена урачунљивост и ублажавање казне

Чланом 23. став 3. КЗ је предвиђено да се учиниоцу кривичног дела, чија је способност да схвати значај свог дела или способност да управља својим поступцима, била битно смањена услед неког из стања из става 2. истог члана (битно смањена урачунљивост), може ублажити казну.

Дакле, из наведене законске одредбе произилази да је иста директно везана за оцену личности учиниоца као и степена кривице те да када суд установи да је учинилац у време извршења кривичног дела био битно смањено урачунљив, може изрећи ублажену казну.

Смањена урачунљивост је факултативни основ за ублажавање казне, јер претпоставља мањи степен кривице. Ако суд утврди да способност учиниоца да схвати значај свог дела и да управља својим поступцима, није била битно смањена, али да је ипак смањена, та се околност може узети у обзир као олакшавајућа околност (чл.54.ст.1.КЗ). У теорији има ставова да смањена урачунљивост и кад није битна, може у склопу других околности, бити основа за блаже кажњавање⁷, али ће тада бити цењена у смислу чл.56. тач.3. КЗ.

С обзиром да кривица представља битну детерминанту за индивидуализацију казне, и нераскидиво је везана за личност учиниоца јер изражава његов субјективни однос према делу, при чему је психички статус извршиоца од непосредног утицаја на остваривање циљева специјалне превенције, јасно је да је утврђивање чињеница из предметног института од превасходног значаја за ублажавање казне.

Учиниоца који је дело извршио у стању битно смањене урачунљивости одговара за кривично дело учињено са умишљајем, али и за кривично дело учињено из нехата, када закон предвиђа одговорност и за тај облик виности.

Према ставу **Апелационог суда у Нишу**, у решењу Кж1 3/2022 од 14.1.2022. године, потребно је да суд пре свега јасно утврди: „у ком степену

⁷ Таховић, Ј.: *Кривично право - општи део*, Савремена администрација, Београд, 1961, стр. 226.

је душевно стање оптуженог (стање привремене душевне поремећености) утицало на његову способност да схвати значај свог дела и да управља својим поступцима, те да ли је у таквом душевном стању оптужени био способан да схвати значај свог дела и да управља својим поступцима, па да у склопу тога да јасне разлоге о урачунљивости оптуженог у време извршења дела“.

Наиме, **Апелациони суд у Нишу** је нашао да се: „Жалбом браниоца оптуженог основано указује да првостепени суд није дао јасне разлоге на основу којих конкретних чињеница и околности закључује да је оптужени, а имајући у виду налаз и мишљење вештака психијатра др Г.Г. и све околности конкретног догађаја, био битно смањено урачунљив. Наиме, вештак психијатар др Г.Г. у налазу и мишљењу утврђује душевно стање оптуженог као стање привремене душевне поремећености, те га ближе описује, налазећи да је оптужени, између осталог, био у стању сличном делиријуму, а затим вештак само констатује да је оптужени био битно смањено урачунљив. Жалбом браниоца оптуженог се основано указује, да је нејасно, да ли је оптужени, у стању, које је утврдио вештак психијатар, услед привремене душевне поремећености, могао да схвати значај свога дела и био способан да управља својим поступцима, при чему утврђено стање привремене душевне поремећености, може довести и до неурачунљивости (чл.23. ст.2. Кривичног законика) и до битно смањене урачунљивости (чл.23. ст.3. Кривичног законика).“

У пресуди **Окружног суда у Београду** Кж. 1765/01 је оцењено да: „Институт битно смањене урачунљивости не искључује умишљај као психички однос оптуженог према делу, па је стога могуће поступати са умишљајем и у стању битно смањене урачунљивости“.⁸

Такво лице се кажњава за учињено кривично дело, с тим што је битно смањена урачунљивост, факултативни основ за ублажавање казне. С обзиром на блажу одговорност учиниоца са битно смањеном урачунљивошћу, потребно је утврдити, да ли је одређени душевни поремећај, имао утицаја на предузимање конкретне радње, која је инкриминисана као кривично дело.

Суд ће у датом случају при одмеравању, ценити да ли поред битно смањене урачунљивости, постоје и друге околности које су евентуално отежа-

8 Пресуда Окружног суда у Београду Кж. 1765/01 од 27. 11. 2001 године, и пресуда Другог општинског суда у Београду К. 1232/00 од 26. јуна 2001. године, Збирка судских одлука "Интермекс Судска Пракса", 2009.

вајућег карактера, те да ли је оправдано и основано у конкретном случају извршити ублажавање казне.

При томе, ће суд нарочито имати у виду личност учиниоца и ценити, зависно од конкретног случаја, нпр:

1. структуру личности учиниоца,
2. да ли је личност повратник,
3. да ли се ради о асоцијалној или антисоцијалној личности,
4. да ли лице има радне навике,
5. да ли прихвата социјално-етичке норме понашања,
6. како ће ублажавање казне деловати на такву личност и то првенствено у погледу специјалне превенције, односно процене да ли ће и ублажена казна утицати на учиниоца да убудуће не чини кривична дела.

Оно што диференцира положај ових учинилаца од урачунљивих учинилаца, је и то што се према њима уз казну морају применити мере безбедности медицинске природе а у смислу чл.81. и 82. КЗ.

5.4.Покушај и ублажавање казне

Чланом 30. КЗ је у ставу 1. предвиђено, да ко са умишљајем започне извршење кривичног дела, али га не доврши, казниће се за покушај кривичног дела, за које се по закону може изрећи казна затвора од пет година или тежа казна, а за покушај другог кривичног дела само кад закон изричито прописује кажњавање за покушај. У ставу 2. истог члана је даље прописано, да ће се учинилац за покушај казнити казном прописаном за кривично дело или ублаженом казном.

Покушај је на тај начин законом предвиђена факултативна околност за ублажавање казне (став 2.) Суд тада може учиниоцу изрећи казну у границама које су прописане за извршено дело, са могућношћу да се покушај узме као олакшавајућа околност (чл.54. КЗ), или може изрећи блажу казну у границама прописаним у члану 57. КЗ.

Покушај је по дефиницији, умишљајно започињање извршења кривичног дела, при чему није наступила последица која је била обухваћена умишљајем учиниоца. Суд као и у случају других института који су факултативни основи за ублажавање казне, најпре утврђује да ли постоји тај институт, у овом случају да ли се ради о покушају, односно да ли је започето извршење дела.

Три су конститутивна елемента покушаја кривичног дела:

1. започињање извршења,
2. одсуство последице и
3. умишљај учиниоца да изврши кривично дело.⁹

Приликом одмеравања казне и оцене суда да ли има места ублажавању казне код покушаног кривичног дела, разматра се карактер и врста последице, као и однос учиниоца према тој последици, која би да је кривично дело довршено наступила.

При томе, велики значај има предмет, време, место и начин извршења и у којој мери је учинилац био свестан тих околности. На основу оцене свих тих околности суд ће одлучити о врсти и висини казне за покушано кривично дело.

Пресудом **Врховног касационог суда** КЗЗ 821/2019 од 04.12.2019. године, усвојен је захтев за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца као основан и утврђено да је правноснажном пресудом Апелационог суда у Београду у корист окривљеног АА повређен закон – члан 439. тачка 3. Законика о кривичном поступку у вези са чланом 57. став 1. тачка 2. Кривичног законика.

Врховни касациони суд је нашао да је наведени захтев основан, јер се из списка предмета утврђује се да је „првостепеном пресудом окривљени АА оглашен кривим због извршења кривичног дела убиство у покушају из члана 113. у вези са чланом 30. КЗ прекорачењем граница нужне одбране, у вези члана 19. став 3. КЗ, за које дело је применом одредаба чланова 56. и 57. КЗ о ублажавању казне испод законом прописаног минимума, осуђен на казну затвора у трајању од три године, у коју казну му је урачунато време проведено у притвору.

Апелациони суд у Београду, као другостепени, преиначио је првостепену пресуду само у погледу одлуке о казни, тако што је применом одредаба чланова 56. и 57. КЗ окривљеног осудио на казну затвора у трајању од две године и шест месеци, у коју казну му је урачунао време проведено у притвору.

Поступајући на овај начин – преиначујући првостепену пресуду у погледу одлуке о казни тако што је окривљеног осудио на казну затвора у трајању

⁹ Лазаревић, Љ.: *Коментар Кривичног законика Републике Србије*, Савремена администрација, Београд, 2006, стр.108.

до две године и шест месеци за кривично дело убиство у покушају из члана 113. у вези члана 30. КЗ, прекорачењем границе нужне одбране у вези са чланом 19. став 3. КЗ увези са чланом 19. став 3. КЗ, Апелациони суд у Београду је учинио повреду кривичног закона из члана 439. тачка 3. ЗКП у вези са чланом 57. став 1. тачка 2. КЗ у корист окривљеног, што се основано истиче у захтеву за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца.

За кривично дело убиство из члана 113. КЗ, Кривичним закоником прописана је казна затвора од 5 до 15 година.

Одредбом члана 56. КЗ, прописани су случајеви у којима је суд, изузетно од општег правила о одмеравању казне у границама прописаним законом за одређено кривично дело, овлашћен да учиниоцу кривичног дела казну ублажи по мери или врсти, те тако учиниоцу кривичног дела може изрећи казну испод границе прописане законом или блажу врсту казне кад закон предвиђа да се казна може ублажити, кад закон предвиђа да се учинилац може ослободити од казне, а суд га не ослободи од казне или када утврди да постоје нарочито олакшавајуће околности и оцени да се и са ублаженом казном може постићи сврха кажњавања.

Одредбом члана 57. став 1. КЗ, прописане су границе за ублажавање казне када за то постоје услови из члана 56. КЗ, па се у смислу одредбе члана 57. став 1. тачка 2. КЗ, ако је за кривично дело као најмања мера казне прописан затвор у трајању од пет година, учиниоцу кривичног дела казна може ублажити до три године затвора.

Одредбом члана 19. став 3. КЗ, прописано је да се учиниоцу који је прекорачио границе нужне одбране казна може ублажити, а ако је учинилац прекорачио границе нужне одбране услед јаке раздражености или препаста изазване нападом, може се и ослободити од казне.

Према стању у списима, окривљени АА је првостепеном пресудом оглашен кривим што је „...у стању повишене афективне напетости са садржајем афекта гнева средњег интензитета, којом приликом су његове способности схватања, значаја дела и могућности управљања поступцима биле смањене до степена битног, али не битно, прекорачујући границе нужне одбране, са умишљајем покушао да лиши живота оштећеног ББ...“.

Приликом одмеравања казне, првостепени суд је ценио све околности из члана 54. КЗ, па је окривљеном на основу чл. 56. и 57. КЗ казну ублажио

испод законом прописаног минимума и осудио га на казну затвора у трајању од три године, имајући у виду да у конкретном случају постоје два основа за ублажавање казне – да је кривично дело остало у покушају (члан 30. став 2. КЗ) и да је поступао у нужној одбрани, чије је границе прекорачио (члан 19. став 3. КЗ), што јесу законски основи за факултативно ублажавање казне, али никако основи за двоструко привилеговање окривљеног у погледу кривичне санкције.

Другостепени суд је у побијаној пресуди нашао да првостепени суд правилно утврдио све одлучне чињенице те да је правилно закључио да се у конкретном случају окривљени није налазио у стању јаке раздражености, нити у прекорачењу нужне одбране услед јаке раздражености.

Како, дакле, у конкретном случају не постоји законски основ за ослобађање окривљеног од казне у смислу члана 19. став 3. КЗ (да је учинилац кривичног дела прекорачио границе нужне одбране услед јаке раздражености или препаста изазване нападом), то је Апелациони суд у Београду, као другостепени, осуђујући окривљеног на казну затвора у трајању од две године и шест месеци, иако је граница ублажавања казне у конкретном случају до три године затвора, сходно одредби члана 57. став 1. тачка 2. КЗ, учинио повреду закона из члана 439. тачка 3. ЗКП у корист окривљеног.“

5.5. Неуспело подстрекавање и ублажавање казне

Чланом 34. став 2. КЗ је предвиђено да ко другог са умишљајем подстрекава, на извршење кривичног дела, чији покушај је по закону кажњив, а дело не буде ни покушано, казниће се као за покушај кривичног дела. Закон не одређује појам подстрекавања, већ садржи само декларативну одредбу, „ко другог са умишљајем подстрекне“, да изврши кривично дело, казниће се казном прописаном за то дело.

Међутим, теорија и пракса су изградиле скоро јединствено схватање, да је подстрекавање стварање одлуке код другог, да изврши кривично дело или учвршћивање такве одлуке. У складу са наведеним је и у одлуци **Врховног суда Србије** Кж.873/86 од 14.10.1986 године, оцењено да је „за постојање подстрекавања на извршење кривичног дела битно, да подстрекнуто лице у време деловања подстрекача није имало чврсту одлуку о извршењу дела, те да је та одлука формирана под утицајем подстрекача, при чему подстрекнуто

лице не мора бити свесно да је његова одлука да изврши кривично дело на-стала под утицајем подстрекача“.¹⁰

Подстрекавање је један од облика саучесништва, и представља умишљај-но навођење другог на извршење кривичног дела.

Умишљај подстрекача са креће у два правца:

1. у односу на само подстрекавање и
2. у односу на кривично дело на које се подстрекава.

Подстрекач треба, да је свестан да својом делатношћу код другог ствара и учвршћује одлуку да то лице изврши кривично дело и да он то хоће од-носно да на то пристаје. Могућ је дакле и директан и евентуални умишљај. Напоменули би да нехатно подстрекавање, и ако је могуће није кажњиво, јер је оцењено да би представљало проширење кривике и одговорности, преко стварних потреба.

Пресудом **Врховног касационог суда** КЗЗ 763/2020 од 28.10.2020. годи-не, одбијени су као неосновани, захтеви за заштиту законитости бранилаца окривљених, поднети против правноснажних пресуда Вишег суда у Неготи-ну и **Апелационог суда у Нишу** Кж1 број 743/2019 од 30.01.2020. године.

По налажењу Врховног касационог суда: „Како из изреке првостепене пресуде јасно произилази да је окривљени АА, као одговорно лице у правном лицу Србија пласт ДОО Топола, у намери да свом привредном друштву и окривљеном ББ прибави противправну имовинску корист наведену у изреци пресуде, обманом довео у заблуду овлашћено лице оштећеног Фонда за раз-вој Републике Србије да изврши незакониту исплату средстава у износу од 2.500.000,00 динара на начин ближе описан у изреци првостепене пресуде, а да је окривљени ББ подстрекавао окривљеног АА и ВВ на извршење кривич-ног дела превара у служби из члана 363. став 3. у вези става 1. КЗ, и помагао им у извршењу истог давањем савета и упутстава, те стварањем услова за извршење истог, а у намери да себи прибави противправну имовинску ко-рист, то су по оцени овог суда радње окривљеног АА правилно правно ква-лификоване као кривично дело превара у служби у саизвршилаштву из члана 363. став 2. у вези става 1. у вези члана 33. КЗ, а радње окривљеног ББ као кривично дело превара у служби подстрекавањем из члана 363. став 2. у вези става 1. у вези члана 34. став 1. КЗ. Следствено томе, Врховни касациони

¹⁰ Благојевић Б.: *Актуелна судска пракса из кривичног права*, Београд, 1996. стр.14.

суд налази да се захтевима за заштиту законитости бранилаца окривљених правноснажне пресуде неосновано побијају због повреде кривичног закона из члана 439. тачка 2. ЗКП“

У погледу одговорности подстрекач је изједначен са извршиоцем кривичног дела. У теорији кривичног права то се назива „принципом еквиваленције у кажњавању подстрекача и извршиоца“.¹¹

Подстрекач је одговоран за свако извршено кривично дело, без обзира на његову тежину, а код покушаја, само кад је покушај кажњив. Ако је дело на које се односило подстрекавање остало у покушају и у том случају се подстрекач једнако третира као и извршилац, и може се блаже казнити и примењују се одредбе из чл.30.ст.2 КЗ и чл.56.ст.1.тач.1. КЗ.

Приликом одмеравања казне, суд посебно одлучује о казни подстрекача а посебно извршиоца-подстрекнутог и примењује одредбе о ублажавању казне у односу на сваког посебно.

Казна подстрекачу може бити блажа али и строжа од казне која је изречена извршиоцу, при чему суд има у виду и одредбе из чл.36. КЗ¹².

Тако је у пресуди **Врховног суда Србије** Кж.І.бр.24/75, изнето „да подстрекавање на извршење кривичног дела представља законом инкриминисани вид саучесништва, због чега се подстрекачу који је оглашен кривим за такву делатност не може истовремено, код одмеравања казне узети као отежавајућа околност да је био иницијатор за извршење дела“.¹³

У судској пракси се разматра и да ли је суд повредио забрану преиначења на штету окривљеног прописану одредбом члана 453. ЗКП, када преиначи пресуду тако што окривљеног уместо за радњу учињену у подстрекавању (чл.34. КЗ) огласи кривим да је дело учинио у помагању (чл.35. КЗ).

За наведену правну ситуацију је значајно што је могућност ублажавања казне могућа само у случају из чл. 34.ст. 2. КЗ (неуспело подстрекавање), а не и за подстрекавање из чл.34. ст.1. КЗ, што је даље значајно и за оцену

11 Бачић,Ф.: *Кривично право- Опћи дио, "Информатор"*, Загреб, 1980, стр.331.

12 Наведеним чланом су предвиђене границе одговорности и кажњивости саучесника. Наиме чл.36. ст.3.КЗРС је предвиђено да лични односи, својства и околности услед којих закон дозвољава ослобођење од казне или које утичу на одмеравање казне, могу се узети у обзир само оном извршиоцу, саизвршиоцу, подстрекачу или помагачу код којег такви односи, својства и околности постоје.

13 Лазаревић, Јб.: *Коментар Кривичног законика Републике Србије*, Савремена администрација, Београд, 2006, стр.108.

покушаја из чл.35. КЗ, а све у вези са применом закона који је повољнији за окривљеног и повреде чл.453. ЗКП.

О наведеном питању је одлучивано у пресуди Врховног касационог суда.

Пресудом Врховног касационог суда Кзз 732/2021 од 30.06.2021. године, одбијен је као неоснован захтев за заштиту законитости браниоца окривљеног, поднет против правноснажне пресуде **Вишег суда у Нишу** Кж1 41/2021 од 30.03.2021. године.

Првостепеном пресудом окривљени је оглашен кривим због извршења кривичног дела изазивање опште опасности из члана 278. став 1. КЗ у **подстрекавању** у вези члана **34. КЗ** и осуђен на казну затвора у трајању од једне године и шест месеци и на новчану казну у одређеном износу од 50.000,00 динара, док је усвајањем жалби окривљеног и браниоца, а након одржаног претреса.

Другостепени суд (Виши суд у Нишу) преиначио првостепену пресуду у погледу чињеничног описа, правне квалификације дела и одлуке о урачунавању мере забране напуштања стана и окривљеног огласио кривим за извршење кривичног дела изазивање опште опасности у **помагању** из члана 278. став 1. у вези члана **35. КЗ** и осудио на казну затвора у трајању од једне године и шест месеци, док је првостепена пресуда у непреиначеном делу потврђена.

Бранилац окривљеног АА у поднетом захтеву истиче да је суд побијаном правноснажном пресудом повредио забрану преиначења на штету окривљеног прописану одредбом члана 453. ЗКП, јер је поступајући искључиво по жалби браниоца окривљеног, док је јавни тужилац изјавио жалбу само због одлуке о кривичној санкцији, изменио пресуду на штету окривљеног. Као измену на штету окривљеног бранилац наводи да је суд из чињеничног описа избацио подстрекавање и окривљеног огласио кривим за радњу помагања, на шта није био овлашћен јер када решава по правном леку уложеном у корист окривљеног не сме донети одлуку која би ишла на његову штету.

Према налажењу **Врховног касационог суда**: „Када је кривично дело извршено помагањем, законом је прописано да ће се учинилац казнити казном прописаном за то кривично дело, или ублаженом казном, што није случај када је кривично дело извршено подстрекавањем где се учинилац кажњава казном прописаном за то кривично дело, што у конкретном случају значи да

је законском одредбом која регулише помагање предвиђена могућност ублажавања казне, што није случај код подстрекавања, па је самим тим другостепени суд, преиначењем првостепене пресуде и оглашавањем окривљеног кривим за извршење истог кривичног дела у помагању пресудио у корист окривљеног, а не на његову штету како се то наводи у поднетом захтеву.

Дакле, како окривљени АА није оглашен кривим за теже кривично дело, нити му је изречена тежа кривична санкција, то по ставу овога суда није учињена битна повреда одредаба кривичног поступка из члана 438. став 1. тачка 10. ЗКП, а како се то неосновано истиче у захтеву за заштити законитости браниоца окривљеног.“

Да би постојала **одговорност подстрекача** битно је, да је његов утицај да се изврши дело од стране извршиоца - подстрекнутог на неки начин и реализован. При одмеравању казне подстрекача се цени и личност подстрекнутог на коју је утицао, јер се из тога утврђује и интензитет подстрекавања.

Дакле значајна је и сама активност подстрекнутог, његове побуде, личност, психичко стање у коме се налазио приликом предузетих радњи. За постојање кривице подстрекача је неопходно да је подстрекнути ушао у «зону кажњавања», а затим се при индивидуализацији казне посебно цени и степен кривице подстрекача.

Од наведеног закон у чл.34.ст.2. КЗ, предвиђа изузетак, и реч је о **тзв. неуспелом подстрекавању**. И у случају неуспелог подстрекавања радња подстрекавања, мора бити предузета са умишљајем и она мора бити усмерена на стварање или учвршћење одлуке код другог да изврши кривично дело. Међутим, разлика је у томе, што није дошло до кажњивог понашања подстрекнутог, он није започео радњу извршења кривичног дела, те је реч о неуспелом подстрекавању.

За неуспело подстрекавање подстрекач је одговоран, само ако се подстрекавање односи на тешка кривична дела.

Ту тежину кривичног дела законодавац је изразио везивањем одредбе из чл.34.ст.2. КЗРС, за покушај из чл.30. КЗРС, и то:

1. за тежину дела која се кажњавају за покушај, то су кривична дела за која се по закону може изрећи пет година затвора или тежа казна и за

2. могућност изрицања казне на начин као што је прописано за покушај кривичног дела, тј. важе они прописи који важе за покушај кривичног дела.

Ово је посебно значајно за одмеравање казне, јер суд сагледавајући личност подстрекача и остале околности дела може у случају неуспелог подстрекавања

1. изрећи казну у границама које су прописане за то дело на које се подстрекавање односило, или
2. применити и одредбе о ублажавању казне из чл.56.ст.тач.1. КЗ у границама прописаним у чл.57. КЗ.

При одмеравању казне суд у случају неуспелог подстрекавања, најпре утврђује:

1. да је предузета радња подстрекавања, од стране подстрекача,
2. да се подстрекавање односило на кривично дело за које се може изрећи казна затвора од пет година или тежа казне,
3. да радња на коју се односило подстрекавање није предузета, а затим се сагледавају,
4. личности подстрекача и подстрекнутог (нпр. да ли је подстрекач користио неке личне слабости подстрекнутог).

Тек након тога суд ће оценом свих околности конкретног случаја, извршити и одмеравање казне и сходно личности учиниоца исту прилагодити конкретном случају и оценити да ли ће се сврха кажњавања остварити изрицањем казне у границама које су прописане за дело на које се односило подстрекавање или је потребно исту ублажити на основу чл.56.ст.1.тач.1. КЗ

Тако, неуспело подстрекавање постоји, кад подстрекач није успео наговорити другу особу на извршење кривичног дела, као и онда када је подстрекач у томе успео, али се подстрекнути предомислио пре него што је започео са делатношћу која значи улазак у „кажњиву зону“, или ако је особа која је била подстрекнута на извршење кривичног дела, била спречена да започне његово остварење.

За неуспело подстрекавање тражи се да је „подстрекач“ непосредно утицао на другу особу. Приликом одмеравања казне, као што је поменуто суд ће ценити управо и тај однос између извршиоца и подстрекнутог, и да ли је

подстрекач искористио евентуално постојећи однос зависности извршиоца према њему, подређености, родитељски ауторитет и сл.

Односно, да ли је подстрекач имао одлучујућу позицију у целокупном процесу извршења кривичног дела, и да ли је његов утицај на извршиоца дела био велики и доминантан.

Врста и висина казне код неуспелог подстрекавања у великој мери зависе од личности подстрекача, његове упорности, односно од његовог удела при доношењу одлуке за извршење кривичног дела, или при учвршћивању такве одлуке.

Свакако је мања могућност за ублажавање казне у случајевима када је подстрекач успео да наметне своју вољу и у таквој мери утицао на подстрекавано лице да је оно у својој свести већ донело одлуку да изврши дело, али до извршења није дошло из неких више објективних околности. Такав подстрекач се показује опаснијим, јер је због своје упорности и жеље за наступањем забрањене последице, исказао виши степен кривице. У супротном, ако подстрекач, због недовољног залагања и мањег утицаја не успе да створи или учврсти одлуку за извршење кривичног дела код подстрекаваног лица, те исто и не предузме радњу извршења, онда је таква делатност подстрекача мањег значаја, те је створена и могућност за одмеравање казне испод границе прописане законом или примену блаже врсте казне.

5.6. Помагање и индивидуализација казне

Одредбом чл. 35.ст.1. КЗ је прописано да ко другом са умишљајем помогне у извршењу кривичног дела, казниће се казном прописаном за то кривично дело или ублаженом казном.

Такође у ст.2. чл.35. КЗ је прописано да, се као помагање у извршењу кривичног дела сматра нарочито: 1.давање савета или упутства како да се изврши кривично дело, 2.стављање учиниоцу на располагање средстава за извршење кривичног дела, 3.стварање услова или отклањање препрека за извршење кривичног дела, као и 4.унапред обећано прикривање кривичног дела, учиниоца, средстава којима је дело извршено, трагова кривичног дела или предмета прибављених кривичним делом.

Из самог законског описа, произилази да је при одмеравању казне за дело у учињено помагањем, од изузетног значаја оцена самог кривичног дела и предузетих радњи и личности учиниоца.

Пресудом Врховног касационог суда је разматрано веома важно питање временског важења одређеног кривичног закона за кривично дело учињено у помагању, што је било значајно и за оцену врсте и висине казне и примену одредаба о ублажавању казне.

Пресудом **Врховног касационог суда** 1420/2021 од 23.03.2022. године одбијени су као неосновани захтеви за заштиту законитости поднети против правноснажних пресуда Вишег суда у Панчеву и Апелационог суда у Београду Кж1 692/21 од 11.10.2021. године.

Врховни касациони суд је оценио да су: „Неосновани наводи захтева за заштиту законитости бранилаца окривљеног БЂ у којем указују на повреду кривичног закона из члана 439. тачка 1. и 2. ЗКП, истицањем да радње које су предметном оптужницом стављене на терет овом окривљеном не представљају кривично дело и да је суд оглашавањем окривљеног кривим за продужено кривично дело проневера у обављању привредне делатности у помагању из члана 224. став 1. у вези члана 35. КЗ применио закон који се у конкретном случају не може применити“.

Врховни касациони суд наводи да: „Кривично дело проневера из члана 364. став 1. Кривичног законика („Службени гласник РС“, број 85/2005, 88/2005 111/2009), који је важио у време извршења кривичног дела, чини онај ко у намери да себи или другом прибави противправну имовинску корист присвоји новац, хартије од вредности или друге покретне ствари које су му поверене у служби или на раду у државном органу, предузећу, установи или другом субјекту или радњи. Дакле, кривично дело из члана 364. став 1. КЗ подразумева проневеру покретних ствари поверених у служби или на раду како у субјекту који не обавља привредну делатност, тако и у субјекту привредног пословања.

Кривично дело проневера из члана 364. став 1. Кривичног законика („Службени гласник РС“, број 94/2016 од 24.11.2016. године, са ступањем на снагу 01.03.2018. године) чини онај ко у намери да себи или другом прибави противправну имовинску корист присвоји новац, хартије од вредности или друге покретне ствари које су му поверене у служби или на раду у државном органу, установи или другом субјекту који не обавља привредну делатност.

Кривично дело проневера у обављању привредне делатности из члана 224. став 1. Кривичног законика („Службени гласник РС“, број 94/2016 од 24.11.2016. године, са ступањем на снагу 01.03.2018. године) чини онај ко у намери да себи или другом прибави противправну имовинску корист присвоји новац, хартије од вредности или друге покретне ствари које су му поверене на раду у субјекту привредног пословања.

Изменама и допунама Кривичног законика од 24.11.2016. године, објављеним у „Службеном гласнику РС“ број 94/2016, кривично дело проневера је „подељено“ у два кривична дела. При томе, деоба је извршена према врсти субјекта у којем су учиниоцу кривичног дела проневере покретне ствари поверене на раду, односно према томе да ли је то субјект који не обавља привредну делатност или субјект привредног пословања и то на кривично дело проневера кажњиво по члану 364. КЗ и кривично дело проневера у обављању привредне делатности кажњиво по члану 224. КЗ.

Кривично дело проневера из члана 364. КЗ је измењено утолико што је од наведених измена извршилац овог кривичног дела само оно лице коме су покретне ствари поверене у служби или на раду у субјекту који не обавља привредну делатност. Истовремено, одредбе које се односе на проневеру у субјекту привредног пословања овим изменама издвојене су у посебно кривично дело - кривично дело проневера у обављању привредне делатности из члана 224. КЗ, чији је заштитни објект привредно пословање и имовина у том пословању, при чему је радња кривичног дела остала неизмењена.

Дакле, наведеним изменама, у Кривични законик је унето кривично дело проневера у обављању привредне делатности из члана 224. КЗ, које задржава јасан правни континуитет са кривичним делом проневера из члана 364. КЗ у случају да су учиниоцу кривичног дела проневере покретне ствари поверене на раду у субјекту привредног пословања. Увођење кривичног дела из члана 224. КЗ је последица потребе да се направи разлика између вршења проневере у субјекту привредног пословања и субјекту који не обавља привредну делатност, јер је раније кривично дело проневера из члана 364. КЗ у потпуности изједначавало ситуације у којима се проневера врши како у субјекту привредног пословања тако и субјекту који не обавља привредну делатност.

Како кривично дело из члана 224. КЗ и поред наведених разлика, у свом законском опису има иста обележја као и раније кривично дело проневера

из члана 364. КЗ и то пре свега радњу извршења, то је јасно да је наведеним изменама задржан јасан правни континуитет ове две инкриминације.

Стога се не могу прихватити као основани наводи захтева за заштиту законитости бранилаца окривљеног НН којима указују да између одредбе члана 364. КЗ која је важила до дана 01.03.2018. године и одредбе члана 224. КЗ која је ступила на снагу дана 01.03.2018. године не постоји правни континуитет инкриминиције. Поред тога, не могу се прихватити ни наводи бранилаца да се радње окривљеног у време њиховог вршења нису могле сматрати ни кривичним делом проневера из члана 364. тада важећег КЗ („Службени гласник РС“, број 85/2005, 88/2005 111/2009), с обзиром да кривично дело из члана 364. тада важећег КЗ подразумева проневеру покретних ствари поверених на раду како у субјекту који не обавља привредну делатност тако и у субјекту привредног пословања, а окривљеном су покретне ствари биле поверене на раду у АД „Железнице Србије“ које се сматра предузећем, а које се сходно одредби члана 112. став 21. КЗ сматра субјектом привредног пословања.

Имајући у виду напред наведено, те висину запрећене казне затвора за кривично дело проневера из члана 364. КЗ важећег у време извршења кривичног дела и за кривично дело проневера из члана 224. КЗ важећег у време доношења нижестепених пресуда, то је суд правилно применио кривични закон правном квалификацијом кривичноправних радњи окривљеног ЂЂ као **продужено кривично дело проневера у обављању привредне делатности у помагању из члана 224. став 1. у вези члана 35. КЗ**, правилно налазећи да су наведене измене и допуне Кривичног законика с обзиром на висину запрећене казне затвора блаже по окривљеног.“

Када је у питању одмеравање и ублажавање казне, значајна је и улога помагача и његов однос са извршиоцем кривичног дела.

Ово стога, јер је помагач је лице које је учесник у извршењу дела, али његове делатности су по правилу, ван радње извршења. Делатношћу помагача се само доприноси, олакшава, помаже учиниоцу да лакше изврши кривично дело.

У субјективном смислу, помагач као саучесник мора имати свест о заједничком деловању са другим учесницима у извршењу дела, али се та свест огледа у томе, да код помагача постоји свест да учествује у туђем делу, да то

дело не врши као своје (што је одлика саизвршилаштва), већ да би другоме, тј. извршиоцу помогао да изврши кривично дело.

Тако је у пресуди **Врховног суда Србије** Кж. 232/86, утврђено да: „за помагање у извршењу кривичног дела није неопходно да помагач лично познаје извршиоце кривичног дела, већ је довољно да код њега постоји свест о томе да помаже извршиоцима, при извршењу кривичног дела“.¹⁴

Према заступљеном мишљењу нема помагања, као ни других облика саучесништва, ако се нека делатност у вези са извршењем кривичног дела, предузима после.

Осим тога за одмеравање и ублажавање казне може бити од значаја и садржај помагања од стране учиниоца и субјективни однос између помагача и извршиоца.

У судској пракси је прихваћено да и психичко помагање извршиоцу, представља облик помагања.

У решењу **Окружног суда у Нишу** Кж.410/04 је наведено: „да би постојало помагање као облик саучесништва, код кривичног дела тешка крађа, оно код помоћи утовара и скривања украдених ствари мора бити унапред обећано“.¹⁵

У пресуди **Врховног суда Србије** Кж. 1180/02 од 17. децембра 2002. године је, оцењено да: када је оптужени другооптуженом који је извршио разбојништво обезбедио пиштољ, који је био власништво његовог оца, као средство за извршење кривичног дела, тиме му је помогао у извршењу дела.“

Помагање је као и остали институти којима је предвиђено ублажавање казне факултативни основ за блаже кажњавање, при чему, се помагач може казнити и казном која је прописана за извршено дело или се може по оцени суда казна ублажити. Суд ће поред наведених начина помагања у ст.2. чл.35. КЗ ценити, да ли су предузете и друге делатности које су такве да на психичком или физичком плану олакшавају учиниоцу извршење кривичног дела, нпр. јачање воље за извршење дела, извиђање места дела, пребацивање учиниоца и средстава извршења до места где ће дело бити извршено и сл.

¹⁴ Симић, И.: *op.cit.*, стр.29.

¹⁵ Билтен судске праксе Окружног суда у Нишу, бр. 22. Интермекс, 2006, стр.87.

Даље је за одмеравање казне, важно и то, да се у конкретном чињеничном стању, разграниче радње помагања од припремних радњи.

У том погледу су битна два елемента, да је припремна радња „помагање себи“ да се лакше изврши кривично дело и да је она увек ван бића кривичног дела, док је помагање, „пругање помоћи другом“, доприношење да се лакше изврши кривично дело.

Код помагача постоји свест да учествује у извршењу кривичног дела другог лица, док умишљај припремних радњи обухвата свест да се припрема своје кривично дело, да се стварају услови за његово лакше извршење. Осим тога, помагање се може вршити и током извршења кривичног дела, што је искључено код припремних радњи, које се увек предузимају пре него што се приступи извршењу дела.

Приликом одмеравања казне треба имати у виду и случајеве кад је помагање предвиђено као самостално дело, зато што се тада не би могле применити одредбе о саучесништву, пошто радња извршења није кажњива.¹⁶

5.7. Неодољива сила и претња и ублажавање казне

Чланом 21.ст.2.КЗ је предвиђено да ако је дело учињено под дејством силе која није неоодољива, учиниоцу се казна може ублажити. Такође је у ст.1. чл. 21. КЗ прописано да није кривично дело које је учињено под дејством неоодољиве силе, а у ст.3. истог члана да ће се, када је дело учињено под дејством неоодољиве силе, као извршилац кривичног дела, сматрати лице, које је применило неоодољиву силу.

Из самих законских одредби произилази да је за ублажавање казне, у конкретном случају значајно утврдити, чиме је био руковођен учинилац дела и да ли је постојао притисак на његову психу, односно тело, да изврши кривично дело, а ако јесте у коликој је мери исти био изражен и да ли је интензитет истог био толико јак, да је под његовим утицајем дело и учињено.

¹⁶ Тако нпр. посебно кривично дело је помагање другом да изврши самоубиство (кривично дело навођење на самоубиство и помагање у самоубиству чл.119.КЗ), јер самоубиство није кривично дело, па се не би могло кажњавати за саучесништво у његовом извршењу. Иста ситуација је и код кривичног дела недозвољени прекид трудноће (чл.120 КЗ), кад се врши са пристанком бремените жене, јер сам побачај није кривично дело, али помагање бременитој жени да га изврши је предвиђено као самостално кривично дело.

У теорији је прихваћено да је сила употреба снаге према неком лицу, која је управљена на то да оно изврши одређену радњу која може бити извршена чињењем или нечињењем.¹⁷

Приликом одмеравања казне и утврђивања да ли има места ублажавању казне, важно је утврдити да ли је дело учињено под утицајем апсолутне (неодољиве) или комплузивне силе.

1. Сила је апсолутна (неодољива) у случају да је услед употребљене снаге, онај према коме је сила употребљена био потпуно лишен могућности, да донесе одлуку о чињењу или нечињењу, или ако је био спречен да ту одлуку реализује. Сила је неоодољива-апсолутна, ако се присиљени никако није могао супротставити сили.
2. Сила је комплузивна, у случају да услед употребе силе, присиљени учинилац, није био лишен могућности да донесе одлуку, али је дејством силе његова одлука изнуђена. Употребом комплузивне силе, није искључено одлучивање присиљеног, али је донесена одлука формирана под утицајем силе. Комплузивна сила може бити непосредна и посредна.

Појам претње, такође, није законом одређен, те је остављено теорији кривичног права и судској пракси да исту ближе дефинише, те је у овом погледу углавном прихваћено схватање, да је претња изјава неког лица,

1. којом се ставља другом лицу у изглед неко зло, које ће му се догодити, ако учини или не учини, оно што се од њега захтева и
2. које предочено зло је подобно да утиче на одлучивање у одређеном правцу.

Претња је најава зла, изјава којом се другом лицу ставља у изглед наношење зла које је подобно и довољно да утиче на његову вољу тако да оно донесе одлуку да предузме, односно пропусти одређену радњу и тиме проузрокује забрањену последицу кривичног дела. Стављањем у изглед неког зла другом лицу утиче се на слободу његовог одлучивања, а пре свега, на усмеравање одлуке у одређеном правцу. За постојање претње је битно да лице које је износи управо буде и лице које ће најављено зло непосредно нанети другом лицу. У противном, нема претње, већ таква најава зла које ће бити нането од стране другог лица, представља само опомену (упозорење).

¹⁷ При употреби силе употребљена снага може бити телесна или механичка, а према чл.112.ст.12. КЗ, као сила сматра се и примена хипнозе или омамљујућих средстава. Сила може бити произведена и дејством више силе, те да је дело извршено под утицајем околности које се нису могле, предвидети, избећи или отклонити (*vis maior*).

Претња може бити усмена, писмена, или учињена конклюдентном радњом. За постојање претње није од значаја, да ли је лице које прети заиста спремно да спроведе претњу. Битно је за суд приликом индивидуализације казне да утврди да ли учинилац коме се прети, и који под утицајем те претње предузима одређене радње, има основа да према конкретним околностима претњу схвати као озбиљну и као остварљиву и могућу. Наведено указује суду на психички однос учиниоца и према радњи и према последици, и од превасходног значаја је у том случају на оцену врсте, висине казне и сврхе кажњавања.

При одмеравању казне, суд ће ценити све околности под којима је дело учињено, при чему, се неодољивост силе, уколико је исте било, процењује посебно у сваком случају, узимајући у обзир како објективну ситуацију, тако и субјективне могућности извршиоца, да се супротстави сили, имајући у виду његову личност и залагање да се одупре притиску. Постојање апсолутне неодољиве силе је основ за искључење постојања кривичног дела, тј. ако је дело учињено под дејством апсолутне силе, сматра се да принуђени није извршио кривично дело, односно да је дело извршио онај ко је употребио силу. Само су комплузивна сила и претња су основи за ублажавање казне.

Да би претња представљала основ за ублажавање казне потребно је да она испуњава одређене услове и то да је:

- 1) озбиљна, при чему се озбиљност претње се процењује са становишта лица коме је она упућена, односно да ли ју је пасивни субјект схватио озбиљно без обзира да ли лице које прети има озбиљну намеру да је спроведе,
- 2) могућа, ако се најављено зло стварно, реално може остварити,
- 3) садашња, што значи да најављено зло непосредно предстоји, да ће бити нането у садашњости или у непосредној блиској будућности. Нема претње ако зло које се ставља у изглед треба да се догоди у далекој будућности, јер она тиме губи реални значај да утиче на вољу другог лица и
- 4) неотклоњива, што значи да се најављено зло није могло у конкретним околностима отклонити на други начин (на пример позивањем у помоћ, пријављивањем лица које прети, применом нужне одбране, бекством, променом места боравка), већ само извршењем кривичног дела.¹⁸

¹⁸ Сила и претња имају вишеструки значај у кривичном праву, јер се код многих кривичних дела јављају као радња извршења (нпр. кривично дело силовања) или као начин извршења (нпр. кривично дело разбојништво и др.). Такође код неких кривичних дела, ако је дело извршено под утицајем силе и претње, исто добија тежи квалификовани облик.

Тако је у судској пракси је прихваћено да: „претња код кривичног дела угрожавања сигурности, не може бити условљена неким будућим понашањем оштећених“.

Такође, у пресуди **Врховног суда Србије**, Кж.128/91 од 05.04.1991 године, је наведено да се „озбиљност претње код кривичног дела разбојништво, оцењује према томе, да ли је објективно могла створити утисак да ће бити реализована, при чему нема значаја да ли је извршилац, стварно намеравао да претњу оствари“.

5.8. Отклоњива правна заблуда и индивидуализација казне

Чланом.29.ст.3 КЗ, је предвиђено да се учиниоцу, који није знао да је дело забрањено, али је то био дужан и могао да зна, казна може ублажити. Одредбом члана 29. ст.1. КЗ је прописано да није кривично дело, оно дело које је учињено у неотклоњивој правној заблуди, а у ст.2. истог члана, да је правна заблуда неотклоњива, ако учинилац није био дужан и није могао да зна да је његово дело забрањено.

Наведеним законским одредбама одређен је кривичноправни значај правне заблуде, али не и њена садржина. У теорији кривичног права није изграђен јединствени појам овог института. У савременој кривичноправној литератури, претежно је схватање правне заблуде као погрешне представе о забрањености дела. Учиниоца је у правној заблуди када има тачну представу о околностима које улазе у биће кривичног дела, али није свестан да је то дело забрањено.¹⁹

За правилно схватање појма правне заблуде и њеног утицаја на одмеравање казне, у односу на конкретног извршиоца и кривично дело, мора се сагледати 1.општи појам кривичног дела који Кривични законик сада прихвата у формалном, објективно-субјективном облику где се као општи формални елементи појављују противправност и одређеност дела у закону (чл.14. КЗ)²⁰ и 2. појам кривице као субјективне компоненте, за чије се постојање тражи поред урачунљивости и виности и свест или могућност свести о забрањености дела (чл.22.ст.1.КЗ).

19 Лазаревић, Љ.: *op.cit.*,стр.101.

20 Чланом 14. ст.1.и ст.2. КЗРС је предвиђено да је кривично дело оно дело које је законом предвиђено као кривично дело, које је противправно и које је скривљено. Нема кривичног дела, уколико је искључена противправност или кривица, иако постоје сва обележја кривичног дела одређена законом. Из законског текста произилази, а што је прихваћено у теорији и у пракси, да општи појам кривичног дела обухвата четири конститутивна елемента: 1.дело, 2.предвиђеност у закону, 3.противправност, 4.кривицу.

При томе се, противправност у формалном смислу, изражава кроз недозвољеност одређеног понашања, поступање насупрот неком правном пропису, односно правним нормама које одређују правила понашања у друштву; кршење правне норме или забране.

За кривицу је дакле потребно да је од стране урачунљивог извршиоца у време извршења дела, дело остварено из умишљаја или из нехата и да је при томе учинилац био свестан или је био дужан и могао бити свестан да је његово дело забрањено.

Заблуда о противправности дела је заблуда о забрањености дела, кад учинилац погрешно мисли да оно што предузима, није правно забрањено, да је он овлашћен на предузимање такве радње. Сама свест о забрањености дела, је посебан самосталан елемент кривице и изван је умишљаја односно нехата.

У том погледу могу се разликовати две ситуације:

1. погрешна свест о одређености дела у закону и
2. погрешна свест о противправности учињеног дела уопште. У првом случају учинилац није знао, није био свестан, да је то што чини прописано неком кривичноправном одредбом као кривично дело.

У ову групу спада и заблуда о тзв. бланкетном кривичном делу, односно када учинилац није свестан неког ванкривичног прописа, који одређује или допуњује биће неког кривичног дела. Такође, ту спада и погрешна представа о одређености дела у закону, када учинилац погрешно тумачи неку околност која је законско обележје дела. У другу групу спадају правне заблуде, када учинилац није свестан противправности дела, односно погрешно сматра, да је у конкретном случају противправност искључена.

Имајући у виду наведена законска одређења, за ублажавање казне и сагледавање учиниоца је посебно значајно да ли је био у отклоњивој или неотклоњивој заблуди.

При томе, се као неотклоњива правна заблуда, сматра заблуда из оправданих разлога, те и да је учинилац био у оправданој правој заблуди, када с обзиром на природу извршеног кривичног дела, околности под којима је дело учињено и његову личност, није могао да има тачну представу. А отклоњива правна заблуда би била правна заблуда из разлога који нису оправдани, и она је у смислу чл.29. ст.3. КЗ основ за ублажавање казне.

Суд би у датом случају, по неком логичном реду ствари, требао прво утврђивати да ли је учинилац био у правној заблуди, затим да ли је у њој био из оправданих разлога, а затим одлучивати о врсти и висини казне, имајући у виду и сврху кажњавања.

Као што је поменуто, кривичноправна ситуација учиниоца, који је кривично дело учинио уз постојање правне заблуде, зависи од тога да ли је та заблуда отклоњива или неотклоњива. Ако се утврди да је неотклоњива, онда недостаје свака основа за друштвени прекор, и учинилац није крив, јер нема кривице, па самим тим у складу са прихваћеним објективно - субјективним појмом кривичног дела, нема ни кривичног дела (чл.29.ст.1. и ст.2. КЗ).

Међутим, ако се утврди да се ради о отклоњивој заблуди, у том случају постоји кривично дело и кривица и учинилац је крив за учињено дело. Дакле, отклоњива правна заблуда не искључује кривицу, и не дира у постојање умишљаја односно нехата, али се може узети у обзир приликом индивидуализације казне. Од тога у коликом степену учинилац није уважио захтеве друштвеног и правног поретка, зависиће и степен кривице, а тиме и врста и висина казне, као могућност њеног ублажавања. Разлози због којих је учинилац сматрао да дело није забрањено, могу се ценити и том смислу, да ли су исти утицали у већој или мањој мери на радње учиниоца.

Утврђивање околности да ли је учинилац био у отклоњивој или неотклоњивој правној заблуди, је од посебног значаја, и представља сложен процес одлучивања и оцене датог случаја. Ако се пође од наведеног, да је неотклоњива правна заблуда, заблуда из оправданих разлога, при чему учинилац није имао нити је могао имати тачну представу о забрањености дела, потребно је утврђивати у сваком конкретном случају постојање разлога који су довели до правне заблуде и њихове оправданости. При томе, би суд узео у обзир природу кривичног дела, околности под којима је дело извршено и личност учиниоца. Такође, суд може имати у виду, а с обзиром на околности датог случаја, позив учиниоца и уопште релацију извршиоца према односном делу, повезаност учиниоца са датим правним поретком, показани степен заинтересованости да схвати прави значај дела и др. Суд ће ценити у предметном случају и да ли се ради о отклоњивој правној заблуди, у којој је учинилац из нехата, када је могао и био дужан да има тачну представу о забрањености дела.

Поменули бисмо да заблуда о противправности скоро да није могућа код кривичних дела која обухватају оне императивне или прохибитивне норме, које су по општем стању друштвене свести, израз широко прихваћене етике датог друштва, израз основних захтева и потреба друштва и које као такве постоје у свести свих људи.

У вези са тим се каже у литератури, да: „ако дело не представља, само повреду права него је истовремено и повреда моралног поретка, заблуда о противправности је по правилу отклоњива, јер правно вредновање произилази непосредно из правног и моралног осећања и оно се зато додатним напором савесности, лако спознаје“.²¹

Постоји с друге стране у кривичном праву, доста кривичних дела која немају тако изразите социјално-етичке основе. Да би правна заблуда била неотклоњива, и да би била искључена свака кривица, учинилац не сме поступати тако да му се може пребацити, да није показао довољан интерес да схвати природу дела и радње коју је предузео.

Правни поредак захтева, више него да човек отклони, само оно што му је сасвим јасно да је забрањено. Човек се мора пре свега трудити да поступа у складу са правом. За учиниоца постоји обавеза, да савесно рашчисти питање недопуштености свог поступка, нарочито ако је у питању поступак, за који се по искуству зна да је део материје која је правно регулисана.

Заблуда је отклоњива и скривљена, ако учинилац није показао ону бригу, коју је према свим околностима и својим особинама, био дужан у датој ситуацији испољити, и која би му помогла да увиди да је дело забрањено.

Наведено је прихваћено и у судској пракси.

Пресудом **Врховног касационог суда** КЗЗ 1345/2019 од 30.01.2020. године, усвојен је као основан захтев за заштиту законитости Републичког јавног тужиоца Ктз 1155/19 од 05.12.2019. године, и утврђено да је правноснажном пресудом Апелационог суда у Београду Кж1 392/2019 од 10.06.2019. године повређен закон - одредба члана 439. тачка 1. Законика о кривичном поступку у вези са одредбом члана 29. став 1. и 2. Кривичног законика, у корист окривљеног АА.

21 Jescheck, H.H.: *Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil*, 5. Auflage, Berlin, 1996, стр.345.

Пресудом Апелационог суда у Београду Кж1 392/2019 од 10.06.2019. године, усвајањем жалбе браниоца окривљеног преиначена је пресуда Вишег суда у Панчеву, тако што је Апелациони суд у Београду окривљеног АА, на основу члана 423. став 1. тачка 1. ЗКП у вези члана 29. став 1. и 2. КЗ ослободио од оптужбе да је извршио кривично дело обљуба са дететом из члана 180. став 2. у вези става 1. КЗ.

У наведеном предмету Апелациони суд у Београду је нашао да се у радњама окривљеног стичу обележја кривичног дела које му се оптужбом ставља не терет, међутим, имајући у виду околности под којима је дело учињено и лична својства окривљеног која се односе на ниво образовања, личне прилике, његове породичне прилике и окружење, по ставу Апелационог суда окривљени није могао да зна да је ступање у полни однос са лицем које није навршило 14 година кривично дело.

По налажењу Врховног касационог суда: „Апелациони суд у Београду је заузео погрешан став да је окривљени АА поступао у неотклоњивој правној заблуди.

Одредбом члана 29. став 1. КЗ, прописано је да није кривично дело оно дело које је учињено у неотклоњивој правној заблуди, а ставом 2. истог члана да је правна заблуда неотклоњива ако учинилац није био дужан и није могао да зна да је његово дело забрањено.

Значи, да би правна заблуда могла да искључи кривицу (а самим тим и кривично дело) неопходно је да учинилац никако није могао да избегне заблуду о забрањености дела, односно да није био дужан и није могао да зна да је дело забрањено, при чему се подразумева да оба услова буду кумулативно испуњена (...)

С тим у вези, након анализе неспорно утврђених чињеница које произилазе из списка предмета и то да је окривљени АА знао узраст оштећене и чињеницу да није навршила ни 14 година (што је утврђено током поступка), да је окривљени знатно старији и да је у време извршења кривичног дела имао 21 годину и 9 месеци, да је емоционална и социјална зрелост окривљеног била у складу са достигнутим календарским узрастом (како је то током поступка утврђено из налаза и мишљења вештака неуропсихијатра), да има трећи степен средњег образовања (за разлику од многих припадника његове етничке заједнице), живео је у иностранству и користи компјутер, односно друштвене мреже преко којих је и дошао у контакт са оштећеном.

Изнете околности без обзира на чињеницу да је припадник ромске мањине као етничке заједнице, која као и свака друга заједница има своје обичаје, супротно закључку Апелационог суда у Београду, а по налажењу Врховног касационог суда указују да је окривљени био дужан и могао је да зна да је његово дело забрањено у ком случају не може бити речи о неотклоњивој правној заблуди. Чак и у ситуацији да окривљени због свог социолошко-културолошког порекла, није знао за забрањеност полних односа са децом, а који закључак је извео нижестепени суд исти је због својих напред описаних личних својстава, према околностима догађаја а посебно што су информације о недозвољености сексуалних односа са децом све присутне и лако доступне преко медија и друштвених мрежа, које су окривљеном и биле доступне и којима се и користио, указују да је окривљени био дужан и могао је за то да зна.

Имајући у виду напред изнете разлоге у вези објективних и субјективних критеријума, а у погледу отклоњивости правне заблуде, Врховни касациони суд је нашао да је погрешан став Апелационог суда у погледу поступања у неотклоњивој правној заблуди на страни окривљеног, самим тим и постојања кривичног дела обљуба са дететом из члана 180. став 2. у вези става 1. КЗ.“

Наведеног става је био и **Апелациони суд у Нишу** у пресуди Кж1 611/2022 од 16.09.2022. године. Апелациони суд је нашао да се жалбеним наводима браниоца оптуженог не доводи се у сумњу закључак првостепеног суда да је оптужени А.А. критичном приликом, у више наврата извршио чин изједначен са обљубом, са дететом, оштећеним малолетним Б.Б. рођеним 07.07.2005. године, те да је извршио продужено кривично дело обљуба са дететом из чл.180. ст.1. Кривичног законика у вези чл. 61. ст. 2. и ст. 1. Кривичног законика.

„Као неосновани су оцењени жалбени наводи браниоца оптуженог којима се истиче да је оптужени критичном приликом поступао у правној заблуди те да није знао да је његово дело забрањено и у том смислу се жалбом указује на психичко стање оптуженог и његове смањене интелектуалне способности. Насупрот жалбеним наводима браниоца оптуженог, по оцени Апелационог суда, првостепени суд је правилно, на основу одбране оптуженог коју је дао у истрази и на главном претресу 11.06.2019. године, утврдио, да се оптужени изјаснио да је сматрао да са лицима млађим од 18 година не сме имати сексуалне односе и да зна да су лица испод 14 или 15 година много млађа од њега.

Такође је првостепени суд на основу налаза и мишљења Комисије вештака Специјалне затворске болнице у Београду од 05.03.2019. године са допуном од 30.12.2020. године, утврдио да оптужени А.А. има уредан ранији развој, да је одрастао и развијао се као старије од двоје деце из брака родитеља, да је редовно завршио основну и средњу школу са добрим успехом, да обавља пољопривредне послове на породичном имању и да познаје социјалне норме и конвенције, те да може да разликује шта је морално и законски дозвољено, а шта није, при чему је првостепени суд и на основу налаза и мишљења вештака психолога утврдио да оптужени познаје шта је морално, а шта није дозвољено.

Имајући у виду наведено, правилно је, по оцени Апелационог суда, првостепени суд утврдио да у конкретном случају оптужени није поступао у правној заблуди, а имајући у виду да је у време извршења кривичног дела имао 19 година живота, његове животне навике, као и чињенице утврђене налазима и мишљењима вештака Специјалне затворске болнице у Београду и психолога, као и природу предметног кривичног дела и предузетих радњи, с обзиром да је оптужени у време извршења дела био свестан чињенице да је оштећени Б.Б. дете, јер нема пуних 14 година, као и да то што са њим има полни однос, на начин како је оглашен кривим, значи чин изједначен са обљубом детета, па је Апелациони суд оценио да је правилан закључак првостепеног суда да је оптужени по субјективним и објективним критеријумима био свестан забрањености конкретног понашања, те да је знао да је такво поступање законом забрањено.“

Питање правне заблуде је увек сложено питање и предмет како практичних тако и теоретских разматрања. Суд приликом оцене да ли се учинилац налазио у правној заблуди, увек полази, као у напред наведеним одлукама, од конкретне личности учиниоца, његовог животног окружења, образовања, навика и других личних и социјалних карактеристика, те након тога одлучује о врсти и висини казне, као и да ли има места ублажавању.

6. ЗАКЉУЧАК

Сумирајући претходна излагања, можемо рећи, да је ублажавање казне у уској вези са савременим кретањима у борби против криминалитета, која су поред организоване друштвене активности репресивне природе, усмерена и према личности човека и циљевима специјалне превенције.

Имајући у виду домаћу судску праксу, која је илустрована наведеним одлукама, може се закључити да постоји примена института ублажавања казне. Законски основи за ублажавање казне пружају могућност суду да потпуније сагледа своју одлуку о кривичној санкцији.

Дате законске могућности омогућавају суду да се у сваком поједином случају конкретизује став закона о интензитету криминалне опасности извршеног дела.

Одлука о казни има значај како за учиниоца кривичног дела, коме је изречена, тако и за ширу јавност и у крајњем представља коначни израз целокупног кривичног поступка.

Казна се задржала у систему кривичних санкција, од настанка кривичног права па до данас. Али су се за то време у великој мери промениле концепције о њеној сврси. Од казне као чисте одмазде, казне без даљег циља, дошло се до казне као средства за остварење друштвено корисних циљева - заштите друштва од криминалитета кроз генералну или специјалну превенцију односно кроз утицај на учиниоца кривичног дела да се не јави као поновни извршилац кривичног дела.

Оријентација на казну, као носећу санкцију система кривичних санкција, као и ослањање на принцип личне одговорности, превентивне утицаје, окренутост човеку, као свесном, слободном и одговорном лицу, усмерава постављени концепт казне, ка личности учиниоца и то у правцу да се њеним изрицањем и извршењем, прилагоди личности учиниоца, а у складу са постављеним циљевима сврхе кажњавања.

Из наведеног следи да судови практично кроз своје одлуке реагују оном врстом и висином казне, која с обзиром на личност учиниоца и извршено дело пружа највише изгледа да ће њоме се остварити сврха кажњавања односно оспособљавање учиниоца да убудуће води друштвено користан живот, а посебно да не врши кривична дела.

Примена одредаба о ублажавању казне у судској пракси, такође указује на значај примене принципа индивидуализације казне, јер из садржаја судских одлука произилази да се у највећем броју случајева основи за блаже кажњавање односе како на само дело тако и на личност учиниоца кривичног дела.

На крају можемо рећи да је у раду, извршена анализа разлога из чл. 56. тач. 1. КЗ за ублажавање казне (када закон предвиђа да се казна може ублажити). Друга два основа за ублажавање казне прописана одредбом чл. 56. тач. 1. и тач. 2. КЗ, такође имају велику примену у судској пракси и биће предмет посебног разматрања.

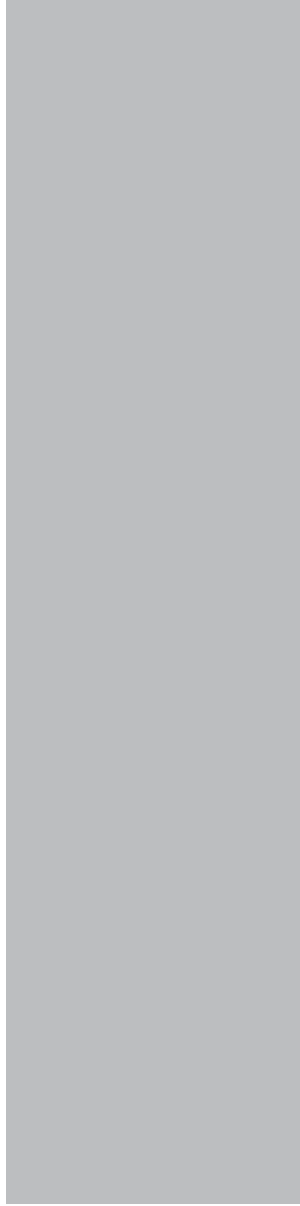
ЛИТЕРАТУРА

1. Бачић, Ф.: *Кривично право- Опћи дио*, "Информатор", Загреб, 1980.
2. Бачић, Ф.: *Отежавајуће и поопштравајуће околности у кажњавању у југословенском кривичном праву*, Југословенска ревија за криминологију и кривично право, бр. 2. Београд, 1964.
3. Благојевић Б.: *Актуелна судска пракса из кривичног права*, Београд, 1996.
4. Група аутора: *Коментар Кривичног закона СФРЈ*, Савремена администрација, Београд, 1980.
5. Игњатовић, А.: *Кривично право, општи део*, Нови Сад, 2007.
6. Jescheck, H.N.: *Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner Teil*, 5. Auflage, Berlin, 1996.
7. Јовашевић, Д.: *Кривично право-општи део*, Београд, 2006.
8. Кос, Д.: *Институт ублажавања казне у процесу њезине индивидуализације*, Хрватски љетопис за казнено право и праксу, бр. 2/2003, Загреб, 2003.
9. Лазаревић, Љ.: *Коментар Кривичног законика Републике Србије*, Савремена администрација, Београд, 2006.
10. Лазаревић, Љ.: *Казне и мере безбедности у савременом кривичном праву*, Завод за издавање уџбеника СРС, Београд, 1969.
11. Новоселец, П.: *Опћи дио казног права*, Загреб, 2004.
12. Симић, И.: *Збирка судских одлука из кривично-правне материје*, Службени гласник, Београд, 1994.
13. Стојановић, З.: *Кривично право, Општи део*, Београд, 2006.
14. Таховић, Ј.: *Кривично право - општи део*, Савремена администрација, Београд, 1961.
15. Хорватић, Ж.: *Принципи легалитета и индивидуализације казне у југословенском кривичном праву прије и након доношења нових кривичних закона*, Југословенска ревија за криминологију и кривично право, број. 1, Београд, 1979.

16. Чејовић, Б.: *Кривично право, општи део*, Службени лист СРЈ, Београд, 2002.
17. Чејовић, Б.: *Кривично право у судској пракси, општи део*, Београд, 1983.

КРИВИЧНО ПРАВО

СУДСКА ПРАКСА



ЗАКОНИТОСТ ДОКАЗНЕ РАДЊЕ ПРЕПОЗНАВАЊЕ ЛИЦА ИЛИ ПРЕДМЕТА У СИТУАЦИЈИ КАДА ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДМЕТ НИСУ ДОСТУПНИ

(чл.90. и чл.100. Законика о кривичном поступку)

Доказна радња препознавања лица или предмета је законита и такав доказ може бити коришћен у кривичном поступку уколико су испуњени услови прописани одредбама чл.90 и чл.100. Законика о кривичном поступку, зависно од тога да ли су лице или предмет доступни.

Из образложења:

Пресудом Основног суда у Нишу 7 К 326/2020 од 29.09.2021. године оптужени АА је оглашен кривим за кривично дело разбојништво из чл.206. ст.1. Кривичног законика и осуђен на казну затвора у трајању од 3 (три) године коју је дужан да издржи по правноснажности пресуде.

Бранилац оптуженог у жалби указује да је првостепени суд, без предлога странака, како је прописано одредбом чл.15. ст.3. Законика о кривичном поступку, изводио доказе и то оне које јавни тужилац није предложио иако му је то суд наложио, а потом је тако изведене доказе прихватио и на њима засновао осуђујућу пресуду. Из тих разлога је, по ставу жалбе браниоца оптуженог, препознавање лица посредством фотографија незаконит доказ, јер не испуњава предпоставку недоступности оптуженог како је прописано чл.90. ст.3. Законика о кривичном поступку.

Изнети жалбени наводи браниоца оптуженог су неосновани, јер је првостепени суд у складу са налозима другостепеног суда из решења којим је првобитно донета пресуда укинута, применом овлашћења из чл.15. ст.4. Законика о кривичном поступку наложио јавном тужиоцу да достави допунске доказе који су неопходни да би се предмет доказивања свестрано расправио, а то је законитост радње препознавања лица посредством фотографија, у ком случају и сам суд, без предлога странака има овлашћење да такве доказе изведе. Супротно наводима жалбе о пасивности јавног тужиоца по налогу суда, из садржине записника о главном претресу дана 29.09.2021. године, коме су присуствовали заменик јавног тужиоца, оптужени и његов бранилац, произилази да је заменик јавног тужиоца предао суду доказе о активности тужилаштва за обезбеђење оптуженог радњи препознавања, те је нетачна тврдња из жалбе да одбрана није присуствовала извођењу ових доказа.

Имајући у виду да одредба чл.100. ст.1. Законика о кривичном поступку прописује да ће се препознавање од стране сведока обавити у складу са чл.90. Законика о кривичном поступку, а да је ст.3. истог члана предвиђена могућност препознавања лица посредством фотографије под условом да је лице недоступно, те имајући у виду да је првостепени суд утврдио да је оптужени у време извођења радње препознавања био недоступан органима поступка, то је оштећеном, ради препознавања учиниоца кривичног дела учињеног на његову штету, у полицији показана фотографија оптуженог заједно са другим фотографијама њему непознатих лица чије су основне особине сличне онима какве је описао, те је ова доказна радња спроведена на начин прописан законом. Како су записник о препознавању лица потписали јавни тужилац, сведок – оштећени, бранилац оптуженог, овлашћено службено лице које је обавило радњу и записничар, то се предузета радња сматра законитим доказом и на њему се може засновати пресуда, због чега се неосновано изјављеном жалбом браниоца оптуженог указује и на битну повреду одредаба кривичног поступка из чл.438. ст.2. тач.1. Законика о кривичном поступку.

(Пресуда Основног суда у Нишу 7 К 326/2020 од 29.09.2021. године и пресуда Апелационог суда у Нишу Кж1 10/2022 од 02.02.2022. године)

Приредила: Снежана Милошевић, судија Апелационог суда у Нишу

ЗАМЕНА НАЧИНА ИЗВРШЕЊА КАЗНЕ ЗАТВОРА

То што се осуђени који казну затвора треба да издржи у просторијама у којима станује није одазвао на разговор на који је позван од стране Управе за извршење кривичне санкције, не представља разлог за доношење решења да осуђени казну затвора издржи у заводу за извршење казне затвора.

Из образложења:

Одредбом чл.45. ст.6. КЗ, прописани су услови који требају бити испуњени да би суд донео решење и одредио да осуђени остатак казне затвора издржи у Заводу за извршење казне затвора. Ти услови су прописани и одредбама закона о извршењу ван заводских санкција, а то је да уколико осуђени једном

у трајању преко шест часова или два пута у трајању до шест часова самовољно напусти просторије у којима станује. Према наведеним одредбама нужно је да је осуђени започео издржавање казне затвора у просторијама у којима станује.

У конкретном случају из списка предмета произилази да осуђени уопште није ступио на издржавање казне затвора у просторијама у којима станује и да је првостепени суд предметно решење донео због тога што се осуђени није одазвао на разговор на који је позван од стране Управе за извршење кривичних санкција, што није законски разлог за доношење побиијаног решења.

У конкретном случају присуство осуђеног који је тренутно недоступан има се обезбедити на исти начин као и када осуђени казну затвора треба да издржи у Заводу за извршење казне затвора, па се у таквој ситуацији осуђени који казну затвора треба да издржи у просторијама у којима станује има привести на издржавање казне затвора у кућним условима. Одредба чл.29. ст.2. и ст.3. Закона о извршењу ванзаводских санкција као и одредба чл.45. ст.6. КЗ, које прописују замену казне затвора у просторијама у којима осуђени станује казном у Установи за извршење казне затвора односе се само на ситуацију када осуђени након што је већ отпочео са издржавањем казне затвора у просторијама у којима станује, самовољно напусти исте једном у трајању од преко шест часова или два пута у трајању до шест часова.

(Решење Основног суда у Бору К.бр. 222/19 од 24.5.2021. године и решење Апелационог суда у Нишу12Кж.2.бр. 333/22 од 23.6.2022.године)

Приредио судија Зоран Поповић

НУЖНА ОДБРАНА

За правилну процену неопходности одбране, а тиме и постојања нужне одбране, неопходно је догађај посматрати у целини, односно узети у обзир све околности под којима су вршени напад и одбрана, те тек након тога извести закључак о томе да ли се нападнуто лице понашало на начин и под условима који одговарају институту нужне одбране. Дакле, код одлучивања о питању да ли је нужна одбрана била неопходно по-

требна за одбијање напада, не може се ценити искључиво адекватност употребљеног средства за напад и одбрану, већ треба ценити и друге околности, као што су интензитет напада, средства која су стајала на располагање нападнутом за одбијање напада, као и друге могућности за одбијање напада, те тек након тога оценити да ли је нападнути у конкретном случају применио адекватан начин одбране.

Из образложења:

“Првостепеном пресудом оптужени Ф. П. је оглашен кривим да је прекорачењем нужне одбране тешко телесно повредио малолетног оштећеног Л. А., у време, на месту и на начин ближе описан изреком побијане пресуде.

Образлажући своје чињеничне и правне закључке, односно одлуку да оптуженог огласи кривим за ово кривично дело, првостепени суд у образложењу побијане пресуде наводи да би се у конкретном случају, о постојању нужне одбране могло радити само до тренутка када је оштећеном Л. А. испала палица из руке. Дакле, по налажењу првостепеног суда, оптужени је све до тог тренутка предузимао радње које би се могле подвести под нужну одбрану, тиме што је на истовремени противправни напад који је оштећени критичном приликом предузео према њему, ударајући га дрвеном палицом, одговорио тако што је оштећеном, песницама задавао ударце по телу, у једном тренутку и у пределу браде, наневши му лаку телесну повреду, а потом га шутнуо у груди, услед чега је оштећеном испала палица из руке.

Доказима изведеним у току поступка првостепени суд је утврдио да је оштећени, након што је пао на земљу, поново дошао у посед палице, на тај начин што је исту отео из руку сведока С. П. и оптуженом задао ударац у пределу главе, те да је оптужени тада извукао нож из јакне, расклопио га и оштећеном задао убод у пределу десне бутине. По налажењу првостепеног суда, оптужени је на описани начин прекорачио границе нужне одбране јер је на напад оштећеног, одговорио неадекватним средством - ножем који је далеко опаснији и убојитији од палице.

Међутим, овакви чињенични закључци првостепеног суда за сада су нејасни и преурањени. Наиме, у конкретної ситуацији, када оштећени Л. А. оптуженом задаје ударце дрвеном палицом, а оптужени се брани голим рукама и оштећеном задаје ударце песницама и једном га шутне услед чега исти пада и испушта палицу из руку, а одмах затим, отимајући палицу из руку сведока С. П., исказује даљу упорност у настојању да оптуженог повреди и

оптуженом задаје ударац у пределу слепоочнице, наносећи му повреду која је констатована и у налазу и мишљењу вештака, када рана почиње да крвари. а оптужени осећа јаку бол и маглу пред очима, те у ситуацији када оптужени тек тада, у стању смањене урачуљивости због афективног узбуђења које по свом квалитету одговара физиолошком афекту страха, вади нож из јакне и оштећеном задаје убод у пределу ноге, а не у витални део тела, настојећи да одбије истовремени противправни напад, нејасно је зашто ове радње оптуженог првостепени суд третира као прекорачење нужне одбране, односно не даје јасне разлоге о томе шта је оптужени у поменутој ситуацији требао да уради да би се сматрало да је његова реакција адекватна и да се ради о нужној одбрани.

При закључивању да је оптужени употребом ножа прекорачио границе нужне одбране, првостепени суд није ценио ни континуитет ни интензитет напада, нити могућности које је оптужени у поменутој ситуацији имао за одбијање напада, односно није цењено да се све време од удараца дрвеном палицом оптужени бранио само рукама, а да је тек у ситуацији када је ударен и повређен том дрвеном палицом у пределу главе, уз осећај јаког бола и обилно крварење из повређеног дела главе, извадио нож и врхом ножа повредио оштећеног у пределу ноге, суд критични догађај није сагледао у целини, те је првостепена пресуда морала бити укинута.

(Пресуда Вишег суда у Нишу К.бр.30/21 од 01.12.2021.године и решење Апелационог суда у Нишу К.бр.1 91/22 од 23.02.2022.године)

Сентенцу приредила Ивана Јаковљевић, виши судијски помоћник

ОЦЕНА ДОКАЗА

Суд може пресуду засновати на чињеницама у чију је извесност уверен, дужан је да савесно оцени доказе и из тога изведе закључак о извесности постојања одређене чињенице. Због тога се искључиво на основу исказа сведока који приликом сведочења изражава несигурност у погледу предмета сведочења не може извести закључак у погледу извесности постојања одређене чињенице.

Из образложења:

Одредбом чл.16. ст.4. ЗКП, прописано је да пресуду суд може засновати само на чињеницама у чију извесност је уверен, а одредбом чл.419. ст.2. ЗКП, прописано је да је суд дужан да на основу савесне оцене сваког доказа појединачно и у вези са осталим доказима изведе закључак о извесности постојања одређене чињенице.

Према подацима из списка предмета, првостепени суд је осуђујућу пресуду према опт. Љ. Ј. засновао искључиво на исказу сведока А.Д. који је изјашњавајући се о томе ко је спорни предмет донео на отпад употребио речи „колико се сећам“. Ово по ставу Апелационог суда упућује на несигурност у наводима сведока, због чега је Апелациони суд отворио претрес и поново испитао сведока А.Д. управо у погледу одлучене чињенице ко је донео спорни предмет и продао га на отпаду. На претресу пред другостепеним судом сведок се изјаснио о начину откупа секундарних сировина па је објаснио да је податак о томе да је оптужени продао тај предмет добио од радника са отпада који су му рекли да је тај предмет донео „највероватније“ оптужени и да су му то радници рекли по сећању, а да он сам се не сећа да ли је оптужени критичном приликом са осталим гвожђем донео и предмет зелене боје који је сведок С. М. препознао као свој.

Првостепени суд погрешно оцењује наведени доказ - исказ сведока Д. А. јер исти нема непосредних сазнања о томе ко је донео спорни предмет, а сазнања које је добио од других радника не упућују на потпуну сигурност да је тај предмет донео оптужени, јер се радници изјашњавају да је исти „највероватније“ донео оптужени а да тако мисле по „сећању“. Када се има у виду исказ сведока Д.А. да дневно има 30-40 откупа то је потпуно јасно да не постоји било каква сигурност да је оптужени донео предмет који је оштећени препознао као свој. Ово тим пре што се у потврди о преузетим секундарним скровинама не наводи критичан предмет по изгледу и тежини већ само отпадно гвожђе у укупно измерењу количини.

Полазећи од наведених одредби, Апелациони суд налази да због потпуне неизвесности у погледу чињенице ко је предмет оштећеног донео и продао на отпаду, нема места закључивању да је оптужени извршио предметно кривично дело на штету оштећеног С. М., односно да нема поузданих доказа да је учинио предметно кривично дело.

Приликом оцене доказа суд треба посебну пажњу да посвети савесности у оцени доказа, а ради извођења закључка о извесности постојања одређене чињенице. Исказе сведока који у себи садрже несигурност у погледу предмета сведочења, а то су обично поштапалице као што су: „чини ми се“, „колико се сећам“, „највероватније“ „ако се не варам“ и слично, суд треба савесно оценити и уколико ниједан други доказ не указује извесност неке чињенице, на основу таквог доказа не може да изводи закључак о извесности постојања одређене чињенице, како је то учинио првостепени суд.

(пресуда Основног суда у Алексинцу К.бр. 384/21 од 14.3.2022.године и пресуда Апелационог суда у Нишу Кж.1 .бр. 424/22 од 20.8.2022.године)

Приредио судија Зоран Поповић

РАЗГРАНИЧЕЊЕ РАДЊИ ИЗМЕЂУ КРИВИЧНОГ ДЕЛА ИЗ ЧЛ.322. КЗ И ЧЛ.23 ЗАКОНА О ЈАВНОМ РЕДУ И МИРУ

Код кривичног дела спречавање службеног лица при вршењу службене радње из чл.322. КЗ као заштитни објект извршења дела предвиђена службена радња коју полицијски службеник у конкретном случају врши. са циљем да се онемогући да је изврши или да се принуди на вршење исте, а код кривичног дела из чл.23. ст.1. ЗЈРМ са циљем ометања овлашћених службених лица у вршењу службене радње.

Из образложења:

Примењујући кривични закон на овако утврђено чињенично стање, првостепени суд налази да су се у радњама оптуженог стекла сва субјективна и објективна обележја кривичног дела ометање службеног лица у вршењу службене дужности из чл.23. Закона о јавном реду и миру.

Приликом образложења свог става, у разложима пресуде, на 10. страни, првостепени суд наводи да се определио за овакву квалификацију дела, имајући у виду ток целог догађаја као и интензитет радњи које је предузео оптужени, сматрајући да његове радње нису биле довољног интензитета да би могле довести до спречавања службеног лица у вршењу службене радње, већ су имале карактер радњи којима се само ометају службена лица у вр-

шењу службене радње. Такође, првостепени суд закључује да је оптужени одгурнуо (а не ударио) полицијског службеника онда када је службена радња легитимисања завршена.

Међутим, Апелациони суд налази да се за сада не може као правилна прихватити правна оцена радњи оптуженог из побијане пресуде. Ово из разлога што првостепени суд приликом правне оцене дела оптуженог губи из вида законска обележја кривичног дела спречавање службеног лица у вршењу службене радње, јер је чл.322. ст.1. КЗ прописано да дело чини онај ко силом или претњом да ће непосредно употребити силу спречи службено лице у вршењу службене радње коју предузима у оквиру својих овлашћења или га на исти начин принуди на вршење службене радње, а ст.3. истог члана, да дело чини онај ко дело из ст. 1. и 2. овог члана учини према службеном лицу у вршењу послова јавне или државне безбедности или дужности чувања јавног реда и мира, спречавања или откривања кривичног дела, хватања учиниоца кривичног дела или чувања лица лишеног слободе. Законом о јавном реду и миру, одредбом чл.23. ст. 1. прописано је да кривично дело ометање службеног лица у вршењу службене дужности врши онај ко прети да ће напасти, покуша да нападне или нападне или на други начин омета службено лице надлежних органа из чл.2. тог закона (између осталих, и припаднике Министарства унутрашњих послова) у вршењу службене дужности.

Из напред наведеног, јасно произилази да се разграничење радњи између наведених кривичних дела врши у односу на заштитни објект, који се помнутим нормама штити. Тако је код кривичног дела спречавање службеног лица при вршењу службене радње из чл.322. КЗ као заштитни објект извршења дела предвиђена службена радња коју полицијски службеник у конкретном случају врши, са циљем да се онемогући да је изврши или да се принуди на вршење исте, а код кривичног дела из чл.23. ст.1. ЗЈРМ са циљем ометања овлашћених службених лица у вршењу службене радње.

(Пресуда Основног судау Нишу 2К.бр.857/21 од 18.01.2022. године и решење Апелационог судау Нишу Кж. 1.бр.343/2022 од 12.07.2022. године)

Приредила: судија Горана Митић

СЛУЧАЈНИ НАЛАЗ

чл.164.Законика о кривичном поступку

За постојање случајног налаза није неопходно да лице према коме се не примењује посебна доказна радња, буде на било који начин доведено у везу са лицем према коме се посебна доказна радња примењује, већ је за коришћење тако прибављеног материјала у поступку довољно да се материјал о кривичном делу или учиниоцу који није био обухваћен одлуком о одређивању посебних доказних радњи, односи на кривично дело из чл.162.овог законика.

Из образложења:

“Наиме, образлажући своју одлуку да снимке тајног праћења и снимања који се налазе на диску број 11., издвоји из списка предмета. првостепени суд у образложењу решења наводи да у односу на окривљеног М. Р. у време извршења дела није била на снази мера тајног праћења и снимања, да поменута мера није била одређена ни према лицу Е. Б. које се са њим критичном приликом налазило у кабини бр.1, а да је А. И. у односу на кога је била на снази мера тајног праћења и снимања радио у кабини бр.2, због чега закључује да је окривљени М. Р. критичног дана неовлашћено сниман и праћен, те да се снимци тајног праћења и снимања морају издвојити из списка предмета.

Дакле, по ставу првостепеног суда, наведени снимци не могу представљати случајни налаз, већ недозвољени доказ, с обзиром да у кабини број 1 која је надзирана, ниједно лице није било обухваћено мером тајног снимања и праћења.

Одредбом чл.164 ЗКП којом је регулисан случајни налаз, прописано је да ако је предузимањем посебних доказних радњи прикупљен материјал о кривичном делу или учиниоцу који није био обухваћен одлуком о одређивању посебних доказних радњи, такав материјал се може користити у поступку само ако се односи на кривично дело из чл.162. овог законика.

Међутим, наведеном законском одредбом није прописано да је за постојање случајног налаза неопходно да лице према коме се не примењује посебна доказна радња, буде на било који начин доведено у везу са лицем према коме се посебна доказна радња примењује, већ је за коришћење тако прибављеног материјала у поступку довољно да се материјал о кривичном

делу или учиниоцу који није био обухваћен одлуком о одређивању посебних доказних радњи, односи на кривично дело из чл.162.овог законика.

С тим у вези, нејасан је закључак првостепеног суда да би у конкретном случају, снимци тајног праћења и снимања настали у кабини бр.1 имали карактер случајног налаза, само у ситуацији да је окривљени М. Р. критичног дана радио у кабини број 2 заједно са А. И. и да је предметни снимак настао за време док је мера тајног праћења и снимања примењивана према А. И.

Имајући у виду да овакав став првостепеног суда нема упориште у закону. жалбени наводи Вишег јавног тужиоца, којима се првостепено решење побија наводима да за законитост прибављеног материјала није од значаја што се у кабини у којој се спроводила посебна доказна радња, налазио М. Р., а неко од лица које је обухваћено одлуком о одређивању посебних доказних радњи, оцењени су као основани”.

*(Решење Вишег суда у Нишу, Посебно одељење за сузбијање корупције
Кпо 4 85/20 од 19.11.2021.године и решење Апелационог суда у Нишу,*

Кж.2.бр.715/2021 од 01.12.2021.године)

Сентенцу приредила Ивана Јаковљевић, виши судијски помоћник

УСЛОВНИ ОТПУСТ

Када се лицу на издржавању казне затвора у установи одреде индивидуални циљеви којима се неће смањити ризик од вршења кривичних дела, тада неће бити места закључку да ће се осуђени на слободи добро владати и да до истека казне неће извршити кривично дело због чега ће се одбити молба за условно отпуштање.

Из образложења:

Основано се жалбом Вишег јавног тужиоца у Нишу указује да је првостепени суд погрешно утврдио одлучне чињенице које представљају подлогу за закључак првостепеног суда да су испуњени услови за пуштање на условни отпуст осуђеног Д. Ј.

Наиме, првостепени суд је ценећи садржину извештаја КПЗ Ниш који је у свему позитиван и који је као индивидуалне циљеве у преваспитању осуђеног дефинисао: одржавање радних навика, повећана брига о менталном здрављу и правилно коришћење ванзаводских проширених права и погодности, који су по ставу установе реализовани у довољној мери због чега се даје мишљење да је условни отпуст оправдан, нашао да треба осуђеног условно отпустити са издржавање казне затвора.

У конкретном случају из списка предмета произилази да је осуђени кривично дело учинио grubим кршењем бланкетних норми из области безбедности јавног саобраћаја и у алкохолисаном стању. Из извештаја Казнено поправног завода се може утврдити да као индивидуални циљ преваспитања осуђеног Драгољуба Јоцића није утврђено било шта што се односи на рад са осуђеним у вези усвајања друштвено прихватљивог понашања, обавезе поштовања норми, едукација везана за указивање на штетност од алкохолизма, спознаје о вредности људских живота и слично, а што је по налажењу суда било неопходно обзиром на кривично дело за које казну издржава. Одредбом члана 13.ст.1.тач.4. Правилника о третману, програму поступања, разврставању и накнадном разврставању осуђених лица(службени гласник РС бр. 55/14) прописано је да програм поступања између осталог садржи индивидуалне циљеве осуђеног у одређеном периоду чијим остварењем ће се обезбедити и смањење ризика од вршења кривичних дела. Индивидуални циљеви се код сваког лица на издржавању казне дефинишу зависно од карактеристика личности, психолошких социјалних и здравствених особености и не постоји јединствен списак таквих циљева а одредбом члана 32 наведеног правилника предвиђена је и могућност измене програма поступања. Међутим све мере морају имати за циљ смањење ризика од вршења кривичних дела.

Како је по налажењу Апелационог суда у конкретном случају извршен потпуно погрешан избор индивидуалних циљева који заправо служе искључиво личним интересима осуђеног а не кориговању његовог неприхватљивог понашања које је испољено приликом извршења кривичног дела. то се не може са основом закључити да ће се осуђени на слободи добро владати и да до истека казне неће извршити ново кривично дело а због чега је условно отпуштање осуђеног Д. Ј. за сада неоправдано.

(Решење Вишег суда у Нишу Куо.бр. 30/22 од 16.5.2022.године и решење Апелационог суда у Нишу 12Кж.уо.бр. 48/22 од 23.5.2022.године.)

Приредио судија Зоран Поповић

ОБАВЕЗНО ИЗУЗЕЋЕ

Када је одлуку о казни доносио судија који је морао бити изузет, првостепена пресуда поводом жалбе а по службеној дужности мора бити укинута.

Из образложења:

Испитујући првостепену пресуду у делу одлуке о казни, поводом жалбе браниоца оптуженог, по службеној дужности, сходно чл. 451 ст. 2 тач. 1 ЗКП, Апелациони суд налази да је у доношењу одлуке у овом делу, учествовао судија који се је морао изузети.

Наиме, ванпретресно веће Основног суда, састава председник већа - судија АА и чланова већа - судија ББ и ВВ. решењем је потврдило оптужницу Основног јавног тужиоца.

Истовреме, члан ванпретресног већа - судија ВВ, поступао је као председник претресног већа, иако је чл. 37. ст. 1. тач. 4 ЗКП, прописано да ће судија бити изузет од судијске дужности ако је одлучивао о потврђивању оптужнице.

Поступањем на наведени начин, учињена је апсолутна битна повреда одредаба кривичног поступка из чл. 438. ст. 1. тач. 4 ЗКП, због које се законитост побијане пресуде у делу одлуке о казни не може испитати и због чега је иста нужно морала бити укинута.

(пресуда Основног суда у Мајданпеку К.бр.61/2019 од 03.11.2021. године и решење Апелационог суда у Нишу Кж1 .бр.360/2022 од 30.05.2022. године)

Приредио судија Саша Бошковић

БИТНА ПОВРЕДА ОДРЕДАБА КРИВИЧНОГ ПОСТУПКА ИЗ ЧЛ.438. СТ.2. ТАЧ.1. ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ

Битна повреда одредаба кривичног поступка из чл.438. ст.2. тач.1. Законика о кривичном поступку постоји ако се пресуда заснива на записнику о претресању као доказу на коме се по одредбама Законика о кривичном поступку не може заснивати у ситуацији када ток претресања

стана и других просторија држаоца или лица на коме се претресање предузима није тонски и оптички снимљен нити су предмети пронађени током претреса посебно фотографисани, те снимци и фотографије приложени записнику о претресању, иако је то обавезно у смислу одредбе чл.157. ст.5. Законика о кривичном поступку, а претресање је предузето без присуства два пунолетна грађанина као сведока у смислу одредбе чл.156. ст.7. Законика о кривичном поступку, с обзиром да су били испуњени услови из чл.156. ст.3. Законика о кривичном поступку.

Из образложења:

Апелациони суд у Нишу као другостепени је, по одржаном претресу, усвојио жалбе јавног тужиоца и браниоца оптужених и преиначио првостепену пресуду тако што је оптуженог АА ослободио од оптужбе, применом одредбе чл.423. тач.2. Законика о кривичном поступку, за кривично дело тешка крађа из чл.204. ст.1. тач.1. Законика о кривичном поступку, јер није доказано да је учинио дело за које је оптужен, док је оптуженог ББ огласио кривим за кривично дело тешка крађа из чл.204. ст.1. тач.1. Кривичног законика, при чему је свој чињенични закључак да је оптужени ББ у критичном периоду, у ..., у ул. ... број 1, у намери да одузимањем туђих покретних ствари себи прибави противправну имовинску корист, обио породичну кућу власништво оштећеног ВВ из .. и из исте одузео новац у износу од 150 еура, у динарској противвредности од 18.600,00 динара, засновао на оцени одбране оптуженог ББ, записника о претресању стана и других просторија ПУ Врање од 20.04.2017. године, потврде о привремено одузетим предметима од 20.04.2017. године и записника о вештачењу НКТЦ у Нишу од 28.04.2017. године, као и осталих доказа.

Основано се жалбом браниоца оптуженог ББ указује да је другостепена пресуда у осуђујућем делу донета уз битну повреду одредаба кривичног поступка из чл.438. ст.2. тач.1. Законика о кривичном поступку, јер се пресуда у односу на овог оптуженог заснива на доказу на коме се по одредбама Законика о кривичном поступку не може заснивати, због чега није могуће испитати законитост и правилност пресуде. Наведена битна повреда одредаба кривичног поступка се огледа у томе што је записник о претресању стана и других просторија ПУ Врање од 20.04.2017.године према начину прибављања у супротности са Законом о кривичном поступку, на који недостатак пресуде жалба браниоца оптуженог ББ основано указује. Ово стога

што из списка предмета произилази да ток претресања стана и других просторија оптуженог ББ, по наредби Основног суда у Врању Кппр. 138/2017 од 18.04.2017. године, није тонски и оптички снимљен, нити су фотографисани пронађени предмети, при чему снимци и фотографије нису приложени записнику о претресању, иако је то обавезно у смислу одредбе чл.157. ст.5. Законика о кривичном поступку.

Наиме, како је претресање стана и других просторија оптуженог ББ предузето без присуства два пунолетна грађанина као сведока, с обзиром да су били испуњени услови из чл.156. ст.3. Законика о кривичном поступку и то због тога што се претпостављао оружани отпор или друга врста насиља и због тога што се очигледно припрема или је отпочело уништавање трагова кривичног дела или предмета важних за поступак, што је у складу са одредбом чл.156. ст.7. Законика о кривичном поступку, који разлози произилазе из записника о претресању стана и других просторија ПУ Врање од 20.04.2017. године, то је у конкретном

случају у смислу одредбе чл.157. ст.5. Законика о кривичном поступку било обавезно тонско и оптичко снимање претреса, као и фотографисање пронађених предмета који су одузети по потврди о привремено одузетим предметима од оптуженог ББ, што није учињено, те је другостепена пресуда у осуђујућем делу захваћена битном повредом одредаба кривичног поступка из чл.438. ст.2. тач.1. Законика о кривичном поступку, на који недостатак другостепене пресуде жалба браниоца оптуженог ББ основано указује.

(пресуда Апелационог суда у Нишу Кж1 306/2019 од 04.06.2019. године и решење Апелационог суда у Нишу Кж3 32/2019 од 27.01.2020. године)

приредила виши судијски сарадник Марија Петровић

ВЕЗАНОСТ СУДА ЗА ПРАВНУ КВАЛИФИКАЦИЈУ ТУЖИОЦА

чл.341. законика о кривичном поступку

Приликом доношења решења којим потврђује оптужницу веће суда (из чл.21. ст.4. ЗКП) је везано за правну квалификацију кривичног дела коју је тужилац навео у оптужници, будући да је чл.340. ЗКП про-

писано да суд није везан за правну квалификацију дела коју је тужилац навео у оптужници или приватној тужби једино приликом доношења решења из члана 337. став 2. и чл. 338. и 339. овог законика, дакле не и код доношења решења из чл.341. ЗКП, којим се оптужница јавног тужиоца потврђује.

Из образложења:

Наиме, у ситуацији када окривљени у својој одбрани наводи да је опојну дрогу држао за сопствену (зло)употребу, која одбрана је поткрепљена и одговарајућим вештачењем из којег произилази да је код окривљеног дошло до развоја зависности од употребе опијата, конкретно канабиса, те документацијом из које јасно произилази да се у ранијем периоду лечио од болести зависности, при чему из одбране окривљеног и описане динамике злоупотребе, произилази да би му количина опојне дроге, пронађена у његовом притежању, била довољна за релативно краћи период злоупотребе, нејасно је из којих конкретних доказа је првостепени суд извео закључак о постојању оправдане сумње о неовлашћеном држању опојне дроге ради даље продаје, који оправдава подизање оптужбе и извођење окривљеног пред суд за кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл.246. ст.1. КЗ.

Ово стога што је једино у случају доношења одлуке о потврђивању оптужнице првостепени суд везан за правну квалификацију из оптужења, односно стандард оправдане сумње мора бити испуњен у односу на сваки од битних елемената бића кривичног дела које је предмет оптужења, па и у погледу намене опојне дроге пронађене у неовлашћеном притежању окривљеног, што је првостепени суд пропустио да учини, на шта се основано указује жалбом браниоца окривљеног, а који недостатак побијаног решења се не може надоместити закључком првостепеног суда да прикупљени докази „не указују нужно да је пронађену опојну дрогу окривљени држао искључиво за сопствене потребе“, без назначења доказа из којих произилази оправдана сумња о намери окривљеног да део опојне дроге канабис, која је од њега уз потврду привремено одузета, неовлашћено стави у промет.

(решење Вишег суда у Лесковцу Кв.бр.44/22 од 04.05.2022. године и решење Апелационог суда у Нишу Кж2 272/2022 од 20.05.2022. године)

Приредио Милан Жикић, Виши судијски сарадник

**ЈАЧИНА УГРОЖАВАЊА ЗАШТИЋЕНОГ ДОБРА КАО ОКОЛНОСТ
ПРИЛИКОМ ОДМЕРАВАЊЕ КАЗНЕ КОД КРИВИЧНОГ ДЕЛА ИЗ
ЧЛ. 246 ст.1 КЗ**

Код кривичног дела недозвољена производња и стављање у промет опојних дрога из чл.246 ст.1 Кривичног законика, не може се код одмеравања казне, у смислу јачине угрожавања заштићеног добра ценити као отежавајућа околност то што се ради о заштићеном добру - здрављу људи.

Из образложења:

„У смислу јачине угрожавања заштићеног добра не може се ценити као отежавајућа околност то што се ради о заштићеном добру - здрављу људи и што је у порасту број конзумента опојне дроге, с обзиром да је законодавац приликом прописивања казне то имао у виду прописујући висок минимум казне која у конкретном случају износи 3 године, са немогућношћу ублажавања исте. У смислу јачине угрожавања заштићеног добра може се само ценити нешто што је везано за конкретно извршење предметног кривичног дела а не заштитни објект кривичног дела који је вреднован управо прописивањем теже кривичне санкције од стране законодавца, те су жалбени наводи тужиоца и у овом делу оцењени као неосновани“.

*(Пресуда Вишег суда у Нишу К.бр.48/21 од 08.11.2021.године и пресуда Апелационог суда у Нишу КжЛ.бр.178/22 од 02.03.2022.године
Сентенцу приредила Ивана Јаковљевић, виши судијски помоћник*

**КРИВИЧНО ДЕЛО СПРЕЧАВАЊЕ И ОМЕТАЊЕ ДОКАЗИВАЊА
чл.336. ст.1.КЗ**

Кривично дело спречавање и ометање доказивања из чл.336. ст. 1. Кривичног законика, може се извршити само у односу на сведока, вештака, преводиоца, тумача или другог учесника у поступку, где се термин *други учесник у поступку* не може односити на саокривљеног у другом предмету.

Из образложења:

У конкретном случају, оптуженом се ставља на терет да је критичном приликом учеснику у поступку пред судом обећао корист и упутио претњу, у намери да то лице давањем лажног исказа утиче на исход поступка, па је и поред изречене мере забране прилажења, састајања, комуницирања са учесником у поступку - саизвршиоцем МН, у предмету Кт. бр. 262/19, а која мера је изречена решењем Основног суда у Пироту 2 Кпнд. бр. 8/19 од 13.06.2019. године. најпре из породичне куће ПМ позвао телефоном МН из села Црвена Река да дође у кућу ПМ, па када је Н дошао, окривљени му је предложио да промени исказ који је Н већ дао у полицији и у тужилаштву у предмету Кт.бр. 262/19 који се води против окривљеног МН и МП, због кривичног дела тешка крађа у саизвршилаштву из чл. 204.ст. 1. тач. 1. у вези чл. 33. КЗ, уз обећање да ће он сносити све трошкове које Н има у том поступку, а у вези ангажовања и плаћања браниоца, па када је Н одбио овакав предлог окривљеног, рекавши да не жели да мења исказ који је претходно дао, окривљени му је упутио речи претње, рекавши му: “да постоји могућност да заједно издржавају затворску казну у истом затвору и да ће то бити лоше по нас”, мислећи на М Н и М П из с. Врандол, саизвршиоце у наведеном поступку.

Кривично дело спречавање и ометање доказивања из чл.336. ст.1. Кривичног законика чини лице које сведоку или вештаку или другом учеснику у поступку пред судом или другим државним органом учини или обећа поклон или другу корист или према њему примени силу или претњу у намери да то лице давањем лажног исказа или недавањем исказа утиче на исход поступка. Дакле, утицање треба да се врши према сведоку, вештаку или другом учеснику у поступку, а појмове ових субјеката треба узети у истом значењу као код кривичног дела давање лажног исказа из чл.335. КЗ.

Следствено наведеном, Апелациони суд налази да се предметно кривично дело може извршити само у односу на сведока, вештака, преводиоца, тумача или другог учесника у поступку, где се термин *други учесник у поступку* никако не може односити на саокривљеног у другом предмету, првенствено из разлога што окривљени у кривичном поступку **не даје исказ, већ износи одбрану**, где искључиво од воље тог окривљеног може зависити у ком ће правцу та одбрана бити усмерена.

Стога је, по налажењу Апелационог суда, погрешан закључак другостепеног суда, који појам “другог учесника у поступку” тумачи “шире”, применом чл.3. ст.1. тач. 1. Закона о програму заштите учесника у кривичном поступку,

где се под учесником у поступку, поред осумњиченог, сведока, сведока сарадника, вештака, стручног лица, сматра и окривљени. Ово из разлога што је чл.5. наведеног Закона стриктно и јасно прописано за која кривична дела се програм заштите примењује. а то су: кривична дела против уставног уређења и безбедности, против човечности и других добара заштићених међународни правом и организованог криминала. Дакле, из наведеног произилази да се у конкретном случају, за кривично дело које се оптуженом ставља на терет, не могу применити одредбе Закона о програму заштите учесника у кривичном поступку, како то чини другостепени суд.

Код оваквог стања ствари, став је Апелационог суда да се основано жалбом браниоца оптуженог побија првостепена пресуда истицањем да у радњама оптуженог не стоје обележја кривичног дела, које му се ставља на терет, па је оптужени, применом одредбе чл.423. тач.1. ЗКП, ослобођен од оптужбе.

(Пресуда Вишег суда у Пироту Кж1.бр.6/21 од 06.07.2021. године и пресуда Апелационог суда у Нишу Кж3 22/2021 од 18.11.2021. године)

Приредила: судија Горана Митић

ПРАВИЛНА ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЈА РАДЊИ ОПТУЖЕНОГ КАО КРИВИЧНО ДЕЛО ИЗ чл.246а ст.1. КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА, А НЕ КРИВИЧНО ДЕЛО ИЗ чл.246. ст.1. КРИВИЧНОГ ЗАКОНИКА

За осуду оптуженог за кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл.246. ст.1. Кривичног законика, за које је оптужен, нужно је пресуду засновати само на чињеницама у чију је извесност суд уверен, а сваку сумњу у погледу чињеница од којих зависи постојање обележја тог или неког другог кривичног дела треба решити у корист оптуженог.

Из образложења:

Пресудом Вишег суда у Зајечару К 2/2019 од 24.01.2019. године оптужени АА из Књажевца је оглашен кривим због кривичног дела неовлашћено држање опојних дрога из чл.246а ст.1. Кривичног законика и осуђен на казну затвора у трајању од 30 (тридесет) дана, у коју му се има урачунати време

provedeno у притвору од 21.12.2017. године до 26.12.2017. године, која ће се извршити тако што ће је оптужени издржавати у просторијама у којима станује у Књажевцу, у улици ББ број 88, без електронског надзора.

На основу чл.246а ст.3. Кривичног законика од оптуженог АА се одузима опојна дрога „Cannabis” нето масе 1,05 грама, 0,93 грама, 1,05 грама, 1,03 грама, 0,32 грама, 0,07 грама и 0,14 грама, која ће се по правноснажности пресуде уништити.

Истом пресудом оптужени је обавезан да плати трошкове кривичног поступка у року од 30 дана по правноснажности пресуде.

Против наведене пресуде жалбу је изјавио Виши јавни тужилац у Зајечару, због битне повреде одредаба кривичног поступка, повреде кривичног закона и непотпуно утврђеног чињеничног стања, са предлогом да се побијана пресуда укине и предмет врати првостепеном суду на поновно суђење.

Побијана пресуда, по оцени овог суда, није захваћена наведеном битном повредом одредаба кривичног поступка, јер образложење садржи јасне, довољне и правилне разлоге из којих се закључује који докази потврђују чињенице које су предмет доказивања, као и то како је првостепени суд ценио изведене доказе, те разлоге зашто налази да се у радњама оптуженог АА стићу сви субјективни и објективни елементи кривичног дела неовлашћено држање опојних дрога из чл.246а ст. 1. Кривичног законика, за које је оглашен кривим, а не кривичног дела за које је оптужен, при чему нема противречности на које жалба указује, па овај суд налази да се пресуда по овом жалбеном основу неосновано побија.

Првостепени суд је на страни 5. образложења пресуде дао јасне, довољне и правилне разлоге о томе због чега није прихватио став јавног тужиоца да је оптужени АА предметну опојну дрогу „Cannabis”, која је од њега одузета по потврди о привремено одузетим предметима од 21.12.2017. године, неовлашћено држао ради продаје. Апелациони суд у потпуности прихвата разлоге првостепеног суда за оцену одбране оптуженог, која је, супротно жалбеним наводима, цењена у склопу анализе свих изведених доказа, те је оцена овог суда да је првостепени суд правилно нашао да је оптужени предметну опојну дрогу неовлашћено држао у мањој количини за сопствену употребу.

На такав закључак управо упућују утврђене одлучне чињенице о количини и врсти опојне дроге, с обзиром да су код оптуженог пронађена 4 пакетића укупне

нето масе 4,45 грама, да су пронађена 3 коришћена опушка, а да су у металној дробилици и пластичној кутији пронађени остаци опојне дроге „Cannabis” у нето маси 0,32 грама и 0,07 грама, затим да су пронађени ризла и метална мерилица, који предмети се користе за прављење „цоинта“, као и чињеница да је анализом урина оптуженог АА утврђено да је у време извршења кривичног дела био позитиван на канабиноид, што све напред наведено, и по налажењу овог суда, упућује да је правилан закључак првостепеног суда о томе да је опојна дрога која је пронађена код оптуженог и коју је неовлашћено држао, најпре била у мањој количини, да је била намењена за сопствену употребу и да ниједним доказом није утврђено да је оптужени исту држао ради продаје.

Из свега наведеног, произилази да је првостепени суд чињенично стање правилно и потпуно утврдио на основу доказа које је извео на предлог странака, уз констатацију да је терет доказивања оптужбе на тужиоцу, како је прописано одредбом чл.15. ст.2. Законика о кривичном поступку. С тим у вези, доказима које је предложио јавни тужилац нису са потребном извесношћу утврђене чињенице да је оптужени АА опојну дрогу, у количини која је код њега пронађена и одузета, неовлашћено држао ради продаје, за коју радњу извршења кривичног дела је оптужен, а све у складу са правилном да при постојању сумњи и индиција, на којима жалба јавног тужиоца инсистира, ове чињенице суд решава у корист оптуженог.

С тим у вези, Апелациони суд налази да су неосновани жалбени наводи јавног тужиоца којима указује да пронађени пакетићи опојне дроге приближно једнаке нето масе, без обзира што вагица за прецизно мерење није пронађена, упућују на закључак да је оптужени опојну дрогу неовлашћено држао ради продаје, с обзиром да вештачењем није поуздано утврђено колико дуго и коју количину опојне дроге оптужени конзумира на дневном или месечном нивоу. Наиме, првостепени суд је поуздано утврдио да је оптужени АА конзумент опојне дроге “Cannabis” коју повремено конзумира, те наведена количина од укупно 4,45 грама нето масе свакако је могла да задовољи његове потребе за краћи временски период. У прилог оваквом закључку првостепеног суда је и чињеница да осим пронађене количине опојне дроге, јавни тужилац није понудио ниједан доказ да је оптужени опојну дрогу држао за даљу продају.

Сходно наведеном, првостепени суд је чињенично стање правилно и потпуно утврдио, а потом на исто правилно применио кривични закон када је нашао да се у радњама оптуженог АА стичу сви и објективни и субјективни

елементи кривичног дела неовлашћено држање опојних дрога из чл.246а ст.1. Кривичног законика, за које га је огласио кривим, док су супротни жалбени наводи јавног тужиоца у погледу другачије правне квалификације и то за кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога из чл.246. ст.1. Кривичног законика, оцењени неоснованим.

(Пресуда Вишег суда у Зајечару К 2/2019 од 24.01.2019. године и пресуда Апелационог суда у Нишу Кж1 258/2019 од 17.05.2019. године)

Приредила: Снежана Милошевић, судија Апелационог суда у Нишу

УПОЗНАВАЊЕ СА САДРЖИНОМ ЗАПИСНИКА О ИСКАЗИМА ЛИЦА КОЈА СУ ОСЛОБОЂЕНА ДУЖНОСТИ СВЕДОЧЕЊА

(чл.406. ст.2. Законика о кривичном поступку)

Записници о ранијем испитивању лица која су ослобођена дужности сведочења (чл.94. ст.1.) не смеју се прочитати и на тако изведеним доказима засновати пресуда ако та лица нису уопште позвана на главни претрес или су на главном претресу изјавила да неће да сведоче, осим ако је, с обзиром на друге доказе, очигледно да би и без тог доказа била донесена иста пресуда.

Из образложења:

Пресудом Апелационог суда у Нишу Кж1 256/2020 од 05.03.2021. године, усвајањем жалбе Основног јавног тужиоца у Владичином Хану, преиначена је првостепена пресуда Основног суда у Сурдулици, Судска јединица у Владичином Хану К 57/2019 од 17.12.2019. године, тако што је оптужени АА оглашен кривим за кривично дело тешка телесна повреда из чл.121. ст.2. у вези ст.1. Кривичног законика и осуђен на казну затвора у трајању од 1 (једне) године, која се има извршити, без примене електронског надзора, тако што ће је оптужени издржавати у просторијама у којима станује и које не сме напуштати, осим у случајевима прописаним законом који уређује извршење кривичних санкција, а уколико оптужени једном у трајању од преко шест часова или два пута у трајању до шест часова самовољно напусти

просторије у којима станује, суд ће одредити да остатак казне затвора издржи у заводу за извршење казне затвора.

Основано се жалбом оптуженог указује да је другостепени суд на претресу поступио противно одредбама чл.450. ст.6. у вези чл.406. ст.2. Законика о кривичном поступку на тај начин што је прочитао исказе привилегованих сведока са записника о њиховом ранијем испитивању, иако они уопште нису позвани на претрес пред другостепеним судом, а то су сведоци који су због сродстава са окривљеним ослобођени од дужности сведочења (чл.94. Законика о кривичном поступку). Иако су на претресу пред другостепеним судом неправилно примењене наведене одредбе Законика, по оцени овог суда као трећестепеног, при постојању осталих доказа у вези истих чињеница које су биле предмет доказивања, другостепени суд је, и без ових доказа на којима се пресуда не може заснивати, чињенично стање правилно и потпуно утврдио и на исто правилно применио материјално право, те ова релативно битна повреда не стоји, јер неправилна примена наведених одредби није била од одлучног утицаја на законитост и правилност другостепене пресуде.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу Кж1 256/2020 од 05.03.2021. године и пресуда Апелационог суда у Нишу Кж3 16/2021 од 10.11.2021. године)

Приредила: Снежана Милошевић, судија Апелационог суда у Нишу

УЧЕСТВОВАЊЕ У ТУЧИ И НЕЖНА ОДБРАНА

Код кривичног дела учествовање у тучи из чл.123 Кривичног законика, учесници се не могу позивати на постојање института нужне одбране из чл.19 Кривичног законика, јер у ситуацији када се сви учесници туче међусобно нападају и бране, њихове делатности немају карактер одбијања противправног напада.

Из образложења:

“Жалбене наводе браниоца којима истиче да је малолетни, сада пунолетни С. И. критичном приликом поступао у нужној одбрани, те да због наведеног, његово понашање није инкриминисано, веће овог суда такође је оценило не-

основаним. Наиме, нужна одбрана је она одбрана која је неопходно потребна да учинилац од себе или другог одбије истовремени противправни напад и за њено постојање морају да буду испуњени одређени услови, како они који се тичу напада тако и услови који се тичу одбране.

Код кривичног дела учествовање у тучи из чл.123 КЗ, које се у конкретном случају, малолетном, сада пунолетном С. И. ставља на терет, долази до физичког обрачунавања између више лица, које често почиње нападом једних и одговором других на такав напад. При том, лице које се брани, није учесник у тучи, све док и само не постане нападач. Уколико се међутим сви учесници у тучи, међусобно и нападају и бране, као је што је у конкретної ситуацији случај, они се не могу позивати на нужну одбрану у смислу чл.19 КЗ, јер тада њихове делатности немају карактер одбијања противправног напада. Из наведених разлога, жалбени наводи браниоца малолетног, сада пунолетног С. И. којима се указује на постојање института нужне одбране, а самим тим и на непостојање дела које се овом лицу ставља на терет, оцењени су као неосновани.”

(Решење Вишег суда у Нишу Км.бр.61/19 од 02.12.2021.године и решење Апелационог суда у Нишу 12 Кжм 1.бр.4/22 од 07.02.2022.године).

Сентенцу приредила Ивана Јаковљевић, виши судијски помоћник

ГРАЂАНСКО ПРАВО

ТЕОРИЈСКО-ПРАКТИЧНА РАЗМАТРАЊА

Сања Костић

Судија Апелационог суда у Нишу

ОСНОВНА ОБЕЛЕЖЈА ДОКТРИНЕ *ПОЉА СЛОБОДНЕ ПРОЦЕНЕ* У ПРАКСИ ЕВРОПСКОГ СУДА ЗА ЉУДСКА ПРАВА

Ratio Legis Est Anima Legis

Латинска пословица

Абстракт:

Фундаментална људска права и основне слободе су након дугог низа година борбе добила признање и правну заштиту у оквиру међународних докумената, универзалног и регионалног карактера и као таква имају изузетан значај за свако демократско друштво.²² Један од најзначајнијих међународних уговора регионалног карактера, који пружа правну заштиту људских права и основних слобода је Конвенција за заштиту људских права и основних слобода (у даљем тексту: Конвенција).²³ Под окриљем Европског суда за људска права (у даљем тексту: Европски Суд), успостављеног Конвенцијом, тумачењем и применом одредби Конвенције, настало је европско право људских права, које има прецедентни карактер. Конвенција је уведена у унутрашњи правни поредак држава чланица њеном ратификацијом, а у Републици Србији је инкорпорисана у прописе унутрашњег правног поретка у рангу закона.²⁴ Конвенција се простира на области на које се односе њене одредбе, али границе те области у пракси није лако одредити, због чега државе чланице имају извесна дискрециона права, односно одређени степен слободе у погледу начина на који испуњавају своје обавезе према Конвенцији.

22 Universal Declaration of Human Rights (1948), International Covenant on Civil and Political Rights (1966), International Covenant on economic, social and cultural rights (1966), European Convention on Human Rights (1950), American Convention on Human Rights (1969), African Charter on Human and Peoples' Rights (1981).

23 https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SRP.pdf, 29.10.2022.

24 Устав Републике Србије, («Службени гласник РС» бр. 98/2006, 16/2022) – Одлука о проглашењу Уставног закона за спровођење Акта о промени Устава Републике Србије - Амандмани I - XXIX - "Сл. гласник РС", бр. 115/2021) чл.16.ст.2: „Општеприхваћена правила међународног права и потврђени међународни уговори саставни су део правног поретка Републике Србије и непосредно се примењују. Потврђени међународни уговори морају бити у складу с Уставом.“

У односу на област на коју се односе та права у пракси је настао израз „**поље слободне процене**“.²⁵ Доктрина поља слободне процене успостављена је аутономно кроз јуриспруденцију суда и резултат је тумачења и примене одредбе Конвенције, створене праксе и њене супсидијарне улоге у европском систему заштите људских права и основних слобода, у контексту бројних области живота. С тим у вези, у овом тексту ће биће приказан развој, аргументи који оправдавају постојање и примену доктрине, фактори који утичу на примену одређивање ширине поља слободне процене, као и ефекти (не) постојања консензуса.

Кључне речи: - Доктрина поља слободне процене; - Европска конвенција о људским правима; - Европски суд за људска права; - принцип супсидијарности

Појам и развој доктрине

Доктрина „поља слободне процене“²⁶ представља одређени степен слободе у погледу начина на који државе уговорнице испуњавају своје обавезе према Конвенцији, што омогућава примену Конвенције у свим државама уговорницама, без обзира на разлике у њиховим националним системима. Наиме, уколико држава прекорачи поље слободне процене, Европски суд ће утврдити повреду одредаба Конвенције. Сходно томе, поље слободне процене омогућава Европском суду неопходну флексибилност да балансира између суверенитета држава уговорница и њихових обавеза према Конвенцији.²⁷

Примењујући одредбе о заштити људских права, државни органи су свакако у бољем положају од Европског суда, јер познају друштвено окружење и домаће прилике, што представља основни разлог за препуштање поља слободне процене држави.

Иако је обим поља слободне процене током времена омеђен судском праксом Европског суда, теорија познаје материјални и структурни концепт слободне процене. Према првом концепту, држава је овлашћена да предузима мере у складу са законом, ради испуњења друштвених циљева, под усло-

25 На званичним језицима Конвенције се користе изрази: *margin of appreciation* и *la marge d'appréciation*

26 Драгољуб Поповић, *Европско право људских права*, Службени гласник, Београд, 2016, 76-78

27 Open Society Justice Initiative, <https://www.justiceinitiative.org/uploads/918a3997-3d40-4936-884b-bf8562b9512b/echr-reform-margin-of-appreciation.pdf>, 29.10.2022.

вом да тиме не крши људска права.²⁸ Сходно другом концепту, нужно је постижање равнотеже између националног и наднационалног права. Европски Суд је првобитно применио доктрину у контексту члана 15, као и у односу на квалификоване одредбе Конвенције, а током наредних деценија, позивање на поље слободне процене постало је све чешће, па се данас може сматрати једном од најважнијих доктрина суда у Стразбуру.

Термин „поље слободне процене“ се први пут помиње 1958. године у предмету *Грчка против Уједињеног Краљевства*²⁹, у извештају Комисије због повреде људских права на Кипру у контексту члана 15. Конвенције. Комисија је сматрала да је надлежна да одлучи да ли је држава уговорница предузела мере у обиму који је то стриктно захтевала хитност ситуације, као и да влада треба да има одређену могућност избора приликом процене која је најхитнија мера.

Текст Конвенције не садржи овај термин, док је поље слободне процене заузело значајно место у ставу 6. Преамбуле Конвенције, који гласи:

*„Потврђујући да Високе стране уговорнице, у складу са начелом супсидијарности, носе првенствену одговорност за обезбеђивање права и слобода гарантованих Конвенцијом протоколима уз њу, и да у ту сврху уживају поље слободне процене које подлеже надзору Европског суда за људска права успостављеног овом Конвенцијом.“*³⁰

Аргументи који оправдавају постојање доктрине, обим поља слободне процене и консенсуз

Доктрина поља слободне процене је не само правни стандард, већ и „израз судског тумачења Европске конвенције“.³¹ Настала је, пре свега, као последица начела супсидијарности³², који је један од основних начела на којима се заснива систем заштите основних људских права и слобода према Конвен-

28 *Ibid.* 5. 78

29 *Greece v. the United Kingdom*, представка бр. 299/57, пресуда од 8. јула 1958.

30 *Ibid.* 2

31 Ivana Krstić, Tanasije Marinković, *Evropsko pravo ljudskih prava*, Savet Evrope, Beograd, 2016, 17.

32 Друга два принципа су принцип ефективности и принцип балансирања између права појединца и интереса заједнице.

цији и који произилази из одредбе члана 1 Конвенције.³³ Начело супсидијарности омогућава појединцу да затражи заштиту пред Европским судом, само у ситуацији уколико пред националним правосуђем није могао да заштити своја права, а искористио је све правне лекове. Стога је примарна одговорност за заштиту људских права на државама уговорницама, док је Европски суд а *posteriori* укључен у предмет. Дајући слободу одлучивања, Суд, заправо, потврђује демократски мандат држава уговорница да одлучују о одређеним питањима људских права.³⁴ Такође, доктрина поља слободне процене дозвољава Европском суду да буде у контакту са правном реалношћу државама чланица у погледу могућности за различиту примену одредби конвенције, задржавајући одређену контролу над понашањем државе.³⁵

У односу на право држава чланица, Конвенција заузима секундарно место, јер је Европски суд још у Белгијском језичком случају³⁶ истако да „не би могао да преузме улогу надлежних државних орагана, јер би тада изгубио супсидијарни карактер међународног механизма колективне гаранције установљеног Конвенцијом. „³⁷

Слобода избора начина на који ће држава чланица извршити пресуду, такође представља последицу начела супсидијарности, о чему се Европски суд прецизно изјаснио у члану 31. пресуде *Маркс против Белгије*,³⁸

„У случају проглашене неусклађености са Европском конвенцијом, држава има обавезу да изврши пресуду, али да јој њена деклараторна природа у суштини препушта одабир средстава које ће употребити. „³⁹

Дакле, имајући у виду супсидијаран механизам заштите, установљен Конвенцијом у односу на националне системе заштите људских права, поље слободне процене се са једне стране јавило као нужна потреба у пракси Европског суда.

33 Високе стране уговорнице јемче свакоме у својој надлежности права и слободе одређене у Делу I ове Конвенције.“

34 *Andrew Legg, The Margin of Appreciation in International Human Rights Law: Deference and Proportionality*, Oxford University Press, Oxford, 2012, 25.

35 *White R.C.A., Ovey C., European Convention on Human Rights*, Oxford University Press, 2002. 80.

36 *Ibid.* 10, 17.

37 *Белгијски лингвистички случај*“ (бр. 2), пара. 5.

38 *Marckx c. Belgique*, представка бр. 6833/74, пресуда од 13. јуна 1979.

39 *Ibid* 17., para. 31.

Међутим, за разлику од мишљења Комисије, током шездесетих и седамдесетих година прошлог века, пресуде Европског Суда нису садржале дискреционо право или поље слободне процене држава уговорница. Поље слободне процене, Европски суд је први пут применио у предмету *Ирска против Уједињеног Краљевства*⁴⁰. У овом случају, Европски Суд је националним властима дозволио широку слободу процене приликом одлучивања о постојању опасности, као и о природи и обиму одступања неопходних за њихово отклањање, будући да је влада Уједињеног Краљевства ограничила личне слободе ирских грађана тако што их је притворила, како би потиснула „спиралу насиља од стране ИРА“.⁴¹

Становиште Европског суда о пољу примене слободне процене има посебан значај у предмету *Handyside против Уједињеног Краљевства*⁴². Ричард Хендисајд, држављанин Велике Британије, био је власник лондонске издавачке куће.

У септембру месецу 1970.године откупио је ауторска праца за објављивање „Мале црвене школске књиге“ за Велику Британију. Књига је била намењена деци школског узраста, са садржајем које се односи на опште образовање, док се једна десетина текста односила на сексуално образовање. Након што су примили више притужби, власти Велике Британије су 30.марта 1971. године предузеле мере у складу са Законом о неморалним публикацијама из 1959.године и 1964.године, а полиција је запленила све примерке књиге, док је против Хендисајда, покренут поступак и изречена му је новчана казна. По жалби Хендисајда, другостепени суд је саслушао сведоке и закључио да је књига неморална, да јој је циљ да заведе већину деце да је читају, да намера Закона да заштити малолетне особе, као и његова одмерена и прецизна примена, испуњава услове за ограничење слободе говора у границама слободне процене државе како би се утврдило шта је „неопходно у демократском друштву“, као и да Хендисајд није доказао да би публикација била оправдана у смислу да је то у интересу јавности.

Хендисајд је поднео представку Комисији, жалећи се на мере које су предузеле британске власти, позивајући се на повреду права на слободу изража-

40 *Ireland v. the United Kingdom*, представка бр. 5310/71, пресуда од 18. јануара 1978.

41 *Ibid.* 19, para.207

42 *Handyside v. the United Kingdom*, представка бр. 5493/72, пресуда од 7. децембра 1976.

вања према члану 10. Конвенције и повреду права на мирно уживање имовине заштићеног чланом 1. Протокола 1.

Европски суд је закључио да су предузете мере биле у складу са Законом о неморалним публикацијама, који је подносилац представке критиковао са аспекта Конвенције, а не са аспекта домаћег права, као и да су исте предузете у складу са заштитом морала, имајући у виду чињеницу да је књига првенствено била намењена деци школског узраста.

Такође, тражећи одговор на питање, да ли је неопходност мешања у демократском друштву у интересу морала, Европски суд је оценио да национални органи имају право на сопствену процену, истичући супсидијарну природу заштите људских права по Конвенцији у односу на националне системе, због чега у конкретном случају нема повреде одредбе члана 10. Конвенције. Осим тога, будући да је заплена књиге извршена у складу са британским правом и у интересу морала, Европски суд је нашао да није повређено ни право на мирно уживање имовине према члану 1. Протокола 1, нити је Хендисајд био жртва дискриминације према члану 14. Конвенције, јер није било доказа који би указивали да је био политички гоњен, нити да су његове друге публикације биле намењене деци, као књига која је забрањена.

„Према томе, члан 10 став 2 оставља уговорницама поље слободне процене. Ово поље се даје и домаћем законодавству и телима, између осталог и судским, од којих се очекује да тумаче и примењују важеће законе“⁴³

Дакле, овом пресудом је успостављен модел поља слободне процене, посебно у односу на стандарде неопходне у демократском друштву и легитимне циљеве, будући да европске државе имају различите основне вредности које оправдавају различито поступање, истовремено узимајући у обзир и различите приступе у решавању питања у државама које имају исти правни систем. Кроз примену поља слободне процене у овом предмету, Европски суд је истакао своју улогу да обезбеди постизање равнотеже између захтева за поштовањем одредби Конвенције и правних система држава уговорница.

„Ипак, Конвенција не оставља државама уговорница неограничено овлашћење за слободну процену. Суд, који је заједно са Комисијом одговоран да осигура да стране уговорнице поштују своје обавезе, овлашћен је да доне-се коначну одлуку о томе да ли је ограничење или казна у складу са слободом

43 Ibid. 21, para. 48

изражавања зајемченом чланом 10. Домаће поље слободне процене, дакле, иде руку под руку са европским надзором.⁴⁴

Међутим, у предмету *Sunday Times против Уједињеног Краљевства*⁴⁵, Европски суд је ограничио поље слободне процене. С обзиром да је новинарска издавачка кућа Sunday times објављивао текстове у вези беба које су рођене у Великој Британији са телесним оштећењима због конзумирања лека Талидомид у трудноћи, за време док је трајао судски поступак, британски суд је утврдио непоштовање суда у овом случају, који институт је прописан одлуком Дома Лордова. Подносилац представке-Sunday Times, је пред Европским судом истицао да је институт непоштовања суда заснован на нејасним и неодређеним правилима и да се не може сматрати да је прописан законом, као и да је подносиоцу представке повређено право на слободу изражавања, док је Европски суд утврдио да је задирање било прописано законом:

„Питање да ли су захтеви доступности и предвидљивости задовољени у овом предмету, компликује чињеница да су се судије ослањале на различита начела. Судско веће је применило начело по коме намеран покушај утицања на исход започетог судског поступка подвргавањем странке јавном притиску представља непоштовање суда. Неки чланови Горњег дома такође су алудирали на ово начело, док су други претпоставили начело по коме је непоштовање суда објављивање материјала који прејудуцира у јавности питања покренутих у текућој парници.“⁴⁶

Такође, у овом предмету, Европски суд је ограничио поље слободне процене и изнео став:

„То не значи да је надзор Суда ограничен на утврђивање да ли је тужена држава своје дискреционо право остваривала разумно, пажљиво и у доброј намери. Чак и она страна уговорница која тако поступа, остаје подложна контроли Суда у погледу усклађености њеног поступања са обавезама које је преузела према Конвенцији.“⁴⁷

У предмету *Ashingdane против Уједињеног Краљевства*,⁴⁸ подносилац представке се жалио да му је онемогућен приступ суду, јер је реч о лицу под

44 Ibid. 21, para. 49

45 *Sunday Times v. the United Kingdom*, представка бр. 6538/74, пресуда од 26. априла 1979.

46 Ibid. 24, para.50.

47 Ibid. 24, para.59.

48 *Ashingdane v. The United Kingdom*, судске одлуке A93(1985)

психијатријским надзором. Наиме, подносилац представке, је дана 23. новембра 1970. године, осуђен од стране суда у Рочестеру, у Кенту, у Енглеској, за опасну вођњу и четири кривична дела незаконитог поседовања ватреног оружја. У кривичном поступку који се водио против њега, достављени су медицински докази да је боловао од менталне болести (параноидна шизофренија) и да је његов ментални поремећај био такве природе или степена да је оправдавао његово задржавање у психијатријској болници. Суд је издао болнички налог према члану 60. Закона о менталном здрављу из 1959. („Закон из 1959. године“) заједно са налогом према члану 65. којим се ограничава отпуштање подносиоца представке без временског ограничења. Исти је првобитно задржан у локалној психијатријској болници, одакле је два је пута побегао, због чега је пребачен у “специјалну болницу” намењену лицима којима је потребно лечење у условима посебне безбедности због њихових опасних, насилних или криминалних склоности. Подносилац представке је задржан у болници у периоду од 1971.године до 1978.године, јер су медицински извештаји указивали да би могао бити опасан уколико се отпусти из болнице. 31. октобра 1978. др Мегвајер, консултант форензички психијатар, који је био одговорни медицински службеник подносиоца представке у болници Бродмоор, известио је да подносилац представке више не представља „претњу коју је раније чинио“ и да би могао да се правилно лечи у отвореној болници. По мишљењу доктора, вероватноћа да ће бити насилан се смањила, иако му је био потребан наставак лечења у болници, па је стога препоручио његово пребацивање у болницу Оуквуд. Подносиоца представке је такође прегледао др Шери, консултант психијатар у болници Оуквуд, који је потврдио ово мишљење. Министар унутрашњих послова је 1. марта 1979. дао сагласност за премештај подносиоца представке у локалну психијатријску болницу, под условом да му се нађе одговарајуће слободно радно место. Међутим, здравствена управа области Кент, локална власт одговорна за болницу Оуквуд, одбила је да прими подносиоца представке у Оуквуд, а државни секретар за социјалне услуге је одбио да усмери његов трансфер тамо, из разлога што су два огранка синдиката медицинског особља спроводила потпуну забрану пријема пацијената који су преступници. Подносиоцу представке није пронађен одговарајући смештај у било којој болници осим у Оуквуду и он је остао у Бродмуру. У међувремену, након што је добио правну помоћ, подносилац представке је у августу 1979. покренуо поступак код Високог суда да оспори законитост свог наставка боравка у Бродмуру. Тек након тога, подносилац представке је пребачен у обичну болницу, где је

најпре био смештен у затворено одељење за шеснаест пацијената, мушкараца и жена, које је било закључано. Од децембра 1980. године, дозвољена му је слобода, без пратње, у кругу болнице два сата дневно, док је у лето 1981. премештен је на отворено одељење. Од тада, редовно одсуствовање без пратње да посети своју породицу постало је обележје његовог живота у Оуквуду. У новембру 1984. ишао је кући сваког викенда од четвртка до недеље и могао је да напусти болницу, од понедељка до среде, само под условом да се ноћу враћа на своје одељење.

У контексту поља слободне процене, Европски суд је закључио да није било повреде одредбе члана 6. Конвенције, односно да државе уживају поље слободне процене и да домаћи суд није повредио право на приступ суду ограничавањем приступа лицу које је под психијатријским надзором, будући да приступ суду према националном праву може бити подвргнут извесним ограничењима, у зависности од потреба друштва.

„Наравно, право на приступ судовима није апсолутно, али може бити подложно ограничењима; ово је дозвољено имплицитно пошто право на приступ по својој природи захтева регулацију од стране државе, регулативу која може варирати у времену и месту у складу са потребама и ресурсима заједнице и појединаца... У доношењу таквог прописа, државе уговорнице уживају одређену слободу процене. Док коначна одлука о поштовању захтева Конвенције остаје на Суду, није део функције Суда да замени процену националних власти било којом другом проценом шта би могла бити најбоља политика у овој области.“⁴⁹

Такође, Европски суд је закључио да право подносиоца представке на слободу и личну безбедност није било ограничено у мери која је већа од оне предвиђене чланом 5. Конвенције, иако је подносилац представке, морао да проведе у строжем режиму у специјалној психијатријској болници деветнаест месеци дуже него што је то било потребно због његовог менталног здравља, због чега је и дошло до кашњења у његовом премештају у обичну психијатријску болницу. Основни аргумент Европског суда у прилог изнетом становишту је да место и услови затварања подносиоца представке у специјалну болницу са строжим режимом нису престали да буду место и услови који се могу повезати са „законитим затварањем ментално оболеле особе“.

49 Ibid 27. para. 57

У предмету *Steel and Morris против Уједињеног Краљевства*⁵⁰, Европски суд је утврдио повреду члана 6. Конвенције. Подносиоци представке су екологиисти који су водили кампању против Мекдоналдових ресторана, публиковањем брошуре “Шта је лоше са McDonald’s-om?”, позивајући их на одговорност за глад и уништавање племенског живота из земаља „трећег света“ из којих се набављају сировине. Мекдоналдова компанија је тужила подносиоце представке за клевету, у ком поступку им је било ускраћено право на бесплатну правну помоћ, јер суд у Британији искључује могућност остварења права на правну помоћ у оваквим парницама, због чега су и поднели представку Европском суду због повреде члана 6. и 10. Конвенције. Међутим, Европски суд је у овом предмету признао поље слободне процене, позивајући се на одредбе домаћег права, али је истовремено оценио да није постојала једнакост оружја, што је и довело до повреде члана 6. Конвенције.

У овом контексту, поменућу и предмет *Sanchez против Француске*⁵¹ чијој је расправи пред Великим већем присуствовао аутор овог текста у јуну месецу 2022.године. Наиме, овај предмет је упућен Великом већу 17.јануара 2021. године, јер је Европски Суд у својој пресуди од 02.09.2021.године нашао да нема повреде члана 10. Европске конвенције, који се односи на слободу изражавања, због осуде локалног одборника да предузме хитне мере у брисању противзаконитих коментара других на зиду свог Фејсбук налога, који је био слободно доступан јавности и коришћен током његове изборне кампање. Подносилац представке, у то време, локални одборник и кандидат за посланика у парламенту, осуђен је у кривичном поступку за подстицање мржње или насиља над групом људи или појединца по основу верске припадности, након његовог пропуста да предузму бржу акцију и избрише коментаре који су други поставили на зиду његовог Фејсбук налога који је био слободно доступан јавности и коришћен током његове изборне кампање. Утврђено је да су коментари били незаконити, јер су дефинисали конкретну групу људи муслиманске вероисповести као и повезаност муслиманске заједнице са криминалним групама, а речник који је употребљен је био увредљив. Такође, статус подносиоца представке, као изабраног представника се не сматра околношћу која ублажава његову одговорност, будући да је он оптужен за недостатак обазривости и реакције у односу на одређене коментаре објављене на зиду његовог Фејсбук налога. Пошто се није могло утврдити да је подносилац представке

50 *Steel and Morris v. The United Kingdom*, представка бр. 68416/01, пресуда од 15. септембра 2005.

51 *Sanchez v. France*, представка бр. 45581/15, пресуда од 2. септембра 2021.

обавештен о садржају коментара пре него што су они постављени, судови су испитали његово понашање искључиво у односу на период објављивања. Подносилац представке је сматран одговорним у својству креатора јавне комуникационе странице на интернету, на којој су поруке које су објавили корисници биле доступне јавности, а његова одговорност је настала као резултат његовог пропуста да избрише незаконите поруке, чим је за њих сазнао. Он је заправо оптужен за другачије понашање од понашања осталих корисника који су постављали коментаре, који су такође осуђени. По мишљењу Европског Суда, било је легитимно сматрати да статус власника зида Фејсбук налога подразумева посебне обавезе, посебно када је, као у случају подносиоца представке, власник одлучио да не искористи опцију ограничавања приступа зиду, уместо тога бирајући да га учини доступним свима. Подносиоцу представке је наложено да плати новчану казну од 3000 евра, која није несразмерна, имајући у виду казну са којом је могао да се суочи и непостојање других утврђених последица по њега.

У вези примене поља слободне процене, Европски суд је у овом предмету констатовао да је мешање у демократском друштву било неопходно, да је “одлука француских судова да осуди господина Санчеца била заснована на релевантним и довољним разлозима повезаним са његовим недостатком будности и нереаговања.”⁵² односно да статус подносиоца представке као одборника и политичке фигуре захтева већу пажњу са његове стране у датим околностима. Предмет је поново упућен Великом већу, на захтев подносиоца представке, где су на одржаној расправи, заступници одговарали на питања Суда, али одлука Великог Већа још увек није коначна и није објављена на званичном сајту Суда.

Доктрина поља слободне процене је нашла широку примену и у предметима који се односе на уживање имовине.⁵³ Неометано уживање имовине је правило опште природе, које обухвата све ситуације које се односе на мешање у имовини појединца. Међутим, имајући у виду на широко постављен концепт одузимања имовине и контролу њеног коришћења у пракси Европског суда, примена правила је у пракси различита.

⁵² *Ibid* 30. para. 31

⁵³ *Stummer v. Austria* , представка бр. 37452/02, пресуда од 7. јула 2011.

У предмету *Sporrong and Lonnroth protiv Шведске*,⁵⁴ подносиоци представке су се жалили на ефекте дугорочних дозвола за експропријацију и забране изградње на имању покојног г. Споронга и на г-ђу Лоннротх, у њиховом својству власника имовине, не оспоравајући да су предметне дозволе за експропријацију и забране изградње биле законите. С друге стране, жалили су се на дужину рокова који су Граду Стокхолму дати за покретање судског поступка за утврђивање накнаде за експропријацију -пет година, продужено за три, затим за пет и на крају за десет година у случају имања Споронг, и десет година у случају госпође Лоннротх. Такође, жалили на чињеницу да су дозволе за експропријацију и забране градње биле на снази током дужег периода -двадесет три и осам година за дозволе; двадесет пет и дванаест година за забране, указујући на штетне ефекте на њихово право својине које су изазвале ове мере. Осим тога, тврдили су и да су изгубили могућност продаје своје имовине по нормалним тржишним ценама, да би се изложили превеликом ризику да су имали расходе на својој имовини, као и да би наишли на потешкоће у добијању хипотека да су их тражили. Сходно наведеном, сматрали су да је њихово право својине било лишено суштине, за време трајања наведених мера, као и да наведене дозволе и забране нису довела до остварења права на надокнаду.

Европски Суд је сматрао да оваква ситуација није утицала на право коришћења и располагања имовином, али је нашао да је иста у пракси знатно смањила могућност вршења овог права и утицала на саму суштину права на својину, те права на мирно уживање имовине, указујући посебно да приликом планирања развоја великих градова државе имају широко поље слободне оцене. Приликом одмеравања општег интереса друштва и заштите права појединца, Европски Суд је утврдио да потребна правична равнотежа неће бити постигнута када одређено лице трпи прекомеран индивидуалан терет, па је предметним дозволама, чије су последице погоршане забраном градње, прекршен члан 1 Протокола 1. у погледу оба подносиоца представке. Дакле, Европски суд је искористио поље слободне оцене, у конкретном случају, да утврди да ли су мере биле неопходне у општем интересу, како би оценио да ли је постигнута разумна равнотежа између средстава и циља који се жели постићи.

Такође, са аспекта поља слободне процене, Европски суд у предмету *Tolstoy Miloslavsky v. the United Kingdom* признаје да државе треба да имају

54 *Sporrong and Lonnroth, v. Sweden*, представка бр. 7151/75, пресуда од 23. септембра 1982.

одређену флексибилност код процене нивоа штете у предметима који се тичу слободе изражавања:

„Надлежне домаће власти су у бољем положају него Европски суд да процене ово питање и стога би требало да уживају шире поље процене у том погледу“⁵⁵

Из наведених примера произилази да се доктрина поља слободне процене примењује у различитим случајевима и њен обим може бити ужи и шири, што јасно произилази из богате судске праксе Европског суда. Најреlevantнији фактор од кога зависи ширина поља слободне процене је (не)постојање консензуса. Приликом утврђивања обима обавеза уговорних страна Конвенције, Европски Суд, између осталог, испитује постојање тзв. европског консензуса⁵⁶. Стандард „Европски консензус“ је генеричка ознака која се користи да опише истрагу Суда о постојању или непостојању заједничке основе, углавном у закону и пракси држава чланица.⁵⁷

У контексту Конвенције, концепт европског консензуса се генерално схвата као основа за еволуцију норми Конвенције кроз праксу и дефинише се као општа сагласност већине држава чланица Савета о одређеним правилима и принципима идентификованим упоредним истраживањем националног и међународног права и праксе.

Наиме, у циљу успостављања консензуса, Европски Суд спроводи упоредну студију примарних правних извора држава чланица, међународних уговора, аката међународних организација, законодавстава земаља које нису чланице Савета, укључујући и европско јавно мњење, као и мишљење експерата. Такође, ради утврђења постојања консензуса, Европски Суд утврђује чињеницу да ли је већина држава чланица Савета усвојила слично решење, па сходно томе цени релевантност одређеног тумачења.

У случају непостојања консензуса, Европски суд је закључио:

⁵⁵ *Tolstoy Miloslavsky v. the United Kingdom*, представка бр. 18139/91, пресуда од 13. јула 1995, пара 48.

⁵⁶ Већина теоретичара користи термин „европски консензус“ да би нагласила улогу консензуса у контексту Конвенције. Консензус је увек играо улогу у међународном праву, било као елемент у развоју обичајног права или као техника доношења одлука у међународним организацијама и на дипломатским конференцијама.

⁵⁷ https://www.coe.int/t/dghl/cooperation/lisbonnetwork/themis/echr/paper2_en.asp, 29.10.2022.

„Тамо где, међутим, не постоји консензус у државама чланицама Савета Европе, било о релативном значају интереса који је у питању или о томе како га најбоље заштитити, маргина ће бити већа. Ово је посебно случај када случај покреће сложена питања и изборе социјалне стратегије.... Такође ће се обично дати широка маргина ако се од државе захтева да успостави равнотежу између конкурентских приватних и јавних интереса или права из Конвенције.“⁵⁸

Насупрот томе, када постоји консензус, подразумева се да је „основно“ значење права уско дефинисано, док се маргина за одступање истовремено умањује.

У предмету *Leyla Sahin против Турске*⁵⁹, подносиатељка представке, студенткиња медицине се супротставила забрани ношења мараме као верском симболу на Универзитету, јер је изгубила је спор пред домаћим судом, жалџи се на повреду члана 2. и члана 9. Конвенције. У одговору на питање да ли унутрашње право државе потписнице Конвенције може да забрани ношење мараме, које налаже исламски обичај, Европски суд је закључио да у конкретном случају није било повреде члана 9. Конвенције, као ни члана 2 Конвенције, те да истицање верских симбола зависи од времена и контекста, док држава треба да се руководи потребом да задовољи традицију, права и слободе, као и јавни ред. Међутим, судија Франсоаз Тулкенс је у издвојеном мишљењу оспаравала поље примене слободне процене и истакла непостојање европског консенсуза у погледу истицања верских симбола на универзитетима, као и да подносиатељка представке својом тежњом да носи мараму, није повредила секуларни карактер турске државе.⁶⁰

Наведена пресуда је значајна са аспекта поља слободне процене „јер се добија утисак да је судско закључивање у том предмету било више окренуто питању односа националног и наднационалног поретка заштите људских права, него што се бавило разматрањем допуштености конкретног поступка одговорне државе.“⁶¹

58 *Dickson v. the United Kingdom*, представка бр. 44362/04, пресуда од 04. децембра 2007, пара 78.

59 *Leyla Sahin v. Turkey*, представка бр. 44774/98, 29 пресуда од 10. новембра 2005.

60 Издвојено мишљење судије Тулкенс у предмету *Leyla Sahin v. Turkey*

61 *Ibid* 5, 72

Закључак

С обзиром на разноликост, ширу и ужу примену и сам еволутивни развој који почива на начелу плурализма, доктрина поља слободне процене омеђена је судском праксом Европског суда, а њена важност се испољава у самом дефинисању обима заштите одређеног конвенцијског права. Почев од Белгијског језичког случаја где „поље слободне процене мора бити изведено из праведне равнотеже између заштите општег интереса заједнице и поштовања основних људских права, придајући посебан значај овом последњем“⁶², током времена, кроз развој јуриспруденције, поље слободне процене је добило своје место и у преамбули Конвенције, а доктрина постала легитмно средство за тумачење Конвенције.

У актуелној судској пракси Европског суда, доктрина поља слободне процене почива на принципу супсидијарности, који представља један од основних принципа у европском праву. Доктрина има за циљ тумачење и разматрање чињеничних и правних питања у сваком конкретном случају, као и испитивање начина на који државе уговорнице примењују Конвенцију. Приликом оцене да ли је поље слободне оцене уже или шире, Европски суд заправо шири или сужава дискрецију која већ постоји код држава уговорница.

Поље слободне процене се чини потпуно оправданим у случајевима који су условљени чињеничним елементима. Међутим, поред испитивања начина на који државе уговорнице примењују Конвенцију, Европски суд утврђује и да ли су ефекти националног тумачења и примене чињеница у складу са Конвенцијом. С тим у вези, ова доктрина, на наведени начин, ограничава надлежност домаћег суда и аутономију држава уговорница, због чега би улога Европског суда требало да се ограничи на испитивање да ли држава уговорница испуњава обавезе у погледу заштите људских права које су преузеле приступањем Конвенцији, будући да су домаћи судови релевантни за утврђивање чињеница у складу са друштвеним приликама у својој земљи.

И на крају, са аспекта потписница држава уговорница, познавање основних постулата ове доктрине је од великог значаја, јер домаћи судови имају примарну одговорност код примене људских права и основних слобода, који представљају *sine qua non* савременог друштва.

62 Ibid 15, пара. 5

Бојана Арсенијевић⁶³

Асистент

Правни факултет Универзитета у Нишу

Остваривање права на издржавање између брачних и ванбрачних партнера у пракси Основног суда у Нишу^{64,65}

Апстракт: Законом је регулисано право на издржавање између супружника и између ванбрачних партнера, услови под којима се оно може остварити, као и посебан парнични поступак за судско остваривање права на издржавање. Егзистенцијални значај права на издржавање указује на нужност провере квалитета функционисања успостављеног правног механизма ради остваривања овог права. Стога је аутор спровео истраживање о парницама за издржавање пред Основним судом у Нишу, које су правноснажно окончане у току 2018. године. У раду аутор представља и анализира резултате истраживања у парничним поступцима у парницама за одређивање, промену висине, престанак или продужетак трајања издржавања, између брачних и ванбрачних партнера. Циљ истраживања био је стицање увида у адекватност примене законских прописа у пракси и степен ефикасности пружања правне заштите у анализираним парницама за издржавање. Резултати истраживања откривају неефикасност поступака у парницама за издржавање и озбиљну неинформисаност грађанства о процесним могућностима у парницама за издржавање.

Кључне речи: поверилац издржавања, дужник издржавања, брачни и ванбрачни партнери, парнице за издржавање, трајање парничног поступка.

63 a.bojana@prafak.ni.ac.rs

64 Рад представља резултат истраживања на пројекту „Одговорност у правном и друштвеном контексту“, који финансира Правни факултет Универзитета у Нишу.

65 Рад је објављен у *Facta Universitatis, Series : Law and Politics*, вол. 19, бр. 1, 2021, стр. 77–82.

УВОДНА РАЗМАТРАЊА

Демографски подаци показују да стопа развода⁶⁶ у Србији расте – у 2017. години износила је 1,3, а у 2019. години 1,6 (Републички завод за статистику, 2011). Раније истраживање спроведено међу радницима центара за социјални рад у Србији показало је да једна од највећих криза са којима се супружници суочавају у бракоразводној парници јесте немогућност раздвајања услед стамбених или економских проблема (Половина, Жегарац, 2007: 400). Наведени резултати указују на потребу ближег осврта на питање остваривања права на издржавање између супружника и бивших супружника.⁶⁷ Право и дужност издржавања постоји, такође, између ванбрачних партнера, за време трајања ванбрачне заједнице и по њеном престанку.⁶⁸ Услови за остваривање права на издржавање између партнера⁶⁹ регулисани су породичноправним одредбама.⁷⁰

Парнице за издржавање, или алиментационе парнице, обухватају све парнице у којима се решавају спорови око издржавања (Мандић, 1991: 37–39), и то парницу за одређивање издржавања, парницу за промену висине издржавања, парницу за престанак издржавања и парницу за продужење трајања издржавања.⁷¹ Поступак у парница за издржавање је води по посебним пра-

66 Стопа развода представља број разведених бракова на 1.000 становника, на посматраној територији у посматраној јединици времена.

67 Вид. чл. 28. и чл. 151. у вези чл. 279. ст. 3. Породичног закона, Сл. гласник РС, бр. 18/2005, 72/2011 – др. закон и 6/2015. (У даљем тексту ПЗ.) Издржавање између супружника и бивших супружника представља личноимовински однос, који настаје закључењем брака, односно престанком брака. О карактеристикама законског издржавања вид. Ковачек Станић, 2014: 109–112. Почуча, Шаркић, 2014: 276–280.

68 Вид. чл. 4. ст. 2. и чл. 152. у вези чл. 279. ст. 5. ПЗ.

69 У раду је коришћена синтагма „брачни и ванбрачни партнери“, с обзиром на блискост установа брака и ванбрачне заједнице, а ради истајања истоветности правне регулативе у области издржавања између лица у браку и у ванбрачној заједници. Притом, потпуно равноправно биће коришћен и законски израз „супружници“, када је реч о брачним партнерима. За потребе овог рада, појам „партнери“ биће коришћен као генерични, означавајући истовремено и брачне и ванбрачне partnere.

70 Према чл. 151. ПЗ, право на издржавање има супружник (поверилац издржавања) који нема довољно средстава за издржавање и неспособан је за рад или је незапослен, а сразмерно могућностима другог супружника (дужника издржавања), под условом да обавезивање дужника издржавања у датим околностима појединачног случаја не би представљало очигледну неправду. Детаљније о материјалноправним претпоставкама за остваривање права на издржавање између партнера, вид. Ковачек Станић, 2014: 112–114. Драшкић, 2011: 379–384. Поњавић, 2011: 324–325. Панов, 2010: 302–306. Цвејић Јанчић: 2009: 122–129.

71 Уколико се промене околности под којима је издржавање одређено, било на страни повериоца издржавања, било на страни дужника издржавања, обавеза издржавања може бити промењена, или може престати. Законом је ограничено трајање издржавања између бивших супружника до пет година од престанка брака. Исто ограничење важи и за трајање издржавања између бивших ванбрачних партнера. Само изузетно, трајање издржавања може бити продужено и после протока пет година од престанка брака, односно од престанка ванбрачне заједнице. Вид. чл. 163. и 164. ПЗ. Поњавић, 2011: 332. Панов, 2010: 307–308.

вилима.⁷² Значајна карактеристика овог посебног поступка јесте овлашћење суда да може да утврђује чињенице и када оне нису међу странкама спорне, као и да самостално истражује чињенице које ниједна странка није изнела.⁷³ Поред истражног начела, истакнут је значај начела процесне ефикасности и начела нарочите хитности, те су рокови прописани на начин који треба да обезбеди промтно одлучивање.⁷⁴ У посебном поступку сужено је начело диспозиције – забрањено је одрицање од права на издржавање и странке се могу судским поравнањем споразумети једино о начину и висини издржавања, не и о самом праву на издржавање (Станковић, 2006: 204). Суд није везан границама тужбеног захтева и може одлучивати и *extra petitum*.⁷⁵ Јавност је искључена,⁷⁶ а о трошковима поступка суд одлучује по слободној оцени, водећи рачуна о разлозима правичности.⁷⁷ Поступак у парници за издржавање може бити вођен као основни или као адхезиони (придружени), уз поступак у парници за развод или поништај брака.⁷⁸

Делотворност прокламоване правне заштите индикована је реалним остваривањем правне заштите у конкретном судском поступку. Предмет овог

72 Модификовањем парничних процесних начела, законодавац је поступак у парници за издржавање прилагодио специфичној природи спора у овим парницама. Реч је о посебном парничном поступку, уређеном посебним процесним одредбама садржаним у чл. 201–208. и 279–282. ПЗ, уз супсидијарну примену Закона о парничном поступку.

73 Вид. чл. 205. ПЗ.

74 Вид. чл. 280. ПЗ. Законом је прописано да се прво рочиште заказује тако да се одржи у року од осам дана од пријема тужбе у суду, и да је другостепени суд дужан да донесе одлуку у року од 15 дана од достављења жалбе.

75 Вид. чл. 281. ПЗ. На пример, уколико дужник издржавања тражи укидање обавезе да даје издржавање, а суд у току поступка утврди да се околности на основу којих је утврђена обавеза давања издржавања јесу промениле, али не у тој мери да оправдавају укидање обавезе, већ само њено смањење, суд може донети одлуку о промени висине издржавања. „Захтевом за престанак обавезе издржавања разведене супруге, међутим, обухваћен је и захтев за смањење раније досуђене обавезе по том основу, о чему се нижестепени судови одлучивали правилном применом материјалног права, у складу са одредбом чл. 3. ст. 3. ЗПП.“ Пресуда Врховног суда Србије Рев 2150/09 од 16.7.2009. године. Вуковић, Станојчић, 2013: 183.

76 Вид. чл. 206. ПЗ, који прописује да је јавност искључена у поступцима у вези са породичним односима, што обухвата и парнице за издржавање. Такође, прописано је да подаци из судских списа спадају у службену тајну, коју су дужни да чувају сви учесници у поступку којима су ти подаци доступни.

77 Вид. чл. 207. ПЗ

78 Законодавац је прописао да се тужба за издржавање супружника може поднети најкасније до закључења главне расправе у брачном спору. Само изузетно, тужба се може поднети најкасније у року од годину дана од дана престанка брака, односно од дана када је учињено последње фактичко давање на име издржавања, уколико бивши супружник није из оправданих разлога поднео тужбу за издржавање у брачном спору. Вид. чл. 279. ст. 2. и 3. ПЗ. Из наведених законских одреби произилази да се парница за издржавање, по правилу, води као адхезиони поступак уз поступак у брачном спору, а само изузетно као посебан поступак, уколико бивши супружник из оправданих разлога није могао да тражи издржавање у брачном спору.

рада јесте представљање резултата емпиријског истраживања, спроведеног ради стицања увида у квалитет функционисања правног механизма за остваривање права на издржавање између партнера. Посебно је значајан финансијски аспект покретања и вођења поступка у парницама за издржавање. Евентуалне препреке у том домену угрожавају право на приступ суду.⁷⁹ Подршку остваривању права на приступ суду прописују одредбе Закона о парничном поступку⁸⁰ и Закона о бесплатној правној помоћи.⁸¹

ПРЕДМЕТ И ОПИС ИСТРАЖИВАЊА

Истраживањем су обухваћени поступци у парницама за издржавање између партнера, који су пред Основним судом у Нишу вођени као основни или адхезиони поступци. Временски оквир истраживања обухватио је поступке правноснажно окончане током 2018. године. Предмет истраживања били су списи судских предмета формирани у парницама за одређивање, промену висине, престанак или продужетак трајања издржавања, између брачних или ванбрачних, садашњих или бивших партнера. Истраживачки узорак чинили су списи 12 судских предмета.⁸² Прикупљени су подаци о парничним стран-

79 Будући да право на правично суђење може бити остварено уколико правни субјект заиста приступи суду и затражи судску заштиту, право на приступ суду представља предуслов остваривања права на правично суђење. Дужност је државе да парнични поступак у својој укупности регулише тако да обезбеди да нико не буде спречен економским препрекама у своме настојању да оствари или одбрани своје право пред судом. Петрушић, 2007: 162, 176.

80 Закон регулише могућност ослобођења од претходног плаћања трошкова поступка, као и могућност постављања бесплатног пуномоћника. Вид. чл. 151. и 170. Закона о парничном поступку, Сл. гласник РС, бр. 72/2011, 49/2013 – одлука УС, 74/2013 – одлука УС, 55/2014, 87/2018 и 18/2020.

81 Бесплатна правна помоћ се састоји од пружања правних савета, састављања поднесака, заступања и одбране, а пружају је адвокати и службе правне помоћи у јединицама локалне самоуправе. Вид. чл. 6. и 9. Закона о бесплатној правној помоћи, Сл. гласник РС, бр. 87/2018. Закон је ступио на снагу 2018. године, али је његова примена била одложена до 01. октобра 2019. године.

82 На основу увида у електронску евиденцију парничних предмета Основног суда у Нишу идентификовани су судски предмети, према одговарајућим критеријумима за формирање истраживачког узорка. Приликом прикупљања података, суочила сам се са неажурношћу наведене електронске евиденције: приликом уписа података могуће је изабрати категорију правног основа (нпр. издржавање између супружника, издржавање између ванбрачних партнера, издржавање између других лица и др.), али су подаци у највећем броју случајева уписивани у оквиру једне категорије, без поштовања осталих диференцијалних категорија (предмети у парницама о издржавању између супружника, или између ванбрачних партнера, уписивани су у категорију издржавања између других лица). Такође, у највећем броју случајева, на основу података у електронској евиденцији, није било могуће утврдити постојање и врсту партнерског односа између странака у парници о издржавању, те је било нужно прегледати списе свих судских предмета ради идентификовања одређеног судског предмета као предмета истраживања. Након прегледаних 626 судских предмета, утврђено је да критеријуме предмета истраживања испуњава укупно 12 судских предмета: П2 1250/15, П2 322/16, П2 511/16, П2 606/16, П2 1388/16, П2 405/17, П2 646/17, П2 903/17, П2 1271/17, П2 319/18, П2 949/18, П2 970/18.

кама (повериоцу и дужнику издржавања), тужбеном захтеву и о току парничног поступка.⁸³

НАЛАЗИ И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА ИСТРАЖИВАЊА

Од 12 обухваћених судских предмета, њих 10 формирано је поводом поступка у парници за одређивање издржавања. Међутим, од овог броја, само четири поступка вођена су као адхезиони, уз поступак у бракоразводној парници. Тужбени захтев за одређивање издржавања усвојен је само у једној парници, док је у чак пет био одбијен. Остали поступци окончани су решењем да је тужба повучена или да се тужба сматра повученом.

Само једна парница вођена је ради промене висине издржавања. Међутим, тужилац је поднеском повукао тужбу, пре одржавања првог рочишта за главну расправу. Такође, само једна парница вођена је ради престанка издржавања, а окончана је усвајањем тужбеног захтева дужника издржавања за утврђивање престанка обавезе издржавања.

У истраживачком узорку није било судских предмета формираних поводом поступка у парници за продужење трајања издржавања.

ПРОФИЛ ПОВЕРИЛАЦА ИЗДРЖАВАЊА⁸⁴

Од укупно 12 судских предмета, у девет предмета (75%) поверилац издржавања била је жена. У преостала три предмета (25%) поверилац издржавања био је мушкарац. Оваква полна структура поверилаца издржавања одговара резултатима раније спроведеног истраживања судске праксе Основног суда у Прокупљу, о издржавању између супружника након престанка брака (Ракић, 2018: 43.). Наиме, у наведеном истраживању поверилац истраживања била је жена у 80% случајева, што потврђује тврдњу о великој заступљености жена као поверилаца издржавања. Такав налаз открива поражавајућу чињеницу о економској несамосталности или, у најблажем случају, економској угроже-

83 Увид у списе предмета обухватао је упознавање садржине тужбе, евентуално противтужбе, поднесака парничних странака, записника са рочишта за главну расправу, службених бележака поступајућих судија, судских одлука и жалби. Применом методе анализе садржаја, прикупљени подаци су уношени у посебно припремљене упитнике.

84 Профил поверилаца издржавања у узорку истраживања, као и дужника издржавања, пружају подаци који се односе на пол, узраст, пребивалиште, степен образовања, запосленост и занимање. Сви изрази употребљени у мушком граматичком роду обухватају једнако лица у мушком и женском роду.

ности жена у заједницама живота у 21. веку, на територијама судова обухваћених истраживањима.⁸⁵

Доминантна узрастна група поверилаца издржавања је преко 59 година (50%), док је близак проценат (42%) поверилаца издржавања припадао је узрастној групи од 39 од 59 године.

У највећем проценту (67%) пребивалиште повериоца издржавања било је у граду. Само у 25% поверилац издржавања имао је пребивалиште на селу. Ови подаци нису непобитни показатељи да партнери са села имају стабилнију економску позицију, која узрокује мање изражену потребу судског остваривања права на издржавање. Напротив, ови подаци вероватније су последица мање информисаности у сеоским срединама о механизмима правне заштите.

Степен образовања био је непознат у чак 75% предмета, док је у преосталих 25% поверилац издржавања имао завршену средњу школу. Према резултатима поменутог ранијег истраживања 85% поверилаца издржавања имало је завршену средњу школу (Ракић, 2018: 44.). С обзиром на истражно начело у поступцима у парницама за издржавање, од судија се очекује већа иницијатива ради прикупљања ових података.

Поверилац издржавања био је незапослен у чак девет предмета (75%), при чему се у два предмета изјаснио да никада у животу није радио. Само

Табела 2 – Старосна структура		
Узрастна група	Број поверилаца издржавања	Проценат од укупног броја (12)
До 18 година	-	-
19–38 година	-	-
39–58 година	5	42%
Од 59 година	6	50%
Непознато	1	8%

Табела 3 – Пребивалиште поверилаца издржавања		
Пребивалиште	Број поверилаца издржавања	Проценат од укупног броја (12)
Село	3	25%
Град	8	67%
Непознато	1	8%

Табела 4 – Образовање поверилаца издржавања		
Степен образовања	Број поверилаца издржавања	Проценат од укупног броја (12)
Незавршена основна школа	-	-
Основна школа	-	-
Средња школа	3	25%
Виша школа или факултет	-	-
Непознато	9	75%

⁸⁵ О територијалној надлежности основног суда у Прокупљу и Нишу видети чл. 3. Закона о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва, Сл. гласник РС, бр. 101/2013.

у по једном предмету поверилац издржавања био је запослен и пензионер. С обзиром на то да је незапосленост повериоца издржавања законски услов остваривања права на издржавање, овакви резултати били су очекивани.

Само у четири предмета били су познати подаци о занимању повериоца издржавања, независно од статуса запослености (занимања: возач, продавац, кројач, чистач у приватном домаћинству). С обзиром на значајан проценат података о (не)запослености, неоправдано су изостали подаци о занимању повериоца издржавања.

Табела 5 – Запосленост повериоца издржавања		
Статус запослености	Број повериоца издржавања	Проценат од укупног броја (12)
Запослен	1	8%
Незапослен	9	75%
Пензионер	1	8%
Непознато	1	8%

Иако (директно) не чине обележја профила повериоца издржавања, значајно је имати у виду и податке о постојању заједничке деце и о дужини трајања брачне или ванбрачне заједнице. У осам предмета поверилац и дужник издржавања имали су заједничке деце – у пет предмета по двоје заједничке деце и у три предмета по једно заједничко дете.⁸⁶ У осталим предметима овај податак био је непознат. Независно од чињенице да ли је парница вођена између супружника или бивших супружника, брак повериоца и дужника издржавања у седам предмета трајао је преко 20 година,⁸⁷ а у једном 18 година. У осталим предметима овај податак био је непознат. Такође, били су непознати подаци о трајању ванбрачне заједнице повериоца и дужника издржавања, у оним предметима који су тицали издржавања између (бивших) ванбрачних партнера.

ПРОФИЛ ДУЖНИКА ИЗДРЖАВАЊА

Полна структура дужника издржавања (75% мушког пола, 25% женског пола) директно је супротна полној структури повериоца издржавања, с обзиром на хетеросексуалност као одлику брачних и ванбрачних заједница у домаћем праву.

⁸⁶ Само у једном предмету поверилац издржавања тражио је издржавање за себе и за заједничку децу, као њихов законски заступник. У току поступка повукао је тужбу у делу којим је тражио издржавање деце.

⁸⁷ Рачунајући од тренутка закључења брака до тренутка правноснажности пресуде о разводу брака (у пет од седам случајева), односно до тренутка правноснажности пресуде о тужбеном захтеву поводом издржавања за време трајања брачне заједнице (у два од седам случајева).

У шест случајева (50% истраживачког узорка) дужник издржавања припадао је узрасној групи преко 59 година, а у четири (33%) узрасној групи од 39 од 58 година. Притом, у потоњој узрасној групи дужник издржавања у свим предметима био је старости преко 50 година. Сличност између старосних структура поверилаца и дужника издржавања указује на малу разлику у годинама између партнера, у истраживачком узорку.

Подаци о пребивалишту дужника издржавања идентични су као и код поверилаца издржавања: у 67% пребивалиште је било у граду, а у 25% на селу.

Слично као и код поверилаца издржавања, у чак 75% податак о степену образовања дужника издржавања био је непознат. У 17% предмета дужник издржавања имао је завршену средњу школу, а само у 8% завршену вишу школу. Непостојање значајнијег процента познатих података о степену образовања дужника издржавања оправдано је само у предметима где је тужба за издржавање повучена или се сматра повученом, под условом да странке нису саслушане на главној расправи. Степен образовања битан је показатељ круга послова који могу бити доступни дужнику издржавања.⁸⁸

Табела 7 – Статус запослености

Статус запослености	Број дужника издржавања	Процент од укупног броја (12)
Запослен	6	50%
Незапослен	1	8%
Пензионер	3	25%
Непознато	2	17%

Дужник издржавања имао је редовна примања у чак 75% истраживачког узорка (у 50% предмета био је запослено лице, а у 25% пензионер). У 8% дужник издржавања био је незапослен, а у преосталих 17% овај податак остао је непознат. Упркос истражним овлашћењима судије у посебном поступку, поверилац издржавања треба (барем да покуша) да пружи податак о запослености дужника издржавања, јер се ради о основном податку који утиче на одређивање издржавања.

Независно од статуса запослености, само у 41% предмета био је познат податак о занимању дужника издржавања (занимања: возач, медицински радник и кројач). Чак у 59% податак о занимању био је непознат, што се чини неоправданим с обзиром на значајан проценат података о (не)запослености.

⁸⁸ Према чл. 151 ПЗ, издржавање се одређује сразмерно могућностима дужника издржавања. Приликом оцене могућности дужника издржавања, суд узима у обзир све околности које могу бити од значаја за одређивање прихода дужника издржавања, како оних прихода које дужник издржавања остварује, тако и оних прихода које дужник издржавања може према редовном току ствари да оствари. Вид. Драшкић, 2011: 384.

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРНИЦА ЗА ИЗДРЖАВАЊЕ

У парницама за одређивање издржавања вођеним као *основни поступци*, решавани су спорови између супружника за време трајања брачне заједнице (33%)⁸⁹ и између бивших супружника (50%), а само у једној парници спор о издржавању између ванбрачних партнера.

Табела 8 – Врста партнерског односа између странака у парницама за одређивање издржавања		
Парнице вођене као основни поступци	Број поступака	Проценат од укупног броја (6)
Издржавање између супружника	2	33%
Заједница живота и даље траје	2	33%
Заједница живота претходно је престала	-	-
Издржавање између бивших супружника	3	50%
Брак разведен у току трајања поступка у парници за издржавање	3	50%
Брак разведен пре подизања тужбе за издржавање	-	-
Издржавање између ванбрачних партнера	1	17%
Издржавање између бивших ванбрачних партнера	-	-

У парницама за одређивање издржавања вођеним као *адхезиони поступци* уз бракоразводну парницу, захтев за издржавање истакао је поверилац издржавања у тужби за развод брака (25%), или у противтужби у поступку по тужби дужника издржавања за развод брака (75%).

⁸⁹ Резултати ранијих истраживања указивали су да судска пракса стоји на становишту да не постоји могућност судског остваривања права на издржавање док међу супружницима постоји заједница живота (О томе: Петрушић, Константиновић Вилић, 2012: 22). Међутим, такав став судске праксе подложен је критици, имајући у виду законске одредбе о праву и дужности издржавања између супружника. У супротном, издржавање између супружника било би претворено у натуралну облигацију, што не одговара природи законског издржавања.

Табела 9 – Динамика истицања захтева за издржавање у поступцима у брачним споровима

Тренутак истицања захтева за издржавање	Број поступака	Проценат од укупног броја (4)
Захтев за издржавање истакнут у тужби	1	25%
Захтев истакнут приликом подизања тужбе за развод	1	25%
Захтев истакнут у току трајања бракоразводне парнице	-	-
Захтев за издржавање истакнут у противтужби	3	75%

У 17% парница решаван је спор о издржавању између супружника, а у чак 75% спор о издржавању између бивших супружника. Само у 8% решаван је спор о издржавању између ванбрачних партнера. У истраживачком узорку није било парница о издржавању између бивших ванбрачних партнера.

Табела 10 – Врсте партнерског односа између странака

Врста партнерског односа	Број поступака	Проценат од укупног броја (12)
Супружници	2	17%
Бивши супружници	9	75%
Ванбрачни партнери	1	8%
Бивши ванбрачни партнери	-	-

ИСХОД ПОСТУПКА

Од 12 судских поступака у истраживачком узорку, три је окончано решењем да је тужба тужиоца повучена, два поступка решењем да се тужба тужиоца сматра повученом, у пет предмета одбијен је тужбени захтев, а у два предмета тужбени захтев је усвојен.

У два од три случаја *повлачења тужбе*, као разлог повлачења био је наведен недостатак финансијских средстава за заступање од стране адвоката, што открива да тарифа накнада за услуге адвоката понекада има одвраћајући утицај за вођење поступка. Разлози неприступања уредно позваних парничних странака на рочиште за главну расправу нису били познати, али против решења да се *тужба сматра повученом* није било жалби.

Пресуде о *одбијању тужбеног захтева* за одређивање издржавања суд је засновао на различитим разлозима. Као најзаступљенији, издвојили су се сле-

дећи: очувана радна способност повериоца издржавања у одговарајућем степену за самостално стицање средстава за издржавање, запосленост повериоца издржавања и старање дужника издржавања о заједничкој деци. У свакој одлуци суд је ценио постојање околности које би утицале да обавезивање дужника издржавања представља очигледну неправду. Интересантно је да је суд у образложењу две пресуде истакао да поверилац издржавања, иако нема сопствене приходе, станује код својих родитеља, или код своје деце, који финансијски помажу или могу да помажу повериоца издржавања. Посматран изоловано, наведени став суда мора бити критикован, јер је супротан законом прописаном редоследу остваривања права на издржавање.⁹⁰

Само у једном предмету *усвојен је тужбени захтев* за одређивање издржавања. Суд је истакао да, иако тужила нема довољно средстава за издржавање и незапослена је, постоји реална могућност тужиле да ипак самостално обезбеђује финансијска средства, само у недовољном износу. Стога је након утврђења постојања могућности туженог дужника издржавања, суд делимично усвојио тужбени захтев тужиле, у износу мањем од траженог.

Суд је утврдио престанак обавезе издржавања по тужби дужника издржавања, услед промењених околности на страни повериоца издржавања – остваривање права на инвалидску пензију, која у свом износу подмирује потребе повериоца издржавања.

Против првостепене пресуде изјављена је жалба у три предмета. Другостепени суд је у сва три предмета одбио жалбу и потврдио првостепену одлуку.

ТРОШКОВИ ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА

Само у два предмета тужилац био је ослобођен од претходног плаћања судских такси, док у једном предмету о захтеву тужиоца није одлучено.⁹¹ Ни у једном предмету није био истакнут захтев за ослобођење од претходног плаћања трошкова поступка, нити за постављањем бесплатног пуномоћника.

Одлука о трошковима парничног поступка зависи од успеха парничних странака; трошкови се досуђују странци која успе у парници, али је могуће и да свака странка сноси своје трошкове.⁹² С обзиром на то да суд може да од-

⁹⁰ Према чл. 166. ПЗ, супружник првенствено остварује право на издржавање од другог супружника.

⁹¹ Решење да се тужба сматра повученом донето је на првом рочишту за главну расправу.

⁹² Вид. чл. 153. Закона о парничном поступку.

лучи и на основу правичности, извлачење квалитативних закључака о трошковима парничног поступка је веома ограничено. Можемо истаћи да је суд у 50% случајева досудио трошкове једној парничној странци, на основу њеног успеха у парници или на основу правичности, док је у 25% случајева свака странка сносила своје трошкове. Коначно, у 25% случајева није било захтева за накнаду трошкова парничног поступка. Износ досуђених трошкова кретао се у распону од 6.000,00 динара до 90.000,00 динара,⁹³ ови износи нису неуобичајено високи, имајући у виду адвокатску тарифу.

Табела 11 – Трошкови парничног поступка

Одлука о трошковима парничног поступка	Број поступака	Проценат од укупног броја (12)
Трошкови досуђени једној странци	6	50%
Свака странка сноси своје трошкове	3	25%
Није био истакнут захтев за накнаду трошкова	3	25%

Обе парничне странке имале су пуномоћнике адвокате у четири предмета, док у три предмета ниједна странка није имала пуномоћника адвоката. У преосталих пет предмета, само је једна од странака имала пуномоћника адвоката.

ТРАЈАЊЕ ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА У ПАРНИЦАМА ЗА ИЗДРЖАВАЊЕ

Док је једна половина парничних поступака окончана у року до девет месеци, трајање поступка у преосталих шест парница било је у интервалу од 15 до 30 месеци. Најдуже трајање поступка износило је 30 месеци, а најкраће два месеца. Разлог трајања поступка може бити временски период између два рочишта, број одржаних рочишта, као и почињање поступка изнова у случају промене поступајућег судије. С обзиром на начело нарочите хитности у овим поступцима, наведени резултати пружају ваљане разлоге за забринутост о ефикасности пружања правне заштите у парницама за издржавање.

У седам предмета, прво рочиште за главну расправу одржано је у периоду од 75 до 136 дана после дана подношења тужбе. У парницама за издржавање вођеним као адхезиони поступци, прво рочиште за главну расправу одржано је

⁹³ Трошкови парничног поступка обухватају трошкове заступања од стране пуномоћника адвоката на одржаним и одложеним рочиштима, трошкове вештачења, и судске таксе.

у периоду од 13 до 70 дана од подношења (против-) тужбе. У једном предмету тужилац је повукао тужбу пре заказивања рочишта за главну расправу, при чему је тужба повучена чак 25 дана након подношења суду. Наведни резултати упућују на несумњив закључак – ни у једном поступку прво рочиште није одржано у законском року од осам дана од пријема тужбе за издржавање у суду.⁹⁴

Расположиви подаци у истраживачком узорку нису омогућили утврђење временског периода од пријема жалбе у другостепеном суду до доношења другостепене одлуке.

ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Ограничени истраживачким узорком, закључци истраживања односе се на праксу Основног суда у Нишу, у парничним предметима поводом парница за издржавање, који су окончани током 2018. године. Њихово представљање тежи да обезбеди основу за будућа истраживања и упоредник за праћење напретка ефикасности правне заштите у парницама за издржавање.

Профил просечног повериоца издржавања у истраживачком узорку карактеришу следећа обележја: реч је о жени, старијој од 50 година, са пребивалиштем у граду, средњег степена образовања, незапосленој, која је имала радничко занимање, а која издржавање тражи после више од 20 година проведених у браку са дужином издржавања. Профил просечног дужника издржавања одређен је следећим карактеристикама: реч о је мушкарцу, старијем од 50 година, са пребивалиштем у граду, средњег степена образовања, запосленом, који има радничко занимање.

Највећи број поступака, чак 84% у истраживачком узорку, вођен је у парницама за одређивање издржавања. У највећем броју случајева, поступак у парницама за издржавање вођен је као основни поступак, а малобројни адхезиони поступци углавном су покретани противтужбом за одређивање издржавања у бракоразводној парници. За разлику од резултата ранијих истраживања, парнице за одређивање издржавања између супружника док траје заједница живота окончане су усвајањем тужбеног захтева.

94 Вид. чл. 280. ПЗ.

У највећем проценту парница (75%) решавани су спорови између бивших супружника, затим спорови између супружника, и у једној парници – спор између ванбрачних партнера.

У истраживачком узорку није било парница између бивших ванбрачних партнера. Разлог томе може бити неинформисаност грађана о постојању права.

Поступак у чак 42% парница за одређивање издржавања окончан је одбијајућом пресудом, а само у 8% усвајајућом пресудом. Чак 42% поступака окончано је решењем да је тужба повучена или да се сматра повученом. У већини случајева, разлог повлачења тужбе био је финансијске природе, што упозорава на проблем у остваривању права на приступ суду. Разлог томе може бити недовољна информисаност грађана о могућностима према Закону о парничном поступку, с обзиром на то да у истраживачком узорку није било истакнутих захтева за ослобођење од претходног плаћања судских трошкова, нити за постављање бесплатног пуномоћника, док је захтев за ослобођење од претходног плаћања судских такси био истакнут само у три предмета.

Проценти случајева у којима једна (42%) или ниједна странка (25%) није имала пуномоћника адвоката, иако значајни, не представљају опасност за остваривање квалитетне правне заштите, с обзиром на истражно начело које важи у поступку у парницама за издржавање. Међутим, наведени проценти могу упућивати на закључак да је тарифа накнада за услуге адвоката понекада одвраћајући фактор за вођење поступка, што директно зависи од економске моћи грађана.

Резултати истраживања показују да начело нарочите хитности није остварено у судским поступцима, чије је трајање износило од шест месеци до 30 месеци. Притом, ни у једном поступку прво рочиште није било заказано у законом прописаном року од осам дана од пријема тужбе у суду. У једном поступку прво рочиште је било одржано чак 136 дана после пријема тужбе у суду.

Егзистенцијална потребе за остваривањем права на издржавање захтева пружање делотворне и благовремене правне заштите. Имајући у виду латентне баријере у приступу суду и дужину трајања судских поступака, стандарди правичног суђења у анализираним парницама за издржавање нису у пуној мери остварени.

Литература:

Вуковић, С. Станојчић, Г. (2013). *Коментар Породичног закона, са судском праксом, обрасцима, регистром појмова и прилозима*, Београд: Пословни биро.

Драшкић, М. (2011). *Породично право и права детета*. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду.

Закон о бесплатној правној помоћи. *Службени гласник РС*. Бр. 87/2018.

Закон о парничном поступку. *Службени гласник РС*. Бр. 72/2011, 49/2013 – одлука УС, 74/2013 – одлука УС, 55/2014, 87/2018 и 18/2020.

Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва. *Службени гласник РС*. Бр. 101/2013.

Ковачек Станић, Г. (2014). *Породично право: партнерско, деље и старатељско право*. Нови Сад: Правни факултет Универзитета у Новом Саду.

Мандић, Љ. (1991). *Поступак у алиментационим парницама*. Магистарски рад. Правни факултет Универзитета у Нишу.

Панов, С. (2010). *Породично право*. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду.

Петрушић, Н. (2007). Право на приступ правди у светлу новог ЗПП. У Петрушић, Н. (Уред.). *Приступ правосуђу – инструменти за имплементацију европских стандарда у правни систем Републике Србије*. Ниш: Правни факултет Универзитета у Нишу. 161–178.

Петрушић, Н. Константиновић Вилић, С. (2012). *Остваривање права на законско издржавање пред правосудним органима у Врању, Бујановцу и Босилеграду*, Врање: Народни универзитет Врање.

Половина, Н. Жегарац, М. (2005). Развод брака у контексту друштвене транзиције. *Социолошки преглед*. 4(XXXIX). 401–417.

Половина, Н. Жегарац, М. (2007). Развод брака у контексту друштвене транзиције из угла стручних радника тимова за развод. *Социолошки преглед*. 3(XLI). 397–410.

Поњавић, З. (2011). *Породично право*. Крагујевац: Правни факултет Универзитета у Крагујевцу.

Породични закон. *Службени гласник РС*. Бр. 18/2005, 72/2011 – др. закон и 6/2015.

Почуча, М. Шаркић, Н. (2014). *Породично право и породичноправна заштита*. Београд: Правни факултет Универзитета у Београду.

Ракић, Н. (2018). *Изддржавање супружника након престанка брака*. Мастер рад. Правни факултет Универзитета у Нишу.

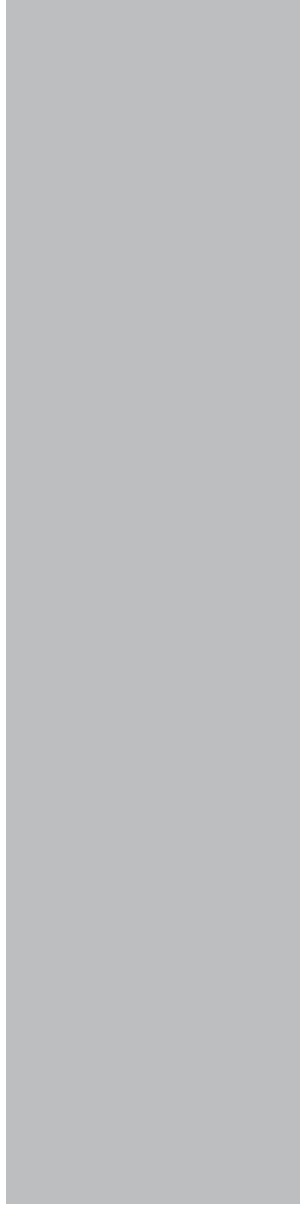
Републички завод за статистику. *Закључени и разведени бракови, подаци од 2011. године*. Преузето 20.10.2020. године. <https://data.stat.gov.rs/Home/Result/180402?languageCode=sr-Latn>

Станковић, Г. (2006). Заштита права на издржавање у Породичном закону Републике Србије. У Станковић, Г. (Уред.). *Зборник радова са научне конференције „Новине у породичном законодавству“*. Ниш: Правни факултет Универзитета у Нишу. 191–209.

Цвејић Јанчић, О. (2009). *Породично право*. Нови Сад: Правни факултет Универзитета у Новом Саду.

ГРАЂАНСКО ПРАВО

СУДСКА ПРАКСА



НИШТАВОСТ ЗАВЕШТАЊА

(члан 158. став. 1. Закона о наслеђивању)

Ништавост неке од одредби завештања не повлачи ништавост ништавост целог завештења ако оно може опстати и без ништаве одредбе, осим уколико та одредба није била одлучујућа побуда због које је завештање сачињено.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужена О. С. је била ванбрачна супруга сада пок. З. Ђ. бив. из ..., у периоду од 1986. године па до његове смрти дана 09.07.2012. године. Неспорно је да је на кућном плацу у ..., у улици ... бр. ... постојала стара породична стамбена зграда која је срушена након заснивања ванбрачне заједнице тужене и пок. З., као и да је на плацу саграђена нова кућа током 1994. године, у којој странке и данас живе, а у чијој изградњи је учествовала и тужена. Дана 24.04.2012. године пред Основним судом у Лесковцу сачињено је судско завештање у предмету 2РЗ.бр.922/12 којим је пок. З. Ђ., бив. из ..., као завешталац оставио својој невенчаној супрузи, овде туженој О., приземље и подрум куће, као и покретне ствари које се буду нашле у моменту његове смрти, и гробну парцелу на Шпителском гробљу, а из разлога јер се она највише брине о њему, нарочито у време сачињавања завештања када је пок. З. био везан за кревет због болести. У завештању је наведено да тестатор својој невенчаној супрузи О. оставља у аманет да имовину коју јој је завештао она завешта његовом сестрићу, овде тужиоцу М. Т., из разлога што су везани једно за друго и што га поштује. Такође, у завештању је наведено да је то његова последња воља и жели да се тако поступи по истој, као и да О. учини тако како је рекао. Неспорно је да тужена није испунила аманет пок. З., као и да је огласила наслеђену имовину на продају.

Одредбом чл.158 Закона о наслеђивању прописано је, да ништавост неке одредбе завештања не повлачи ништавост и самог завештања ако оно може опстати без ништаве одредбе или ако та одредба није била одлучујућа побуда због које је завештање сачињено.

Како је одредбом чл.159 ст.1 Закона о наслеђивању прописано да је ништава одредба завештања којом завешталац одређује наследника свом наследнику, то значи да је одредба којом тестатор својој невенчаној супрузи О.

оставља у аманет да завештану имовину она завешта његовом сестрићу, овде тужиоцу М., ништава. Међутим, првостепени суд је правилно закључио да је одлучујућа побуда због које је завештање сачињено била да његова имовина остане његовом сестрићу, овде тужиоцу М., а да тужену О. обезбеди у смислу несметаног коришћења непокретности које су предмет тестамена за њеног живота, што су потврдили и саслушани сведоци М. Љ., Д. И., М. Р., Ј. Т. и М. С.. С обзиром на то да је ништава одредба тестамена којом се овде туженој О. оставља у аманет да завештану имовину завешта овде тужиоцу М. Т., била одлучујућа побуда због које је завештање сачињено, то је предметно завештање ништаво у целости.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж. 329/22 од 10.03.2022. године),

Аутори сентенце: Александар Пантић, судија Апелационог суда у Нишу и Миша Вујичић, судијски помоћник Апелационог суда у Нишу.

ПРАВНО ДЕЈСТВО НАСЛЕДНИЧКЕ ИЗЈАВЕ О ОДРИЦАЊУ ОД НАСЛЕЂА (Члан 213 Закона о наслеђивању)

Правно дејство наследничке изјаве о одрицању од наслеђа не може обухватити и наслеђе на оној имовини која у тренутку давања изјаве није чинила заоставштину и са чијим постојањем такав наследник није био упознат, те у погледу новопронађене имовине такав наследник мора поново дати наследничку изјаву, односно исти може у парничном поступку тражити утврђење свог наследног дела на новопронађеној имовини.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању од стране првостепеног суда тужилац и тужени Б.Б. су синови сада пок. Г.Г., а тужена В.В. му је била супруга. Пок. Г.Г. је преминуо дана ... год., те је расправљана његова заоставштина пред Општинским судом у Нишу у предмету О бр. 195/2004. Решењем Општинског суда у Нишу О бр. 195/2004 од 10.02.2004. год. за наследнике су оглашени тужена В.В. на новчаном потраживању код ад Б. и тужени Б.Б. на телефонском прикључку. Тужилац се том приликом изјаснио да се не прихвата наслеђа. Тужени су дана 07.03.2018. год. пријавили да је накнадно

пронађена имовина пок. Г.Г., те је у оставинском поступку поводом накнадно пронађене имовине тужилац изјавио да се прихвата наслеђа са чиме се тужени нису сагласили. Решењем Основног суда у Нишу 30 бр. 1655/18 од 04.01.2019. год. прекинут је поступак расподеле накнадно пронађене заоставштине пок. Г.Г., те тужилац против овде тужених упућен на парницу ради доказивања свог наследног права.

На основу овако утврђеног чињеничног стања првостепени суд закључује да тужбени захтев није основан, јер је тужилац у оставинском поступку дао негативну наследничку изјаву, чиме се одрекао наслеђа на заоставштини свога оца. Наведена изјава има конститутивно дејство и делује ретроактивно, због чега се по ставу првостепеног суда сматра да лице које се одрекло наслеђа, у конкретном случају тужилац, никада није постало наследник. Обзиром да одрицање од наслеђа не може бити делимично, то тужилац не може бити оглашен наследником само на делу заоставштине. Постојање предметне имовине је било познато парничним странкама у тренутку отварања наслеђа, те се не ради о новопронађеној имовини.

Међутим, Апелациони суд налази да се овакав правни став и закључак првостепеног суда за сада не може прихватити као јасан, правилан и на закону заснован, на шта се основано указује жалбом тужиоца, имајући у виду погрешну примену материјалног права која је проузроковала да чињенично стање буде непотпуно утврђено.

Основано се жалбом тужиоца указује да суштина поступка код накнадно пронађене имовине јесте давање могућности наследнику који се одрекао наслеђа на заоставштини која је у том тренутку утврђена од стране оставинског суда, да буде оглашен наследником управо на оној имовини која тада није чинила заоставштину и са чијим постојањем такав наследник у тренутку давања изјаве о одрицању није био упознат. Правно дејство наследничке изјаве о одрицању од наслеђа не може обухватити и наслеђе на оној имовини која у тренутку давања изјаве није чинила заоставштину и са чијим постојањем такав наследник није био упознат, јер би у том случају наследник као савесно лице сносило последице заблуде коју није скривио, чиме би била повређена његова имовинска права заснована на одредби члана 36 Закона о основама својинскоправних односа и одредбама члана 3, 8, 9 и 212 става 1 Закона о

наслеђивању. Није спорно да је изјава о одрицању од наслеђа неопозива, али у односу на имовину која је у том тренутку оглашена заоставштином оставиоца, и иста се не може односити на имовину о којој у том тренутку није расправљано у оставинском поступку. Пресуда парничног суда код новопронађене имовине у ситуацији када се тужилац као наследник одрекао наслеђа на тада утврђеној заоставштини управо служи успостављању правног стања какво је постојало у моменту смрти оставиоца и има ретроактивно дејство у односу на новопронађену имовину, обзиром да се тужилац има сматрати наследником на истој од момента отварања наслеђа, односно смрти оставиоца. Сва ранија одрицања од наслеђа немају никакав правни значај у односу на имовину која је накнадно пронађена.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж бр. 180/2021 од 19.10.2021. год., судија Јадранка Митровски са судијским саветником Оливером Николић)

ПРАВО СВОЈИНЕ

(Члан 19 Закона о основама својинскоправних односа)

Право својине може се стећи на посебном делу зграде, дакле на стану као посебној стамбеној јединици која представља грађевинску целину, а не на једној просторији-соби која је у саставу те зграде као стамбене целине.

Из образложења:

Право својине може се стећи на посебном делу зграде дакле на стану као посебној стамбеној јединици која представља грађевинску целину, а не на једној просторији-соби која је у саставу те зграде као стамбене целине, како су тужиоци определили свој захтев. Без обзира што је изведеним доказима утврђено да су тужиоци за време трајања брачне заједнице, својим средствима и радом учествовали у изградњи ове просторије изнад гараже која представља саставни део породичног објекта на коме су тужилац Љ. и тужена сувласници са одређеним уделитема, тужиоци нису пружили доказе да просторија – соба од 15 м² коју су саградили представља посебну стамбену целину на којој се може стећи право својине.

У конкретном случају, тужиоци током поступка нису предложили доказе којима би се на поуздан начин утврдило да просторија- соба која је у саставу породичне стамбене зграде у сувласништву тужиоца Љ. и тужене, представља посебну просторну и функционалну целину да би се на истој могло стећи право својине, а на њима је био терет доказивања ових чињеница, на шта се основано указује жалбом тужене, будући да доградња или адаптација стамбеног простора не представљају основ за стицање својине те тужиоци према туженој могу истаћи само облигациони захтев за исплату вредности уложеног рада и материјала, због чега је првостепена пресуда морала бити преиначена и захтев тужилаца за утврђивање својине по основу градње као и захтев за редукцију уговора о доживотном издржавања у односу на просторију која је предмет спора, одбијен.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж. 2777/22 од 02.09.2022. године),

Автори сентенце: Снежана Лазих, судија Апелационог суда у Нишу и Миша Вујичић, судијски помоћник Апелационог суда у Нишу.

ПРАВИЛНА ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА НАКНАДУ МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ

(члан 154 и 155 Закона о облигационим односима)

Када је оштећена здравствену заштиту без додатних материјалних трошкова могла остварити и у државној здравственој установи тада јој, у односу на штетника, не припада право на накнаду материјалне штете у виду трошкова лечења повреде на приватној клиници.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању од стране првостепеног суда тужила је дана ...01.2017. год. око 17,00 часова доживела незгоду у Н., у ул. ..., тако што се на улици, на потесу од аутобуске станице ка семафору, оклизнула на лед и пала, и том приликом задобила тешку телесну повреду у виду прелома скочног зглоба леве ноге.

Према налазу вештака медицинске струке нема пропуста у лечењу тужиље на Клиници за ортопедију и трауматологију Клиничког Центра Н., а који би утицали на развој инфекције оперативне ране, услед чега првостепени суд правилно закључује да не постоји узрочно последична веза између дужине и интензитета физичких болова, страха и душевних болова које трпи тужила и методе лечења у Клиничком Центру Н., већ су сви видови нематеријалне штете за које је тужилји досуђена накнада у складу са одредбом члана 200 Закона о облигационим односима последица пада и повреде тужиље на улици због неочишћеног леда, а за коју делатност је несумњиво одговоран тужени.

Међутим, основано се жалбом туженог указује да првостепени суд није правилно применио материјално право у делу одлуке којом је тужилји на име накнаде материјалне штете, која се огледа у трошковима лечења које је тужила имала у приватној здравственој установи, досудио укупан износ од 115.790,00 динара, према приложеним фактурама од стране тужиље, обзиром да се не ради о трошковима који су у конкретном случају били нужни, већ су исти могли бити избегнути лечењем тужиље у државној здравственој установи. Наиме, према исказу саме тужиље њој није био ускраћен пријем у државну здравствену установу, нити је та здравствена установа у конкретном случају била онемогућна да јој пружи потребну здравствену негу, већ је тужила самоиницијално напустила државну ортопедску клинику и због тога што није могла да чека свог лекара, о чијем радном времену је могла претходно да се информише, лечење због бољег комфора наставила у приватној здравственој установи. Из наведеног следи да се тужила није лечила у приватној клиници из нужде и из разлога што такво лечење није могла обавити у државној здравственој установи, већ се ради о избору тужиље који је допринео да материјална штета у виду трошкова лечења буде већа, односно о избору који је довео до настанка овог вида штете. Из допунског налаза и мишљења вештака медицинске струке несумњиво проистиче да је лечење у Клиничком Центру Н. било адекватно стању и потребама тужиље, да начин лечења у државној здравственој установи није изазвао потребу за лечењем тужиље у приватној Поликлиници, да није било пропуста Клиничког Центра у лечењу тужиље, да би тужила на исти начин као у приватној била збринута и у државној здравственој установи, као и да би дужина активног лечења у приватној и државној установи временски и по квалитету била приближна. Поред наведеног лечење у приватној здравственој установи није било од

утицаја на интензитет и дужину трајања физичких болова и страха, те из свега наведеног следи да лечење тужиље у приватној Поликлиници “В.В.” није било медицински ни економски оправдано, те се тако настали трошкови не могу превалити на туженог, обзиром да у овом делу нема узрочно последичне везе између пада тужиље и лечења у приватној клиници, све у смислу одредбе члана 155 Закона о облигационим односима. Имајући у виду да је материјалну штету у виду додатних трошкова лечења проузроковала сама тужиља без оправданих разлога, у смислу одредбе члана 192 Закона о облигационим односима, то је првостепена одлука у овом делу морала бити преиначена, а тужбени захтев одбијен као неоснован.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж бр. 1828/2021 од 07.09.2021. год., судија Јадранка Митровски са судијским саветником Оливером Николић)

ПРАВО НА ИМОВИНУ

(Члан 1 Протокола 1 уз Европску Конвенцију за заштиту људских права и основних слобода и члан 58 став 1 Устава Републике Србије)

У ситуацији када је накнада за одузето земљиште одређена решењем у управном поступку и исплаћена правном претходнику тужиље, тужиља у парничном поступку не може поново остварити накнаду за исту непокретности на основу фактичке експропријације, јер је експропријација спроведена у јавном интересу и под условима одређеним законом.

Из образложења:

Правилно је првостепени суд закључио, на основу изведених доказа које је правилно ценио у смислу чл.8 ЗПП, пре свега налаза и мишљења вештака, Грађевинског факултета у Београду, који је извршио идентификацију парцеле, да је кп.бр.... КО ..., на којој је школа изграђена, а која се води у јавним књигама на туженог, са правом коришћења и представља градско грађевинско земљиште, била предмет експропријације према решењу Градског Народног одбора од 16.09.1948. године означена у површини од 5.50 декада као њива, а које решење није произвело правно дејство, с обзиром на то да није било потврђено од стране Владе ФНРЈ у складу са одредбом

чл.6 Закона о експропријацији и да је за исту парцелу донето ново решење о експропријацији 13.03.1950 године у свему према чл. 29 тада важећег Закона о експропријацији, којим је правном предходнику тужиље као ранијем власнику, одређена накнада за експроприсану непокретност у обвезницама.

Стога се неосновано жалбом тужиље оспорава правилност и законитост првостепене пресуде у смислу да суд није дао довољне и јасне разлоге за своју одлуку коју је засновао само на налазу вештака Грађевинског факултета у Београду, не прихватајући и не ценећи остале изведене доказе, будући да се управо из налаза и допунског изјашњења ове установе утврђује да је за непокретност за коју тужиља тврди да је фактички изузета из поседа њеног правног претходника без накнаде, решењем надлежног органа накнада одређена, па у таквој ситуацији тужиља не може у парничном поступку поново остварити право на накнаду за исту непокретност јер се не ради о фактички експроприсаној непокретности без спроведеног поступка експропријације и одређивања накнаде већ је експропријација спроведена у јавном интересу и под условима одређеним законом.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж. 2359/21 од 06.10.2021. године),

*Аутори сентенце: Снежана Лазић, судија Апелационог суда у Нишу
и Миша Вујичић, судијски помоћник Апелационог суда у Нишу.*

ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА- МАНЕ ВОЉЕ

(Члан 62 Закона о облигационим односима)

Поклонодавац се не може позвати на то да је приликом закључења уговора о поклону, којим је општини поклонио своју непокретну имовину, био у битној заблуди јер је веровао да ће закључењем уговора о поклону од стране општине добити право на здравствено осигурање, а да ће му имовина након што оствари право на здравствену заштиту бити враћена.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужилац Р. Г. закључио је са туженом Општином уговор о поклону који је оверен пред Општинским судом у ... –

Одељење у ... под Ов.бр.... од 04.03.2009.године, којим је туженом поклонио своју непокретну имовину уписану у лн.бр. и ... КО ..., у обиму удела од 1/2 као и целу кп.бр.... у КО ... Према чл.1 уговора, након његовог потписивања поклонодавац предаје у посед и својину поклонопримцу ову имовину без икаквих терета и правних и других претензија од стране трећих лица. По захтеву туженог решењем РГЗ СКН ... од 05.03.2009.године, имовина која је предмет уговора о поклону, уписана је на име туженог. Тужилац Р. Г. преминуо је након подношења тужбе а поступак је настављен по предлогу законског наследника С. Г., брата оставиоца према решењу Основног суда у Куршумлији О.бр.191/16 од 24.01.2017.године. Исказима сведока Н. М. и Д. М. утврђено је на који је начин дошло до закључења уговора о поклону.

Одредбом чл.62 ЗОО је прописано да код уговора без накнаде, битном заблудом се сматра и заблуда о побуди која је била одлучна за преузимање обавезе.

Правилно је првостепени суд, на основу оцене свих изведених доказа и то саслушањем тужиоца као странке и сведока, закључио да је мотив за закључење правног посла између странака био бестеретно располагање односно чињење поклона туженом у циљу остварења здравственог осигурања сада пок. поклонодавца Р. Г., а не закључење неког другог правног посла, те су без утицаја његова очекивања да ће тужени након остварења права на здравствено осигурање сада пок.Р. Г., истом вратити непокретну имовину којом је располагао овим уговором у корист туженог, да је поклонодавац предложио закључење таквог уговора и да је био способан да схвати значај правних радњи које предузима. На правно ваљан начин, првостепени суд је утврдио да није било мана у погледу воље правног претходника тужиоца као поклонодавца, нити да је предузете правне радње учинио у заблуди будући да је уговор састављен по вољи поклонодавца, да је исти потписао и да је знао за последице закључења овог уговора, да ће имовина која је предмет поклона, након овере прећи на поклонопримца, те да су уговарачи јасно изразили своју вољу да желе да закључе тај уговор након чега је поклонодавац остварио право на здравствену заштиту, у складу са усменим договором са овлашћеним лицем туженог.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж. 2190/22 од 14.07.2022. године),

Аутори сентенце: Снежана Лазић, судија Апелационог суда у Нишу и Миша Вујичић, судијски помоћник Апелационог суда у Нишу.

ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ КОЈА ПОТИЧЕ ОД ЛОВОСТАЈЕМ ЗАШТИЋЕНЕ ДИВЉАЧИ

(члан 4. ст. 1. тач. 34. и члан 88. ст. 2. Закона о дивљачи и ловству)

Лице које је претрпело штету услед излетања ловостајем заштићене дивљачи на државни пут има право на накнаду штете, иако је ловачко друштво на чијем подручју се догодио штетни догађај предузело превентивне мере у циљу спречавања ризика од штете.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, дана 31.05.2017. године на државном путу на релацији С.–Н. дошло је до саобраћајне незгоде када је испред путничког возила којим је управљао тужилац, крећући се у колони брзином од 40-50 км/х, са бедема поред пута скочио срндаћ, ударио у возило и пао на супротну коловозну траку. Услед судара дошло је до оштећења возила а срндаћ је угинуо. Висина материјалне штете на возилу је утврђена налазом вештака машинске струке.

Првостепени суд је правилно утврдио да је до штетног догађаја дошло на тај начин што је једно грло ловостајем заштићене дивљачи – срндаћ излетело на коловоз државног пута и ударило у предњи део тужиоачевог возила којим је он и управљао, чиме је нанета материјална штета, и да је за њену накнаду одговоран тужени као ловачко друштво. Државни пут представља део ловишта, сходно одредбама чл. 4. ст. 1. тач. 34. Закона о дивљачи и ловству, тако да је за штету насталу услед непредвиђеног, ничим изазваног и изненадног излетања срндаћа као ловостајем заштићене дивљачи одговоран тужени, јер је та одговорност установљена одредбом члана 88. став 2. истог закона. Притом, тужилац као оштећено лице има право на накнаду штете сходно ст. 1. истог члана, јер из утврђеног чињеничног стања не произилази да је могао предузети било какве мере за спречавање штете од дивљачи, поготово у ситуацији где је несумњиво утврђено да на предметној деоници не постоје саобраћајни знаци који упозоравају на могућност појаве дивљачи на путу.

Жалбеним наводима туженог се неосновано оспорава закључак првостепеног суда о одговорности за штету, и указује на доказе о мерама које су предузете у ловишту ради спречавања настанка штета од дивљачи. Међу странкама није спорно да је тужени предузимао превентивне мере чији је циљ спречавање, или барем умањивање ризика од штете коју дивљач може нанети

људима и имовини, и ове мере су свакако биле предузете сходно одредби члана 87. Закона о дивљачи и ловству. Међутим, предузимање тих радњи не ослобађа туженог одговорности за штету која је настала упркос предузетим радњама. Одговорност туженог се не заснива само на цитираним одредбама чл. 87 и 88. Закона о дивљачи и ловству, већ и на принципу објективне одговорности за опасну ствар сходно чл. 174. Закона о облигационим односима, из разлога што тужени управља ловиштем у реону пута на коме се десило штетни догађај и до штете је дошло услед изненадног излетања дивљачи на пут и на возило тужиоца, што је за њега као возача представљало блиску, изненадну и покретну препреку коју није могао да избегне при дозвољеној брзини. Како на страни возача није било пропуста који су допринели настанку штете, а тужени није сходно правилу о терету доказивања из чл. 231. ЗПП пружио доказе да се на конкретан случај има применити одредба чл. 177. ЗОО, на туженом је као имаоцу ловостајем заштићене дивљачи обавеза да тужиоцу надокнади укупну утужену штету.

Првостепени суд је правилно оценио неоснованим противтужбени захтев за накнаду штете услед уништења дивљачи – срдњаћа, јер је правилно утврђено да је до штете настало излетањем дивљачи на коловоз по коме се кретало тужиочево возило, а не радњом или пропустом тужиоца - противтуженог, тако да је захтев за накнаду штете на дивљачи правилно оцењен као неоснован.

Пресуда Апелационог суда у Нишу 43 Гж.413/2022 од 12.05.2022. године.

Аутор сентенце: судија Снежана Тодоровић и Иван Васиљковић, судски саветник Апелационог суда у Нишу.

НЕПОСТОЈАЊЕ СПОСОБНОСТИ ЗА ДАВАЊЕ ЗАЛОЖНЕ ИЗЈАВЕ

(члан 103. ст. 1. Закона о облигационим односима, члан
53. ст. 2. тач. 3. Закона о јавном бележничтву)

Ништава је заложна изјава пословно неспособног лица, без обзира што јавни бележник није, сходно одредби члана 53. ст. 2. тачка 3. Закона о јавном бележничтву, одбио да сачини јавнобележнички запис.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, сада пок. ЂЂ је дана xx.xx.2017. године дала заложну изјаву у форми јавнобележничког записа, којом је успостављена извршна вансудска хипотека на непокретности у њеној својини, ради обезбеђења дуга туженог ГГ према туженом ДД. Ради давања ове изјаве, јавни бележник је изашао на лице места и изјава је дата у кући пок. ЂЂ, а на јавнобележничком запису је наведено да иста говори српски језик, да је писмена али да није у могућности да потпише изјаву, те је ставила рукознак, и стоји да је бележник утврдио да је странка способна и овлашћена за давање заложне изјаве. Пок. ЂЂ је преминула двадесет дана након сачињавања заложне изјаве. Према налазу и мишљењу вештака неуропсихијатара, пок. ЂЂ у време сачињавања заложне изјаве није била способна и није могла да схвати значај и последице предузетих правних радњи, пошто је реч о особи која је претходно доживела инфаркт мозга, да је боловала од карцинома са метастазама, а да је подрхтавање руку услед чега није могла да потпише заложну изјаву може бити последица секундарних метастаза у мозгу, које саме по себи компромитују способност расуђивања. Особе које су у тој фази малигне болести, а пок. ЂЂ је у то време примала лек против болова “Тродон”, су психофизички исцрпљене, апатичне, адинамичне и сугестибилне, те су због тога неспособне за расуђивање. Приликом изјашњења на рочишту наведено је да се делиријум јавља код 85% таквих пацијената.

Првостепени суд је потпуно и правилно утврдио чињенично стање, на основу кога је правилно закључио да пок. ЂЂ услед тежине болести од којих је боловала и терапија које је примала, али и година живота, није била способна да схвати правни значај радње коју је предузела практично непосредно уочи своје смрти, којом је успоставила терет на својој непокретности. Правилно је цењени налаз вештака одговарајуће струке, као и његова изјашњења на рочишту, из којих је несумњиво утврђен обим последица које су болести од којих је боловала пок. ЂЂ оставиле на њене менталне капацитете.

Жалбеним наводима тужених се неосновано указује на изјаву вештака дату на рочишту, да се делиријум као узрок когнитивних оштећења јавља код 85% пацијената који су се као и пок. ЂЂ налазиле у терминалној фази болести, и сугерише да је она могла бити у преосталој групи од 15% пацијената. Наиме, делиријум је само један од елемената у оцени психичког статуса пок. ЂЂ, тако да наведени процентуални износи не утичу на правилност оцене

првостепеног суда. У том смислу, и сама чињеница да пок. ЂЂ, иако је била писмена, није била у стању да потпише заложну изјаву услед израженог подрхтавања руку, па је на исту ставила свој рукознак, детаљно је образложена налазом као последица догађања у централном нервном систему, што само по себи компромитује њену способност за испољавање аутентичне воље при закључивању правних послова.

Жалбом тужених се такође неосновано указује и на садржину јавнобележничког записа о давању заложне изјаве, у коме је констатовано да је пок. ЂЂ способна и овлашћена за давање заложне изјаве, пошто оваква констатација ствара само обориву претпоставку да је то заиста био случај. Јавни бележник не мора да поседује стручна знања медицинске струке ради давања оцене нечије пословне способности, што му није ни улога сходно одредбама Закона о јавном бележничштву, већ је дужан да пре предузимања радње за коју је овлашћен изврши процену пословне способности странке која се разумно може очекивати од њега, тако да чињеница да бележник у конкретном случају није искористио могућност која му је дата цитираном одредбом члана 53. ст. 2. тачка 3. овог закона не значи да је лице заиста било пословно способно и у стању да се стара о својим правима и интересима.

Пресуда Апелационог суда у Нишу 43 Гж.826/2021 од 30.09.2021. године

*Аутор сентенце: судија Снежана Тодоровић и Иван Васиљковић,
судски саветник Апелационог суда у Нишу*

ВОЉА ДА СЕ СТВАР НЕ КОРИСТИ, ПАСИВНО ПОНАШАЊЕ СУВЛАСНИКА И ОДСУСТВО ПРОТИВПРАВНОСТИ ДРЖАВИНЕ СТВАРИ КОД ДРУГОГ СУВЛАСНИКА

(Члан 219 Закона о облигационим односима)

Пасивним понашањем сувласника у погледу овлашћења у погледу употребе стана или актом напуштања истог може се манифестовати воља да ствар не користи, тако да сувласник који ствар не употребљава нема право на накнаду за коришћење стана од стране другог сувласника, уколико понашање другог сувласника – држаоца ствари није противправно.

Из образложења:

Према чињеничном стању утврђеном од стране првостепеног суда, тужиља је била удата за туженог Б.Б. и заједно са туженом В.В. су живели у породичној заједници почев од 2001.године, а пресудом првостепеног суда П2 204/13 од 03.12.2013.године је брак разведен и деца парничних странака су поверена тужиљи на самостално вршење родитељског права.

У периоду када се критично догађај одиграо, у току је био парнични поступак ради утврђивања ништавости вансудског поравнања, које поравнање су закључили туженици међусобно, тако што је истим туженик Б.Б. туженој В.В. признао право својине на предметном стану. Како је исти стечен у току трајања породичне заједнице између парничних странака, тужиља је дана 18.09.2013. године поднела тужбу, а правоснажном пресудом Основног суда у Бору П.349/15 од 13.10.2015.године, утврђено је њено право својине по основу стицања, као и њен сувласнички удео од 49,63% на стану у улици ... бр..., у којем су парничне странке пре тога и живеле. Напустивши предметни стан, са млађом малолетном ћерком, тужиља је преко пуномоћника дана 19.02.2016. године поднела тужбу ради предаје, односно предложила је да се изврши цивилна деоба продајом предметног стана и поделом добијеног износа од продајне цене у сразмери утврђених наведених сувласничких делова, а парнични поступак је решењем Основног суда у Бору П.109/16 од 19.02.2016.године обустављен и исти је након правоснажности решења настављен пред Основним судом у Бору по правилу ванпарничног поступка у предмету Р1.16/18, у којем је донето решење дана 19.02.2019.године којим је утврђено да физичка деоба предметног стана није могућа, те да ће се иста извршити цивилном деобом. Према исказу тужиље саслушане у својству странке, стан је напустила крајем децембра 2014.године и са млађом ћерком се преселила у једноипособан стан код кумова, за који је плаћала само комуналије. --- На основу грађевинског вештачења је утврђено да би тужиља могла издати у закуп део стана који јој припада за износ од 6.998,00 динара месечно, односно да закупнина за предметни стан површине површине 75 м2 износи 14.100,00 динара, што за удео од 49,63% износи 6.998,00 динара.

Како су тужени користили цео стан без правног основа, односно и део тужиље као сувласника, првостепени суд је нашао да су дужни да тужиљи исплате

накнаду по основу стицања без основа у смислу чл. 219 ЗОО и то у висини сразмерног дела закупнине коју би тужила остварила да је свој сувласнички удео на предметном стану издавала у закуп, будући да је тужила као сувласник ове била онемогућена у свом праву да као сувласник користи непокретност, а ово право тужиле да своју ствар држи, да се њоме користи и располаже у границама свог сувласничког удела, те како је државина тужених као сувласника противправна, то тужила има право на накнаду јер према одредби чл. 3 ЗОСПО забрањена повреда права својине, па је донета побијана пресуда.

Предњи закључци првостепеног суда се не могу прихватити као правилни из разлога јер је побијана пресуда заснована на погрешној примени материјалног права, будући да је тужили на основу примене одредбе чл. 219. ЗОО од стране првостепеног суда досуђена накнада изгубљене потенцијалне закупнине сразмерно величини њеног удела, што у суштини представља накнаду штете у виду измакле користи из чл. 189. ЗОО. Притом је првостепени суд пропустио да потпуно утврди чињенично стање неопходно за примену сваког од претходно наведених појединачних правних основа за досуђење накнаде.

Наиме, по основу извршне исправе, напред наведене пресуде којом је утврђен удео тужиле на предметном стану, тужила је, независно од поступка за деобу ствари, исто тако имала овлашћење да покрене и поступак извршења ради предаје у државину сувласничког удела, што за сада није утврђено, а према датим разлозима, у извршном поступку који је у току тражи продају непокретности. Указује се и на то да је одредбом чл. 194. Породичног закона регулисан правни институт становања (*habitatio*) у корист родитеља који врши родитељско право, док су одредбом чл. 198. ст. 2 тач. 1 и 2 ПЗ као мера заштите од заштите од насиља у породици предвиђени издавање налога за иселење из породичног стана или куће без обзира на право својине и издавање налога за усељење у породични стан, што је тужили такође било на располагању ради разрешења предметне ситуације, уколико је циљ био омогућавање коришћења самог стана.

Предње је од значаја за утврђење околности савесности тужених, а што је опет од утицаја на обим враћања у смислу чл. 214. ЗОО, односно за остварења тужиле на право на законску затезну камату. Притом, током првостепеног поступка тужила није пружила доказе на околност да је имала намеру да издаје у закуп свој удео у предметном стану, нити да је постојао уговор о закупу истог

који је евентуално осујећен радњама тужених, односно није доказана чињеница ни да су тужени издавали предметни стан у закуп и на тај начин остваривали корист коју су у целини задржавали за себе и туженој нису уступали њен део. Дакле, чињеница да ли је тужиља својом вољом напустила предметни стан, без намере да се у исти враћа, да ли су је тужени спречавали у коришћењу истог, те да ли је иницирала поступак за предају стана у судржавину, су чињенице на основу којих је првостепени суд могао закључити да је тужиља као сувласник на предметном стану заиста била спречавана од стране тужених да исти користи, сразмерно свом сувласничком уделу и да су тужени несавесни корисници туђе ствари, што је у конкретном случају изостало.---

Сусвојина постоји на физички неподељеној ствари, у конкретном случају на стану, даје право сваком од сувласника да користи цео стан. Пасивним понашањем сувласника у погледу овлашћења у погледу употребе стана или актом напуштања истог може се манифестовати воља да ствар не користи, тако да сувласник који ствар не употребљава нема право на накнаду за коришћење стана од стране другог сувласника, уколико понашање другог сувласника – држаоца ствари није противправно. Уколико су тужени предметну непокретност на којој имају право сусвојине користили само за становање и притом исти нису издавали у закуп, у том случају је погрешан закључак првостепеног суда да се ради о употреби туђе ствари у смислу чл. 219. у вези чл. 210. ЗОО.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж бр. 814/2021 од 05.10.2021. год., судија Горан Контић са судијским саветником Оливером Николић)

НЕДОЗВОЉЕНОСТ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ

Чл. 85 Закона о пореском поступку и пореској администрацији

Суд нема овлашћење да налаже доношење одлуке којом се окончава сам поступак принудне наплате, већ да спречава спровођење одређене мере у поступку.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужила је дана 30.10.2001. године закључила Уговор о међусобним правима и обавезама бр. ... са ВВ ДОО по којем је тужили предат у етажну својину једнособан стан у ул. ..., бр. зграде..., бр. улаза..., поткровље, бр. посебног дела ..., површине м², уписан у Лист непокретности бр. ..., КО Н. Тужила је исплатила уговорену купопродајну цену као и порез на пренос апсолутних права, по наведеном уговору овреним пред Општинским судом под II Ов.бр. од 30.10.2001. године. Тужила је у државини предметног стана од 2001. године, али није уписала право својине на предметном стану у Катастру непокретности, због чега се као власник истог и даље води ВВ ДОО. Како наведено друштво није измирило своју пореску обавезу, тужени РС, Министарство финансија - Пореска управа - Филијала А К је покренула поступак наплате пореске обавезе, између осталог и из наведене непокретности. Решењем..... од 23.07.2018. године установљена је претходна мера обезбеђења пореске обавезе наплате пореза непокретности, забраном располагања, отуђења и оптерећења. Решењем наведене филијале о принудној наплати пореске обавезе из непокретности бр. ... од 22.11.2018. године је одређена принудна наплата на предметном стану, а другим решењем, под истим бројем и датумом, установљено је и законско založno право – хипотека на наведеном стану. Забележка која се односи на предметни стан, уписана на основу Решења о установљењу претходне мере обезбеђења наплате пореза из непокретности, Министарства финансија Пореска управа Филијала А К, бр.....од 23.07.2018. године још увек није брисана.

Дакле, правилно првостепени суд налази да је тужила титулар права које спречава спровођење принудне мере обезбеђења и самог поступка принудне наплате на предметном стану, па је у ставу другом изреке правилно утврдио да је недозвољена принудна наплата пореске обавезе на предметном стану у погледу којег тужила поседује пуноважан правни основ за стицање, настао пре доношења решења о претходној мери обезбеђења наплате пореске обавезе. Такође, у складу са предњим, првостепена пресуда ће служити за брисање забележбе код надлежне службе РГЗ- Филијала Н, као мера отклањања последица доношења решења којим је установљена претходна мера обезбеђења принудне наплате пореза из предметног стана, будући да забележка уписана по том решењу није брисана. Апелациони суд је становишта да

ни са аспекта пореске обавезе, исти стан пред истим органом не може истовремено имати двоструки третман: и као предмет уговора на основу којег је тужили наплаћена пореска обавеза на име преноса апсолутних права, и као предмет извршења у власништву трећег лица као власника, а ради наплате пореске обавезе која не потиче из међусобног односа тужиле и трећег лица по предметном стану, односно чији супсидијарни дужник није тужила. Тужила у складу са цитираном одредбом Закона о пореском поступку и пореској администрацији има право да се о њеном тужбеном захтеву, за који је надлежан суд, одлучи независно од исхода самог пореског поступка у којем је изјављена жалба пореског обвезника.

Одлучујући о делу тужбеног захтева тужиле којим је тражила да се укине Решење о установљењу претходне мере обезбеђења наплате пореза из непокретности, Министарства финансија Пореска управа Филијала А К, бр. ... од 23.07.2018. године и све радње у односу на наведену непокретност, првостепени суд је правилно одбацио тужбу у наведеном делу из разлога што суд нема законка овлашћења да у парничном поступку у смислу одредбе чл. 1 ЗПП укида решење о принудној наплати пореске обавезе, као управном акту, већ је само овлашћен да одлучи о излучној тужби и захтеву за утврђивање недозвољености принудне наплате на предметном стану, али је погрешно закључио да је у таквој ситуацији првостепени суд овлашћен да налаже обуставу спровђења поступка принудне наплате.

У складу са одредбом чл. 85. ст. 2 Закона о пореском поступку и пореској администрацији првостепени суд има овлашћење само да наложи прекид или обустављање спровођења одређене мере у току поступка и то на ствари из ст. 1, на којој треће лице, које није порески обвезник и његов члан домаћинства, има право које спречава продају. То значи да суд нема овлашћење да налаже доношење одлуке којом се окончава сам поступак принудне наплате, већ да спречава спровођење одређене мере у поступку, која би, према циљном тумачењу одредеби, очигледно могле да доведу до штетних последица у виду продаје ствари и губитка права трећег, што овде није предмет тужбеног захтева. На предњи закључак упућује и норма из ст. 3. цитираног члана, која прописује да Пореска управа може да прекине, односно обустави примену мера принудне наплате над тим предметом, што значи да одлука суда не искључује доношење одлука од стране пореског органа о току и исходу поступка, нити их може заменити. Са друге

стране, одлука суда спречава спречава спровођење принудне наплате на предметној непокретности, чиме се у потребној мери остварује правна заштита угроженог субјективног права странке, а избегава задирање у надлежности другог органа, односно гране државне власти.

Пресуда Апелационог суда у Нишу, Гж1283/2022 од 10.05.2022. године

Аутори сентенце: Горан Контић, судија Апелационог суда у Нишу и Милан Мештровић, судијски помоћник Апелационог суда у Нишу.

АЛЕАТОРНОСТ УГОВОРА О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ

(чл. 203. ст. 1. Закона о наслеђивању)

Алеаторност уговора о доживотном издржавању не процењује се само према временском размаку између закљученог уговора и смрти примаоца издржавања, већ према свим околностима конкретног случаја. Чињеница да је пок. примаоцу издржавања дијагностификовано тешко малигно обољење у време закључења побијаног уговора не води закључку да уговор није представљао никакву неизвесност за даваоца издржавања.

Из образложења:

Пок. З. Н. бив. из Г. боравио је у Немачкој када је у току 2011. године, због лошег здравственог стања, примљен на клинику Света Елизабета у Ревензбургу. Након прегледа и установљеног здравственог стања код пок. З. и закључка да се ради о карциному жучних водова, тзв. Кладски тумор, пок. З. је затражио да странке дођу по њега, као синови. Странке су у Немачкој сазнале да је отац болестан. По доласку у Србију пок. З. је наставио лечење и први пут се јавио на одељење онкологије болнице у Лесковцу дана 12.03.2011. године... Пок. Зоран је умро 13.09.2011. године. У току лечења у Србији пок. Зоран је сачинио уговор о доживотном издржавању са туженим Н. па је такав уговор оверен и потписан у Основном суду у Лесковцу 16.03.2011. године и заведен под бројем 2 РЗ. бр.291/11. Вештак медицинске струке је дао мишљење да се ради о тумору жучних путева који спада у групу тумора са јако лошом прогнозом и

брзим током, да спада у групу тумора који лоше реагују на хемио терапију, те да због ових чињеница, у случају пок. З. може се претпоставити извесност смрти од неколико месеци до годину дана, као и да је уговор о доживотном издржавању сачињен у моменту када је болест била у одмаклој фази и дефинитивна прогноза болести била лоша са извесним предвиђањем смртног исхода. Странке су живеље у истој кући, с тим што је тужени живеље на приземљу заједно са оцем, пок. З. и мајком, док је тужилац живеље на спрату. Тужени је због посла често ишао и Италију, где се задржавао по неколико дана, али од маја месеца 2011. године више није одлазио у Италију. Тужени се бринуо о пок. З. и пре него што се разболео, с тим што је након болести, док је био у Италији, о пок. З. бринула сестра странака којој је тужени за бригу о оцу плаћао. Тужени је купио гробно место и делимично сносио трошкове за куповину споменика.

На основу овако утврђеног чињеничног стања, по налажењу Апелационог суда, тужилац у току поступка није доказао да су испуњени услови прописани чл. 203. Закона о наслеђивању за поништај уговора о доживотном издржавању који је у својству примаоца издржавања пок. З. Н. отац тужиоца, закључио са туженим Н. Н. из Г. као даваоцем издржавања, дана 16.03.2011. године, оверен од стране Основног суда у Лесковцу под бројем 2 РЗ.бр.291/2011.

Одредбом чл. 203. ст. 1. Закона о наслеђивању прописано је да на захтев законских наследника примаоца издржавања, суд може поништити уговор о доживотном издржавању ако због болести или старости примаоца издржавања уговор није представљао никакву неизвесност за даваоца издржавања.

Супротно закључку првостепеног суда, а уважавајући жалбене наводе туженог, Апелациони суд је на основу поновне оцене доказа изведених пред другостепени судом закључио да је предметни уговор, иако је пок. З. као примаоцу издржавања у време закључења уговора већ била дијагностификована болест, представљао неизвесност за даваоца издржавања, овде туженог. Тужени је преминуо 6 месеци након закључења. Међутим, алеаторност уговора о доживотном издржавању не процењује се само према временском размаку између закљученог уговора и смрти примаоца издржавања, већ према свим околностима конкретног случаја. Чињеница да је пок. примаоцу издржавања дијагностификовано тешко малигно обољење у време закључења побијаног уговора не води закључку да уговор није представљао никакву неизвесност

за даваоца издржавања. Дужина живљења увек представља неизвесност и не може се предвидети, па чак и код особе са дијагностикованим тешким обољењем, као што је био З. Тужени својим поступцима ни на један начин није довео у сумњу питање мотива закључења предметног уговора, нити је тужилац на било који начин доказао да је тужени искоришћавао болест примаоца издржавања да би стекао несразмерну имовинску корист и изиграо права законских наследника. Чињеница смрти примаоца издржавања у релативно кратком временском периоду након закључења уговора није представљала мотив за закључење предметног уговора, већ је уговор закључен да би се примаоцу издржавања обезбедило уговорено издржавање у складу са одредбом чл. 194. Закона о наслеђивању. Тужени је и пре закљученог уговора о доживотном издржавању живео у заједници са пок. З. и бринуо о њему, што је потврђено исказима саслушаних сведока, пре свих исказом Д. А, Л. А. и Д. А. којима је другостепени суд поклонио веру. Закључењем оспореног уговора дошло је до усаглашавања фактичког са правним стањем. Поред тога, уговор је закључен на иницијативу примаоца издржавања који је био свестан свог здравственог стања, због чега се изводи закључак да је овим уговором хтео да се осигура, односно обезбеди неког ко ће бринути о њему у тешком периоду живота који му је предстоја, с обзиром на врсту и прогнозе даљег тока болести.

(Пресуда Основног суда у Лесковцу II бр.761/18 од 14.05.2020. године и пресуда Апелационог суда у Нишу Гж бр.534/2021 од 10.03.2022. године)

Аутор сентенце: Јасмина Кузмановић, виши саветник у Апелационом суду у Нишу

ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ КОЈА ПОТИЧЕ ОД ЛОВОСТАЈЕМ ЗАШТИЋЕНЕ ДИВЉАЧИ

(члан 4. ст. 1. тач. 34. и члан 88. ст. 2. Закона о дивљачи и ловству)

Лице које је претрпело штету услед излетања ловостајем заштићене дивљачи на државни пут има право на накнаду штете, иако је ловачко друштво на чијем подручју се догодио штетни догађај предузело превентивне мере у циљу спречавања ризика од штете.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, дана 31.05.2017. године на државном путу на релацији С.–Н. дошло је до саобраћајне незгоде када је испред путничког возила којим је управљао тужилац, крећући се у колони брзином од 40-50 км/х, са бедема поред пута скочио срндаћ, ударио у возило и пао на супротну коловозну траку. Услед судара дошло је до оштећења возила а срндаћ је угинуо. Висина материјалне штете на возилу је утврђена налазом вештака машинске струке.

Првостепени суд је правилно утврдио да је до штетног догађаја дошло на тај начин што је једно грло ловостајем заштићене дивљачи – срндаћ излетело на коловоз државног пута и ударило у предњи део тужиочевог возила којим је он и управљао, чиме је нанета материјална штета, и да је за њену накнаду одговоран тужени као ловачко друштво. Државни пут представља део ловишта, сходно одредбама чл. 4. ст. 1. тач. 34. Закона о дивљачи и ловству, тако да је за штету насталу услед непредвиђеног, ничим изазваног и изненадног излетања срндаћа као ловостајем заштићене дивљачи одговоран тужени, јер је та одговорност установљена одредбом члана 88. став 2. истог закона. Притом, тужилац као оштећено лице има право на накнаду штете сходно ст. 1. истог члана, јер из утврђеног чињеничног стања не произилази да је могао предузети било какве мере за спречавање штете од дивљачи, поготово у ситуацији где је несумњиво утврђено да на предметној деоници не постоје саобраћајни знаци који упозоравају на могућност појаве дивљачи на путу.

Жалбеним наводима туженог се неосновано оспорава закључак првостепеног суда о одговорности за штету, и указује на доказе о мерама које су предузете у ловишту ради спречавања настанка штета од дивљачи. Међу странкама није спорно да је тужени предузимао превентивне мере чији је циљ спречавање, или барем умањивање ризика од штете коју дивљач може нанети људима и имовини, и ове мере су свакако биле предузете сходно одредби члана 87. Закона о дивљачи и ловству. Међутим, предузимање тих радњи не ослобађа туженог одговорности за штету која је настала упркос предузетим радњама. Одговорност туженог се не заснива само на цитираним одредбама чл. 87 и 88. Закона о дивљачи и ловству, већ и на принципу објективне одговорности за опасну ствар сходно чл. 174. Закона о облигационим односима, из разлога што тужени управља ловиштем у реону пута на коме се десио штетни догађај и до штете је дошло услед изненадног излетања дивљачи

на пут и на возило тужиоца, што је за њега као возача представљало блиску, изненадну и покретну препреку коју није могао да избегне при дозвољеној брзини. Како на страни возача није било пропуста који су допринели настанку штете, а тужени није сходно правилу о терету доказивања из чл. 231. ЗПП пружио доказе да се на конкретан случај има применити одредба чл. 177. ЗОО, на туженом је као имаоцу ловостајем заштићене дивљачи обавеза да тужиоцу надокнади укупну утужену штету.

Првостепени суд је правилно оценио неоснованим противтужбени захтев за накнаду штете услед уништења дивљачи – срндаћа, јер је правилно утврђено да је до штете настало излетањем дивљачи на коловоз по коме се кретало тужиочево возило, а не радњом или пропустом тужиоца - противтуженог, тако да је захтев за накнаду штете на дивљачи правилно оцењен као неоснован.

Пресуда Апелационог суда у Нишу 43 Гж.413/2022 од 12.05.2022. године.

Аутор сентенце: судија Снежана Тодоровић и Иван Васиљковић, судски саветник Апелационог суда у Нишу.

ДОКАЗИВАЊЕ УСВОЈЕЊА

(чл. 29. ст. 2. и чл. 63. ст. 4. Закона о општем управном поступку)

Записник о усвојењу није једини доказ о постојању усвојења. У ситуацији када не постоји записник о усвојењу и када чињеница усвојења није унета у матичне књиге рођених, постојање усвојења може се доказивати другим доказима.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужиља је, у поступку расправљања заоставштине сада пок. З. Г. решењем Јавног бележника Јована Стингића Кладова УПП:... од ... године упућена да покрене парнични поступак против овде туженог, М. П. ради доказивања свог права на наслеђе, одн. да је унука по праву представљања иза смрти пок. усвојеног сина Г. П. З. Тужиља је рођена ... године у браку В. Г. и А. Г. обоје из Јб. Отац тужиље, В. Г. рођен је ... године у М. од мајке М. Д. М. Д. је по рођењу детета извршила пријаву рођења пред надлеж-

ним матичарем у Месној канцеларији у М. о чему је састављен записник дана ... године. У матичну књигу рођених отац тужиле уписан је са именом З. под редним бројем ... за матично подручје М. за ... годину, без наведеног имена оца, са податком о мајци, са именом М. Д. Након овога, тужилиног оца усвојили су З. и В. Г. Усвојење је извршено пред Центром за социјални рад у Неготину, а што је уписано у књигу закључених усвојења на страни ... под редним бројем ... за ... годину, са датумом и бројем записника о закљученом усвојењу: ... године, бр. ... без навођења врсте усвојења. Решењем Станице милиције Кладово број Уп. И. бр. ... од ... године, дозвољена је промена имена за Г. З. у име В. рођеног ... године као ванбрачно од мајке М. Д. а који је Решењем за социјални рад у Неготину број ... од ... године усвојен од стране Г. В. и З. из Љ.

На основу овако утврђеног чињеничног стања, правилно је првостепени суд усвојио тужбени захтев и утврдио да је тужилин отац, В. Г, сада бив. из Љ, усвојен непотпуним усвојењем од стране З. Г. и В. Г, обоје из Љ, које усвојење је уписано у Књигу закључених усвојења код Центра за социјални рад Кладово на страни ... под редним бројем ... за ... годину, те да тужила има право на наслеђе по праву представљања иза смрти оца В. Г.

У ситуацији када не постоји записник о усвојењу и када чињеница усвојења није унета у матичне књиге рођених, као што је случај у овој правној ствари, постојање усвојења мора се доказивати другим доказима. По налажењу Апелационог суда, изведеним доказима је утврђено да је сада пок. В. усвојен од стране В. и З. Г. Ова чињеница потврђена је уверењем Центра за социјални рад Кладово број ... од ... године, из ког уверења се потврђује не само постојање записника о усвојењу, већ и да је исто уписано у књигу закључених усвојења на страни ... под редним бројем ... за ... годину. Према чл. 29. ст. 2. Закона о општем управном поступку, уверења и друге исправе о чињеницама о којима се води службена евиденција издају се сагласно подацима из службене евиденције и имају доказну вредност јавне исправе. Тужени у току поступка није спорио доказну вредност наведеног уверења, већ је инсистирао да се постојање усвојења може доказати једино записником о усвојењу. Супротно наводима туженог, записник о усвојењу се не може сматрати јединим доказом о постојању усвојења већ исти представља јавну исправу и доказ о току и садржини предузетих радњи и датих изјава, сходно чл. 63. ст. 4. ЗОУП. Чињеница усвојења тужилиног оца потврђена је и решењем Станице милиције Кладово број Уп. И. бр. ... од ... године, којим је, како се у изреци овог решења наводи, дозвољава промена имена за Г. З. у име В. рођеног ... године као ванбрачно од мајке М. Д, а који је решењем Центра за

социјални рад у Неготину број ... од ... године усвојен од стране Г. В. и З. из Лб. Из садржаја наведеног решења, правилно је првостепени суд закључио да су у тренутку доношења истог подносиоци захтева за промену имена Г. З. у име Г. В. били усвојиоци Г. З. односно В. којем су већ претходно дали своје презиме, а тим решењем накнадно извршили промену имена свом усвојенику, тужилином оцу, за шта су били испуњени услови предвиђени у чл. 10. тада важећег Закона о личном имену („Сл. гл. СРС”, бр. 45/71), којим је било прописано у ст. 2. да ће се малолетном лицу променити лично име на захтев оба родитеља или усвојιοца и у ст. 3. да се ново презиме малолетног лица не може разликовати од презимена родитеља или усвојιοца из предње цитиране одредбе.

Супротно жалбеним наводима, то што чињеница усвојења није уписана у матичну књигу рођених не може се сматрати непостојањем усвојења. У конкретном случају, у матичну књигу рођених није извршен упис усвојилаца као родитеља, већ је остала уписана као родитељ мајка, М. Д, а ово из разлога што су, према тада важећем Упутству о вођењу матичних књига („Сл. лист СФРЈ”, бр. 42/68), усвојιοци као родитељи могли бити уписани само у случају када су оба родитеља детета остала непозната, што се није могло применити на конкретан случају, из разлога што је мајка сада пок. В. била позната одмах по његовом рођењу, док је само отац као родитељ остао непознат.

(Пресуда Основног суда у Неготину, Судске јединице у Кладову I6 П 564/2020 од 25.05.2021. године и пресуда Апелационог суда у Нишу Гж бр.2667/2021 од 22.03.2022. године)

Аутор сентенце: Јасмина Кузмановић, виши саветник у Апелационом суду у Нишу

ПРОЦЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОД ТУЖБЕ РАДИ ПОНИШТАЈА ПРИЗНАЊА ОЧИНСТВА И ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ НЕПОТПУПНЕ ПРОЦЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

(чл. 256. ст. 5. Породичног закона и 211. ст. 2. Закона о парничном поступку)

Породични закон, поред тужбе ради оспоравња очинства (чл. 252. ПЗ), регулише и тужбу ради поништаја признања очинства (чл. 253), а супарничарске заједнице код ове две тужбе су различите. Кад тужбом

ради поништаја признања очинства као странке у спору нису обухваћени сви нужни супарничари прописани чл. 256. ст. 5. Породичног закона, суд не може да одбаци тужбу као непотпуну и неразумљиву, већ се у таквој ситуацији доноси мериторна одлука о тужбеном захтеву, а непотпуна процесна заједница тужених нужних супарничара санкционише одбијањем тужбеног захтева.

Из образложења:

Првостепени суд је, позивајући се на одредбе чл. 192. ст. 1, у вези чл. 98, 101. ст. 5. и 211. ЗПП и чл. 256. ст. 4. Породичног закона, одбацио тужбу тужиље, јер је утврдио да је иста поднета са непотпуним и неразумљивим тужбеним захтевом, због чега су испуњени услови одређени чл. 294. ст. 1. тач. 7. ЗПП.

Првостепени суд сматра да је тужба непотпуна и неразумљива из разлога што тужбом нису обухваћана сва лица која су учесници материјалноправног односа, односно сва лица прописана чл. 256. ст. 4. ПЗ која су у спору ради оспоравања очинства нужни и јединствени супарничари, због чега је тужбу одбацио. Одредбом чл. 211. ст. 2. ЗПП је прописано да се тужбени захтев одбија као неоснован када тужбом као странке нису обухваћени сви нужни супарничари, из чега следи да непотпуна процесна заједница тужених нужних супарничара не представља недостатак који би спречавао поступање по тужби, или недостатак због којег би се тужба могла третирати као неразумљив или непотпун поднесак у смислу чл. 101. ст. 1. у вези чл. 98. ст. 3. и 192. ЗПП. Кад тужбом као тужени нису обухваћени сви нужни супарничари, суд не може да одбаци тужбу као непотпуну. У таквој ситуацији се доноси мериторна одлука о тужбеном захтеву, а непотпуна процесна заједница тужених нужних супарничара се санкционише одбијањем тужбеног захтева, а не применом одредаба ЗПП које уређују поступање по неразумљивим или непотпуним поднесцима, како је погрешно поступио првостепени суд.

Тужиља је у конкретном случају означила предмет спора—оспоравање очинства. Међутим, из реферата тужбе и самог тужбеног захтева произилази да је тужиља тражила поништај изјаве о признању очинства. Како суд није везан правним основом, чак и када је исти наведен, као што је овде случај, већ се основ спора утврђује на основу навода из тужбе и тужбеног захтева, то је нејасан закључак првостепеног суда да је основ спора оспоравање очинства. Првостепени суд није имао у виду да Породични закон, поред тужбе ради ос-

поравња очинства (чл. 252. ПЗ), регулише и тужбу ради поништаја признања очинства (чл. 253), те да су супарничарске заједнице код ове две тужбе различите. Одредбом чл. 256. ст. 4. ПЗ прописано је да су странке у спору ради оспоравања очинства: дете, мајка, мушкарац који се по овом закону сматра оцем детета и мушкарац који тврди да је отац детета (нужни и јединствени супарничари), док је ст. 5 истог члана прописано да су странке у спору ради поништаја признања очинства: лице које је дало изјаву о признању очинства, лице које је дало изјаву о сагласности са признањем очинства, а лице које има правни интерес да изјава буде поништена само ако се ради о условима за ништавост признања (нужни и јединствени супарничари).

У поновном поступку, првостепени суд ће најпре на основу навода из тужбе и тужбеног захтева утврдити основ спора, затим ће утврдити да ли су тужбом обухваћени сви нужни и јединствени супарничари, након чега ће бити у могућности да, правилном применом материјалног права донесе правилну и закониту одлуку о тужбеном захтеву.

(Решење Вишег суда у Лесковцу П2. 12/21 од 14.10.2021. године и решење Апелационог суда у Нишу Гж2. 11/2022 од 18.01.2022. године)

Аутор сентенце: Јасмина Кузмановић, виши саветник у Апелационом суду у Нишу

УТВРЂЕЊЕ АПСОЛУТНЕ НИШТАВОСТИ УГОВОРА

(члан 103. Закона о облигационим односима)

Може се раскинути само правно ваљан уговор, а не и уговор који је апсолутно ништав, односно који није ни настао.

Из образложења:

Правилан је закључак првостепеног суда да се не ради о алтернативно постављеном тужбеном захтеву, имајући у виду да непостојећи уговори по својим последицама и правном дејству су изједначени са апсолутно ништавим уговорима, па је супротно жалбеним наводима, правилно првостепени суд одлучио само о захтеву за утврђење ништавости уговора, правилно налазећи да је исти ништав у смислу одрбе чл.103. Закона о облигационим односима, јер је закључен од стране невласника предметне парцеле и супротно

императивним прописима о располагању стварима у јавној својини, па као такав не производи правно дејство.

Последице утврђења апсолутне ништавости уговора су да се сматра да исти није ни закључен, па с тим у вези није од утицаја чињеница на коју указује трећетужени у жалби, да је уговор раскинут три дана пре покретања ове парнице, а ово из разлога што се може раскинути само правно ваљан уговор, а не и уговор који је ништав, односно који није ни настао. На ништавост уговора суд пази и по службеној дужности, сходно одредби чл.109. ст.1. Закона о облигационим односима, па чињеница да је уговор једнострано раскинут од стране закупаваца, овде првотуженог и друготуженог, није од утицаја на другачије одлучивање по захтеву тужиоца за утврђење апсолутне ништавости предметног уговора.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж.485/22 од 07.06.2022.године), аутор сентенце Мирјана Милутиновић, саветник у Апелационом суду у Нишу)

УГОВОР О РАСПОДЕЛИ ИМОВИНЕ ЗА ЖИВОТА

(члан 106 до 117 Закона о наслеђивању)

За пуноважност уговора о уступању и расподели имовине за живота потребна је сагласност свих уступничевих потомака, који ће бити позвани да га наследе. Сагласност потомака је потребна с обзиром да имовина која је обухваћена уговором о уступању и расподели имовине за живота не чини његову заоставштину.

Из образложења:

Споразум о расподели имовине за живота има статус уговора о уступању и расподели имовине за живота, који је био регулисан одредбама чл.106 до 117 Закона о наслеђивању, који је објављен у Сл. гласнику Социјалистичке Републике Србије са почетком примене од 01.јануара 1975.године и важио до 05.05.1996.године, када је на снагу ступио нови Закон о наслеђивању. Имајући у виду да је предметни споразум - уговор о уступању и расподели имовине за живота закључен 1993.године, правилно закључује првостепени суд да се на исти примењују одредбе Закона о наслеђивању који је важио у том моменту.

Уговор о уступању и расподели имовине за живота је по правилу једнострано обавезан, добротин и строго формалан правни посао. У тренутку закључења уговора настаје само обавеза на страни претка да потомцима преда имовину која је предмет уговора, а за предату имовину, предак не добија никакву накнаду. Објективно битан састојак уговора о уступању и расподели имовине за живота је имовина која је предмет уговора, а коју предак преноси на потомке. При томе, уступилац не мора потомцима једнако расподелити имовину, чак не мора свим потомцима уопште и разделити имовину. Овим уговором може бити обухваћена само она преткова имовина која постоји у тренутку закључења уговора. Наследно-правно дејство уговора о уступању имовине огледа се у околности да имовина која је предмет уговора не улази у уступичеву заоставштину, а то значи да не подлеже режиму наследно правних норми: из ње се не може намирити нужни део уступичевих наследника, нити се по отварању његовог наследства та имовина може урачунати у наследни део уступичевог законског наследника. Да би уговор произвео наведене последице, за његову пуноважност најпре је потребна сагласност свих уступичевих потомака, који ће бити позвани да га наследе. Сагласност потомака је потребна обзиром да имовина која је обухваћена уговором о уступању и расподели имовине за живота не чини његову заоставштину, то потомак, који се није сагласио са уговором остаје без једног дела наследног дела, заправо вредности имовине која је обухваћена уговором.

Имајући у виду напред наведено основан је жалбени навод тужилаца који указује да је поред супруге О., сина М. и ћерке Љ., сада пок. Т. имао и две ванбрачне ћерке С. и Т., које нису дале сагласност ни приликом закључења и овере спорног уговора, а ни касније, а последица недавања сагласности води до трансформисања предметног уговора у уговор о поклону са свим правним последицама те трансформације. Из наведеног разлога је неприхватљив закључак првостепеног суда да тужени током поступка нису доказали ни једним доказом, иако је на њима био терет доказивања, да су наведена лица заиста потомци сада пок. Т.М. код чињенице која се утврђује увидом у завештање сада пок. Т., у коме он сам наводи ова два лица као своје ванбрачне ћерке Т. и С. које искључује из наслеђа и не признаје их као своје ћерке, али без даљег навођења разлога услед којих их не признаје. Стога се не може прихватити закључак првостепеног суда да је тужила, по основу наведеног Споразума о расподели имовине за живота постала

власник имовине која је обухваћена истим јер је судбина и опстанак овог Споразума у директној вези са накнадном сагласношћу ванбрачних ћерки сада пок. Т.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж. 1228/22 од 10.05.2022.године), аутор сентенце Мирјана Милутиновић, саветник у Апелационом суду у Нишу)

РАСКИД УГОВОРА О ДОЖИВОТНОМ ИЗДРЖАВАЊУ

(члан 201.ст.1. и чл. 202.ст.1. Закона о наслеђивању)

Уговор о доживотном издржавању закључује с обзиром на личност уговорника, што је посебно изражено у случају када обавеза даваоца издржавања не подразумева новчано давање, већ лично ангажовање и бригу о примаоцу издржавања. Противно је самој сврси уговора о доживотном издржавању када би се прималац издржавања противно својој вољи приморао на останак у уговорном односу, без уважавања његових личних ставова, осећања и захтева.

Из образложења:

Одредбом чл. 201 ст. 1 Закона о наслеђивању, прописано је да ако се међусобни односи уговорника из било ког узрока толико поремете да постану неподношљиви, свако од њих може захтевати да суд раскине уговор, док је одредбом чл. 202 ст.1. истог Закона прописано да ако се после закључења уговора околности толико промене да његово испуњење постане знатно отежано, суд може на захтев једне или друге уговорнице, њихове односе изнова уредити или раскинути.

У конкретном случају је утврђено да су односи уговорних страна поремећени до мере непоправљивог, имајући у виду да парничне странке међусобно не комуницирају и да од пресељења тужиље у ... тужени не извршава своје уговорне обавезе. Правилан је закључак првостепеног суда да је без утицаја на другачије одлучивање чињеница да ли је тужени уредно испуњавао своје уговорне обавезе до одласка тужиље у, што је потом довело и до фактичке немогућности извршавања уговорних обавеза, јер је противно самој сврси уговора о доживотном издржавању када би се прималац издржавања противно својој вољи приморао на останак у уговорном односу, без

уважавања његових личних ставова, осећања и захтева. Ово због тога што се уговор о доживотном издржавању закључује с обзиром на личност уговорника, а што је посебно изражено у случају када обавеза даваоца издржавања не подразумева новчано давање, већ лично ангажовање и бригу о примаоцу издржавања, што је у конкретном случају и била суштинска обавеза туженог по предметном уговору (да доживотно издржава тужиљу, да је негује и пази, у болести одводи до лекара, да је после смрти сахрани на примерен начин, подигне јој надгробни споменик и изда подушја по месном обичају). За такав уговор, пресудно је да постоји поверење између уговорних страна једне према другој и да је прималац издржавања уверен да друга страна мари за његову добробит, да је не схвата само као просту обавезу и посао, већ да је посматра као особу у невољи коме су пажња и старање неопходни и да буде сигурна да ће јој се друга страна наћи када јој је то потребно. У конкретном случају је утврђено да су међусобно поверење и несметана комуникација странака постојали до момента закључења уговора, али како је време пролазило, међусобни односи странака су се до те мере нарушили да тужиља више не жели да се тужени брине о њој, те да је иста након пресељења у ... код рођака прекинула сваки контакт са туженим, а након само шест месеци од закључења уговора поднела је тужбу за раскид уговора, као и да је тужиља до окончања поступка остала доследна у свом ставу да се уговорни однос између њих раскине.

Како су се односи између парничних странака пореметили у толикој мери да онемогућавају извршавање уговора у периоду дужем од годину дана, а како је предмет обавезе туженог, као даваоца издржавања, с обзиром на садржину готово немогуће испунити ако не постоји сарадња са тужиљом, као примаоцем издржавања, правилно је првостепени суд оценио да су међусобни односи уговорника постали неподношљиви, тако да се више не остварује сврха уговора, у смислу одредбе чл.201. ст.1. Закона о наслеђивању, због чега су се стекли услови за његов раскид по захтеву тужиље, као примаоца издржавања, како је правилно одлучио првостепени суд у ставу првом изреке.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж.1767/22 од 21.06.2022.године), аутор сентенце Мирјана Милутиновић, саветник у Апелационом суду у Нишу)

ПРАВНИ ИНТЕРЕС ЗА ПОДНОШЕЊЕ ТУЖБЕ ЗА УТВРЂЕЊЕ (чл.194 и 294 ст.1 тач.6 ЗПП)

Суд ће због непостојања правног интереса, тужбу за утврђење постојања права доживотног плодоуживања, одбацити сходно чл. 294 ст.1 тач.6 ЗПП, и неће мериторно одлучивати о тужбеном захтеву.

Из образложења:

За подношење утврђујуће тужбе неопходно је да тужилац има правни интерес, како то произилази из чл.194. став 2.ЗПП. Правни интерес постоји када тужилац има оправдану потребу за пружањем правне заштите. Сматра се да он постоји ако је законодавац посебним прописом предвидео могућност тражења правне заштите, а у свим осталим случајевима тужилац је дужан да га докаже. Мериторним одлучивањем по тужби са тужбеним захтевом за утврђење,сходно наведеном, уређује се одређена материјалноправна ситуација на коначан и ауторитативни начин, односно одлучује да ли је странка основано или не тражила судску заштиту и то тек уколико суд утврди постојање правног интереса.

Одредбом чл. 294. ст. 1. тач. 6. Закона о парничном поступку, прописано је да суд по претходном испитивању тужбе доноси решење којим се тужба одбацује ако утврди да не постоји правни интерес тужиоца за подношење тужбе из чл. 194. овог закона. Дакле првостепени суд је најпре био дужан да цени да ли тужилац има правни интерес за подношење тужбе и да ли је доставио доказе у том смислу, а тек онда, уколико нађе да постоји правни интерес тужиоца за утврђивање права својине на непокретности, мериторно одлучи о таквом захтеву. Сходно наведеном, мериторно одлучивање о постављеном тужбеном захтеву и одбијање истог због недостатка правног интереса чини изреку пресуде нејасном и противречном датим разлозима, на шта се основано жалбом тужиље указује, због чега је првостепена пресуда морала бити укинута.

(Из решења Апелационог суда у Нишу 45 Гж 1834/20 од 02.09.2020. године)

Аутор сентенце: Миљана Стојковић, судија Апелационог суда у Нишу

НАКНАДА ТРОШКОВА У СПОРОВИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД НАСИЉА У ПОРОДИЦИ

У поступцима за заштиту од насиља у породици, примена чл. 153 Закона о парничном поступку и оцена успеха у спору је зависна од утврђења, да ли је насиље у породици извршено или не, а не од броја тражених и одређених мера заштите.

Из образложења:

Неосновани су жалбени наводи туженог којима се указује на неправилну примену чл. 153 ЗПП-а уз образложење су тужиоци поставили укупно седам тужбених захтева од којих су у спору успели само са два и трећим делимично. Ово стога, што је у овом поступку одлучивано о заштити од насиља у породици и утврђено је, да је тужени у два догађаја за које је и тражена судска заштита акте насиља извршио. Стога околност колико је од тражених мера заштите изречено не може представљати успех у спору у смислу чл. 153 ЗПП-а, јер у овом поступку сходно чл. 287 Породичног закона суд није везан границама тужбеног захтева и може одредити како неку од мера заштите која је тражена, тако и мере заштите које нису тражене, зависно од процене којом мером се најбоље постиже заштита.

(Пресуда Апелационог суда у Нишу, 32Гж бр.369/22 од 21.09.2022. године, судија Зорица Стошић)

ПРАВНИ ОСНОВ ПОТРАЖИВАЊА И ПРЕДЛАГАЊЕ ДОКАЗА У ПОСТУПКУ КОЈИ СЕ ВОДИ КАО ПОВОДОМ ПРИГОВОРА ПРОТИВ ПЛАТНОГ НАЛОГА

Члан 460 Закона о парничном поступку

У поступку који се води као поводом приговора против платног налога, странке могу достављати све доказе којима располажу у вези са тужбеним захтевом, уз ограничења из чл. 308 и 314 ЗПП-а, независно од тога која је веродостојна исправа послужила за иницирање поступка извршења.

Из образложења:

У конкретном случају првостепени суд је правилном применом напред цитираног чл. 1065 ЗОО нашао, да је између странка постојао правни посао – уговор о кредиту по коме постоји дуг туженог по основу невраћене главнице и обрачунате камате, па правилно закључује, да постоји обавеза туженог да тужиоцу исплати дуг, а у износу обрачунатом од стране судског вештака, са припадајућом законском затезном каматом.

Наводима жалбе туженог се правилност одлуке првостепеног суда не доводи у сумњу.

Тужени у жалби препричава ток извршног поступка по предлогу за дозволу извршења на основу менице као веродостојне исправе, указује на неисправност менице коју је и првостепени суд ценио као такву али да је супротно томе усвојио тужбени захтев иако предметна меница не представља валидну исправу.

Предњи жалбени наводи су без утицаја на одлучивање, имајући у виду да је тужилац поступак у овој правној ствари иницирао предлогом за дозволу извршења на основу веродостојне исправе – менице, али да је по приговору туженог, као извршног дужника донето решење о извршењу стављено ван снаге у делу у коме је одређено извршење и поступак настављен као по приговору против платног налога. Ово стога, што се поступку који се води као поводом приговора против платног налога у свему поступа у складу са одредбама Закона о парничном поступку.

С тим у вези, одлука првостепеног суда је заснована на утврђеном чињеничном стању на основу оцене свих изведених доказа, пре свега закључених уговора између странака и налаза и мишљења вештака економско-финансијске струке, из кога је утврђено укупно стање дуга туженог према тужиоцу, па је на овакво чињенично утврђење првостепени суд примено релевантно материјално право. Стога формална неисправност менице не утиче на постојање обавезе туженог, јер се накнада у овој правној ствари након што је поступак настављен у парници, више не потражује по основу менице, већ на основу одредаба закљученог уговора о готовинском кредиту.

С тим у вези неосновано је и указивање туженог, да је тужилац морао да покрене нов поступак уколико је хтео да наплату тражи на основу уговора, јер када се поступак настави као поводом приговора против платног налога

тј. у парници, сходно чл. 460 ст. 2 и 3 ЗПП-а суд одмах заказује рочиште за главну расправу, странке могу да износе нове чињенице и да предлажу нове доказе, а тужени може да истиче и нове приговоре у погледу побијаног дела платног налога најкасније до закључења првог рочишта за главну расправу. Обзиром да се на даљи поступак – парницу, примјењују и остале одредбе Закона о парничном поступку, странке имају могућност да предложе и доставе све доказе којима располажу у вези са предметом тужбеног захтева, уз ограничења прописана чл. 308 и чл.314 ЗПП-а.

Из Решења Апелационог суда у Нишу 32Гж бр.2461/22 од 11.10.2022.године,

Аутор сентенце Зорица Стошић, судија Апелационог суда у Нишу

САДРЖИНА ТУЖБЕ ПО ЗАКОНУ О ЗАБРАНИ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Члан 43 Закона о забрани дискриминације

Код оцене испуњености услова за одбачај, разумљивост и потпуност поднете тужбе се не цени само по садржини петитума, већ и према садржини реферата тужбе.

Из образложења:

Нејасни су и противуречни стању у списима предмета разлози првостепеног суд за одбацивање тужбе, да ли поднету тужбу сматра неразумљивом или непотпуном. Дата аргументација, да петитум тужбе не садржи све што је потребно (радњу повреде, чињенице које образују ту радњу, опис извршене дискриминације и лично својство по коме је дискриминација учињена), у супротности је са стањем у списима предмета, односно садржином поднете тужбе, обзиром да се петитумом тужбе као радња извршења акта дискриминације наводи у односу на тужени Основни суд у Л. – достава решења Р2.70/19 од 23.07.2020. године Центру за социјални рад; у односу на тужени Центар за социјални рад као радња дискриминације је наведена достава истог решења Граду Л, Градској управи; а у односу на Град Лесковац, Градску управу – доношење решења бр.092-208-00-14/2020-00010 од 11.09.2021. године којим је тужилац обрисан из јединственог бирачког списка, а рефератом

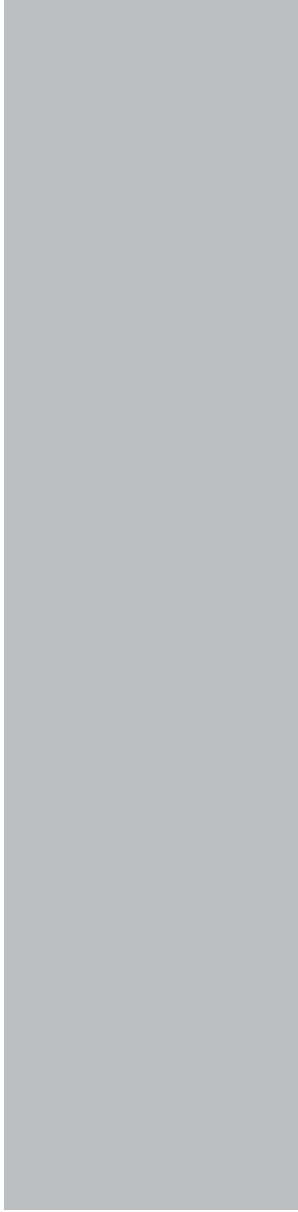
тужбе је наведено лично својство – делимично стављање под старатељство тужиоца.

Обзиром на све наведено, побијано решење је укинато, па ће у поновном поступку првостепени суд пре свега омогућити тужиоцу да се изјасни у погледу неуредности и непотпуности поднете тужбе, затим ће оценит уредност и потпуност исте, при томе ће водити рачуна и правилном означању туженог Основног суда у Лесковцу, након чега ће бити у прилици да правилно и потпуно утврди чињенично стање и правилном применом материјалног права одлучи о поднетом захтеву тужиоца.

Из Решења Апелационог суда у Нишу 32Гж бр.3244/22 од 18.10.2022.године,

Аутор сентенце Зорица Стошић, судија Апелационог суда у Нишу

РАДНО ПРАВО



ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОСНОВУ ФАЛСИФИКОВАНЕ ДИПЛОМЕ

(чл. 179 ст. 3 тач. 6 и 8 Закона о раду)

Предаја послодавцу фалсификоване дипломе о стеченом стручном образовању представља повреду радне обавезе у продуженом трајању и отказни разлог прописан чланом 179. ставом 3. тачком 6. и 8. Закона о раду, односно сматра се таквим понашањем запосленог због којег он не може наставити рад код послодавца.

Из образложења:

Оспореним решењем туженог од 03.07.2020. године тужиоцу су отказани напред наведени уговори о раду са анексима, те му је радни однос престао даном достављања решења, а из разлога што је достављањем послодавцу неверодостојне дипломе од 23.06.1997. године учинио повреду радне обавезе из члана 179. став 2. тачка 5. Закона о раду, у вези члана 9. став 1. алинеја 1. уговора о раду број од 17.01.2003. године, члана 10 тачка 1 и 2 уговора о раду број од 15.12.2006. године и Анекса уговора о раду број од 10.04.2012. године, у вези са чланом 15. тачка 3. односно члана 14. став 1. Закона о раду важећег у време закључења уговора, као и непоштовање радне дисциплине из члана 179. став 3. тачка 6. и 8. Закона о раду.

Полазећи од тако утврђеног чињеничног стања, правилно је одлучио првостепени суд када је одбио као неоснован захтев тужиоца, правилном применом материјалног права, у свему дајући разлоге које прихвата и Апелациони суд.

Чланом 14. ставом 1. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр. 70/2001 и 73/2001), који се примењивао у време доношења решења број од 13.07.2001. године и закључења уговора о раду број од 17.01.2003. године, када је тужилац предао туженом неверодостојну (фалсификовану) диплому о завршеном IV степену стручне спреме, било је прописано да је запослени дужан да обавести послодавца, пре закључења уговора о раду, о свом здравственом стању или другим околностима које битно утичу на обављање послова за које заснива радни однос или могу да угрозе живот и здравље других лица, док је ставом 3. истог члана било прописано, да у случају да запослени не поступи у складу са ставом 1. овог члана, да послодавац може запосленом да откаже уговор о раду. Чланом 16. ставом 3. истог закона, било

је прописано да је запослени дужан, да приликом заснивања радног односа, послодавцу достави документа којима се доказује испуњеност услова за рад.

Чланом 15. тачком 3) Закона о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 75/14), који се примњује у време доношења спорног решења, прописано је да је запослени дужан да обавести послодавца о битним околностима које утичу или би могле да утичу на обављање послова утврђених уговором о раду. Чланом 26. ставом 1. истог закона прописано је да је кандидат дужан да, приликом заснивања радног односа, послодавцу достави исправе и друге доказе о испуњености услова за рад на пословима за које заснива радни однос, утврђених правилником. Чланом 179. ставом 3. тачком 6. прописано је, да послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који не поштује радну дисциплину, и то ако је дао нетачне податке који су били одлучујући за заснивање радног односа, а тачком 8. ако не поштује радну дисциплину прописану актом послодавца, односно ако је његово понашање такво да не може да настави рад код послодавца. Чланом 184. ставом 1. истог закона, прописано је да отказ уговора о раду из члана 179. тач. 1) и став 2. и 3. овог закона послодавац може дати запосленом у року од шест месеци од дана сазнања за чињенице које су основ за давање отказа, односно у року од годину дана од дана наступања чињеница које су основ за давање отказа.

Из напред цитираних одредби Закона о раду који се примењивао у време доношења решења број од 13.07.2001. године и закључења уговора о раду број од 17.01.2003. године и одредби Закона о раду који се примњује у време доношења спорног решења, следи да послодавац може отказати уговор о раду запосленом ако му је овај дао нетачне податке који су били одлучујући за заснивање радног односа.

Одлучујући подаци тичу се стручне спреме, односно образовања, радне способности, радног искуства, положеног стручног испита и других посебних услова од којих зависи успешно обављање послова за које се запослени прима. Када се има у виду напред утврђено чињенично стање, односно да је тужилац код туженог 1987. године засновао радни однос на неодређено време, са нижом стручном спремом, на пословима физичког радника, да је након што је туженом доставио фалсификовану диплому Машинске техничке школе „.....“ о стеченом IV степену стручне спреме образовног профила – електротехничар, тужени са тужиоцем закључивао уговоре о раду са анексима, на основу којих је тужиоцу поверавано обављање послова за које се захтева

завршена средња школа и IV степен стручне спреме, то је правилно одлучио првостепени суд када је одбио као неоснован захтев тужиоца, јер је тужилац користећи фалсификовану диплому поступио супротно наведеним одредбама Закона о раду, будући да је туженом доставио нетачне податке који су били одлучујући за прелазак са послова физичког радника на ново радно место, са којих разлога се понашање тужиоца који је туженом предао фалсификовану диплому о свом стручном образовању сматра таквим понашањем због којег тужилац не може да настави рад код туженог, односно његово понашање је такво да не може да настави рад код туженог, који отказни разлог је прописан чланом 179. ставом 3. тачком 6. и 8. Закона о раду, који се примењује у време доношња спорног решења, а који отказни разлог је био прописан и Законом о раду који се примењивао у време када је тужилац туженом предао фалсификовану диплому. Предаја неверодостојне (фалсификоване) дипломе о стеченом образовању као доказ о испуњености услова за заснивање радног односа, представља повреду радне обавезе у продуженом трајању, па како је тужилац предајом фалсификоване дипломе туженог довео у заблуду у погледу чињенице о стручној спреми и у заблуди га одржавао све време трајања радног односа закљученог на основу такве дипломе, то се ради о продуженој повреди радне обавезе и како је тужени, одмах по сазнању да је диплома тужиоца фалсификована, тужиоцу доставио упозорење о постојању разлога за отказ уговора о раду са анексима, а након тога отказао уговор о раду решењем од 03.07.2020. године, то, супротно наводима жалбе тужиоца, објективни рок за отказ уговора о раду прописан чланом 184. Закона о раду није протекао.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу 47 Гж1 1860/2022 од 15.07.2022. године)

Сентенцу приредила: Даниела Радовић, судија Апелационог суда у Нишу

ВЕЗАНОСТ ПАРНИЧНОГ СУДА ЗА ПРАВНОСНАЖНУ ОДЛУКУ ДОНЕТУ У УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

Парнични суд када у парници одлучује о тужбеном захтеву, везан је за правноснажну и коначну одлуку донету у управном поступку од стране надлежног органа која одлука је од прејудицијелног значаја за одлучивање у парници и није овлашћен да пренспитује законитост и правил-

ност управног решења. Са тим у вези, пропуст тужиоца као запосленог да у управном поступку изјави правни лек против решења о утврђивању коефицијента за обрачун и исплату плате, о чему је био поучен у правној поуци тог решења, не може се отклонити у парничном поступку позивањем на непосредну примену одредаба Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата у Управи за извршење кривичних санкција.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је код тужене био у радном односу на неодређено време, на пословима обезбеђења, у Одсеку притвора у Радни однос је засновао 2006. године. Решењем тужене бр. од 19.08.2020. године тужиоцу је престао радни однос закључно са 24.08.2020. године, отказом који је дао сам тужилац као државни службеник. Нов Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места ступио је на снагу 19.07.2019. године, у складу са којим је тужена донела решење бр. од 09.08.2019. године којим је тужиоца распоредила на послове обезбеђења, разврстано у звање “старији командир”, почев од 09.08.2019. године. Те послове је тужилац обављао и по претходном Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места. Решењем тужене бр. од 26.08.2019. године, које је донето у вези са решењем о распоређивању бр. од 09.08.2019. године, тужилац је разврстан у XIII платну групу, први платни разред, који припадају звању “командира”, а не звању “старијег командира” (XII платна група), те му је одређен основни коефицијент за обрачун и исплату плате у висини 1,70 уместо коефицијента 1,88 који припада XII платној групи и звању “старији командир”. Истим решењем тужилац је поучен о могућности изјављивања жалбе Жалбеној комисији Владе у року од 8 дана од дана пријема решења. Тужилац није изјављивао жалбу против тог решења, па је исто постало правноснажно (неспорно међу странкама). У периоду из тужбе тужиоцу је плата обрачунавана и исплаћивана по основном коефицијенту 1,70 сагласно решењу бр. од 26.08.2019. године. На основу резултата економско – финансијског вештачења утврђена је висина разлике плате од износа исплаћених по коефицијенту 1,70 до износа који би били исплаћени по коефицијенту 1,88 за период од августа 2019. године до августа 2020. године. Поднеском од 22.09.2021. године тужилац је прецизирао тужбени захтев у складу са налазом и мишљењем вештака.

Полазећи од овако утврђеног чињеничног стања, а с позивом на Уредбу о коефицијентима за обрачун и исплату плата у Управи за извршење кривичних санкција, првостепени суд је закључио да је тужбени захтев тужиоца основан, па га је усвојио одлучујући као у изреци првостепене пресуде под ставом један.

Међутим, по оцени Апелационог суда, првостепени суд је на основу чињеничног стања које је правилно и потпуно утврдио, извео погрешан закључак о основаности постављеног тужбеног захтева, због чега је првостепена пресуда услед погрешне примене материјалног права морала бити преиначена одбијањем тужбеног захтева, и то из следећих разлога:

Наиме, парнични суд када у парници одлучује о тужбеном захтеву, везан је за правноснажну и коначну одлуку донету у управном поступку од стране надлежног органа која одлука је од прејудисијелног значаја за одлучивање у парници и није овлашћен да преиспитује законитост и правилност управног решења. Под коначним решењем у управном поступку подразумева се првостепено решење против којег се не може изјавити жалба, али се може покренути управни спор. Сва другостепена решења су коначна у управном поступку. Под правноснажним решењем у управном поступку подразумева се решење против којег се не може изјавити жалба, нити покренути управни спор, односно против којег је безуспешно вођен управни спор, тј. против којег је тужба у управном спору одбијена. Такође, истеком рока за жалбу, правноснажно постаје и оно решење против кога жалба није изјављена.

У конкретном случају, тужиоцу је у периоду из тужбе плата обрачунавана и исплаћивана по основном коефицијенту 1,70 сагласно решењу бр. од 26.08.2019. године, које је истеком рока постало правноснажно, а имајући у виду да тужилац није изјављивао жалбу против тог решења (неспорно међу странкама). Насупрот закључку и правном схватању првостепеног суда, Апелациони суд је становишта да се пропуст тужиоца да против наведеног решења изјави правни лек у управном поступку, о чему је био поучен у правној поуци наведеног решења, не може отклонити у парничном поступку позивањем на непосредну примену одредаба Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата у Управи за извршење кривичних санкција. Ово из разлога што је парнични суд везан правноснажним решењем по коме је тужиоцу обрачунавана и исплаћивана плата у периоду из тужбе (решење бр. од 26.08.2019. године), на начин што није овлашћен да преиспитује његову

законитост. Због тога је Апелациони суд ожалбену пресуду преиначио тако што је тужбени захтев тужиоца одбио у целини као неоснован, одлучујући као у ставу првом изреке ове пресуде.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу 46 Гж1 236/2022 од 28.04.2022. године)

*Сентенцу приредио: Дамјан Мирчић, виши судијски сарадник
у Апелационом суду у Нишу*

ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА У ОБРАЗОВНО – ВАСПИТНОЈ УСТАНОВИ И ГРАНИЦЕ ДИСКРЕЦИОНОГ ОВЛАШЋЕЊА КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ПРИ ИЗБОРУ КАНДИДАТА

Члан 154 Закона о основама система образовања и васпитања
(“Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 – др. Закон)

Циљ расписивања конкурса ради заснивања радног односа у образовно – васпитној установи није само да се испоштује форма и избор кандидата изврши по процедури прописаној законом, већ да се избебре онај кандидат који ће најбоље и најуспешније обављати послове управљеног радног места.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, дана 21.02.2020. године директор тужене донео је одлуку о расписивању конкурса за пријем у радни однос на неодређено време једног наставника географије, са 90% радног времена, а 26.02.2020. године донео је решење о именовању трочлане конкурсне комисије, са задатком да спроведе поменути конкурс, који је објављен у листу “Послови” од2020. године. На конкурс су се јавила пет кандидата, међу њима и тужилац АА из Дана 18.05.2020. године одржана је седница конкурсне комисије на којој су након избора председника комисије, размотрене пријаве у смислу њихове благовремености и уредности (потпуности), о чему је сачињен записник. Конкурсна комисија сачинала је листу кандидата који испуњавају услове са пријем у радни однос по предметном конкурс, након чега је дана 10.06.2020. године сачинила записник о већању и гласању на коме је једногласно донето решење да се за радно место наставника географије изабере кандидат АБ, а потом је донела решење број од 03.07.2020. године о избору

наведеног кандидата. Решењем директора тужене број од 21.07.2020. године одбијена је као неоснована жалба тужиоца изјављена против решења конкурсне комисије број од 03.07.2020. године, а исто решење је потврђено.

На основу наведеног, правилно и потпуно утврђеног чињеничног стања првостепени суд је правилно одлучио када је ставом првим и другим изреке усвојио тужбени захтев тужиоца, а за свој закључак дао је разлоге које прихвата и Апелациони суд.

Наиме, одредбом члана 193. ст. 1 Закона о раду ("Сл. гласник РС" бр. 24/2005,... 113/2017) уређено је да се запосленом у писаном облику доставља решење о остваривању права, обавеза и одговорности, са образложењем и поуком о правном леку, осим у случају из члана 172. овог закона.

Из цитираног прописа произлази да се о правима, обавезама и одговорностима запосленог одлучује решењем. Одлучивање може отпочети тек пошто се утврде чињенице од значаја за примену релевантног прописа. Решење има увод, изреку и образложење. Увод садржи назив органа, пропис на основу кога се одлучује и датум одлучивања. Изрека садржи исказ о праву, обавези или одговорности запосленог (оно о чему се одлучује). Садржина одлуке зависи од права које се запосленом признаје, обавезе која се запосленом поверава, одговорности која се према запосленом утврђује. Образложење садржи разлоге којима се оправдава одлука. Оно треба да покаже да се одређено право или одређена обавеза, односно одговорност, може применити према одређеном запосленом. Њиме се одређени пропис конкретизује везивањем за одређни животни догађај и одређеног запосленог. Ако то везивање захтева да буду испуњени неки услови, из образложења мора бити видљиво да они постоје. Оно мора указати и на чињенице које омогућују конкретизацију прописа, а ако је потребно и оцену доказа (код одлуке о одговорности).

Одредбама Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" бр. 88/2017 и 27/2018 – др. закон) уређене су основе система предшколског, основног и средњег образовања и васпитања и образовања одраслих, и то: принципи, циљеви, исходи, стандарди образовања и васпитања, знања, вештина и ставова (компетенције), начин и услови за обављање делатности предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања и васпитања, врсте програма образовања и васпитања, оснивање, организација, финансирање и надзор над радом установа образовања и васпитања, као и друга питања од значаја за образовање и васпитање (чл. 1 ст. 1). Овим законом уређени су и радни односи запослених у установи (чл. 1 ст. 2).

Радни однос на неодређено време уређен је одредбама члана 154. истог закона, којим је у ставу 1 прописано да се пријем у радни однос на неодређено време врши на основу конкурса који расписује директор. Директор доноси одлуку о расписивању конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет страници Министарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом достављају установи (став 2). Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор. Обавезни члан комисије је секретар установе. Комисија има најмање три члана (став 3). Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139. овог закона, у року од осам дана од дана истека рока за пријем пријава (став 4). Кандидати из става 4. овог члана, који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолошку процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака (став 5). Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам дана од дана пријема резултата психолошке процене способности за рад са децом и ученицима (став 6). Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима са листе из става 6. овог члана и доноси решење о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима (став 7). Кандидат незадовољан решењем о изабраном кандидату може да поднесе жалбу директору, у року од осам дана од дана достављања решења из става 7. овог члана (став 8). Директор о жалби одлучује у року од осам дана од дана подношења (став 9). Кандидат који је учествовао у изборном поступку има право да, под надзором овлашћеног лица у јавној служби, прегледа сву конкурсну документацију, у складу са законом (став 10). Ако по конкурс у није изабран ниједан кандидат, расписује се нови конкурс у року од осам дана (став 11). Решење из става 7. овог члана оглашава се на званичној интернет страници Министарства, када постане коначно (став 12).

Имајући у виду цитиране прописе, Апелациони суд је становишта да циљ расписивања конкурса није само да се испоштује форма и избор кандидата изврши по процедури прописаној законом, већ да се изабере онај кандидат који ће најбоље и најуспешније обављати послове упражњеног радног места. Управо овај циљ, искључује самовољу и неуважавање објективних критеријума при вршењу дискреционог права конкурсне комисије приликом избора кандидата, јер је њено дискреционо право да по сопственом нахођењу изврши пријем кандидата у радни однос, ограничено не само условима конкурса, већ и интере-

сом установе, који захтева да буде изабран онај кандидат који ће најуспешније обављати послове радног места на које се бира. Због тога решење из члана 154. ст. 7 Закона о основама система образовања и васпитања мора садржати разлоге којима се конкурсна комисија руководила приликом избора кандидата, а из којих несумњиво произлази да ће изабрани кандидат успешније обављати послове конкретног радног места у односу на кандидате који нису изабрани, а били су учесници и испуњавали услове предметног конкурса.

У конкретном случају, конкурсна комисија је решењем бр. од 03.07.2020. године одлучила да се по конкурсном расписаном у листу “Послови” од 2020. године, у радни однос на неодређено време са 90% радног времена, на радно место наставника географије, прими АБ, мастер географ из Међутим, исто решење не садржи разлоге из којих би произлазило да ће наведени кандидат успешније обављати послове наставника географије у односу на неизабране кандидате међу којима се нашао и тужилац АА, а који су такође били учесници и испуњавали услове предметног конкурса. Изостанак таквих разлога представља повреду правила из цитираног чл. 193. ст. 1 Закона о раду у вези чл. 154. Закона о основама система образовања и васпитања и води закључку да је спорно решење бр. од 03.07.2020. године конкурсна комисија донела мимо граница дискреционе власти која није апсолутна, већ је ограничена начелима уговорног права, а нарочито начелом забране злоупотребе права. Како је конкурсна комисија своје дискреционо право да изврши избор између више кандидата који испуњавају услове конкурса, применила противно његовој природи и циљу (што је евидентно из садржине оспореног решења) и како тужена, сходно одредби чл. 231. Закона о парничном поступку, није доказала да је доношењем решења о избору напред означеног кандидата задовољен интерес тужене установе да буде изабран кандидат који ће најуспешније обављати послове радног места наставник географије, то је првостепени суд правилно поништио као незаконито решење бр. од 03.07.2020. године. Незаконитост тог решења повлачи за собом и незаконитост решења директора тужене бр. од 21.07.2020. године, те је и оно правилно поништено као незаконито, уз налагање туженој да поново спроведе избор и пријем кандидата по предметном конкурсном.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу 46 Гжс1 2275/2022 од 22.07.2022. године)

Сентенцу приредили: Биљана Стаменковић, судија Апелационог суда у Нишу и Дамјан Мирчић, виши судијски сарадник у Апелационом суду у Нишу

**ОДЛУКА УСТАВНОГ СУДА ПО ИЗЈАВЉЕНОЈ УСТАВНОЈ
ЖАЛБИКАО ПРЕТХОДНО ПИТАЊЕ У РАДНОМ СПОРУ
И РАЗЛОГ ЗА ПРЕКИД ПАРНИЧНОГ ПОСТУПКА**

(чл. 223. ст. 1 тач. 1 Закона о парничном поступку)

Одлучивање о уставној жалби по правилима из чл. 82 – 92 Закона о Уставном суду, коју је тужени као бивши запослени поднео Уставном суду против пресуде Врховног касационог суда, на којој је тужилац као послодавац засновао тужбени захтев у радном спору покренутом против запосленог ради наплате новчаног потраживања, јесте претходно питање од чијег претходног решавања зависи одлука о тужбеном захтеву у том радном спору.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужена АА била је у радном односу код тужиоца на пословима безбедности и здравља на раду и лабораторијских анализа, на неодређено време, на основу уговора о раду од 06.11.2013. године. Решењем тужиоца од 08.12.2014. године туженој АА отказан је уговор о раду, те јој је радни однос престао 31.12.2014. године због престанка потребе за њеним радом, услед технолошких, економских и организационих промена, а које решење је као незаконито поништено пресудом Основног суда у Нишу П1 бр. од 13.09.2016. године и обавезан тужилац “ББ” д.о.о. Ниш да тужену АА врати на рад и обезбеди јој сва права из радног односа. Наведена пресуда потврђена је пресудом Апелационог суда у Нишу Гж1 бр. од 03.10.2017. године. Добровољно поступајући по правноснажној и извршној судској пресуди од 13.09.2016. године, туженој АА тужилац је исплатио укупан износ од 1.732.604,11 динара (исплате су вршене у више наврата током 2017, 2018. и 2019. године), и то на име трошкова парничног поступка, на име штете у висини изгубљених нето зарада, на име пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, на име камате и на име паушалне накнаде штете (уместо враћања тужене АА на рад), а све у појединачним износима ближе специфицираним у тужби, који нису били спорни међу странкама. Пресудом Врховног касационог суда Рев2 бр. од 27.03.2019. године, преиначене су пресуде нижестепених судова, и то пресуда Апелационог суда у Нишу Гж1 бр. од 03.10.2017. године и пресуда Основног суда у Нишу П1 бр. од 13.09.2016. године, тако што је тужбени захтев тужене АА одбијен као неоснован, као и захтев за накнаду трошкова парничног поступка, и иста обаве-

зана да тужиоцу “ББ” ДОО Ниш накнади трошкове поступка. Ослањајући се на наведену ревизијску пресуду, а с позивом на правила из чл. 210 ЗОО која уређују стицање без основа, тужилац је тужбом од 31.08.2020. године тражио повраћај свих новчаних износа које је туженој АА добровољно платио на основу правноснажне и извршне пресуде Основног суда у Нишу П1 бр. од 13.09.2016. године, са законском затезном каматом од дана подношења тужбе до коначне исплате. Против пресуде Рев2 бр. од 27.03.2019. године, тужена АА изјавила је уставну жалбу дана 19.12.2019. године.

На основу наведеног, правилно и потпуно утврђеног чињеничног стања првостепени суд је правилно одлучио у ставу другом изреке ожалбене пресуде када је одбио тужбени захтев у делу којим је тражена исплата износа од 480.773,30 динара са затезном каматом почев од 31.08.2020. године, правилно налазећи да је основан приговор недостатка пасивне стварне легитимације изјављен од стране тужене АА. За своју одлуку дао је јасне и правилне разлоге које прихвата и Апелациони суд.

Због тога је првостепена пресуда као правилна и законита потврђена у ставу другом изреке.

Међутим, закључак првостепеног суда за одлуку из става првог изреке побијане пресуде не може се за сада прихватити као правилан и законит, јер првостепена пресуда у том делу не садржи разлоге о одлучним чињеницама, а дати разлози су нејасни и противуречни, што представља недостатак због кога се не може испитати. На тај начин је првостепени суд учинио битну повреду одредаба парничног поступка из чл. 374. ст. 2 тач. 12 Закона о парничном поступку, на које повреде жалба тужене основано указује, а због чега је ожалбена пресуда морала бити укинута у том ставу изреке.

Одредбом чл. 12. Закона о парничном поступку, је прописано да ако одлука зависи од претходног питања да ли постоји неко право или правни однос, а о том питању још није донео одлуку суд или други надлежни орган (претходно питање), суд може сам да реши то питање ако посебним прописима није другачије предвиђено. Одредбом чл. 223. ст. 1 тач. 1 Закона о парничном поступку је прописано да суд може да одреди прекид поступка, ако је одлучио да сам не решава о претходном питању (чл. 12).

Из цитираних законских одредби произилази да је услов за одређивање прекида поступка постојање претходног правног питања о коме надлежни орган није донео одлуку, а које је од битног значаја за одлучивање о тужбеном захтеву.

У конкретном случају, тужбени захтев тужиоца суштински је заснован на пресуди Врховног касационог суда Рев 2 бр. од 27.03.2019. године и тврдњи да је доношењем те пресуде отпао основ по коме су утужена потраживања плаћена туженој АА (чл. 210. ЗОО). Питање опстанка наведене пресуде у правном промету зависи од одлуке Уставног суда по уставној жалби коју је тужена изјавила против исте пресуде дана 19.12.2019. године, а о којој Уставни суд још увек није одлучио по правилима из чл. 82 – 92 Закона о Уставном суду. Због тога се не може прихватити као јасан и правним аргументима образложен став првостепеног суда да одлучивање о поднетој уставној жалби није претходно питање у односу на питање постојања или непостојања основа по коме су туженој АА вршена спорна плаћања током 2017, 2018. и 2019. године, а који основ се огледао у правноснажној и извршној пресуди Основног суда у Нишу П1 бр. од 13.09.2016. године.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу 46 Гж1 3471/2021 од 24.02.2022. године)

Сентенцу приредила: Биљана Стаменковић, судија Апелационог суда у Нишу

ОБЈЕКТИВНА ОДГОВОРНОСТ ПОСЛОДАВЦА ЗА НАСТАЛУ ШТЕТУ

Закон о раду
Члан 164.

Оспособљеност запосленог за послове на ангажованом радном месту и обезбеђена заштитна средства и опрема коју при томе користи, не искључује одговорност послодавца за штету коју тај запослени претрпи повредом од опасне ствари.

Из образложења:

Одредбом члана 173. Закона о облигационим односима, прописано је да штета настала у вези са опасном ствари, односно опасном делатношћу сматра се да потиче од те ствари, односно делатности, изузев ако се докаже да оне нису биле узрок штете, а чланом 174. истог закона да за штету од опасне ствари одговара њен ималац, а за штету од опасне делатности одговара лице које се њом бави.

Према прописима о безбедности и здрављу на раду, послодавац је дужан да рад организује и мере заштите на раду спроведе тако да запослени уз нормалну пажњу може да обавља рад без опасности по свој живот и здравље. Пропуштање ове дужности повлачи одговорност послодавца за штету која запосленом услед тога настане. Наведеној обавези одговара право запосленог на безбедност и заштиту живота и здравља на раду.

У конкретном случају, тужила је у моменту повређивања испуњавајући своје радне задатке радила у кухињи, које радно место је место са повећаним ризиком од повређивања, па је посао који је обављала имао карактеристике делатности код које није искључена могућност од повређивања. Иако је тужени тужили обезбедио лична заштитна средства за безбедан рад, до повреде тужиле је дошло услед сечења поврћа, у конкретном случају целера уз коришћење професионалног ножа, који сам по себи представља опасну ствар, из чега произлази објективна одговорност туженог (без обзира на кривицу) за штету коју је тужила претрпела.

Опасна ствар мора бити надгледана или употребљавана са највећом пажњом, па у конкретном случају нож који је тужила користила критичном приликом, свакако представља опасну ствар, како је то правилно закључио и првостепени суд, јер је створен ризик за околину при њеној употреби, приликом коришћења, због чега за штету одговара, без обзира на кривицу њен ималац. Чињеница да је актом о процени ризика код туженика утврђена која радна заштитна средства су предвиђена за радно место тужиле, да је тужила имала заштитну опрему, да је тужени набавио више врста гумених рукавица као и да је тужила оспособљена за безбедан и здрав рад, не искључују могућност настанка повреде при употреби оваквих ствари и чињеницу да је управо тужила радила у кухињи користећи опасну ствар од које је постојала значајна могућност од повређивања, те је до тога и дошло. Самим тим последично се не искључују постојање објективне одговорности послодавца, те су по становишту Апелационог суда жалбени наводи туженог којим истиче искључиву одговорност тужиле неосновани.

Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж1 2037/2022 од 12.05.2021. године

Сентенцу приредила судијски помоћник Невена Петковић

**ПОНАШАЊЕ ЗАПОСЛЕНОГ
КАО РАЗЛОГ ЗА ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ**

Закон о раду

Члан 179. став 2. тачка 1.

Поступање супротно издатом реверсу од стране послодаваца представља прекорачење датих овлашћења од стране запосленог и поступање мимо прописане процесуре, чиме је испуњен услов за отказ уговора о раду.

Из образложења:

Одредбом члана 179. став 2. тачка 1. Закона о раду (“Службени гласник РС”, број. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014.....95/2018) прописано је да послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који својом кривицом учини повреду радне обавезе и то ако несавесно или немарно извршава своје обавезе.

Одредбом члана 180. став 1. и 2. Закона о раду, прописано је да је послодавац дужан да пре отказа уговора о раду у случају из члана 179. став 2. и 3. Овог закона, запосленог писаним путем упозори на постојање разлога за отказ уговора о раду и да му остави рок од најмање осам дана од дана достављања упозорења да се изјасни на наводе из упозорења. У упозорењу из претходног става овог члана, послодавац је дужан да наведе основ за давање отказа, чињенице и доказе који указују на то да су се стекли услови за отказ и рок за давање одговора на упозорење.

Чланом 16. став 2. тачка 1. Уговора о раду, прописано је да послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који својом кривицом учини повреду радне обавезе и то ако несавесно или немарно извршава радне обавезе.

Да би отказни разлог могао бити примењен, послодавац утврђује чињенице за које закон везује њихов настанак као и доказе на којима заснива отказни разлог. Суд у спору из радног односа, испитује законитост решења о отказу уговора о раду, са становишта правилне примене материјалног права у погледу повреде правила поступка и утврђеног чињеничног стања из оспореног решења.

У складу са цитираним одредбама закона, у упозорењу на постојање разлога за отказ уговора о раду због повреде радне обавезе, послодавац мора

навести чињенични основ који представља повреду радне обавезе и основ за отказ уговора о раду, уз прецизно навођење времена, места и радње извршења повреде радне обавезе, јер је смисао самог упозорења да се запосленом стави до знања да је изазвао настанак отказног разлога, те да му се омогући да се о томе изјасни. С тим у вези, у конкретној правној ствари, тужилац је као пословођа код туженог послодавца имао обавезу да за врсту посла који обавља предвиди и обезбеди неопходан алат и материјал, да попуни и сачини реверс како би запослени Н.Н. као лице коме је било поверено извођење тих радова, изашао на терен ради извршавања радног задатка. Након сачињавања реверса, тужилац је, уместо да изда налог да се три канте жуте боје прибаве из магацина, наложио свом подређеном Н.Н. да оде до гараже и да канте са бојом, које се налазе у гаражи, узме и утовари у камион предузећа, заједно са бојом за бетон и поред указивања подређеног да наведена радња није у складу са издатим реверсом. И поред тог указивања, тужилац га је путем телефона обавестио да канте превезе у “xxx”, приватну радњу супруге тужиоца. Надређени пословођа М.М. је извршење радње прекинуо налагањем да се канте са фарбом из објекта супруге тужиоца врате у камион.

Самим тим у конкретном случају и нема услова за поништај решења о отказу уговора о раду, како правилно закључује првостепени суд. Законитост побијаног отказног решења правилно је цењена од стране првостепеног суда на основу одредби важећег Закона о раду, а понашање тужиоца је било супротно опису послова његовог радног места и правилима струке, при чему је био свестан својих пропуста у раду. Наведене чињенице, првостепени суд је закључио брижљивом оценом сваког доказа појединачно, узимајући у обзир и изјаве сведока и суочење истих, те са наведеног разлога нису основани ни жалбени наводи тужиоца да суд поклања веру сведоцима само на основу усменог казивања, обзиром да су сведоци ти у чијим исказима су утврђене одлучујуће чињенице у конкретном случају.

Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж1 4093/2021 од 13.01.2022.године

Сентенцу приредила судијски помоћник Невена Петковић

НЕПОШТОВАЊЕ РАДНЕ ДИСЦИПЛИНЕ КАО РАЗЛОГ ЗА ОТКАЗ УГОВОРА О РАДУ

Закон о раду

Члан 179. став 3. тачка 8.

Свесним поступањем у непоштовању радне дисциплине, у смислу неоправданог изостајања са посла, запослени је испољио вољу за наступање последице престанка радног односа.

Из образложења:

Одредбом члана 179. став 3. тачка 8. Закона о раду („Службени гласник РС“ бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014) прописано је послодавац може да откаже уговор о раду запосленом који не поштује радну дисциплину прописану актом послодавца, односно ако је његово понашање такво да не може да настави рад код послодавца.

У конкретној правној ствари тужилац је својим неоправданим изостанцима са посла дана 21.08.2020. године и 05.09.2020. године проузроковао доношење упозорења од стране послодавца, сходно цитираном члану 180. Закона о раду, у коме је наведен основ за давање отказа због учињене повреде радне дисциплине, да је изостајање било неоправдано као и да постоје чињенице и докази који указују на то да су се стекли услови за отказ уговора о раду, на које упозорење се тужилац као запослени није изјаснио иако је исто било истакнуто на огласној табли у периоду од 19.10.2020. године до 24.10.2020. године. Како је тужилац наставио са изостајањем са посла и 16.10.2020. године, 17.10.2020. године и 24.10.2020. године, послодавац је спровео дисциплински поступак и донео решење дана 27.10.2020. године о изрицању дисциплинске мере односно опомене са најавом отказа уговора о раду које је тужилац одбио да прими, те наставио са неоправданим изостајањем са посла и 07.11.2020. године, 13.11.2020. године и 14.11.2020. године.

У поступку пред првостепеним судом утврђено је да је тужилац у већ наведеним датумима изостајао са посла, као и да за недоласке није имао оправдање. Имајући у виду чињеницу да је послодавац у конкретној ситуацији поступио у свему према одредбама Закона о раду узимајући у обзир повреду радне дисциплине које је тужилац извршио, као и чињеницу да наведене недоласке није оправдао, то је по оцени Апелационог суда правилан закључак првостепеног суда да је тужилац у конкретном случају извршио повреду

радне дисциплине. Наиме, поштовање радне дисциплине подразумева обавезу запосленог да савесно и одговорно обавља послове на којима ради и да поштује организацију рада, што подразумева обавезу поштовања радног времена, затим савесно, одговорно и благовремено испуњавање обавеза свог радног места, као и одговарајуће понашање на раду и у вези са радом, према послодавцу и према осталим запосленима и према имовини послодавца.

Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж1 1635/2022 од 02.09.2022.године

Сентенцу приредила судијски помоћник Невена Петковић

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ НА РАДУ

Закон о забрани дискриминације

Члан 16. став 1.

Нема дискриминације запосленог коме је право на коришћење службеног мобилног телефона престало његовим распоређивањем код послодавца, на пословима који не подлежу оваквом овлашћењу.

Из образложења:

Основну карактеристику дискриминације представља неоправдано прављење разлике, па правилна примена одредби чл.16.став 1.Закона о забрани дискриминације, којим је овај институт регулисан у области рада, подразумева утврђење, постојања понашања којим се нарушава давање једнаких могућности и једнаких услова за уживање свих права из области рада, због којих се запослени ставља у неповољнији положај у односу на остале запослене, а све с обзиром на одређена лична својства. У конкретној правној ствари тужени је донео Правилник о коришћењу службених мобилних телефона дана 16.01.2014. године, којим је регулисано да право на њихово коришћење имају запослени у Општинској управи, који су таксативно наведени, руководиоци одељења, служби и одсека, секретар Општинског већа, запослени распоређени на инспекторским пословима, возачи и матичари, а на основу ког Правилника је тужила и задужила спорну опрему док је била на једној од наведених функција односно на месту шефа одељења за локалне пореске

послове до 04.08.2016. године. Како је у међувремену тужила премештена на радно место израде планских докумената при Одељењу за привреду, водoprивреду, друштвене делатности, приватно предузетништво и финансије Општинске управе Општине В....., то правилно закључује првостепени суд да је отпао правни основ по којем би она имала права на наведену опрему. Предметно решење од 17.08.2016. године, на основу кога тужили престаје право на коришћење службеног мобилног телефона и лаптоп рачунара, је донесено у складу са већ наведеним Правилником а исто решење тужила у управном поступку није побијала обзиром да је имала право на изјављивање правног лека против спорног решења.

Да би се остварило право на судску заштиту од дискриминације потребно је да се утврди неједнако поступање у односу на неко лично својство, а уколико се неједнако поступање утврди, потребно је да постоји објективно и разумно оправдање за неједнако поступање, које се процењује по томе да ли се учињеним разликовањем тежило легитимном циљу, ако такав циљ постоји и да ли постоји однос сразмерности између учињеног разликовања и циља којем се тежило. Правилно првостепени суд образлаже, супротно наводи-ма жалбе, да тужила није доказала вероватним да у конкретној чињенично правној ситуацији постоји основаност њеног тужбеног захтева, јер није навела који су то запослени стављени у повољнији положај у односу на њу, као и да ју је самим чином одузимања права на мобилни телефон и лаптоп тужени ставио у неповољнији положај од запослених из идентичне ситуације. Такође, од стране тужилачке стране није пружен било какав доказ да је то учињено, како тужила тврди, из разлога њених политичких убеђења.

Пресуда Апелационог суда у Нишу Гж1 1144/2022 од 07.04.2022.године

Сентенцу приредила судијски помоћник Невена Петковић

ПОСЕДОВАЊЕ СТАТУСА ЗАПОСЛЕНОГ КАО УСЛОВ ЗА СТИЦАЊЕ ПРАВА НА ЈУБИЛАРНУ НАГРАДУ

Док је у радном односу, запослени према послодавцу има законом прописана права, и то на одговарајућу зараду, безбедност и здравље на раду, здравствену заштиту, заштиту личног интегритета, достојанство

личности и друга права у случају болести, смањења или губитка радне способности и старости, материјално обезбеђење за време привремене незапослености, као и право на друге облике заштите, у складу са законом и општим актом, односно уговором о раду. Статус запосленог се губи престанком радног односа, по основима и на начин који су предвиђени законом. Са губитком тог статуса, престају и наведена права.

Из образложења:

Према чињеничном стању на коме је заснована ожалбена пресуда, тужилац је код туженог био у радном односу на пословима самосталног референта, почев од 01.08.1973. године. Дана 01.08.2013. године, тужилац је навршио 40 година рада. У то време у примени је био Колективни уговор ЕПС-а од 04.02.2013. године, који је регулисао право на јубиларну награду за 10, 20 и 30 година рада проведених код послодавца, док исто право није регулисао за 40 година рада код послодавца. Дана 28.01.2015. године ступио је на снагу Посебан колективни уговор за Електропривреду Србије који је у чл. 49 регулисао право запослених на јубиларну награду и за 40 година рада проведених код послодавца. Тужиоцу је код туженог радни однос престао закључно са 06.03.2015. године због одласка у старосну пензију, на основу решења туженог од 26.02.2015. године. Дана 03.06.2015. године, директор туженог донео је одлуку број 7933/1 о исплати јубиларних награда запосленима са увећаним стажом осигурања, којом је поред осталог предвидео (у тачки 1) да се запосленима који су остварили право на јубиларну награду пре ступања на снагу ПКУ за Електропривреду Србије ("Сл. гласник РС" бр. 15/15) за време проведено на раду код послодавца, у које се урачунава пун стаж осигурања, изврши исплата јубиларних награда, и то за 10 година укупног рада, у висини једне зараде; за 20 година укупног рада, у висини две зараде; за 30 година укупног рада, у висини три зараде; и за 40 година укупног рада, у висини четири зараде. На основу ове одлуке, тужени је групи запослених исплатио јубиларну награду, дана 26.06.2015. године. Тужилац је туженом поднео два захтева за исплату јубиларне награде за 40 година рада, један захтев у јулу, а други захтев у децембру 2015. године. Тужба у овој правној ствари поднета је 25.02.2016. године.

Полазећи од овако утврђеног чињеничног стања, првостепени суд је закључио да је тужбени захтев тужиоца основан, па је исти усвојио одлучујући као у изреци првостепене пресуде.

Међутим, по оцени Апелационог суда, првостепени суд је на основу чињеничног стања које је правилно и потпуно утврдио, извео погрешан закључак о основаности постављеног тужбеног захтева, због чега је првостепена пресуда морала бити преиначена одбијањем тужбеног захтева и то из следећих разлога:

Чланом 5. став 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/2005,... 75/2014) запослени је појмовно одређен као физичко лице које је у радном односу код послодавца.

Према цитираној законској одредби, запослени је свако физичко лице које је засновало радни однос. Ако га је засновало, оно мора да испуњава општи услов и посебне услове. Општи услов тиче се узраста од 15 година, док се посебни услови утврђују актом о организацији и систематизацији послова. Статус запосленог стиче се без обзира на пол, рођење, расу, боју коже, старост, трудноћу, здравствено стање, инвалидност, националну припадност, вероисповест, брачни статус, породичне обавезе, сексуално опредељење, политичко или друго уверење, социјално порекло, имовно стање, члановство у политичким организацијама или синдикатима или неко друго лично својство. Док је у радном односу, запослени према послодавцу има законом прописана права, и то на одговарајућу зараду, безбедност и здравље на раду, здравствену заштиту, заштиту личног интегритета, достојанство личности и друга права у случају болести, смањења или губитка радне способности и старости, материјално обезбеђење за време привремене незапослености, као и право на друге облике заштите, у складу са законом и општим актом, односно уговором о раду (чл. 12 став 1). Такође, има и одређене обавезе (дужности), и то: да савесно и одговорно обавља послове на којима ради; да поштује организацију рада и пословања код послодавца, као и услове и правила послодавца у вези са испуњавањем уговорних и других обавеза из радног односа; да обавести послодавца о битним околностима које утичу или би могле да утичу на обављање послова утврђених уговором о раду; и да обавести послодавца о свакој врсти потенцијалне опасности за живот и здравље и настанак материјалне штете (члан 15).

Статус запосленог се губи престанком радног односа, по основима и на начин који су предвиђени законом. Са губитком тог статуса, престају и напред наведена права. Према члану 175. тачка 2 Закона о раду, радни однос престаје кад запослени наврши 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања, ако се послодавац и запослени друкчије не споразумеју.

У конкретном случају, тужилац је јубиларних 40 година рада код туженог као послодавца навршио дана 01.08.2013. године, када је у примени био Колективни уговор ЕПС-а од 04.02.2013. године, који је регулисао право на јубиларну награду за 10, 20 и 30 година рада проведених код послодавца, док исто право није регулисао за 40 година рада код послодавца. У тој јубиларној 2013. години тужилац није имао право на признавање и исплату јубиларне награде, услед непостојања правог основа који би то право регулисао (за 40 година рада код послодавца).

Дана 28.01.2015. године ступио је на снагу Посебан колективни уговор за Електропривреду Србије (“Сл. гласник РС” бр. 15/15) који је у чл. 49 регулисао право запослених на јубиларну награду и за 40 година рада проведених код послодавца.

Тужиоцу је код туженог радни однос престао закључно са 06.03.2015. године због одласка у старосну пензију, на основу решења туженог од 26.02.2015. године заснованог на напред цитираном чл. 175. тач. 2 Закона о раду. Дана 03.06.2015. године, директор туженог донео је одлуку број 7933/1 о исплати јубиларних награда запосленима са увећаним стажом осигурања, којом је поред осталог предвидео (у тачки 1) да се запосленима који су остварили право на јубиларну награду пре ступања на снагу ПКУ за Електропривреду Србије за време проведено на раду код послодавца, у које се урачунава пун стаж осигурања, (ретроактивном применом тог ПКУ) изврши исплата јубиларних награда, и то за 10 година укупног рада, у висини једне зараде; за 20 година укупног рада, у висини две зараде; за 30 година укупног рада, у висини три зараде; и за 40 година укупног рада, у висини четири зараде. Овом одлуком је тужени практично дозволио ретроактивну примену ПКУ за Електропривреду Србије из јануара 2015. године, у односу на запослене (а не и бивше запослене, односно лица којима је радни однос престао) који су право на исплату јубиларне награде стекли пре ступања на снагу истог ПКУ.

Имајући у виду да на дан 03.06.2015. године, када је директор туженог донео одлуку број 7933/1 о исплати јубиларних награда запосленима са увећаним стажом осигурања, тужилац није имао статус запосленог у смислу напред цитираног чл. 5. ст. 1 Закона о раду (радни однос му је престао дана 06.03.2015. године због одласка у старосну пензију), то није имао основа да позивајући се на исту одлуку којом је дозвољена ретроактивна примена чл. 49. ПКУ за Електропривреду Србије (“Сл. гласник РС” бр. 15/15) тражи исплату јубиларне награде за 40 година

рада проведених у радном односу код послодавца, у висини која није била спорна међу странкама. Ово из разлога што поменуто право тужилац није могао да стекне, јер је статус запосленог изгубио пре 03.06.2015. године, односно пре него што је тужени као послодавац дозволио ретроактивну примену чл. 49. ПКУ за Електропривреду Србије из 2015. године. Због тога је преиначењем првостепене пресуде његов тужбени захтев одбијен у целини као неоснован.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу 46 Гж1 2013/2022 од 26.05.2022. године)

Сентенцу приредили: Биљана Стаменковић, судија Апелационог суда у Нишу и Дамјан Мирчић, виши судијски сарадник у Апелационом суду у Нишу

ПОСТОЈАЊЕ ПРАВНОГ ИНТЕРЕСА КАО ОПШТА ПРОЦЕСНА ПРЕТПОСТАВКА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ СУДСКЕ ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ

Постојање правног интереса за остваривање судске правне заштите представља општу процесну претпоставку за сваки тужбени захтев ма каквог карактера он био – кондемпнаторног, деклараторног или конститутивног. Допуштеност сваке парнице зависи од постојања правног интереса, а изостанак правног интереса повлачи недопуштеност вођења парнице и доношења мериторне одлуке.

Из образложења:

Према чињеничном стању садржаном у списима предмета, решењем Скупштине општине од 20.10.2010. године тужени АА именован је на место директора Центра за социјални рад општине, на мандатни период од четири године, односно до 20.12.2014. године. Дана 10.01.2011. године, на основу решења о именовању, тужени АА је са туженим Центром за социјални рад општине закључио уговор о раду. Дана 24.08.2013. године тужени АА требало је да наврши 65 година живота и испуни услов за престанак радног односа основом члана 175 тачка 2 Закона о раду. Пре тог датума одржана је седница Управног одбора туженог Центра за социјални рад општине, дана 04.07.2013. године, на којој је постигнута саглас-

ност да се туженом АА продужи радни однос до истека његовог мандата, односно до 20.12.2014. године. Споразум о продужењу радног односа број закључен је дана 10.07.2013. године, између туженог АА са једне стране и председника УО Центра за социјални рад општине са друге стране. Исти је достављен Скупштини општине дана 17.09.2013. године, која је на седници од 18.09.2013. године донела решење којим се тужени АА разрешава са дужности директора Центра за социјални рад општине Дана 27.09.2013. године, на седници УО Центра за социјални рад општине донета је одлука о раскиду наведеног споразума о продужењу радног односа бр. од 10.07.2013. године. Ради поништаја решења СО од 18.09.2013. године о разрешењу, тужени АА је пред Вишим судом у повео парницу против Општине која је правноснажно завршена усвајајућом пресудом тог суда П бр. од 31.03.2015. године (у делу којим је тражен поништај наведеног решења о разрешењу), а која је постала правноснажна дана 10.09.2015. године. Истом пресудом су туженом АА досуђени трошкови парничног поступка у износу од 131.000,00 динара, ради чије наплате је он поднео предлог за извршење Основном суду у дана 15.10.2015. године, који је усвојен решењем тог суда 2 И бр. од 16.10.2015. године, уз одређивање трошкова извршења у износу од 19.620,00 динара. Међу странкама није било спорно да је наведено извршење спроведено, те да је тужени АА (као извршни поверилац), од тужиоца Општине (као извршног дужника), принудно наплатио поменуте трошкове парничног и извршног поступка. Предметном тужбом од 20.09.2017. године тужилац Општина тражио је утврђење да је ништав и без правног дејства Споразум о продужењу радног односа број од 10.07.2013. године, закључен између туженог АА и туженог Центра за социјални рад општине Одговором на тужбу тужени АА оспорио је основаност тужбеног захтева, а тужени Центар за социјални рад општине признао је тужбени захтев.

На основу утврђеног чињеничног стања, првостепени суд је без претходне оцене испуњености услова за мериторно одлучивање о предмету спора, оценио неоснованим тужбени захтев тужиоца и исти одбио одлучујући као у изреци ожалбене пресуде под ставом један.

Међутим, закључак првостепеног суда за сада се не може прихватити као правилан и законит, јер првостепена пресуда не садржи разлоге о одлучним чињеницама, а дати разлози су нејасни и противуречни, што представља недостатак због кога се не може испитати. На тај начин је првостепени суд

учинио битну повреду одредаба парничног поступка из чл. 374 ст. 2 тач. 12 ЗПП, на коју повреду жалба тужиоца основано указује. Ова повреда је даље довела до тога да се првостепена пресуда у поступку њене жалбене контроле не може испитати са становишта правилне примене материјалног права, а из разлога што је чињенично стање остало погрешно и непотпуно утврђено, због чега је иста морала бити укинута.

Наиме, парнични поступак покреће се тужбом (чл. 191 ЗПП), која представља резултат страначке диспозиције и правну радњу у којој се истиче захтев за пружање правне заштите одређеног садржаја. Ту заштиту тужилац тражи од суда према туженом у односу на кога тврди да се према њему (тужиоцу) налази у одређеној грађанскоправној обавези коју неће добровољно да испуни (кондемнаторна тужба), или у односу на кога тврди да је у своју корист овлашћен тражити ауторитативно утврђење садржаја неког правног односа (деклараторна тужба), или да произведе одређене промене у правном односу (конститутивна тужба). Постојање правног интереса за остваривање судске правне заштите представља општу процесну претпоставку за сваки тужбени захтев ма какавог карактера он био – кондемнаторног, деклараторног или конститутивног. Допуштеност сваке парнице зависи од постојања правног интереса, а изостанак правног интереса повлачи недопуштеност вођења парнице и доношења мериторне одлуке. Постојање правног интереса за вођење конкретне парнице представља, дакле, апсолутну процесну претпоставку о чијем постојању суд води рачуна по службеној дужности. За допуштеност сваког конкретног захтева за пружање судске заштите, а како би суд био дужан да о постављеном тужбеном захтеву расправља и донесе мериторну одлуку, тужилац мора изнети тврдњу да тражи правну заштиту одређеног садржаја (кондемнаторни, утврђујући или преображајни захтев), јер је његово субјективно право повређено или угрожено, и учинити вероватним да ће његов тужбени захтев, ако буде усвојен, за њега представљати остварење одређене правне користи, коју без повољне судске одлуке не би могао остварити. Дакле, суд у сваком посебном случају може да одбије да пружи заштиту парничној странци која нема правни интерес за подношење конкретне тужбе, јер се право на правну заштиту може признати само лицу које очекује одређену правну корист коју на други начин не може остварити. Уколико је наведена процесна претпоставка испуњена, суд ће приступити мериторном одлучивању о предмету спора, тако што ће тужбени захтев ус-

војити или одбити. У супротном, одбациће тужбу, без упуштања у меритум спора.

У конкретном случају, а у смислу претходно реченог, првостепени суд је пропустио да утврди у чему се састоји правни интерес тужиоца за подношење предметне тужбе, у ситуацији постојања одлуке УО Центра за социјални рад општине од 27.09.2013. године којом је раскинут спорни споразум број од 10.07.2013. године о продужењу радног односа (а која одлука се помиње у образложењу пресуде Апелационог суда у Нишу Гж1 бр. од 10.09.2015. године), и у ситуацији када је туженом АА истекао мандат 20.12.2014. године и када је он 24.08.2013. године испунио услов да му радни однос престане основом члана 175 тачка 2 Закона о раду (испуњењем услова за старосну пензију).

Наведени пропуст ће првостепени суд отколнити у поновном поступку, тако што ће ценити постојање тужиоачевог правног интереса за вођење предметне парнице, па уколико нађе да исти не постоји, решењем ће одбацити тужбу без упуштања у мериторно одлучивање о предмету спора. Супротно томе, уколико нађе да правни интерес постоји (и у чему се састоји, односно коју конкретну правну корист тужилац жели да оствари предметном тужбом), првостепени суд ће предметни спор решити одговарајућом мериторном одлуком.

Пошто отклони битну повреду одредаба парничног поступка из чл.374 ст.2 тач.12 ЗПП и поступи у складу са напред изнетим примедбама, првостепени суд ће бити у прилици да у овој парници донесе правилну и закониту одлуку, засновану на потпуним, јасним и непротивречним разлозима.

(Из решења Апелационог суда у Нишу 47 Гж1 1160/2021 од 04.11.2021. године)

Сентенцу приредили: Даниела Радовић, судија Апелационог суда у Нишу и Дамјан Мирчић, виши судијски сарадник у Апелационом суду у Нишу

ПРАВА КОЈА ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ОБАВЉЕНОГ ФАКТИЧКОГ РАДА

(члан 60 став 4 Устава Републике Србије)

Право на правичну накнаду за обављени рад могу остварити и лица која немају статус запослених и нису у радном односу код послодавца, али искључиво под условом да су била у државини фактичког рада код послодавца, односно да су тај рад обавили, и да је њихов фактички радни ангажман код послодавца имао обележја и карактеристике радног односа у квалитативном смислу. Поред права на правичну накнаду за обављени рад, запослени који је био у државини рада код послодавца са одликама радног односа, чији је дефект исказан само у одсуству акта о заснивању радног односа, има право и на уплату доприноса за обавезно социјално осигурање и исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада.

Из образложења:

Према чињеничном стању на коме је заснована побијана пресуда, тужилца је у временском периоду од 12.09.2018. до 12.10.2018. године, према распореду смена и радног времена који је важио за све запослене који су у радном односу код туженог, била присутна у СТР “.....” и обављала послове који спадају у делатност туженог – рад за касом, сипање горива и рад у кафићу у оквиру СТР “.....” У истом временском периоду тужилца је редовно долазила у просторије туженика ради обављања наведених послова, послове је обављала пуно радно време, њено радно ангажовање било је континуирано и фиксно, третирана је као запослени у смислу уписивања у евиденцију туженог о присутности на раду, обављала је рад уз присуство других запослених, али и самостално, а приликом обављања послова имала је овлашћење да самостално брине о новцу који у току рада задужује и да исти предаје самостално приликом примопредаје смене запосленом из наредне смене. Тужилца је сачињавала вирмане и готовинске рачуне приликом наплате услуга не само у циљу обуке, већ их је и потписивала. За наведени временски период тужилци нису уплаћени прописани доприноси и није јој исплаћена зарада, као ни трошкови за долазак и одлазак са рада. Тужилца је тужбом тражила утврђење да је била у радном односу код туженог у периоду од 12.09.2018. до 12.10.2018. године, исплату зараде и накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада, као и уплату доприноса. Противтужбом тужени је тражио обавезивање тужилце на исплату накнаде штете причињене на раду,

заснивајући противтужбени захтев на одлуци туженог од 31.10.2018. године о књижењу разлика по попису благајне са стањем на дан 09.10.2018. године, донете на основу извештаја комисије од 09.10.2018. године образоване одлуком туженог од истог датума.

На основу наведеног, правилно и потпуно утврђеног чињеничног стања првостепени суд је правилно оценио основаним тужбени захтев, а неоснованим противтужбени захтев и одлучио као у изреци ожалбене пресуде, дајући за свој закључак разлоге које прихвата и овај суд.

Наиме, радни однос се, по правилу, заснива уговором о раду, који закључују запослени и послодавац, и сматра се закљученим када га потпишу запослени и директор, односно предузетник, или запослени кога овласти директор, односно предузетник, како је то предвиђено чланом 30 Закона о раду. Како Закон о раду не познаје и не признаје фактички рад, као рад ван радног односа, то је у одредби члана 32 прописао да ако запослени не закључи уговор о раду, сматра се да је запослени засновао радни однос на неодређено време даном ступања на рад.

Међутим, то не значи да сваки рад без уговора о раду, води заснивању радног односа. Рад ван радног односа је и рад на повременим и привременим пословима и рад на основу уговора о делу. Уколико се не ради о тој врсти рада или посла, потребно је да тако успостављен однос између запосленог и послодавца, по својој садржини и квалитету, има све карактеристике радног односа. У том смислу, потребно је, не само уредно и савесно обављање одређених послова и воља запосленог да те послове обавља, већ и сагласност послодавца за успостављање таквог радног односа, односно таквог рада, јер послодавац је тај који одлучује да ли има потребу за запошљавањем нових радника.

Дакле, као изузетак од правила да се радни однос заснива уговором о раду, рад код послодавца без уговора о раду, који би водио заснивању радног односа у смислу члана 32 Закона о раду, морао би имати карактеристике радног односа, како у погледу квалитета рада, тако и у погледу права и одговорности који произилазе из радног односа, као што је радно време, зарада, накнада зараде, друга примања из радног односа и др.

Имајући у виду да је у периоду од 12.09.2018. до 12.10.2018. године тужила код туженог била у државини рада, односно обављала фактички рад који је имао све карактеристике радног односа у смислу напред реченог, то

је првостепени суд правилно усвојио тужбени захтев у делу којим је тражено утврђење да је у означеном периоду тужила код туженог била у радном односу.

Права која су предмет тужбеног захтева имају утемељење у одредби чл. 60 ст. 4 Устава Републике Србије, а ближе су регулисана чл. 104, чл. 105, чл. 106, чл. 111 – 113 и чл. 118 ст. 1 тач. 1 Закона о раду. Она су предвиђена само за лица која имају својство запослених, а према чл. 5 наведеног закона запослени јесте физичко лице које је у радном односу код послодавца. Међутим, право на правичну накнаду за обављени рад могу остварити и лица која немају статус запослених и нису у радном односу код послодавца, али искључиво под условом да су била у државини фактичког рада код послодавца, односно да су тај рад обавили, и да је њихов фактички радни ангажман код послодавца имао обележја и карактеристике радног односа у квалитативном (садржајном) смислу. Поред права на правичну накнаду за обављени рад, запослени који је био у државини рада код послодавца са одликама радног односа, чији је дефект исказан само у одсуству акта о заснивању радног односа (у конкретном случају уговора о раду), има право и на уплату доприноса за обавезно социјално осигурање и исплату накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада.

Како је у периоду из тужбе тужила код туженог била у државини фактичког рада и како је њен радни ангажман имао обележја и карактеристике радног односа, како по садржини, тако и по квалитету, то је првостепени суд правилно обавезао туженог да тужилци плати накнаду за обављен фактички рад у неоспореном новчаном износу од 28.000,00 динара, затим да за тужилцу уплати припадајуће доприносе за обавезно социјално осигурање, као и да јој плати накнаду трошкова за долазак и одлазак са рада у износу према налазу и мишљењу вештака економско – финансијске струке који није био споран у обрачунском смислу, а које трошкове је тужила неспорно имала и исти су били у функцији обављања рада код туженог.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу 47 Гж1 1621/2020 од 11.02.2021. године)

Сентенцу приредила: Даниела Радовић, судија Апелационог суда у Нишу

САДРЖИНА ОБРАЗЛОЖЕЊА РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ОДЛУЧУЈЕ О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИМА ЗАПОСЛЕНОГ

(члан 193 став 1 Закона о раду)

О правима, обавезама и одговорностима запосленог одлучује се решењем које мора имати упориште у пропису који се конкретизује кроз њега. Поред увода и изреке, решење послодавца има и образложење којим се одређени пропис конкретизује везивањем за одређени животни догађај (утврђен чињенични основ) и одређеног запосленог, а ако то везивање захтева да буду испуњени неки услови, из образложења мора бити видљиво да они постоје.

Из образложења:

Према чињеничном стању садржаном у списима предмета, тужила је код тужене засновала радни однос 1987. године, на основу решења од 22.08.1987. године. Ради усклађивања са одредбама Закона о раду, у смислу чл. 287 ст. 1, парничне странке су дана 30.09.2009. године закључиле уговор о уређивању међусобних права, обавеза и одговорности. Дана 09.11.2009. године, директор тужене донео је одлуку бр. којом је тужили изрекао дисциплинску меру престанак радног односа, због теже повреде радне обавезе у смислу чл. 141 ст. 1 тач. 14 Закона о основама система образовања и васпитања, која се огледа у неизвршавању или несавесном, неблаговременом или немарном вршењу послова или налога директора у току рада. Против тог решења тужила је изјавила приговор Управном одбору тужене, који га је одбио као неоснован решењем бр. од 25.11.2009. године и потврдио побијано решење од 09.11.2009. године, након чега је директор тужене донео решење бр. од 26.11.2009. године о престанку радног односа. Ради поништаја сва три наведена решења и ради враћања на рад, тужила је против тужене повела радни спор пред Основним судом у Нишу, који је у првом степену завршен одбијајућом пресудом тог суда П1 бр. од 13.01.2014. године, која је по жалби тужиле преиначена пресудом Апелационог суда у Нишу Гж1 бр. од 16.12.2014. године, тако што је тужбени захтев усвојен у целини. Обзиром да тужена није поступила по преиначеној првостепеној пресуди П1 бр. од 13.01.2014. године (која је постала извршна дана 30.01.2015. године), тако што тужилу није добровољно вратила на рад, тужила је враћање на рад тражила у извршном поступку, предлогом за извршење од 01.04.2015. године, који је усвојен решењем Основног суда у Нишу И бр. од 02.04.2015. године. Дана 16.07.2015. године, тужена

је донела решење бр., којим се извршава пресуда Апелационог суда у Нишу Гж1 бр. од 16.12.2014. године, тако што се тужила тужила позива да се на посао јави дана 23.07.2015. године, у 10 часова, у складу са којим решењем је тужила поступила и јавила се на рад 23.07.2015. године, са којим датумом је од стране тужене пријављена на обавезно социјално осигурање. Наредног дана тужила је започела коришћење годишњег одмора за 2015. годину, на основу решења тужене бр. од 21.07.2015. године, којим је тужили одобрен годишњи одмор у трајању од 26 радних дана и одлучено да тужила исти искористи у целини почев од 24. јула, закључно са 28. августом 2015. године, уз обавезу да се на посао јави 31.08.2015. године. За време док је тужила била на годишњем одмору, директор тужене донео је решење бр. од 11.08.2015. године којим се утврђује да је престала потреба за радом тужиле. Против овог решења тужила је изјавила приговор Управном одбору тужене који је као неоснован одбијен решењем тог органа бр. од 02.09.2015. године. Тужбом коју је у овој правној ствари поднела 17.09.2015. године, тужила је тражила оцену законитости оба наведена решења (од 11.08.2015. године и од 02.09.2015. године). Истим решењима претходио је План рационализације броја запослених у Општини бр. од 26.12.2014. године, са изменом од 02.02.2015. године, донет од стране Општинског већа општине, којим је предвиђено да тужена установа може имати највише 36 запослених на неодређено време, те да се предвиђа рационализација за два запослена враћена по правноснажним судским пресудама. Општина је туженој упутила допис бр. од 25.06.2015. године којим је тужену обавестила да на општим, правним, финансијским, административним и сличним пословима може имати само једног запосленог, сходно одредбама Правилника о ближим условима за почетак рада и обављање делатности у установама за децу. Дана 07.07.2015. године, директор тужене донео је одлуку о покретању поступка утврђивања вишка запослених за два административна радника, након чега је Управни одбор тужене донео решење бр. од 20.07.2015. године о формирању трочлане комисије, са задатком да утврди предлог листе запослених за чијим радом је престала потреба и да га достави директору тужене до 10.08.2015. године. У складу са тим решењем, комисија је запосленима који ће бити бодовани (три административна радника) упутила анкетни лист бр. од 24.07.2015. године, са захтевом да сву документацију за бодовање доставе најкасније до 05.08.2015. године како би комисија извршила бодовање и утврдила предлог листе запослених за чијим радом је престала потреба. Запослени су обавештени да ће у случају недостављања података у наведеном року, бити ранжирани на основу доступних и

рапосложивих података у туженој установи. Дана 05.08.2015. године, комисија је извршила бодовање три кандидата и о свом раду сачинила записник бр. од 05.08.2019. године, а потом и прелиминарну ранг листу, те одлучила да се иста објави на огласној табли тужене установе, са роком за улагање приговора 5 дана од дана објављивања на огласној табли. Бодовање је извршено применом критеријума предвиђених Правилником о раду тужене бр. од 12.09.2014. године. У питању су следећи критеријуми: рад остварен у радном односу у установама образовања; образовање; резултати рада код последњег послодавца; имовно стање; здравствено стање; и број деце. Запослени АВ је избодован са 43 бода, АА (тужиља) са 39 бодова, а АВ са 32 бода. По истеку рока за изјављивање приговора, комисија је сачинила коначну ранг листу, а на основу ње предлог листе запослених за чијим радом је престала потреба бр. од 10.08.2015. године, којим се директору тужене установе предлаже да радни однос престане тужиљи АА и запосленој АВ, јер имају најмањи број бодова. Дана 14.08.2015. године, Школској управи у достављено је обавештење директора тужене бр. од 11.08.2015. године о постојању вишка два административна радника. Ослањајући се на решења од 11.08.2015. и 02.09.2015. године (која су предмет ове парнице), директор тужене донео је решење бр. од 23.09.2015. године о престанку радног односа, против кога је тужиља повела засебан радни спор, у коме је тражила поништај тог решења и враћање на рад, а који спор је завршен усвајајућом пресудом Основног суда у Нишу П1 бр. од 06.10.2016. године, потврђену пресудом Апелационог суда у Нишу Гж1 бр. од 17.03.2017. године. По ревизији тужене, обе наведене пресуде укинуте су решењем Врховног касационог суда Рев2 бр. од 14.02.2018. године и предмет враћен Основном суду у Нишу на поновно суђење, са образложењем да одлука о (не)законитости решења бр. од 11.08.2015. године и бр. од 02.09.2015. године (која су предмет ове парнице), представља претходно питање за испитивање законитости решења о претсанку радног односа бр. од 23.09.2015. године (које је предмет друге парнице).

На основу изложеног чињеничног стања првостепени суд је правилно закључио да је тужбени захтев основан, па га је усвојио те поништио решења бр. од 11.08.2015. године и бр. од 02.09.2015. године, одлучујући као у изреци ожалбене пресуде под ставом један.

Овакав закључак прихвата и Апелациони суд, али из других разлога, а не оних које је дао првостепени суд.

Наиме, оспореним решењем директора тужене бр. од 11.08.2015. године, из чијег уводног дела произлази да је засновано на чл. 192 Закона о раду и предлогу комисије бр. од 10.08.2015. године, утврђује се да је за радом тужиле АА престала потреба. У његовом образложењу наведено је, поред осталог, да је на ранг листи мањи број бодова имала административни радник АА, те је комисија предложила директору да утврди да је престала потреба за радом овог административног радника.

Чланом 193 ст. 1 Закона о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/2005,... 75/2014) уређено је да се запосленом у писаном облику доставља решење о остваривању права, обавеза и одговорности, са образложењем и поуком о правном леку, осим у случају из члана 172. овог закона.

Из цитираног прописа произлази да се о правима, обавезама и одговорностима запосленог одлучује решењем. Одлучивање може отпочети тек пошто се утврде чињенице од значаја за примену релевантног прописа. Решење има увод, изреку и образложење. Увод садржи назив органа, пропис на основу кога се одлучује и датум одлучивања. Изрека садржи исказ о праву, обавези или одговорности запосленог (оно о чему се одлучује). Садржина одлуке зависи од права које се запосленом признаје, обавезе која се запосленом поверава, одговорности која се према запосленом утврђује. Образложење садржи разлоге којима се оправдава одлука. Оно треба да покаже да се одређено право или одређена обавеза, односно одговорност, може применити према одређеном запосленом. Њиме се одређени пропис конкретизује везивањем за одређени животни догађај и одређеног запосленог. Ако то везивање захтева да буду испуњени неки услови, из образложења мора бити видљиво да они постоје. Оно мора указати и на чињенице које омогућују конкретизацију прописа, а ако је потребно и оцену доказа (код одлуке о одговорности).

Према члану 131 Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 72/09,... 53/13), који се у конкретном случају примењује, запослени који је у установи у радном односу на неодређено време, а остао је нераспоређен или има статус запосленог са непуним радним временом, остварује право на преузимање стављањем на листу запослених са које се врши преузимање (став 1). Лице из става 1 овог члана утврђује се до 15. августа за сваку наредну школску годину, у оквиру школске управе по јединицама локалне самоуправе, а на основу пријава установа о запосленима који имају право на преузимање. Право на преузимање остварује се споразумом, уз сагласност запосленог (став 2).

Како је напред наведено, образложењем решења се одређени пропис конкретизује везивањем за одређени животни догађај (утврђен чињенични основ) и одређеног запосленог, а ако то везивање захтева да буду испуњени неки услови, из образложења мора бити видљиво да они постоје. Образложење решења мора указати и на чињенице које омогућују конкретизацију прописа, а ако је потребно и оцену доказа (код одлуке о одговорности запосленог).

Из наведеног следи да решење послодавца мора имати упориште у пропису који се конкретизује кроз то решење. Како решење директора тужене бр. од 11.08.2015. године, које је у суштини деклараторног карактера (њиме се констатује чињеница да је код тужене престала потреба за радом тужиље), нема упориште у цитираним одредбама чл. 131 Закона о основама система образовања и васпитања, те како тужени није био у обавези да га донесе (према правном схватању из решења Врховног касационог суда Рев2 бр. од 14.02.2018. године), то је исто правилно поништено као незаконито.

И у ситуацији када би решење бр. од 11.08.2015. године, имало упориште у законском пропису, исто би било неправилно и незаконито, јер из његовог образложења не произлази да је засновано на правилно извршеном бодовању применом критеријума из тужениковог Правилника о раду бр. од 12.09.2014. године, тим пре што критеријум – резултати рада код последњег послодавца – није могао бити примењен у односу на тужиљу, из разлога што она није могла имати резултате рада код чињенице да јој је код тужене радни однос престао дана 27.11.2009. године на основу решења директора тужене бр. од 26.11.2009. године, а да је непосредно након враћања на рад отпочела коришћење целог годишњег одмора за 2015. годину. Поред наведеног, тужљи очито није омогућено учешће у поступку бодовања, јер је тужена пропустила да јој достави прелиминарну ранг листу (обзиром да се тужилца налазила на годишњем одмору), на коју листу је имала право изјављивања приговора, а који пропуст оспорено решење од 11.08.2015. године чини незаконитим актом. Његова незаконитост повлачи за собом и незаконитост решења Управног одбора тужене бр. од 02.09.2015. године, те је и оно правилно поништено као незаконито.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу 47 Гж1 2084/2021 од 20.05.2021. године)

Сентенцу приредила: Даниела Радовић, судија Апелационог суда у Нишу

ПРАВНОСНАЖНА УПРАВНА ОДЛУКА КАО ПРЕДУСЛОВ ЗА ВОЂЕЊЕ РАДНОГ СПОРА РАДИ НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗБОГ НЕПОСТУПАЊА ПОСЛОДАВЦА ПО ТОЈ ОДЛУЦИ

Предуслов за вођење парнице у којој запослени тражи исплату новчаног потраживања – накнаду трошкова превоза за пратиоца, јесте постојање коначне и правноснажне управне одлуке којом би наведено право запосленом претходно било признато у управном поступку, а по којој одлуци послодавац није поступао, односно није вршио исплату. Таква одлука била би од прејудицијелног значаја за одлучивање у парници и парнични суд не би имао овлашћење да преиспитује њену законитост и правилност (био би везан за њу). Само под тим условима би запослени имао право да потражује исплату наведеног потраживања које би се суштински свело на исплату накнаде штете због непоступања послодавца по коначној и правноснажној управној одлуци.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је професионални припадник Војске Републике Србије, у својству подофицира са чином старијег водника. У радном је односу код тужене почев од 22.07.2002. године, са местом рада у Војној пошти Дана 29.12.2014. године, на путу до посла, на месту сувозача у путничком аутомобилу, тужилац је доживео саобраћајну несрећу у којој је задобио тешке телесне повреде опасне по живот. У периоду од јануара 2015. године, закључно са септембром 2016. године, тужилац је ради прегледа и лечења одлазио у Војну болницу Ниш (укупно 25 пута) по упутима војног лекара амбуланте која се налази у оквиру ВП На наведене прегледе тужилац је одлазио у пратњи његове супруге. Судско – медицинским вештачењем које је по предлогу тужиоца изведено као доказ на главној расправи, потврђено је да је током спорног периода тужиоцу био неопходан пратилац, због његовог здравственог стања које је било нарушено у великој мери. За поменутих 25 одлазака у Војну болницу Ниш, тужиоцу су плаћени путни трошкови, али исти му нису плаћени и за његову супругу као пратиоца. Предметном тужбом тужилац потражује исплату путних трошкова за пратиоца.

На основу тако утврђеног чињеничног стања, првостепени суд је нашао да тужбени захтев тужиоца није основан, па га је одбио одлучујући као у изреци

ожалбене пресуде под ставом један. Овакав закључак прихвата и Апелациони суд, али из других разлога, а не оних које је дао првостепени суд.

Наиме, одредбом чл. 216 ст. 1 Закона о Војсци Југославије (“Сл. лист СРЈ” бр. 43/94,... 37/2002, “Сл. лист СЦГ” бр. 7/2005 и 44/2005 и “Сл. гласник РС” бр. 116/2007,... 10/2015) који је на снази у трећем делу којим је уређено социјално осигурање, прописано је да се здравственим осигурањем обезбеђује војним осигураницима и члановима њихових породица право на коришћење здравствене заштите и право на новчану накнаду и помоћ. Према члану 217 истог закона, здравствена заштита војних осигураника која се овим законом обезбеђује обухвата, поред осталог, лекарске прегледе, лечење болесника и друге врсте медицинске помоћи – у здравственим и другим специјализованим установама и у стану болесника и др (тачка 3).

Чланом 225 ст.1 регулисано је да војном осигуранику припада накнада путних трошкова, која обухвата: 1) накнаду за трошкове превоза; 2) накнаду за трошкове исхране и смештаја за време путовања и боравка у другом месту. Накнада путних трошкова из става 1. овог члана припада лицу из тог става ако је: 1) од војног лекара - појединца, војне лекарске комисије, војне здравствене установе или друге здравствене установе позван или упућен у друго место у вези са остваривањем права из здравственог осигурања одређених овим законом; 2) из места у коме је на служби, односно из места боравка у коме нема лекара морао да путује до најближег лекара или здравствене установе у другом месту ради лекарског прегледа или лечења (став 2). Висину накнаде из става 1. овог члана прописује савезни министар за одбрану (став 3).

Чланом 226 предвиђено је да накнада путних трошкова припада лицу из члана 225. овог закона и за пратиоца ако је по оцени војног лекара - појединца, војне лекарске комисије, војне здравствене установе или друге здравствене установе том лицу потребан пратилац за време путовања и боравка у том месту.

Чланом 230 регулисано је да прописе о начину остваривања здравствене заштите која се по овом закону обезбеђује на терет средстава здравственог осигурања војних осигураника доноси Савезна влада.

Уредбом о начину остваривања права из здравственог осигурања војних осигураника и чланова њихових породица (“Сл. лист СРЈ” бр. 36/94 и “Сл. гласник РС” бр. 88/2019), која је донета на основу напред цитираног чл. 230 Закона о Војсци Југославије, уређен је начин остваривања права из здравстве-

ног осигурања војних осигураника и чланова њихових породица утврђених Законом о Војсци Југославије (члан 1). Према члану 30 ст. 1 овог прописа, осигурано лице - професионални војник и чланови његове породице остварују накнаду путних трошкова, накнаду погребних трошкова и посмртну помоћ код војне јединице, односно војне установе код које је осигурано лице - професионални војник било на служби. Чланом 35 уређено је да команда војне јединице, односно војне установе жалбу осигураног лица на решење о остваривању права на накнаду и помоћ, са свим списима, доставља фонду.

Из цитираних прописа следи да пасивна стварна легитимација тужене за учешће у овој парници произлази из чл. 30 ст. 1 Уредбе о начину остваривања права из здравственог осигурања војних осигураника и чланова њихових породица, имајући у виду да право из чл. 226 Закона о Војсци Југославије (на накнаду трошкова превоза за пратиоца) војни осигураник остварује код војне јединице код које је на служби. У конкретном случају то је Војна пошта код које је тужилац на служби. Наведено право, тужилац као војни осигураник, могао би остварити искључиво по правилима општег управног поступка, и то у првом степену пред командом војне јединице код које је на служби (ВП), а у другом степену (по жалби на првостепену управну одлуку) пред Фондом за социјално осигурање војних осигураника. Ово произлази из тумачења одредбе чл. 35 поменуте Уредбе. Одлука Фонда као другостепеног органа је коначна и против ње је заштита обезбеђена у управном спору, подношењем тужбе Управном суду у смислу одредаба Закона о управним споровима.

Предуслов за вођење предметне парнице, у којој тужилац тражи исплату новчаног потраживања – накнаду трошкова превоза за пратиоца, јесте постојање коначне и правноснажне управне одлуке којом би наведено право тужиоцу било признато, а по којој одлуци тужена није поступала, односно није вршила исплату. Таква одлука била би од прејудицијелног значаја за одлучивање у парници и парнични суд не би имао овлашћење да преиспитује њену законитост и правилност (био би везан за њу). Само под тим условима би тужилац имао право да потражује исплату наведеног потраживања које би се суштински свело на исплату накнаде штете због непоступања послодавца по коначној и правноснажној управној одлуци. Како таква одлука не постоји у конкретном случају, нити је тужилац предложио доказе у том правцу, то

је првостепени суд правилно одлучио када је постављени тужбени захтев одбио као неоснован, јер у конкретном случају не постоји основ за исплату тражене накнаде штете у висини трошкова превоза за тужиочевог пратиоца.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу 47 Гж1 2320/2020 од 13.05.2021. године)

Сентенцу приредили: Даниела Радовић, судија Апелационог суда у Нишу и Дамјан Мирчић, виши судијски сарадник у Апелационом суду у Нишу

ПОВРЕДА ЗАПОСЛЕНОГ НА РАДНИЧКИМ СПОРТСКИМ ИГРАМА И ПРАВО НА НАКНАДУ ШТЕТЕ

(чл. 164 Закона о раду и чл. 22 Закона о пензијском и инвалидском осигурању)

Повреда коју запослени доживи на радничким спортским играма у организацији синдиката, не представља повреду на раду у смислу члана 22 Закона о пензијском и инвалидском осигурању, јер није у просторној, временској и узрочној повезаности са обављањем посла по основу кога је запослени осигуран. За такву повреду запослени нема право да од послодавца потражује исплату накнаде штете (нематеријалне и материјалне) сходно чл. 164 Закона о раду, уколико је на радничке спортске игре ишао добровољно, односно није имао обавезу – налог послодавца за учешће на њима.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је у радном односу код туженог ЈП из , на пословима пословође ресторана. Из садржине записника бр. од 23.08.2011. године, који је састављен на редовној седници ГО Синдиката , произлази да је тај синдикат био организатор сусрета радника, и то у периоду од 8. до 11. септембра 2011. године, а да су домаћини радничких спортских игара били Тужилац је био учесник тих игара. Из садржине споразума бр. од 06.05.2011. године произлази да су се “.....” и Синдикат споразумели да се повреда запосленог на наведеним радничким спортским играма сматра повредом на раду, као и да запослени има право на накнаду зараде због привремене спречености за рад проузроковане оваквом повредом у висини 100% зараде коју би остварио у месецу у којем је наступила привремена спреченост за

рад. Дана 09.09.2011. године тужилац је као учесник наведених игара, приликом играња фудбала, доживео повреду у виду пуцања Ахилове тетиве леве ноге, која представља тешку телесну повреду, због које је био на боловању до 06.12.2011. године, а поводом које је сачињен и извештај о повреди на раду број од 26.09.2011. године. Судско – медицинским вештачењем је утврђено да је тужилац трпео физичке болове јаког интензитета од момента повређивања у наредна три сата, болове средњег интензитета у трајању од три недеље, болове слабијег интензитета око два месеца. Код тужиоца постоји умањење опште животне активности од 12%, као и трајни инвалидитет који процентуално износи 5%. Тужилац је трпео страх јаког интензитета од повређивања у наредна три сата, страх средњег интензитета од седам дана и страх слабијег интензитета у наредна три месеца, а због задобијене повреде дошло је до умањења естетског изгледа процентуално изражено 15%. Настали видови нематеријалне штете у директној су узрочној вези са насталом повредом. Из приложених рачуна произлази да је тужилац за време лечења плаћао партиципацију и путне трошкове. Из достављене одлуке тужене Компаније “Дунав осигурање” произлази да је у предмету одштетног захтева тужиоца одлучено да исти нема право на накнаду штете, јер наведена повреда није покривена полисом осигурања.

Полazeћи од овако утврђеног чињеничног стања, првостепени суд је закључио да је тужбени захтев тужиоца делимично основан у делу којим је тражена исплата накнаде нематеријалне штете, па је о истом одлучио као у изреци ожалбене пресуде под ставом један и два, док је захтев за исплату накнаде материјалне штете оценио основаним па га је усвојио одлучујући као у изреци ожалбене пресуде под ставом три.

Међутим, по оцени Апелационог суда, првостепени суд је на основу чињеничног стања које је правилно и потпуно утврдио, погрешном применом материјалног права солидарно обавезао тужене према тужиоцу на исплату накнаде нематеријалне и материјалне штете, због чега је првостепена пресуда морала бити преиначена у ставу првом и трећем изреке одбијањем тужбеног захтева као неоснованог, и то из следећих разлога:

Наиме, одредбом члана 164. Закона о раду прописано је да ако запослени претрпи повреду на раду или у вези са радом, послодавац је дужан да надокнади штету у складу са законом и општим актом. Исказ „у складу са законом“, употребљен у наведеној одредби, значи у складу са Законом о облигационим односима. Због тога послодавац одговара по правилима Закона о облигационим односима о одго-

ворности за штету по основу кривице (члан 154. став 1), односно о одговорности за штету од опасне ствари и опасне делатности (чланови 173. и 174).

Према члану 22. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, под повредом на раду се сматра: повреда осигураника која се догоди у просторној, временској и узрочној повезаности са обављањем посла по основу кога је осигуран, проузрокована непосредним краткотрајним механичким, физичким или хемијским дејством, наглим променама положаја тела, изненадним оптерећењем тела или другим променама физиолошког стања организма (став 1); повреда проузрокована на начин из став 1. тог члана, коју осигураник – запослени претрпи при обављању посла на који није распоређен, али који обавља у интересу послодавца код кога је запослен (став 2); повреда проузрокована на начин из става 1. тог члана коју осигураник претрпи на редовном путу од стана до места рада или обрнуто, на путу предузетом ради извршења службених послова и на путу предузетом ради ступања на рад, као и у другим случајевима утврђеним законом (став 3); обољење осигураника које настане непосредно или као искључива последица неког несрећног случаја или више силе за време обављања посла на основу кога је осигуран, или у вези са њим (став 4); повреда проузрокована на начин из става 1. до 4. тог члана коју осигураник претрпи у вези са коришћењем права на здравствену заштиту по основу повреде на раду или професионалне болести (став 5).

Насупрот закључку првостепеног суда, Апелациони суд налази да повреда коју је тужилац доживео на радничким спортским играма дана 09.09.2011. године не представља повреду на раду у смислу напред цитираног чл. 22 Закона о пензијском и инвалидском осигурању, јер није у просторној, временској и узрочној повезаности са обављањем посла по основу кога је тужилац осигуран (пословођа ресторана у ЈП), те да због тога тужени нису у обавези да тужиоцу сходно чл. 164 Закона о раду солидарно накнаде штету (нематеријалну и материјалну) коју је претрпео због те повреде. Ово и из разлога што је тужилац на радничке спортске игре ишао добровољно, односно није имао обавезу – налог од стране туженог ЈП као послодавца, да на наведеним спортским играма учествује.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу 47 Гж1 3923/2021 од 10.11.2021. године)

Сентенцу приредила: Даниела Радовић, судија Апелационог суда у Нишу

ПОСТОЈАЊЕ УЗРОЧНЕ ВЕЗЕ ИЗМЕЂУ ПОСТУПКА ПОСЛОДАВЦА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПРОПУШТАЊА И НАСТАЛЕ ШТЕТЕ, КАО ПРЕДУСЛОВ ЗА КОНСТИТУИСАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ ПОСЛОДАВЦА ЗА ШТЕТУ

(чл. 164 Закона о раду)

У ситуацији када запослени претрпи повреду на раду која није последица штетне радње послодавца која би се огледала у одређеном чињењу или нечињењу (пропусту), односно која није настала кривицом послодавца, нити услед опасне ствари или опасне делатности, послодавац не сноси одговорност за настану штету ни по правилима о субјективној одговорности, ни по правилима о објективној одговорности.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, тужилац је у радном односу код туженог, у трећем павиљону, на пословима командира. Дана 30.08.2012. године, око 10 часова, тужилац се приликом изласка из тоалета, на излазним вратима из трећег павиљона, оклизнуо и пао. Том приликом задобио је ударац јаког интензитета у пределу главе и био је без свести неколико секунди. Повређеном тужиоцу помогли су присутни осуђеник АА, командир ББ и радник КПЗ-а ВВ, тако што су га сместили на клупу како би му се указала помоћ. Командир ББ је тужиоца пребацио марицом до излазне капије завода, где је на позив радника дежурне службе стигла хитна помоћ која је повређеног тужиоца превезла у болницу. Судско – медицинским вештачењем утврђено је да је тужилац критичном приликом задобио повреду главе у виду нагњечења (угруваности) коже и поткожних ткива главе и повредног потпуног и трајног губитка слуха на десном уву. Наведена повреда главе нанета је дејством тупине механичког оруђа. У време настанка, повреда главе са повредним трајним и потпуним губитком слуха, квалификована је од стране вештака као тешка телесна повреда. Вештачењем су утврђени интензитет и трајање физичких болова и страха, као и проценат умањења опште животне активности који према налазу вештака износи 30%. На основу исказа сведока ВВ утврђено је да је тужилац критичном приликом био у униформи, да под није био клизав и да је тужилац пао одмах по изласку из просторије. Допунским судско – медицинским вештачењем утврђено је поред осталог и то да је тужилац током 1999. године због вртоглавице праћене нестабилношћу при ходу затражио помоћ неуролога који је поставио дијагнозу “синдром вртоглавице” и ”повишен крвни притисак

непознатог порекла”, да наредних 12 и по година (од краја марта 1999. године до 30.08.2012. године) тужилац није имао сличне тегобе, нити стања налик вртоглавици или нестабилности при ходу, док је у јулу 2012. године утврђен повишен крвни притисак (190/100 mm/Hg) у склопу реакције на тежак стрес. У допунском налазу и мишљењу вештака констатовано је да се тегобе у виду вртоглавице, нестабилности у ходу и повишеног крвног притиска које је тужилац имао марта 1999. године, не могу довести у везу са тегобама и дијагнозама постављеним на дан повређивања 30.08.2012. године. Поднеском од 23.04.2021. године тужилац је прецизирао тужбени захтев.

На основу утврђеног чињеничног стања првостепени суд је правилно закључио да је тужбени захтев неоснован у целини, те исти одбио одлучујући као у изреци ожалбене пресуде, из разлога које прихвата и Апелациони суд.

Наиме, према одредби чл. 164 Закона о раду, ако запослени претрпи повреду или штету на раду или у вези са радом, послодавац је дужан да му накнади штету, у складу са законом и општим актом.

Порекло штете коју запослени може да претрпи на раду или у вези са радом, јесте у повреди права запосленог, или у повреди, односно нарушавању здравља самог запосленог. Повреда права запосленог постоји кад послодавац донесе одлуку или предузме радњу која није у складу са законом или општим актом, док се повреда, односно нарушавање здравља запосленог тиче повреде на послу и професионалне болести.

Под повредом на раду подразумева се повреда осигураника проузрокована непосредним и краткотрајним механичким, физичким или хемијским дејством, наглим променама положаја тела, изненадним оптерећењем тела или другим променама физиолошког стања организма. Дакле, ударима и падовима. Повредом на раду сматрају се и повреде запосленог на путу од куће до посла и обратно, на путу предузетом ради извршавања радних задатака, на путу предузетом ради ступања на рад, као и у вези са коришћењем права на здравствену заштиту поводом повреде на раду или професионалне болести (чл. 22 Закона о пензијском и инвалидском осигурању).

Према одредбама чл. 24 Закона о пензијском и инвалидском осигурању, професионалне болести су болести које су настале у току осигурања, проузроковане дужим непосредним утицајем процеса и услова рада на радним местима, односно пословима које је осигураник обављао, уколико су обухваћене листом професионалних болести које утврђују министар надлежан за

послове пензијског и инвалидског осигурања и министар за послове здравља, на предлог фонда.

Ако је штета настала због повреде права запосленог, основ одговорности је кривица која се претпоставља у смислу чл.154 ст.1 Закона о облигационим односима. Претпоставка је оборива, а терет њеног обарања сноси послодавац. С друге стране, ако је штета настала због повреде или професионалне болести запосленог, основ одговорности може бити кривица или ризик пословања послодавца. Кривица је основ одговорности кад штета није настала услед опасне ствари или опасне делатности. Ризик је основ одговорности, кад је штета настала услед опасне ствари или опасне делатности послодавца. Тада се одговора независно од кривице, по члану 154 ст. 2 ЗОО.

За штету због повреде запосленог на раду, послодавац може одговарати и по основу кривице и по основу ризика. Ако је повреда настала независно од опасне ствари или опасне делатности, ангажује се кривица, а ако је настала од опасне ствари или опасне делатности ангажује се ризик. За штету због професионалне болести запосленог ангажује се само ризик. Кад се као основ одговорности ангажује кривица, примењују се правила о субјективној одговорности. Кад се ангажује ризик, примењују се правила о објективној одговорности. Услови одговорности су да је запослени претрпео штету, да постоји узрочна веза између радње послодавца и штете и да не постоје разлози за искључење одговорности.

Како у конкретном случају не постоји штетна радња (чињење или нечињење, односно пропуст) туженог као послодавца, а тиме ни узрочна веза између штетне радње и штете коју је тужилац претрпео због повреде која му се на радном месту десила дана 30.08.2012. године, те како иста повреда није настала нити кривицом туженог као послодавца, нити услед опасне ствари или опасне делатности, то тужени не може бити одговоран за насталу штету ни по правилима о субјективној одговорности, ни по правилима о објективној одговорности.

(Из пресуде Апелационог суда у Нишу 47 Гж1 4157/2021 од 21.09.2021. године)

Сентенцу приредила: Даниела Радовић, судија Апелационог суда у Нишу

**УСЛОВИ ЗА ПРЕОБРАЖАЈ
РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У РАДНИ ОДНОС НА
НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ**
(чл. 37 ст. 6 Закона о раду)

Испуњени су услови за прерастање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време у ситуацији ако је запослени код послодавца радио на истоврсним пословима по основу више уговора о раду закључених на одређено време, а који фактички и правно представљају један уговор, чији је укупно трајање дужи од пет радних дана по истеку законског максимума трајања радног односа на одређено време.

Из образложења:

Према утврђеном чињеничном стању, посредовањем Филијале Националне службе за запошљавање у Бору, странке су дана2012.године, закључиле уговор о стручном оспособљавању, којим се тужени обавезао да на терет Филијале Националне службе, у року од годину дана, стручно оспособи тужиоца за самостални рад у струци, а тужилац да се стручно оспособи за самосталан рад по налазима непосредног руководиоца. У мају месецу 2013. године, тужилац је пред комисијом успешно положио писани и усмени део приправничког испита. Даном2013.године тужилац је са туженим закључио уговор о раду на одређено време од годину дана, због повећаног обима посла, на радном месту стручног пројектанта за системске и програмске модуле у Одељењу информациони систем у саставу Сектора за инжењеринг и пројектовање. Истеком времена на који је закључен уговор о раду, тужени је даном2014.године, донео решење којим је тужиоцу престао радни однос, а наредног дана странке су закључиле уговор о раду на одређено време од једне године за послове стручног пројектанта информационих система у истом Сектору и Одељењу као у претходном уговору. У време важења тог уговора, странке су даном2013. године закључиле уговор о раду којим су због измена Закона о раду и општих аката туженог променили одређене услове рада, а тужилац је распоређен на радно место самосталног истраживача за развој и одржавање информационих система у Центру за развој и одржавање информационих система у саставу Сектора за инкубатор центре и радионице. Решењем туженог од2015.године тужиоцу је престао радни однос истеком времена на који је заснован, а истог дана закључен је уговор о раду на период од две године, за исте послове на којима је тужилац радио по

основу претходног уговора. По истеку овог уговора, тужени је решењем од2017.године констатовао престанак радног односа тужиоца због истека рока на који је заснован. Тужилац је тужбеним захтевом тражио да се поништи као неправилно и незаконито решење туженог о отказу Уговора о раду бр..... од2017. године и да се утврди да је тужилац засновао радни однос код туженог на неодређено време дана2017. године и да се наложи туженом да тужиоца врати на рад и распореди на послове у складу са стручном спремом и радним искуством, као и да се обавезе тужени да му накнади материјалну штету услед незаконитог престанка радног односа, почев од2017. године као дана незаконитог престанка радног односа закључно са 2017.године, у појединачним месечним износима са законском затезном каматом почев од последњег дана у наредном месецу за сваки претходни месец, до коначне исплате, са припадајућим доприносима на ову основицу, као и да уредно попуњене обрасце М-4 и М-8 за наведени период на име тужиоца достави надлежном РФЗО фонду - Филијала Бор. Тужени је оспорио тужбени захтев тужиоца из разлога што уговори о раду нису закључени са тужиоцем за обављање истих послова, нити је тужилац испунио услове у смислу да није наставио своје усавршавање уписом на мастер или докторске студије, као и из разлога јер нису испуњени услови из члана 27 Закона о буџетском систему и Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору који се примењује на туженог као научно-истраживачку институцију.

Код напред утврђеног чињеничног стања, првостепени суд је закључио да је тужилац стручно оспособљен, да је након положеног приправничког испита примљен у радни однос код туженог на одређено време због повећаног обима посла у оквиру своје струке, и све време је обављао послове стручног пројектанта за системске и програмске модуле у сектору за инжењеринг, Одељење информациони системи, да је његов радни однос без прекида трајао дуже од две године, јер су решења о раскиду Уговора о раду која имају декларативни карактер доношена само формално, а притом није било никаквог прекида у раду тужиоца, те да су испуњени услови из чл. 37 Закона о раду, због чега је одлучио као у изреци.

Међутим, основано се жалбом туженог указује да је првостепени суд на утврђено чињенично стање погрешно применио материјално право.

Одредбом члана 37. став 6. Закона о раду („Сл. гл. РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14) прописано је да ако је уговор о раду на одређено време закључен супротно одредбама овог закона или ако запослени остане да ради код послодавца најмање пет радних дана по истеку времена за које је уговор закључен, сматра се да је радни однос заснован на неодређено време.

Сагласно наведеној правној регулативи, испуњени су услови за прерастање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време у ситуацији ако је запослени код послодавца радио на истоврсним пословима по основу више уговора о раду закључених на одређено време, а који фактички и правно представљају један уговор, чије је укупно трајање дуже од једне године и пет радних дана. Осим тога, приликом пружања судске заштите примениће се одредба која је била на снази у време доношења спорног уговора односно Уговора о раду од 20.05.2015.године, чијим истеком је тужиоцу престао радни однос.

У конкретном случају, тужилац је на основу закљученог уговора о раду од2013.године на одређено време од годину дана, распоређен на радно место стручног пројектанта за системске и програмске модуле у Одељењу информациони систем у саставу Сектора за инжењеринг и пројектовање, на основу уговора о раду на одређено време од2014.године, распоређен је на радно место стручног пројектанта информационих система у истом Сектору и Одељењу као у претходном уговору, на основу уговора о раду од2013. године распоређен је на радно место самосталног истраживача за развој и одржавање информационих система у Центру за развој и одржавање информационих система у саставу Сектора за инкубатор центре и радионице, док је уговором од2015.године, на период од две године, тужилац распоређен на истим пословима на којима је радио по основу претходног уговора.

Сходно наведеном, основано се жалбеним наводима туженог указује да је тужилац по основу раније закључених уговора обављао друге послове у другој организационој јединици туженог, што произилази из самих уговора, због чега нису испуњени кумулативни услови из цитиране одредбе члана 37. Закона о раду којим су прописани услови за преображај радног односа, јер тужилац није обављао исте послове на основу закључених уговора на одређено време у законском временском континуитету.

С тим у вези, супротно закључку првостепеног суда, имајући у виду да тужилац није обављао исте послове по основу претходно закључених уго-

вора, то исти није испунио ни услов од пет година радног стажа за радно место самосталног истраживача за развој и одржавање информационих система предвиђен Правилником о организацији и систематизацији послова код туженог на које је тужилац распоређен уговором од2015. године.

Из изнетих разлога, по оцени овог суда, у конкретном случају нису испуњени услови за прерастање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време. Решење о престанку радног односа у конкретном случају има деклараторно дејство, односно њиме се само констатује да је дошло до престанка радног односа истеком рока за који је уговор о раду закључен, па у ситуацији када нису испуњени услови за преображај радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време, исто је правилно и законито.

Из пресуде Апелационог суда у Нишу 2 Гж1 3024/20 од 13.07.2021. године, против које је одбијена ревизија тужиоца пресудом Врховног касационог суда Рев2 2410/21 од 01.12.2021. године

Сентенцу приредио: Судијски сарадник Душан Паравина

НЕПОСТОЈАЊЕ ОБАВЕЗЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ ОД СТРАНЕ ПОСЛОДАВЦА КАО ПОСЛЕДИЦЕ НЕПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНОГ У РАДНИ ОДНОС ПРЕМА ОБЈАВЉЕНОМ КОНКУРСУ

(чл. 164 Закона о раду и чл. 172 Закона о облигационим односима)

У ситуацији када је послодавац примио у радни однос запосленог на основу конкурса, након што су претходно поништене одлуке послодавца којима су у радни однос по конкурс примана друга лица, нису испуњени услови за накнаду штете запосленом за период у коме исти није обављао рад код послодавца, због одсуства кумулативног испуњења свих законских претпоставки за накнаду штете запосленом од стране послодавца, као и претпоставки за одговорност правног лица за штету коју његов орган проузрокује трећем лицу у вршењу или у вези са вршењем својих функција, прописаних одредбама чл. 164 Закона о раду, односно чл. 154 и чл. 172 ст. 1 Закона о облигационим односима.

Из образложења:

Према чињеничном стању садржаном у списима, произилази да се тужиља јавила на оглас који је тужени објавио у листу „Послови”2014. године, за пријем 4 извршиоца, на пословима, у радни однос на неодређено време. Истим огласом су били означени општи и посебни услови које кандидати треба да испуне и рок у коме се пријаве подносе, па је тужиља благовремено доставила потпуну документацију. Тужени је донео Одлуку од2015. године којом су изабрани други кандидати, против наведене одлуке тужиља је водила парнични поступак и правноснажном и извршном пресудом Основног суда у Бујановцу од2016. године поништено је решење туженог од2015. године као незаконито. а туженом наложено да изврши поновни избор кандидата у складу са условима из објављеног конкурса. Тужени је поступајући по правноснажној пресуди донео нове одлуке бр. и, обе од2016. године, којима су за кандидате у пријем за радни однос изабрана друга лица, па је тужиља поново водила парнични поступак и пресудом Основног суда у Бујановцу од2017. године, која је потврђена пресудом Апелационог суда поништене су одлуке туженог и туженом је наложено да изврши поновни избор кандидата у складу са условима из огласа објављеног у листу “Послови” од2014. године. У поновном избору тужени је донео две одлуке бр. и обе од2017. године, које су такође поништене пресудом Основног суда у Бујановцу2018. године, туженом је наложено да изврши поновни избор између пријављених кандидата па је коначно тужени донео Одлуку бр. од2018. године којом је тужиља изабрана између пријављених кандидата и на основу тога је и закључен уговор о раду бр. од2018. године. Тужиља је ступила на рад2018. године. Тужбеним захтевом тужиља тражи накнаду штете због немогућности остваривања зараде у периоду од2014. године до2018. године, сматрајући да је ова штета настала незаконитим радом туженог, јер је незаконитим одлукама бирао кандидате који нису испуњавали услове за заснивање радног односа. Висина тужбеног захтева је утврђена на основу налаза и мишљења вештака економско-финансијске струке, а на основу зараде која је исплаћена, која је била примљена на наведено радно место по објављеном огласу, а која није испуњавала услове за пријем у радни однос. Тужени је оспорио тужбени захтев указујући да није било незаконитог рада, а осим тога да би запослени остварио право

на накнаду штете због неисплаћене зараде, потребно је да се рад по основу кога се потражује накнада материјализовао, односно да је запослени радио, чега у конкретном случају нема јер је тужила радни однос засновала уговором о раду од2018. године.

Одредбом члана 164. Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење) прописано је да ако запослени претрпи повреду или штету на раду или у вези са радом, послодавац је дужан да му накнади штету, у складу са законом и општим актом. Право на накнаду штете прописано је и одредбом члана 154. Закона о облигационим односима, па ко другоме проузрокује штету дужан је накнадити је, уколико не докаже да је штета настала без његове кривице. Штета је умањење нечије имовине (обична штета) и спречавање њеног повећања (измакла корист), као и наношење другоме физичког или психичког бола или страха (нематеријална штета), сходно члану 155. истог закона. Оштећеник има право како на накнаду обичне штете, тако и на накнаду измакле користи, што је прописано одредбом члана 189. закона, док је одредбом члана 190. истог закона прописано да ће суд, узимајући у обзир и околности које су наступиле после проузроковања штете досудити накнаду у износу који је потребан да се оштећеникова материјална ситуација доведе у оно стање у коме би се налазила да није било штетне радње или пропуштања.

Одговорно лице је дужно успоставити стање које је било пре него што је штета настала и суд ће досудити оштећенику накнаду у новцу кад он то захтева, изузев ако околности датог случаја оправдавају успостављање ранијег стања, сходно члану 185. став 1. и 4. Закона о облигационим односима. Законом о облигационим односима је у члану 172. став 1. прописано да правно лице одговара за штету коју његов орган проузрокује трећем лицу у вршењу или у вези са вршењем својих функција.

Имајући у виду цитиране одредбе Закона о раду и Закона о облигационим односима, за одговорност тужене у овој правној ствари релевантна је одредба члана 172. ст. 1. Закона о облигационим односима. Да би се могло говорити о одговорности правног лица за штету у смислу цитиране одредбе, потребно је претходно да се испуне услови за одговорност тог лица за штету коју је његов орган проузроковао. Ти услови су постојање штете (члан 155. 300). кривице, да је штетних проузроковао штету намерно или крајњом

непажњом (члан 158. 300) и узрочне везе између предузете радње и настале штете.

Незаконитим радом органа сматра се поступање супротно закону, другом пропису и општим актом, као и пропуштање да се исти примене. Неправилан рад органа је чињење или нечињење противно уобичајеном или прописаном начину обављања делатности који штети праву или интересима неког лица. Дакле, поступање органа које је у складу са законским прописима или је у оквиру његових овлашћења, не може представљати ни неправилан, ни незаконит рад. Чак и погрешна примена одговарајуће законске норме или евентуална погрешна процена испуњености услова за доношење одређене одлуке не представља, сама по себи, повреду дужности у вршењу функције тог органа, на основу кога би он био одговоран за евентуалну штету коју неко лице претрпи. У таквој ситуацији, сходно Уставним и законским одредбама, лице незадовољно одлуком надлежног органа, има право на жалбу или друго правно средство против одлуке којом се одлучује о њеном праву, обавези или на законом заснованом интересу у одговарајућем законом прописаном поступку, односно има право на редован и ванредни правни лек, у складу са законом.

У конкретном случају, директор тужене је поступао у оквиру својих овлашћења, примењујући законе који се односе на заснивање радног односа, па тужени не може бити одговоран за штету која је евентуално настала услед погрешне примене прописа, односно погрешне процене испуњености услова за доношење одлука о пријему у радни однос. Из изнетих разлога, сама чињеница да је парнични поступак, по тужби тужиле за поништај одлука о пријему у радни однос, окончан повољно по тужилу, не значи да су одлуке туженог последица неправилног и незаконитог рада органа туженог. Стога, како нема незаконитог рада органа тужене, не постоји основ да се тужени обавезе да тужилу накнади материјалну штету, будући да није утврђена узрочна веза између предузете радње туженог (доношења одлуке по конкурс) и настале штете.

Осим тога, право на зараду је право које се гарантује запосленом за обављени рад и време проведено на раду, сходно члану 104. и 105. Закона о раду. Право на накнаду штете због изгубљене зараде, у смислу члана 164. Закона о раду, припада запосленом. Послодавац одговара за штету ако је својом незаконитом одлуком повредио право запосленог, па је дужан да такву

штету накнади запосленом ако постоје основ и услови одговорности и ако не постоје разлози за њено искључење. У конкретном случају, поред тога што је утврђено да није било незаконитог рада туженог, у смислу члана 172. ЗОО, тужиљи не припада право на накнаду штете због немогућности остваривања зараде у периоду када није била у радном односу код туженог, јер јој такво право не припада сходно цитираним одредбама Закона о раду којима су регулисана права запослених, насупрот закључку првостепеног суда.

Из пресуде Апелационог суда у Нишу Гж1 1703/21 од 25.01.2022. године

Сентенцу приредио: Судијски сарадник Душан Паравина



Program za elektronsko kancelarijsko poslovanje

e-Fakture

Šaljite fakture elektronski, bez troškova štampe i slanja, uvek uz izveštaj o prijemu fakture.

e-Delovodnik

Uredite svoju dokumentaciju i knjige dokumenata digitalno i efikasno.

e-Poštar

Ubrzajte razmenu dokumenata, smanjite troškove i kreirajte procedure odobravanja.

Beograd

063/379-761
063/379-948

Novi Sad

063/379-961
063/379-772

Niš

063/379-619
063/379-661



Pravna i ekonomska izdavanja
za uspešno i zakonito poslovanje

✉ kancelarko@paragraf.rs

🌐 Kancelarko.rs

NAŠ TIM

Za uspešno poslovanje potrebna je kvalitetna pravno-ekonomska baza. Za kvalitetnu bazu potreban je profesionalan tim. Naš tim broji preko:

- ◆ 190 zaposlenih koji se svakodnevno brinu o tome da dobijete blagovremenu i tačnu informaciju
- ◆ 200 stalnih autora iz oblasti pravnih, ekonomskih i ostalih nauka
- ◆ 18.000 višegodišnjih korisnika koji svojim sugestijama doprinose kvalitetu baze "Paragraf Lex"

BUDŽETSKI
INSTRUKTOR

SUDSKA
PRAKSA

SLUŽBENA
MIŠLENJA

PRAVNO-
EKONOMSKE
VESTI

OBRASCI

CARINSKA
TARIFA

STRANA
SUDSKA
PRAKSA

PROPISI

MODELI

PRAVO
U PRAVOSUĐU

EVROPSKO
ZAKONODAVSTVO

PORESKO
RAČUNOVODSTVENI
INSTRUKTOR

INSPEKTOR

PRAVO
U JAVNOM
SEKTORU

PRAVO
U PRIVREDI

SPECIJALIS
ZA CARINE

Želite pouzdanu pravno-ekonomsku bazu na koju možete da se oslonite i koja će Vam ponuditi stručne tekstove, pronaći odgovore i biti Vaš virtuelni saradnik?

IMAMO REŠENJE ZA VAS!



www.paragraf.rs



Pravna i ekonomska izdanja
za uspešno i zakonito poslovanje

www.paragraf.rs